

제1강 살인죄

♣ 학습목표

사람의 시기를 설명할 수 있다.

존속살해죄와 관련하여 '직계존속'의 범위를 설명할 수 있다.

자살교사·방조죄의 법리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

사람의 시기와 종기

직계존속

자살교사·방조

♣ 사전테스트

1. 살해의 수단·방법은 제한이 없다. 작위·부작위, 직접적·간접적 방법을 불문한다.

정답 : O

2. 계부나 계모를 살해한 경우에도 존속살해죄가 성립한다.

정답 : X

3. 자살교사·방조죄에서 자살자 본인은 필요적 공범에 해당하나 불가벌이다.

정답 : O

♣ 돌발퀴즈

사형집행 직전의 사형수도 살인죄의 객체가 된다.

[정답] O

[해설] 살인죄의 사람이란 생명이 있는 자연인으로 타인을 의미하며 법인은 제외된다. 자연인인 이상 생존능력의 유무는 묻지 않는다. 예컨대 사형집행 직전의 사형수도 본 죄의 객체가 된다.

♣ 강의내용

1. 보통살인죄(형법 제250조 제1항)

1. 의의

살인죄는 사람을 살해함으로써 성립하는 범죄이다.

2. 행위객체

사람이다.

(1) 사람

본죄의 사람이란 생명이 있는 자연인으로 타인을 의미하며 법인은 제외된다. 자연인인 이상 생존능력의 유무는 묻지 않는다. 예컨대 사형집행 직전의 사형수도 본 죄의 객체가 된다. 태아와 사자는 살인죄의 객체에서 제외된다. 여기서 사람이란 자기 이외의 타인을 의미하므로 자살은 살인죄에 해당되지 않지만, 타인의 자살에 관여하면 범죄가 된다(제252조 제2항 자살관계죄).

(2) 사람의 시기 - 진통설

분만이 개시되는 규칙적인 진통이 있는 때를 사람의 시기로 보는 견해이다(분만개시설). 여기서 진통은 자궁구의 개방진통을, 제왕절개수술의 경우에는 절개한 때를 의미한다.

판례(대판 2007.6.29. 2005도3832)는 “사람의 생명과 신체의 안전을 보호법익으로 하고 있는 형법의 해석으로는 규칙적인 진통을 동반하면서 분만이 개시된 때(소위 진통설 또는 분만개시설)가 사람의 시기(始期)라고 봄이 타당하다.”고 판시하여 진통설을 취한다.

(3) 사람의 종기

사람의 종기에 관해서는 맥박종지설(심장사설, 통설), 뇌사설 등이 대립하나, 의학적으로 뇌사상태일 경우이라도 호흡과 심장박동이 계속되는 한 살아있는 사람으로 보아야 하므로 맥박종지설이 타당하다.

(4) 장기등이식에관한법률

현행 장기등이식에관한법률(제정 1999.2.8, 법률 제5858호)에 의하여 뇌사자의 장기이식이 허용되고 있는 바, 동법이 뇌사자를 사망한 자로 입법화한 것인지에 대해 견해의 대립이 있다.

이에 대해서는 긍정설과 부정설이 대립하는 바, 부정설을 취하면 뇌사자의 장기적출행위의 형사책임은 살인죄의 구성요건해당성은 있으나 법령에 의하여 위법성이 조각되는 것으로 이해될 수 있다(정당행위). 반면에 긍정설을 취하면 뇌사자의 장기를 적출하는 행위는 이미 죽은 자를 또 죽이는 것에 불과하므로 살인죄의 구성요건해당성이 배제되어 불가벌이 된다.

3. 행위

살해이다. 살해란 고의로 사람의 생명을 자연적인 사기에 앞서서 단절시키는 것이다.

살해의 수단·방법은 제한이 없다. 작위·부작위, 직접적·간접적 방법을 불문한다. 그러나 미신적 방법에 의한 살해는 인정되지 않는다(불능범). 강제·기망으로 피해자를 자살케 한 경우 의사지배가 인정되면 제253조 위계·위력에 의한 살인죄가, 의사지배가 부정될 경우에는 제252조 제2항 자살관계죄가 성립한다.

4. 죄수

- ① 원칙 : 피해자의 수에 따라서 결정된다. 생명은 일신전속적 법익이기 때문이다.
- ② 하나의 행위에 의한 수인의 살해행위는 수개의 살인죄의 상상적 경합범이다.
- ③ 시간적으로 접촉된 수인의 살해행위는 수개의 살인죄의 경합범이다.
- ④ 동일인에 대한 살인예비·미수는 살인기수에 흡수된다(불가벌적 사전행위).

II. 존속살해죄(형법 제250조 제2항)

1. 의의

존속살해죄는 자기 또는 배우자의 직계존속을 살해함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄의 법적 성격은 행위객체에 대한 특수한 신분관계로 형이 가중되는 불법가중적 구성요건이고, 행위자의 신분으로 형이 가중되는 부진정신분범이다.

2. 구성요건

(1) 행위주체

피해자의 직계비속 또는 그 배우자이다.

(2) 행위객체

자기 또는 배우자의 직계존속이다.

(가) 자기의 직계존속

- ① 법률상의 직계존속(양친자관계 포함)을 의미하므로 사실상의 직계존속은 제외된다. 반드시 호적의 기재가 기준이 되는 것은 아니므로 버려진 아이를 호적에 친자로 입적시켰으나 입양요건을 갖추지 아니한 경우에는 직계존속이라 할 수 없다(대판 1983.6.28. 81도2466).
- ② 혼인 외 자인 경우 생부의 인지가 있어야만 직계존속의 관계가 인정된다. 반면에 생모의 경우에는 인지나 출생신고가 없어도 자의 출생으로 당연히 법률상의 직계존속이 된다(대판 1980.9.9. 80도1731).
- ③ 타가에 입양되어도 실부모와의 친자관계는 그대로 존속하므로 직계존속이 된다(대판 1967.1.31. 66도1483). 그러므로 양자로 입양된 甲이 자신의 생모를 살해한 경우 존속살해죄가 성립한다. 그러나 계부·계모는 법률상 1촌의 인척관계에 있으므로 직계존속이 아니다.

(나) 배우자의 직계존속

민법상 혼인절차에 의한 법률상의 배우자만을 의미하고 사실혼은 제외된다. 여기서 배우자는 살아 있는 배우자를 의미한다. 다만 배우자의 신분관계는 살해행위에 착수할 때 존재하면 족하므로 동일한 기회에 배우자를 먼저 살해하고 계속하여 그 직계존속을 살해한 때에도 본죄가 성립한다.

III. 자살교사·방조죄

1. 자살교사·방조죄

(1) 의의

자살교사·방조죄란 타인을 교사·방조하여 자살하게 함으로써 성립하는 살인죄의 감경적 구성요건(자살관련죄)이다. 본죄는 불가벌인 자살행위에 대한 대항범으로서의 성격을 가지고 있다. 자살이 처벌되지 않는 이유는 살인죄나 상해죄에 있어서 사람이란 타인을 의미하므로 자살은 구성요건해당성이 없기 때문이다. 그러나 자살 자체는 처벌하지 않지만 타인의 자살에 관여한 행위는 당벌성이 인정되므로 처벌대상이 된다.

(2) 구성요건

(가) 행위주체

제한이 없고 자연인이면 모두 주체가 된다. 단 자살자 본인은 필요적 공범에 해당하나 불가벌이다.

(나) 행위객체

행위자 이외의 자연인이며, 자기 또는 배우자의 직계존속도 여기에 포함된다(존속상해죄 불성립). 다만 여기서 자연인이란 자살의 의미를 이해하고 의사결정 능력이 있어야 하므로 유아와 정신병자는 본죄의 객체가 될 수 없다.

(다) 행위

- ① 자살교사는 자살의사 없는 자에게 자살을 결의하게 하는 것이다. 자살방조는 이미 자살을 결의한 자의 자살을 용이하게 하는 것을 말한다. 자살교사나 자살방조는 모두 그 수단·방법은 제한 없고, 명시적·묵시적을 불문한다. 따라서 妻가 자살하려는 것을 보고도 방치하여 妻가 사망한 경우와 같이 본죄는 부작위에 의하여도 행해질 수 있다.
- ② 본죄는 총칙상의 공범이 아니라 독립된 범죄처벌규정이므로 자살의 교사·방조 그 자체를 실행행위로 보아야 하고, 따라서 자살의 교사·방조에 착수한 때에 실행의 착수가 있다.
- ③ 그리고 본죄는 독립된 범죄처벌규정이므로 형법 제252조 제2항의 자살방조죄를 범한 자에 대해서는 형법 제32조의 감경 규정이 적용될 수 없다.
- ④ 그리고 본죄는 예비를 처벌하는 규정이 없으므로 가령 甲이 자신을 죽여 달라는 A의 부탁을 받고 필요한 독약을 준비하였으나 심경이 변하여 살해를 포기하고 준비하였던 독약을 버린 경우 예비죄로 처벌할 수 없다.

♣ 확인학습문제

1. 살인의 죄에 관한 설명으로 잘못된 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 뇌사설에 의하면 뇌사자는 '살아있는 자'가 아니므로 장기이식을 위해 뇌사자의 심장을 적출하더라도 이는 살인죄의 구성요건에 해당하는 행위로 볼 수 없다.
- ② 자신의 妻가 자살하려는 것을 목격하고도 그 자살을 방치한 경우에는 부작위에 의한 살인죄가 성립할 수 있다.

- ③ 甲이 자신을 죽여 달라는 A의 부탁을 받고 필요한 독약을 준비하였으나 심경이 변하여 살해를 포기하고 준비하였던 독약을 버린 경우 예비죄로 처벌할 수 없다.
- ④ 사람의 생명과 신체의 안전을 보호법익으로 하고 있는 형법의 해석으로는 규칙적인 진통을 동반하면서 분만이 개시된 가 사람의 시기(始期)라고 봄이 타당하다.
- ⑤ 사실상의 직계존속이 분만직후의 영아를 살해하면 보통살인죄가 성립한다.

【정답】 ②

【해설】 살인행위에 대하여는 행위지배가 없어 살인죄는 성립할 수 없으므로 결국 부작위에 의한 자살방조죄가 성립한다.

2. 존속살해죄의 대한 기술 중 잘못된 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 인지를 거치지 않은 혼인외자가 실부를 살해한 때는 존속살해죄가 성립하지 않는다.
- ② A(女)가 그의 문전에 버려진 생후 며칠 밖에 되지 아니한 영아인 甲을 주어다 기르고 그 夫와의 친생자인 것처럼 출생신고를 하였으나 입양요건을 갖추지 아니하였다면 성인이 된 甲이 A를 살해하였다고 하여도 존속살해죄로 처벌할 수 없다.
- ③ 甲과 乙이 공동으로 甲의 父를 살해한 경우 甲은 존속살해죄, 乙은 보통살인죄의 공동정범이 된다.
- ④ 양자로 입양된 甲이 자신의 생모를 살해한 경우 존속살해죄가 성립한다.
- ⑤ 혼인외 출생자가 그 생모를 살해한 때에도 존속살해죄에 해당한다.

【정답】 ③

【해설】 판례에 의하면 甲과 乙은 존속살해죄의 공동정범이 되고, 다만 乙은 보통살인죄로 처벌된다.

3. 유부남인 乙은 B녀와 정교를 맺어 B가 甲을 출산하자 자신의 처인 A 몰래 甲을 자신과 A 사이의 혼인 중의 출생자로 호적(가족관계부)신고를 하였다. 그 후 성인이 된 甲이 자신의 처지를 비관하다가 乙과 B를 살해하였을 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙과 B에 대한 보통살인죄
- ② 乙에 대한 보통살인죄, B에 대한 존속살해죄
- ③ 乙에 대한 존속살해죄, B에 대한 보통살인죄
- ④ 乙과 B에 대한 존속살해죄
- ⑤ 무죄

【정답】 ④

【해설】 乙이 甲을 혼인 중의 출생자로 호적(가족관계부)신고를 하였다는 혼인외의 출생자를 인정한 것이라고 할 수 있다. 따라서 乙은 甲의 법률상의 직계존속이므로 甲이 乙을 살해한 경우 甲은 존속살해죄가 된다. 그리고 B는 생모이므로 당연히 직계존속이 된다.

♣ 학습내용 정리

1. 살인죄에서 ‘사람’이란 생명이 있는 자연인으로 타인을 의미하며 법인은 제외된다.
2. 존속살해죄의 ‘직계존속’은 법률상의 직계존속(양친자관계 포함)을 의미하므로 사실상의 직계존속은 제외된다.

3. 자살교사·방조죄란 타인을 교사·방조하여 자살하게 함으로써 성립하는 살인죄의 감경적 구성요건(자살관련죄)이다.

제2강 상해죄, 폭행죄

♣ 학습목표

- 상해죄에서 상해의 의미를 설명할 수 있다.
- 중상해죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 폭행죄의 법리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 상해
- 상대적 상해개념
- 중상해
- 폭행

♣ 사전테스트

1. 자상행위도 상해죄의 구성요건에 해당한다.
정답 : X
2. 중상해죄는 사람의 신체를 상해하여 신체에 대한 위험을 발생하게 하게 함으로써 성립하는 범죄이다
정답 : X
3. 정신과적 증상인 외상 후 스트레스 장애는 상해에 해당한다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

AIDS 감염행위는 중상해죄에 해당한다고 볼 수 있다.

[정답] O

[해설] 중상해죄에서 불치 또는 난치의 질병이란 치료의 가능성이 없거나 현저히 곤란한 질병을 의미하는 것으로 AIDS 감염이 대표적인 사례가 된다.

♣ 강의내용

1. 상해죄(형법 제257조 제1항)

1. 의의

고의로 타인의 신체를 상해함으로써 성립하는 범죄이다.

2. 구성요건

(1) 행위객체

본죄의 행위객체는 사람(타인)의 신체이다. 타인의 신체에 대하여 상해가 가해져야 하므로 자상행위는 본죄의 구성요건에 해당하지 않는다. 다만 자상행위도 특별법에 의하여 예외적으로 처벌되는 경우(병역법 제75조; 군형법 제41조 제1항)가 있다.

그러나 타인을 강요하여 자상하게 한 때에는 본죄의 간접정범이 된다. 가령 甲이 乙을 강요하여 乙의 손가락을 절단하게 한 경우 강요죄가 성립할 뿐만 아니라 강요에 의한 자상(自傷)이 상해죄의 구성요건에 해당하지 않는다고 하더라도 甲에게는 의사지배가 인정되어 상해죄의 간접정범이 된다(강요죄와 상상적 경합).

(2) 행위

상해이다.

(가) 상해의 개념 - 생리적 기능 훼손설

상해개념을 협의로 파악하여 사람의 생리적 기능을 훼손하거나 건강을 해치는 것이 상해라고 보는 견해로 내부적 생리기능훼손은 상해로, 외부적 완전성침해는 폭행으로 보는 것이 다수견해의 입장이다.

판례(대판 1999.1.26. 98도3732) 역시 “상해는 피해자의 신체의 완전성을 훼손하거나 생리적 기능에 장애를 초래하는 것으로, 반드시 외부적인 상처가 있어야만 하는 것이 아니고, 여기서의 생리적 기능에는 육체적 기능뿐만 아니라 정신적 기능도 포함된다.”고 판시하여 생리적 기능 훼손설을 취한다.

(나) 상대적 상해개념

상대적 상해개념이란 각 구성요건별로 상해가 가지는 기능에 착안하여 상해개념에 차이를 두어 경미한 상해를 배제시키고자 하는 이론이다. 즉 이 이론은 “일상생활상 간과될 정도의 것으로서 방치하더라도 자연치유 될 수 있는 경미한 상해”에 대해서는 특히 강간치상죄나 강도치상죄와 같은 결과적 가중범 소정의 상해에 해당하지 않는 것으로 보아 결과적 가중범에서 나타나는 엄벌주의를 제한하려는 대법원 판례의 추세로부터 추론되는 개념이다.

<상대적 상해개념에 따라 상해를 부정한 경우>

- ① 피고인이 피해자를 강간하려다가 미수에 그치고 그 과정에서 위 피해자의 왼쪽 손바닥에 발생한 약 2센티미터 정도의 굵긴 가벼운 상처(대판 1987.10.26. 87도1880) ㄱ41
- ② 강간도중 흥분하여 피해자의 왼쪽 어깨를 입으로 빨아서 생긴 동전크기 정도의 반상출혈상(대판 1986.7.8. 85도2042)
- ③ 피고인이 피해자와 연행문제로 시비하는 과정에서 피해자에게 발생한 약 1주간의 치료를 요하는 좌측팔 부분의 든 동전크기의 멍(대판 1996.12.23. 96도2673)

④ 부녀의 음모를 1회용 면도기로 일부(위에서 아래로 가로 약 5cm, 세로 약 3cm) 깎은 경우(대판 2000.3.23. 99도3099) 司43

(다) 상해의 수단·방법

제한이 없다. 유형적·무형적 방법에 의해서도 가능하며, 부작위나 타인을 도구로 하는 간접 정범도 가능하다.

(3) 주관적 구성요건 - 고의

사람의 생리적 기능의 훼손에 대한 인식과 의욕으로 미필적 고의로서 충분하다. 판례(대판 2000.7.4. 99도4341)는 “상해죄의 성립에는 상해의 원인인 폭행에 대한 인식이 있으면 충분하고 상해를 가할 의사의 존재까지는 필요하지 않다.”고 판시한 바 있다.

II. 중상해죄(형법 제258조 제1항)

1. 의의

(1) 개념

중상해죄는 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 하거나, 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 함으로써 성립하는 범죄이다(→ 신체에 대한 위험의 발생이 아니다).

(2) 성격

(가) 가중적 구성요건

중상해죄나 존속중상해죄는 모두 단순상해죄에 비해 결과반가치의 측면에서 불법이 가중되는 가중적 구성요건이다.

(나) 부진정결과적 가중범 여부

본죄는 미수범처벌규정이 없으며, 중한 상해의 결과를 고의로 야기한 경우보다 과실로 야기한 경우를 더 무겁게 처벌하는 것은 형의 균형이 맞지 않는다 할 것이므로 본죄는 부진정결과적 가중범으로 보아야 한다.

2. 구성요건

(1) 기본범죄

상해이다.

(2) 중한 결과

생명에 대한 위험, 불구, 불치나 난치의 질병이다.

(가) 생명에 대한 위험

생명에 대한 구체적인 위험이 발생한 경우로 치명상을 입은 때가 이에 해당한다. 피해자가 실제로 사망에까지 이른 경우에는 상해치사죄가 성립한다.

(나) 불구

신체외형상 중요부분의 절단 또는 신체기능의 지속적인 상실의 경우이다(ex. 청력상실, 허절단, 남근절단 등). 이 때 신체의 어느 부위가 중요부분인가의 판단은 피해자의 개인적인 사정을 고려하지 않고 신체조직에 있어서의 기능을 의학적·객관적으로 판단하여 결정하여야 한다. 따라서 안부에 폭력을 가하여 실명케 한 경우는 중상해가 되지만(대판 1960.4.6. 4292형상395), 하구치 2개의 탈락상은 중상해에 해당되지 아니한다(대판 1960.2.29. 4292형상413).

(다) 불치 또는 난치의 질병

치료의 가능성이 없거나 현저히 곤란한 질병이다. ex.) AIDS 감염, 정신병기억상실, 척추장애 등

(3) 미수

본죄에는 미수범 처벌규정이 없으므로 중상해의 결과가 발생하지 아니하고 단순상해의 결과가 발생한 경우에는 단순상해죄의 기수범으로 처벌되고, 단순상해의 결과조차 발생하지 않았다면 단순상해죄의 미수범으로 처벌된다.

III. 폭행죄(형법 제260조 제1항)

1. 의의

사람의 신체나 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 폭행하는 내용의 범죄이다.

2. 구성요건

(1) 행위객체

사람의 신체이다. 여기서 사람은 자연인인 타인을 의미한다.

(2) 행위

폭행이다.

(가) 폭행의 개념

본죄의 폭행은 사람의 신체에 대한 직접적인 유형력의 행사를 말한다(협의의 폭행).

■ 형법상 폭행의 개념

유 형	내 용	보 기
최광의	대상(사람, 물건)을 불문하고 유형력을 행사하는 모든 경우	내란죄, 소요죄, 다중불해산죄
광의	사람에 대한 직접·간접의 유형력의 행사	공무집행방해죄, 도주죄, 강요죄
협의	사람의 신체에 대한 유형력의 행사	폭행죄, 특수공무원폭행죄, 외국원수 폭행죄, 존속폭행죄
최협의	상대방의 반항을 억압하거나 현저히 곤란하게 할 정도의 강력한 유형력의 행사	강도죄, 강간죄

(나) 폭행의 수단·방법

수단·방법은 무제한하다. 사람의 신체에 대한 일체의 공격방법이 가능하다. 예컨대 손과 발로 구타하거나 밀치는 행위, 사람에게 돌등의 물건을 집어 던지거나 침을 뱉거나 옷이나 손을 잡아당기는 행위 등이 이에 해당한다. 던진 돌이 명중하지 않고 스치거나 소지품에 맞은 경우와 같이 신체에 접촉하지 않는 유형력의 행사도 가능하다(대판 1990.2.13. 89도1406). 또한 소음에 의한 폭행도 가능하며, 폭언의 수차 반복도 폭행이다.

(다) 사람의 신체에 대한 유형력의 행사

유형력의 행사는 사람의 신체에 대한 것이어야 한다. 따라서 사람의 신체와 관계없는 유형력의 행사는 폭행이 아니다.

- ① 타인의 마당에 인분을 던지는 행위(대판 1977.11.28. 75도2673)
- ② 방문을 발로 차는 행위(대판 1984.2.14. 83도3186)
- ③ 상대방이 덤벼들면서 빵을 꼬집고 주먹으로 쥐어박기 때문에 상대방을 부등켜 안은 행위(대판 1977.2.8. 76도375)
- ④ 상대방의 시비를 만류하면서 조용히 이야기하자고 팔을 2, 3회 끌어당긴 행위(대판 1986.10.14. 86도1796)
- ⑤ 욕설을 한 것 외에 별다른 행위를 한 적이 없다면 이는 유형력의 행사라고 보기 어려울 것이다(대판 1990.2.13. 89도1406).

(3) 실행의 착수와 기수시기

폭행의 의사를 가지고 사람의 신체에 유형력의 행사를 직접 개시했을 때 실행의 착수가 인정된다. 본죄는 거동범이므로 유형력의 행사만 있으면 곧바로 기수가 된다. 다만 형법상의 폭행죄는 미수범을 처벌하지 않지만, 폭처법에 해당하는 폭행죄의 경우에는 미수범은 처벌된다(동법 제6조).

3. 반의사불벌죄

피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없고(제260조 제3항), 공소가 제기된 경우에는 공소기각의 판결을 선고해야 한다(형소법 제327조 6호). 그러나 폭처법의 적용을 받는 때에는 반의사불벌죄가 될 수 없다(폭처법 제2조 제4항).

♣ 확인학습문제

1. 甲은 국가대표 축구선수 乙의 황금의 오른쪽 다리를 완전히 못쓰게 만들어 축구계를 떠나게 할 작정으로 엽총으로 乙의 무릎을 겨냥하여 쏘았다. 그러나 원래 목적했던 결과는 발생하지 않고 단지 걷기에 불편한 정도의 부상을 입히는데 그쳤다. 甲의 형사책임은?

- ① 살인미수죄
- ② 중상해죄
- ③ 상해죄와 중상해미수죄의 상상적 경합
- ④ 상해죄
- ⑤ 중상해미수죄

[정답] ④

【해설】 단지 걷기에 불편한 정도에 그친 경우 신체의 고유기능이 상실된다고 볼 수 없기 때문에 중상해라고 볼 수는 없다. 또한 중상해죄는 미수를 처벌하는 규정이 없다. 따라서 단 순상해죄에 해당된다.

2. 다음의 상해죄에 관한 설명 중 판례의 태도와 다른 것은?

- ① 신체의 완전성을 훼손하거나 생리적 기능에 장애를 초래하는 것으로, 반드시 외부적인 상처가 있어야만 하는 것이 아니며, 생리적 기능에는 육체적 기능뿐만 아니라 정신적 기능도 포함된다.
- ② 폭행에 의해 실신한 후 한참 만에 정신을 차리게 되었다면 외부적으로 상처가 발생하지 않았다고 하더라도 상해죄가 성립한다.
- ③ 피해자인 여성을 강제로 눕혀 옷을 벗긴 뒤 1회용 면도기로 피해자의 음모를 위에서 아래로 가로 약 5cm, 세로 약 3cm 정도 깎은 경우 강제추행치상죄의 상해에 해당한다.
- ④ 상해죄의 성립에는 상해의 원인인 폭행에 대한 인식이 있으면 충분하고 상해를 가할 의사의 존재까지는 필요하지 않다.
- ⑤ 1~2개월간 입원할 정도로 다리가 부러진 상해 또는 3주간의 치료를 요하는 우측흉부자상은 중상해에 해당하지 않는다.

【정답】 ③

【해설】 피해자의 음모의 모근 부분을 남기고 모간 부분만을 일부 잘라냄으로써 음모의 전체적인 외관에 변형만이 생겼다면, 이로 인하여 피해자에게 수치심을 야기하기는 하겠지만, 그것이 폭행에 해당할 수 있음은 별론으로 하고 강제추행치상죄의 상해에 해당한다고 할 수는 없다(대판 2000.3.23. 99도3099).

3. 다음 중 판례에 의할 때 폭행에 해당하는 경우를 고른 것은?

- ① 사람에게 근접하여 욕설을 하면서 때릴 듯이 손발이나 물건을 휘두르거나 던지는 행위
- ② 타인의 집의 대문이나 방문을 발로 차는 행위
- ③ 욕설을 한 것 외에 별다른 행위를 한 적이 없는 경우
- ④ 상대방의 시비를 만류하면서 조용히 이야기하자고 팔을 2, 3회 끌어당긴 행위
- ⑤ 상대방이 덤벼들면서 뺨을 꼬집고 주먹으로 쥐어박기 때문에 상대방을 부등켜 안은 행위

【정답】 ①

【해설】 피해자에게 근접하여 욕설을 하면서 때릴 듯이 손발이나 물건을 휘두르거나 던지는 행위는 직접 피해자의 신체에 접촉하지 않았다고 하여도 피해자에 대한 불법한 유형력의 행사로서 폭행에 해당한다(대판 1990.2.13. 89도1406).

♣ 학습내용 정리

- 1. 상대적 상해개념이란 각 구성요건별로 상해가 가지는 기능에 착안하여 상해개념에 차이를 두어 경미한 상해를 배제시키고자 하는 이론이다.
- 2. 중상해죄는 부진정결과적 가중범으로 보아야 한다.
- 3. 폭행죄는 사람의 신체나 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 폭행하는 내용의 범죄이다.
- 4. 상해죄나 폭행죄에서 사람은 자연인인 타인을 의미한다.

제3강 특수폭행죄, 업무상 과실치상죄, 중과실치상죄

♣ 학습목표

- 특수폭행죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 업무상 과실의 의미를 설명할 수 있다.
- 중과실의 내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 특수폭행
- 흥기휴대
- 업무상 과실
- 중과실

♣ 사전테스트

- 범행과는 전혀 무관하게 우연히 흥기를 소지하는 경우는 휴대가 아니다.
정답 : O
- 법률상 규정된 주의를 다한 경우에는 업무상 과실은 문제될 수 없다.
정답 : X
- 중과실은 통상의 과실에 비해 주의의무를 현저히 태만히 한 경우이다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

위법한 사무는 업무상 과실에 있어 업무에 포함되지 않는다.

[정답] X

[해설] 무면허 운전과 같이 사무의 적법·위법도 업무에 포함된다.

♣ 강의내용

1. 특수폭행죄(형법 제261조)

1. 의의

특수폭행죄는 단체 또는 다종의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 사람의 신체에 대하여 폭행을 함으로써 성립하는 범죄이다.

2. 구성요건

(1) 단체 또는 다종의 위력을 보이는 경우

- ① 단체는 공동목적을 가진 다수인의 계속적·조직적 결합체로서 공동목적의 적법·불법을 불문한다. 단체는 어느 정도 계속성을 가질 것을 요한다.
- ② 다종은 단체를 이루지 못한 다수인의 집합으로 집단적 위력을 과시할 정도의 다수이면 족하다. 이 때 공동목적의 유무는 불문한다.
- ③ 위력을 보인다는 것은 사람의 의사를 제압할 만한 세력을 상대방에게 인식시키는 것을 말하며, 위력은 유형력·무형력을 불문한다. 위력을 보이는 것에 의하여 상대방의 의사가 현실로 제압될 필요도 없다.

(2) 위험한 물건의 휴대

(가) 위험한 물건

- ① ‘위험한 물건’이라 함은 객관적 성질이나 사용방법에 따라서 사람의 생명·신체에 해를 줄 수 있는 물건을 말한다. 위험한 물건의 위험성 여부는 구체적인 사안에 따라서 사회통념에 비추어 그 물건을 사용하면 상대방이나 제3자가 곧 살상의 위험을 느낄 수 있으리라고 인정되는 물건인가에 따라 판단하여야 한다(대판 1998.2.27. 97도3421). 즉 살상용으로 제조된 것뿐만 아니라 사용방법에 따라서 사람을 살상할 수 있으면 위험한 물건이 된다.

판례 (대판 1997.2.25. 96도3411)

司51

빈 양주병으로 머리를 내리쳐 타박상을 가한 경우, 그 빈 양주병은 ‘위험한 물건’에 해당한다.

- ② ‘위험한 물건을 휴대하여’라고 규정한 취지에 비추어 볼 때 위험한 물건은 동산에 한하며, 휴대가 불가능한 전신주, 돌담벽, 기둥, 콘크리트 바닥 등은 제외된다. 위험한 물건은 물체임을 요하므로 손이나 발과 같은 사람의 신체의 일부는 여기에 해당하지 않는다.

<위험한 물건을 인정한 경우>

- ① 피고인이 공기총에 실탄을 장전하지 아니하였다고 하더라도 범행 현장에서 공기총과 함께 실탄을 소지하고 있었고 피고인으로서 언제든지 실탄을 장전하여 발사할 수도 있으므로 공기총이 ‘위험한 물건’에 해당한다(대판 2002.11.26. 2002도4586). 辯2
- ② 피고인이 깨어진 유리조각을 들고 피해자의 얼굴에 던졌다면 이는 위험한 물건을 휴대하였다고 볼 것이다(대판 1982.2.23. 81도3074). 司44
- ③ 삼날 길이 21cm 가량의 야전삽이 폭력행위등처벌에관한법률 제3조 제1항 소정의 ‘흉기 기타 위험한 물건’에 해당한다(대판 2001.11.30. 2001도5268).

- ④ 자동차는 원래 살상용이나 파괴용으로 만들어진 것이 아니지만 사람의 생명 또는 신체에 위해를 가하거나 다른 사람의 재물을 손괴하는 데 사용되었다면 폭력행위등처벌에관한법을 제3조 제1항의 '위험한 물건'에 해당한다(대판 2003.1.24. 2002도5783).
- ⑤ 피고인은 자신의 애인인 피해자가 전화를 끊어버렸다는 이유로 피해자에게 농약을 먹이려 하고 당구큐대로 폭행한 사안에서, 농약과 당구큐대는 '위험한 물건'에 해당한다(대판 2002.9.6. 2002도2812).

<위험한 물건을 부정한 경우>

- ① 피고인이 당구장에서 피해자가 시끄럽게 떠든다는 이유로 당구공으로는 피해자의 머리를 툭툭 건드린 정도에 불과한 것으로 피고인이 당구공으로 피해자의 머리를 때린 행위로 인하여 사회통념상 피해자나 제3자에게 생명 또는 신체에 위험을 느끼게 하였으리라고 보이지 아니하므로 위 당구공은 폭처법상의 '위험한 물건'에는 해당하지 아니한다(대판 2008.1.17. 2007도9624). 辯2
- ② 피해자가 먼저 식칼을 들고 나와 피고인을 찌르려다가 피고인이 이를 저지하기 위하여 그 칼을 뺏은 다음 피해자를 혼계하면서 위 칼의 칼자루 부분으로 피해자의 머리를 가볍게 쳤을 뿐이라면 피해자가 위험성을 느꼈으리라고는 할 수 없다(대판 1989.12.22. 89도1570). 辯2

(나) 휴대 - '휴대하여'의 의미

1) 문제점

위험한 물건의 "휴대"라 함은 범행현장에서 사용할 의도 아래 위험한 물건을 몸 또는 몸 가까이 소지하는 것을 말한다(대판 1991.4.9. 91도427). 그런데 특수폭행죄의 성립에 있어서 '휴대하여'의 의미를 어떻게 해석할 것인가 하는지는 예컨대 자동차로 사람을 거칠게 밀어붙이는 등 일상적인 언어의 의미상 도저히 소지하였다고 할 수 없는 규모를 가진 위험한 물건을 사용하여 폭행한 경우에도 이를 '휴대하여' 폭행한 것으로 해석하여 특수폭행죄의 성립을 인정할 것인지와 직접 관련된 문제이다.

2) 판례의 태도

판례(대판 1997.5.30. 97도597)는 위험한 물건을 '휴대하여'라는 말은 소지뿐만 아니라 널리 이용한다는 뜻도 포함하고 있다는 입장인바, 판례에 의하면 자동차를 널리 이용한 폭행은 얼마든지 가능하므로 위의 사례에서 특수폭행죄가 성립한다.

(다) '휴대'에 대한 상대방의 인식의 요부

위험한 물건은 범행 이전부터 몸에 지녀야 할 필요는 없고 범행현장에서 소지한 경우도 포함된다. 이때 휴대를 상대방에게 인식시켜야 하는가와 관련하여 휴대사실은 단지 행위 수단 때문에 불법이 가중된 것에 불과하므로 위험한 물건의 존재를 피해자에게 인식시킬 필요도 없다(대판 2007.3.30. 2007도914).

(라) 범행과 무관한 우연한 휴대

휴대는 위험한 물건을 범행현장에서 그 범행에 사용하려는 의도로 소지하는 것을 말하므로 범행과는 전혀 무관하게 우연히 이를 소지하는 경우는 휴대가 아니다(대판 1990. 4.24. 90도401).

가령 甲이 어머니 심부름으로 주방에서 쓰는 식칼을 구입하여 귀가하다가 길거리에서 타인의 신용카드를 습득하게 되자, 이 신용카드를 현금자동인출기에서 현금을 인출한 경우 판례에 의하면 타인의 신용카드를 현금으로 인출한 경우 절도죄가 성립하는바, 甲이 절취행위 당시에 위험한 물건인 식칼을 소지하고 있었더라도 이는 절도를 위하여 소지한 것이 아니므로 현금인출행위에 대해서는 특수절도죄가 아니라 단순절도죄만이 성립한다.

(3) 폭행

폭행죄의 경우와 동일하다.

II. 업무상 과실치상죄(형법 제268조)

1. 의의

(1) 개념

업무상 과실치상죄는 업무상 과실로 사람을 사상함으로써 성립하는 범죄이다.

(2) 형가중의 근거

본죄의 업무와 같은 위험한 업무에 종사하는 자에게는 타인의 생명·신체를 침해하지 않도록 해야 할 고도의 주의의무가 있다(주의의무설).

2. 구성요건

(1) 행위주체

업무상 과실치상죄의 주체는 일정한 업무에 종사하는 자로 제한된다(부진정신분범).

(2) 업무상 과실

(가) 업무의 요건

사람이 사회생활상의 지위에서 계속적으로 행하는 사무이다.

1) 사회생활상의 지위

사회생활상의 지위에 따른 사무여야 하고, 자연적인 생활현상(식사, 수면, 가사 등)은 업무가 아니다. 예컨대 주부가 요리한 음식이 식중독을 유발한 경우에는 업무성을 인정할 수 없으나, 식당 주방장이 조리한 음식 때문에 식중독이 발생한 경우에는 업무성이 인정된다.

또한 생활수단인 사회적 활동의 성격을 갖는 한 업무성이 인정되므로 통상적인 비영업적 운전이나 자전거를 타고 완구를 배달하는 점원의 행위도 업무에 해당한다(대판 1972.5.9. 72도 701).

2) 계속성

객관적으로 상당한 횟수로 반복하여 행해지거나 반복·계속의 의사로 행해진 것이어야 한다. 따라서 호기심으로 단 1회 운전한 행위는 업무가 되지 않지만(대판 1966.5.31. 66도536), 단 1회의 행위라도 장래 반복할 의사로 행한 것이면 업무에 해당된다. 예컨대 자동차 시승운전, 개업의사의 첫 의료행위가 이에 해당한다. 다만 반복·계속은 매일 또는 단시일 안에 있어야 할 필요는 없다.

3) 사무

사무는 사람이 사회적 지위에서 계속적으로 하는 일로 사람의 생명·신체를 침해할 위험이 높은 일에 국한된다(ex. 자동차운전, 치료행위, 각종 위험시설물관리, 육아, 보육원의 아동보호행위 등). 또한 공무·

私務, 영리·비영리, 주된 사무·부수적 사무 등 업무의 종류를 불문한다. 사무의 적법·위법도 불문한다.ex.) 무면허의료행위나 무면허운전자의 운전이나(대판 1970.8.18. 70도820)

(나) 업무상 과실

이는 업무상 주의되는 의무를 태만히 하는 것을 말한다. 여기서 주의의무의 범위는 법령의 형식적 기준에 한하지 않고 관습·조리상 요구되는 모든 경우까지 포함한다. 따라서 법률상 규정된 주의를 다한 경우에도 업무상 과실은 문제될 수 있다.

III. 중과실치상죄(형법 제268조)

중과실치상죄는 행위자가 보여준 경솔·무모한 태도로 주의의무위반이 극히 현저한 경우이다. 즉, 통상의 과실에 비해 주의의무를 현저히 태만히 한 경우이다(경솔한 과실).

<중과실이 인정된 경우>

- ① 성냥불이 꺼진 것을 확인하지 아니한 채 플라스틱 휴지통에 던진 경우(대판 1993.7.27. 93도135).
- ② 피고인이 84세 여자 노인과 11세의 여자아이를 상대로 안수기도를 함에 있어서 그들을 바닥에 반드 시 눕혀 놓고 기도를 한 후 한 손 또는 두 손으로 그들의 배와 가슴 부분을 세게 때리고 누르는 등의 행위를 여자 노인에게는 약 20분간, 여자아이에게는 약 30분간 반복하여 그들을 사망케 한 경우 (대판 1997.4.22. 97도538).

<중과실이 부정된 경우>

- ① 호텔오락실의 경영자가 그 오락실 천정에 형광등을 설치하는 공사를 하면서 그 호텔의 전기보안담당자에게 아무런 통고를 하지 아니한 채 무자격 전기기술자로 하여금 전기공사를 하게 한 경우(대판 1989.10.13. 89도204).
- ② 연탄아궁이로부터 80센티미터 떨어진 곳에 쌓아둔 스폰지 요, 솜 등이 연탄아궁이 쪽으로 넘어지면 서 화재현장에 의한 화재가 발생한 경우(대판 1989.1.17. 88도643).
- ③ 경찰관인 피고인들은 동료 경찰관인 甲 및 피해자 乙과 함께 술을 많이 마셔 취하여 있던 중 갑자기 甲이 총을 꺼내 乙과 같이 총을 번갈아 자기의 머리에 대고 쏘는 소위 “러시안 룰렛 게임”을 하다가 乙이 자신이 쏜 총에 맞아 사망한 경우(대판 1992.3.10. 91도3172). → 甲에게는 중과실치상죄가 인정되었음.

♣ 확인학습문제

1. 특수폭행죄에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 부동산의 일부인 전신주나 돌담벽 또는 기둥이나 신체의 일부인 주먹은 위험한 물건에 해당하지 않는다.
- ② 甲이 깨어진 유리조각을 들고 피해자의 얼굴에 던졌다면 이는 특수폭행죄에 해당한다.
- ③ 자동차범퍼로 사람을 들이받은 경우에도 특수폭행죄에 해당한다.
- ④ 범행에 사용할 의도로 위험한 물건을 소지하면 족하고 피해자에게 이를 인식시킬 필요는 없다.
- ⑤ 특수폭행죄는 폭행죄에 대하여 행위방법의 위험성 때문에 불법이 가중되는 구성요건이므로 범행과는 무관하게 위험한 물건을 소지한 경우에도 본죄에 해당된다.

【정답】 ⑤

【해설】 "흥기 기타 위험한 물건을 휴대하여 그 죄를 범한 자"란 범행현장에서 그 범행에 사용하려는 의도아래 흥기를 소지하거나 몸에 지니는 경우를 가리키는 것이지 그 범행과는 전혀 무관하게 우연히 이를 소지하게 된 경우까지를 포함하는 것은 아니다(대판 1990.4.24, 90도401).

2. 甲과 업무상과실치사상죄에 있어서의 업무의 개념에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 업무는 사회생활상의 지위에 따른 업무이어야 한다. 따라서 家事로서의 취사·세탁·냉난방·육아 등은 사회생활상의 지위에 따른 것이 아니므로 업무가 될 수 없다.
- ② 업무는 객관적으로 상당한 횟수 반복하여 행하여지거나 또는 반복·계속할 의사로 행해진 것이어야 한다. 따라서 호기심으로 단 1회 운전한 것만으로는 업무라고 할 수 없다.
- ③ 업무는 그것이 사무인 이상 본무·경무·부수적 업무인가를 불문하고, 또 공무·사무 여부도 불문하며, 영리를 위한 것이건 오락을 위한 것이건 상관없다.
- ④ 업무는 사람이 사회생활상의 지위에 기하여 계속해서 행하는 사무인 이상, 생명·신체에 대하여 위험성 있는 업무일 필요는 없다.
- ⑤ 업무는 사회생활상 용인되는 사무인 이상, 적법한 업무인가 또는 부적법한 업무인가를 불문한다. 따라서 무면허운전자의 운전행위나 무면허의사의 치료행위도 업무에 속한다.

【정답】 ④

【해설】 업무상과실치사상죄에서의 업무란, 본죄의 보호법익이 생명·신체의 건강에 있다는 점에 비추어, 그 성질상 생명·신체에 대하여 위험성 있는 업무여야 한다.

3. 甲과 乙은 안수기도를 하면서 교대로 고령의 여자노인(84세)의 배와 가슴부분을 약 20분간 반복하여 손으로 세게 때리고 눌러 사망케 하였다. 甲과 乙사이 누구의 행위에 의하여 사망하였는지 판명되지 아니한 경우 甲과 乙의 죄책은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 과실치사죄의 공동정범
- ② 중과실치사죄의 공동정범
- ③ 과실치사죄의 미수
- ④ 무죄
- ⑤ 상해치사죄의 공동정범

【정답】 ②

【해설】 고령의 여자 노인은 약간의 물리력을 가하더라도 골절이나 타박상을 당하기 쉽고, 더욱이 배나 가슴 등에 그와 같은 상처가 생기면 치명적 결과가 올 수 있다는 것은 피고인 정도의 연령이나 경험 지식을 가진 사람으로서는 약간의 주의만 하더라도 쉽게 예견할 수 있음에도 그러한 결과에 대하여 주의를 다하지 않아 사람을 죽음으로까지 이르게 한 행위는 중대한 과실이라고 보아, 피고인에 대하여 중과실치사죄로 처단한 원심판결을 수긍한 사례(대판 1997.4.22, 97도538).

♣ 학습내용 정리

1. 특수폭행죄에 있어 위험한 물건의 "휴대"라 함은 원칙적으로 범행현장에서 사용할 의도 아래 위험한 물건을 몸 또는 몸 가까이에 소지하는 것을 말한다.
2. 업무상 과실치사상죄의 주체는 일정한 업무에 종사하는 자로 제한되지만, 중과실치사상죄의 주체에는 제한이 없다.
3. 업무상 과실치사상죄에 있어 주의의무의 범위는 법령의 형식적 기준에 한하지 않고 관습·조리상 요구되는 모든 경우까지 포함한다.

제4강 낙태죄와 유기죄

♣ 학습목표

- 낙태죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 유기죄와 영아유기죄의 의미와 내용을 설명할 수 있다.
- 학대죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 낙태
- 이치와 치거
- 영아유기
- 학대죄

♣ 사전테스트

- 범행과는 전혀 무관하게 우연히 흉기를 소지하는 경우는 휴대가 아니다.
정답 : O
- 유기죄에서 요부조에는 경제적 요부조자도 포함된다.
정답 : X
- 학대죄에서 학대행위는 단순히 상대방의 인격에 대한 반인륜적 침해만으로는 부족하고 적어도 유기에 준할 정도에 이르러야 한다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

임산부가 자연적인 분만기 전에 태아를 모체 밖으로 배출을 시킨 경우 낙태죄에 해당한다는 것이 판례의 태도이다.

[정답] X

[해설] 해당 내용은 최근 헌법재판소에서 헌법불합치를 받아 더이상 낙태죄를 구성하지 않는다.

♣ 강의내용

I. 낙태죄

낙태죄는 2019년 4월 11일 헌법재판소의 2017헌바127 결정에 따라 형법 제269조 제1항 및 제270조 제1항에 대하여 헌법불합치 결정이 내려졌고, 입법자가 개정 시한인 2020년 12월 31일까지 법률을 개정하지 않아 위 조항들은 2021년 1월 1일부터 효력을 상실하였다. 다만 낙태죄 관련 규정 전체가 효력을 상실한 것은 아니며, 형법 제269조 제2항·제3항 및 제270조 제2항은 조문상 여전히 존재한다.

1. 동의낙태죄(형법 제269조 제2항)

- ① 임신부의 촉탁·승낙을 받아 낙태케 함으로써 성립하는 범죄로 자기낙태죄와 필요적 공범관계에 있다(대항범). 행위는 부녀의 촉탁·승낙을 받아 낙태하게 하는 것이다.
- ② 여기서 촉탁이란 임부가 낙태를 의뢰·부탁하는 행위를 말하고, 승낙이란 시술자 쪽에서 낙태에 관한 부녀의 동의를 얻는 행위를 말한다. 여기서 촉탁·승낙이나 승낙은 임부가 자유로운 상태에서 진의로 의사표시를 한 경우여야 하므로 촉탁·승낙이 폭행·협박에 의하여 강요되거나, 중대한 착오나 기만에 의하여 이루어진 경우에는 진의에 의한 촉탁·승낙이라고 할 수 없으므로 부동의낙태죄를 구성한다.
- ③ 낙태하게 하는 것이란 본죄의 주체가 스스로 낙태행위를 하는 것을 말한다. 따라서 본인이 직접 시술하지 않고 임부에게 낙태를 교사·방조한 경우에는 자기낙태죄의 교사범·방조범이 될 뿐이다.

II. 단순유기죄(형법 제271조 제1항)

1. 의 의

유기죄란 노유·질병 기타 사유로 인하여 부조를 요하는 자를 보호할 의무 있는 자가 유기함으로써 성립하는 범죄이다. 유기죄의 성격은 의무범적 진정신분범이다.

2. 구성요건

(1) 행위주체

요부조자를 보호해야 할 법률상 또는 계약상 의무를 갖고 있는 보호의무자이다. 여기서 보호의무란 요부조자의 생명·신체에 대한 위험으로부터 요부조자를 보호해주어야 할 의무를 말한다.

(가) 법률상의 보호의무

- ① 보호의무가 법률에 규정되어 있는 경우로 공·사법을 불문한다. ex) 경찰관직무집행법상의 경찰관의 보호조치 의무(제4조), 도로교통법상의 사고운전자의 구호의무(제54조 제1항, 제148조) 등
- ② 보호의무가 민법상 부양의무와 반드시 일치하여야 할 필요는 없다. 왜냐하면 유기죄에서는 요부조자는 일상생활을 하기 위한 동작에 타인의 조력이 필요한 자임에 반하여, 민법상의 피부양자는 경제적 곤궁으로 인하여 경제적 부양이 필요한 자이므로 보호의무자와 부양의무자의 의무의 내용이 다르기 때문이다. 따라서 민법상 선순위부양의무자가 있다고 하더라도 후

순위부양의무자가 요부조자를 사실상 보호하고 있다면 후순위부양의무자가 유기죄의 주체가 된다.

- ③ 누구에게나 과해지는 일반적인 법적 의무, 즉 일반적 부조의무는 신분의 특수성이 인정될 수 없으므로 본죄의 보호의무가 될 수 없다. ex.) 경범죄처벌법 제1조 7호의 요부조자 신고의무

(나) 계약상의 보호의무

계약은 명시적·묵시적, 유상·무상을 불문한다. 또한 피유기자가 반드시 계약당사자일 필요는 없으며, 가령 치매노인의 자녀들과 계약을 맺고 간병을 담당하는 간병인이 치매노인을 영양실조에 걸리게 한 경우와 같이 유기자와 제3자 사이의 계약도 무방하다.

(다) 관습·조리·사무관리에 근거한 보호의무의 인정 여부

형법규정(제271조 제1항)은 유기죄의 보호의무의 발생근거를 법률상 또는 계약상의 의무로 제한하고 있다. 그러나 보호의무를 작위의무의 일종으로 파악하게 된다면 보호의무의 발생근거는 위법한 선행행위·관습·조리·사무관리에까지 확대될 수 있다. 예컨대 실화행위자가 실화 후에 불이 난 건물 안에 우연히 술 취한 사람이 자고 있는 것을 발견했으나 살해의 고의 없이 방치하여 자고 있던 사람이 소사한 경우가 이에 해당한다.

이에 대하여 판례는(대판 1977.1.11. 76도3419) “현행 형법은 유기죄에 있어서 구법과는 달리 보호법익의 범위를 넓힌 반면에 보호책임없는 자의 유기죄는 없애고 법률상 또는 계약상의 의무있는 자만을 유기죄의 주체로 규정하고 있어 명문상 사회상규상의 보호책임을 관념할 수 없다.”고 판시하여 부정설을 취하고, 다수견해도 판례와 동일하게 부정설을 취한다.

(라) 부진정부작위범의 보증인지위에 대한 관계

유기죄의 보호의무와 부진정부작위범의 보증인지위의 성립범위가 일치하는가가 문제된다. 왜냐하면 유기죄의 보호의무의 발생근거인 법령, 계약은 부진정부작위범의 보증인지위의 발생근거로도 기능하며, 또한 유기죄는 부작위에 의하여도 성립이 가능하기 때문이다.

이에 대하여 각칙의 특별규정은 총칙의 규정에 우선하는 것이므로 입법자가 유기죄의 보호의무를 법률상·계약상의 의무로 제한한 취지에 따라 설사 부작위에 의한 유기의 경우라 할지라도 보호의무의 발생근거는 확장될 수 없다. 따라서 그러므로 유기죄의 보호의무와 부진정부작위범의 보증인지위의 성립범위는 일치하지 않고, 후자가 전자보다 넓은 개념이다.

(2) 행위객체

노유, 질병 기타 사정으로 인하여 부조를 요하는 자이다. 요부조자란 다른 사람의 도움 없이는 자기의 생명·신체에 대한 위험을 스스로 극복할 수 없는 자를 말한다. 그리고 기타 사정이라 함은 요부조자의 범위를 확대하는 일반요건으로 만취자, 마취·최면상태에 있는 자, 장애인, 분만중의 부녀자 등이 해당된다. 다만 경제적 요부조자는 포함되지 않는다.

(3) 행위 : 유기이다.

(가) 의의 및 유형

유기란 요부조자를 보호하지 않음으로써 그의 생명·신체에 위험을 가져오는 행위를 말한다. 유기의 종류에는 ① 적극적 유기(移置)가 있는데, 이는 요부조자를 보호 받는 상태에서 보호 없는 상태로 옮기는 것이다(협의의 유기). 여기서는 요부조자를 장소적으로 이전할 것을 필요로 한다(ex. 고려장). ② 또한 소극적 유기(置去)가 있는데, 이는 요부조자를 종래 상태대로 두고 떠나거나 생존에 필요한 보호를 하지 않는 것이다(광의의 유기). 즉 요부조자를 장소적으로 이전하지 않

고 생명·신체에 위험을 초래하는 일체의 행위를 말한다. 통설과 판례는 적극적 유기와 소극적 유기를 유기행위태양으로 포괄한다.

(나) 수단·방법 및 기수시기

유기의 수단·방법에는 제한이 없다. 유형적·무형적, 작위·부작위를 불문한다. 따라서 단순히 요부조자가 위험에 빠지는 것을 방치한 경우도 유기가 된다. 그리고 유기죄는 추상적 위법범이므로 유기행위만으로도 기수가 성립한다. 따라서 타인의 구조를 기대할 수 있거나, 타인의 구조가 없으면 스스로 구조할 의사로 근처에 머물고 있는 때에도 본죄가 성립한다.

III. 영아유기죄(형법 제272조)와 학대죄(형법 제273조 제1항)

1. 영아유기죄

- ① 본죄는 직계존속이 치욕을 은폐하기 위하거나, 양육할 수 없음을 예상하거나, 특히 참작할 만한 동기로 인하여 영아를 유기함으로써 성립하는 범죄이다.
- ② 본죄는 ㉠ 법률상·계약상의 의무 있는 자만이 주체가 될 수 있다는 점에서 진정신분범의 성격을 지니고 있고, ㉡ 직계존속이 영아유기죄를 범할 때에는 특수한 범행동기로 인하여 직계존속 이외의 사람이 영아유기죄를 범할 때에 비하여 형벌이 감경된다는 점에서 부진정신분범의 요소를 지니고 있다.
- ③ 본죄의 영아는 부조 없이는 활동할 수 없는 유아 일반을 의미한다. 따라서 영아살해죄의 ‘분만 중 또는 분만 직후의 영아’와는 그 의미에서 구별된다.

2. 학대죄

- ① 학대죄란 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람을 학대함으로써 성립하는 범죄이다. 학대죄는 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에게 육체적으로 고통을 주거나 정신적으로 차별대우를 하는 행위가 있음과 동시에 범죄가 완성되는 상태범 또는 즉시범이라 할 것이다(대판 1986.7.8. 84도2922).
- ② 본죄의 행위주체는 사람을 보호 또는 감독하는 신분자이다(진정신분범). 본죄는 유기죄와는 달리 보호·감독의 근거가 법률·계약에 제한되지 않고 사무관리·관습·조리에 의해서도 가능하다.
- ③ 본죄의 행위는 학대이다. 학대의 의미는 피해자에게 정신적·육체적 고통을 가하는 가혹한 대우를 의미한다. 그리고 학대의 정도에 있어서 학대의 개념에는 생명·신체의 안전을 위태롭게 할 만한 행위만이 포함된다고 해야 한다(헌재성의 원칙). 따라서 학대행위는 단순히 상대방의 인격에 대한 반인륜적 침해만으로는 부족하고 적어도 유기에 준할 정도에 이르러야 한다(대판 2000.4.25. 2000도223).

♣ 확인학습문제

1. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 대한민국 헌법재판소는 형법 제269조 제1항 및 제270조 제1항에 대하여 헌법불합치 결정을 하였다.
- ② 헌법재판소는 위 조항들에 대하여 입법개선 시한을 정하여 그 시한까지 입법이 이루어지지 않을 경우 해당 조항이 효력을 상실하도록 하였다.
- ③ 입법자가 헌법재판소가 정한 시한까지 법률을 개정하지 아니함에 따라 형법 제269조 제1항 및 제270조 제1항은 2021년 1월 1일부터 효력을 상실하였다.

- ④ 헌법재판소는 형법상 낙태죄 규정 전체가 헌법에 위반된다고 판단하였다.
- ⑤ 형법 제269조 제2항·제3항 및 제270조 제2항의 규정은 헌법재판소의 심판 대상이 아니었다.

[정답] ④

[해설] 대한민국 헌법재판소는 2019.4.11. 결정(2017헌바127)에서 형법상 낙태죄 규정 전체에 대해 판단한 것이 아니라 **일부 조항만을 심판 대상으로 삼아 판단하였다.**
헌법재판소가 심판 대상으로 삼은 조항은 다음 두 조항이다.

- **형법 제269조 제1항** : 자기낙태죄
- **형법 제270조 제1항** : 의사 등의 낙태죄

헌법재판소는 위 조항들이 임신 전 기간에 걸쳐 낙태를 전면적으로 형사처벌하는 점에서 임신한 여성의 자기결정권을 과도하게 제한하여 과잉금지원칙에 위반된다고 보았다.

2. 유기죄에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 자동차 운전수가 교통사고를 내어 통행인을 부상시키고 도주하면 유기죄가 성립하나, 상해범이 기절한 피해자를 그대로 두고 도주하면 유기죄가 성립하지 않는다.
- ② 타인이 구조하지 않으면 다시 데리고 올 생각으로 타인의 집 대문 앞에 유아를 버리고 근처에서 지켜보고 있어도 유기죄는 성립한다.
- ③ 유기죄는 법문상 법률상 또는 계약상의 보호의무 있는 자만이 주체가 될 수 있으나 판례는 조리, 관습, 또는 사회상규에 의한 보호의무도 인정한다.
- ④ 유기죄는 진정신분범에 해당하며, 또한 살인죄에 대해 보충관계에 있으므로 유기시에 사망에 대한 예견·인용이 있으면 살인죄가 성립한다.
- ⑤ 동거 또는 내연관계를 맺은 사정만으로는 법률혼에 준하는 보호를 받는 사실혼관계를 인정할 수 없다.

[정답] ③

[해설] 판례는(대판 1977.1.11. 76도3419) 현행 형법에 의하면 명문상 사회상규상의 보호 책임을 관념할 수 없다고 판시하여 부정설을 취한다.

3. 유기죄에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 강간치상범이 실신상태에 있는 피해자를 구호하지 않고 숲 속에 방치한 경우에 강간치상죄외에 별도로 유기죄는 성립하지 않는다.
- ② 어머니가 전격성간염에 걸려 장내출혈의 증세까지 생긴 만11세 남짓한 딸에게 수혈이 최선의 치료방법이라는 의사의 권유를 받았으나 종교적인 이유로 수혈을 거부함으로써 사망하게 한 경우에는 유기치사죄가 성립한다.
- ③ 자신이 운영하는 주점에 손님으로 와서 수일 동안 식사는 한 끼도 하지 않은 채 계속하여 술을 마시고 만취한 피해자를 주점 내에 그대로 방치하여 저체온증 등으로 사망에 이르게 한 경우에는 법률상 또는 계약상의 부조의무를 인정할 수 있으므로 유기치사죄의 성립을 인정할 수 있다.
- ④ 유기죄에서의 보호의무는 부진정부작위범에서의 보증인의무와 동일하다.
- ⑤ 피고인과 피해자가 특정지점까지 가기 위하여 길을 같이 걸어간 관계가 있다는 사실만으로는 피고인에게 피해자를 구조해야 할 의무가 발생하지 않는다.

[정답] ④

[해설] 유기죄의 보호의무와 부진정부작위범의 보증인지위의 성립범위는 일치하지 않고, 후자가 전자보다 넓은 개념이다.

♣ 학습내용 정리

1. 유기죄란 노유·질병 기타 사유로 인하여 부조를 요하는 자를 보호할 의무 있는 자가 유기함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 영아유기죄는 직계존속이 치욕을 은폐하기 위하거나, 양육할 수 없음을 예상하거나, 특히 참작할 만한 동기로 인하여 영아를 유기함으로써 성립하는 범죄이다.
3. 학대죄는 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람을 학대함으로써 성립하는 범죄이다.

제5강 협박죄

♣ 학습목표

협박죄의 의의를 말할 수 있다.

협박과 경고의 차이를 설명할 수 있다.

협박죄의 기수시기에 대한 판례와 학설의 입장을 설명할 수 있다.

사회상규에 반하지 않는 협박이 협박죄를 구성하는지를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

협박

경고

해악의 고지

협박죄의 기수시기

♣ 사전테스트

1. 협박죄에 대하여는 미수범처벌규정이 있다

정답 : O

2. 판례는 협박죄를 다수견해와 동일하게 침해범으로 이해한다.

정답 : X

3. 협박행위가 사회상규상 용인될 만한 수단으로 평가되고, 권리남용이 아닌 한 위법성이 조각된다.

정답 : O

♣ 돌발퀴즈

협박은 범죄행위이지만 경고는 범죄행위가 아니다.

[정답] O

[해설] 해악발생에 대한 경계를 촉구하는 충고에 불과한 경고는 범죄행위가 아니라는 점에서 협박과 구별된다.

♣ 강의내용

I. 의의

1. 내용

협박죄(형법 제283조 제1항)는 사람을 협박함으로써 성립하는 범죄이다. 다른 범죄와의 구별에 있어서 본죄는 의사결정의 자유와 함께 행동의 자유까지도 보호하는 강요죄와 구별되고 재물·재산상의 이익을 목적으로 하는 공갈죄와도 구별된다.

2. 보호법익·보호정도

보호법익은 개인의 자유로운 신체활동의 전제가 되는 개인의 의사결정의 자유이다. 그리고 보호정도는 위험범이다(판례). 그러나 다수설은 본죄를 침해범으로 본다.

3. 미수범의 처벌

폭행죄와는 달리 본죄에 대하여는 미수범처벌규정이 있다(형법 제286조).

4. 특별형법

- ① 본죄를 2인 이상이 공동하여 범하거나 집단적으로 범하는 경우에는 본죄가 적용되지 않고 폭처법 제2조, 제3조에 의해 가중 처벌된다.
- ② 형사사건의 수사·재판과 관련하여 보복 등의 목적으로 협박죄를 범한 자는 특가법 제5조의 2 제2항에 의하여 가중 처벌된다.

II. 구성요건

1. 행위객체

협박죄의 객체는 살아 있는 사람이다. 다만 본죄는 자연인만을 그 대상으로 예정하고 있을 뿐 법인은 협박죄의 객체가 될 수 없다.

판례 (대판 2010.7.15. 2010도1017) 辯1·2·3 司56

[1] 협박죄에서 협박이란 일반적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 정도의 해악을 고지하는 것을 의미하며, 그 고지되는 해악의 내용, 즉 침해하겠다는 법익의 종류나 법익의 향유 주체 등에는 아무런 제한이 없다. 따라서 피해자 본인이나 그 친족뿐만 아니라 그 밖의 '제3자'에 대한 법익 침해를 내용으로 하는 해악을 고지하는 것이라고 하더라도 피해자 본인과 제3자가 밀접한 관계에 있어 그 해악의 내용이 피해자 본인에게 공포심을 일으킬 만한 정도의 것이라면 협박죄가 성립할 수 있다. 이 때 '제3자'에는 자연인뿐만 아니라 법인도 포함된다 할 것인데, 피해자 본인에게 법인에 대한 법익을 침해하겠다는 내용의 해악을 고지한 것이 피해자 본인에 대하여 공포심을 일으킬 만한 정도가 되는지 여부는 고지된 해악의 구체적 내용 및 그 표현방법, 피해자와 법인의 관계, 법인 내에서의 피해자의 지위와 역할, 해악의 고지에 이르게 된 경위, 당시 법인의 활동 및 경제적 상황 등 여러 사정을 종합하여 판단하여야 한다.

[2] 협박죄는 사람의 의사결정의 자유를 보호법익으로 하는 범죄로서 형법규정의 체계상 개인적 법익, 특히 사람의 자유에 대한 죄 중 하나로 구성되어 있는바, 위와 같은 협박죄의 보호법익, 형법규정상 체계, 협박의 행위 개념 등에 비추어 볼 때, 협박죄는 자연인만을 그 대상으로 예정하고 있을 뿐 법인은 협박죄의 객체가 될 수 없다.

[3] 채권추심 회사의 지사장이 회사로부터 자신의 횡령행위에 대한 민·형사상 책임을 추궁당할 지경에

이르자 이를 모면하기 위하여 회사 본사에 ‘회사의 내부비리 등을 금융감독원 등 관계 기관에 고발하겠다’는 취지의 서면을 보내는 한편, 위 회사 경영지원본부장이자 상무이사에게 전화를 걸어 자신의 횡령 행위를 문제삼지 말라고 요구하면서 위 서면의 내용과 같은 취지로 발언한 사안에서, 위 상무이사에 대한 협박죄를 인정한 원심의 판단을 수긍한 사례.

2. 행위 : 협박이다.

(1) 형법상 협박의 개념

구 분	개 념	해 당 범 죄
광의 (일반적 의미)	일반적으로 사람에게 공포심을 일으키게 할 만한 해악을 고지하는 것(위협범). 상대방이 현실로 공포심을 일으켰음을 요하지 않는다.	공무집행방해죄(제136조), 소요죄(제115조), 특수도주죄(제146조), 직무강요죄(제136조 제2항), 다중불해산죄(제116조)
협 의	일정한 해악의 고지로 상대방을 현실로 외포케 하는 것(침해범)	협박죄(제283조), 공갈죄(제350조), 강요죄(제324조)
최협의	상대방의 반항을 현저히 곤란하게 하거나 상대방의 반항을 억압할 정도의 공포심을 일으킬 해악을 고지하는 것(침해범)	강간죄(제297조), 강제추행죄(제298조), 강도죄(제333조), 준강도죄(제335조), 점유강취죄(제325조)

(2) 협박죄의 협박

(가) 의의

협박이란 상대방에게 해악을 고지하는 것을 말한다. 협박은 해악의 발생이 직접·간접적으로 행위자에 의하여 좌우될 수 있어야 한다는 점에서 해악발생에 대한 경계를 촉구하는 충고에 불과한 경고와 구별된다. 협박은 범죄행위이지만 경고는 범죄행위가 아니므로 이에 대한 구별이 불가피하게 요구될 수밖에 없다.

예컨대 공부를 열심히 하지 아니하면 시험에 떨어진다고 말하는 것은 경고에 불과하지만, 무슨 수를 써서라도 공부를 하는 것을 방해하여 시험에 떨어지게 만들겠다고 해악을 통보하는 것은 협박이 된다.

(나) 해악의 내용

해악의 내용에는 제한이 없고, 본인뿐만 아니라 본인과 밀접한 관계에 있는 제3자에 대한 것도 불문한다. 작위 뿐만 아니라 부작위도 포함하며 어느 직에 취임하면 살해하겠다는 조건부라도 무방하다. 해악의 발생시기도 현재·미래를 불문한다. 집단절교나 따돌림(왕따)을 통보하는 행위도 협박이 될 수 있다.

다만 협박죄가 성립하기 위해서는 적어도 발생가능한 것으로 생각될 수 있는 정도의 구체적인 해악의 고지가 있어야 한다. 이 때 고지되는 해악의 내용이 불법적인 필요도 없으므로 고소권의 행사와 같은 정당한 권리의 행사의 고지도 협박이 될 수 있다(통설).

그러나 같은 동리에 사는 동년배간에 동장직을 못하게 하였다는 불만의 표시로서 “두고 보자”는 말을 한 경우와 같이 해악의 고지가 아닌 단순한 폭언정도로는 협박에 해당한다고 하기 어렵다.

[1] 형법 제283조에서 정하는 협박죄의 성립에 요구되는 ‘협박’이라고 함은 일반적으로 그 상대방이 된 사람으로 하여금 공포심을 일으키기에 충분한 정도의 해악을 고지하는 것으로서, 그러한 해악의 고지에 해당하는지 여부는 행위자와 상대방의 성향, 고지 당시의 주변 상황, 행위자와 상대방 사이의 관계·지위, 그 친숙의 정도 등 행위 전후의 여러 사정을 종합하여 판단되어야 한다. 한편 여기서의 ‘해악’이란 법익을 침해하는 것을 가리키는데, 그 해악이 반드시 피해자 본인이 아니라 그 친족 그 밖의 제3자의 법익을 침해하는 것을 내용으로 하더라도 피해자 본인과 제3자가 밀접한 관계에 있어서 그 해악의 내용이 피해자 본인에게 공포심을 일으킬 만한 것이라면 협박죄가 성립할 수 있다.

[2] 피고인이 혼자 술을 마시던 중 A정당이 국회에서 예산안을 강행처리하였다는 것에 화가 나서 공중전화를 이용하여 경찰서에 여러 차례 전화를 걸어 전화를 받은 각 경찰관에게 경찰서 관할구역 내에 있는 A정당의 당사를 폭파하겠다는 말을 한 사안에서, 피고인은 A정당에 관한 해악을 고지한 것이므로 각 경찰관 개인에 관한 해악을 고지하였다고 할 수 없고, 다른 특별한 사정이 없는 한 일반적으로 A정당에 대한 해악의 고지가 각 경찰관 개인에게 공포심을 일으킬 만큼 서로 밀접한 관계에 있다고 보기 어렵다.

(다) 해악의 고지의 방법

무제한하다. 언어나 문서·거동에 의하더라도 무방하며 문서인 경우 허무인 명이나 익명으로 하더라도 관계없다. 직접적·간접적, 명시적·묵시적을 불문한다. 제3자를 시켜서 할 수도 있고, 가해자가 제3자이더라도 무방하다. 그리고 해악의 통고는 조건부인 경우도 상관없다.

2인 이상이 공동하여 협박한 경우에는 폭처법 제2조 제2항이 우선 적용된다.

(3) 기수시기

- ① 협박죄를 침해범으로 보면 해악의 고지로 인하여 상대방이 현실로 공포심을 느꼈을 때 기수가 된다. 그러나 해악을 고지하였으나 전혀 공포심을 느끼지 않은 경우에는 본죄의 미수가 된다. 이는 다수견해의 태도이다.
- ② 이에 대하여 본죄를 위험범으로 보면 상대방에게 해악을 고지하여 상대방이 이를 인지하게 될 때 기수가 된다. 이는 판례의 태도이다.

[판결요지] 협박죄의 기수에 이르기 위하여 상대방이 현실적으로 공포심을 일으킬 것을 요하는지 여부(소극) [다수의견] (가) 협박죄가 성립하려면 고지된 해악의 내용이 행위자와 상대방의 성향, 고지 당시의 주변 상황, 행위자와 상대방 사이의 친숙의 정도 및 지위 등의 상호관계, 제3자에 의한 해악을 고지한 경우에는 그에 포함되거나 암시된 제3자와 행위자 사이의 관계 등 행위 전후의 여러 사정을 종합하여 볼 때에 ① 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기에 충분한 것이어야 하지만, 상대방이 그에 의하여 현실적으로 공포심을 일으킬 것까지 요구하는 것은 아니며, 그와 같은 정도의 ② 해악을 고지함으로써 상대방이 그 의미를 인식한 이상, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부와 관계없이 그로써 구성요건은 충족되어 협박죄의 기수에 이르는 것으로 해석하여야 한다. (나) 결국, ① 협박죄는 사람의 의사결정의 자유를 보호법익으로 하는 위험범이라 봄이 상당하고, ② 협박죄의 미수범 처벌조항은 ㉠ 해악의 고지가 현실적으로 상대방에게 도달하지 아니한 경우나, ㉡ 도달은 하였으나 상대방이 이를 지각하지 못하였거나 ㉢ 고지된 해악의 의미를 인식하지 못한 경우 등에 적용될 뿐이다.

(4) 고의

협박죄에 있어서의 협박이라 함은 일반적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지하는 것을 의미하므로 그 주관적 구성요건으로서의 고의는 행위자가 그러한 정도의 해악을 고지한다는 것을 인식, 인용하는 것을 그 내용으로 하고 고지한 해악을 실제로 실현할 의도나 욕구는 필요로 하지 아니한다(대판 1991.5.10. 90도2102).

III. 위법성

1. 협박행위가 권리행사의 수단으로 행해진 경우

이 문제는 ‘목적과 수단의 관계’에 비추어 결정하여야 한다. 따라서 사회상규상 용인될 만한 수단으로 평가되고, 권리남용이 아닌 한 위법성이 조각된다(통설, 판례). 예컨대 채무변제를 독촉할 목적으로 생명·신체에 대한 위해를 고지한 경우 위법성이 조각되지 않는다.

판례 (대판 1984.6.26. 84도648)

피해자가 甲을 대리하여 동인 소유의 여관을 피고인에게 매도하고 피고인으로부터 계약금과 잔대금 일부를 수령하였는데 그 후 甲이 많은 부채로 도피해 버리고 동인의 채권자들이 채무변제를 요구하면서 위 여관을 점거하여 피고인에게 여관을 명도하기가 어렵게 되자 피고인은 피해자에게 여관을 명도 해주던가 명도소송비용을 내놓지 않으면 고소하여 구속시키겠다고 말한 경우 피고인이 매도인의 대리인인 위 피해자에게 위 여관의 매도 또는 명도소송비용을 요구한 것은 매수인으로서 정당한 권리행사라 할 것이며 위와 같이 다소 위협적인 말을 하였다고 하여도 이는 사회통념상 용인될 정도의 것으로서 협박으로 볼 수 없다.

2. 형사고소를 하겠다고 고지하여 협박한 경우

목적과 수단의 관계에 비추어 불법적 목적을 달성하기 위해 고소권을 남용한 것이 아닌 한 위법성이 조각된다(통설, 판례). 따라서 공금을 횡령한 직원에게 유용한 돈을 보전해 놓지 않으면 고소하겠다고 하는 것은 정당한 권리행사이나, 성관계를 갖지 않으면 고소하겠다고 하는 것은 권리남용이 되어 협박이 된다(이 때에는 사안에 따라서 강요죄나 강간죄의 성부가 문제된다).

IV. 반의사불벌죄

본죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(형법 제283조 제3항).

♣ 확인학습문제

1. 다음 기술 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 협박죄는 의사결정의 자유와 함께 행동의 자유까지도 보호하는 강요죄와 구별되고 재물·재산상의 이익을 목적으로 하는 공갈죄와도 구별된다.
- ② 협박죄의 객체는 사람이고, 사법상 권리능력이 인정되는 법인도 본죄의 객체가 될 수 있다.
- ③ 보호법익의 정도와 관련하여 협박죄는 위험범이다.
- ④ 협박죄에서 해악은 현재의 위해만이 아니라 장래의 위해까지 포함하며, 해악의 실행의 여부가 조건부여도 상관없다.
- ⑤ 2인 이상이 공동하여 협박한 경우에는 폭처법 제2조 제2항이 우선 적용된다.

[정답] ②

[해설] 협박죄의 객체는 사람인바, 사람이란 자연인인 타인을 의미하므로 법인은 본죄의 객체가 될 수 없다(대판 2010.7.15. 2010도1017).

2. 협박죄에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 허무인 명의나 익명으로 작성된 문서에 의한 해악의 고지는 협박이 될 수 없다.

- ② 피고인이 피해자의 장모가 있는 자리에서 서류를 보이면서 “피고인의 요구를 들어주지 않으면 서류를 세무서로 보내 세무조사를 받게 하여 피해자를 망하게 하겠다”라고 말하여 피해자의 장모로 하여금 피해자에게 위와 같은 사실을 전하게 하고, 그 다음날 피해자의 처에게 전화를 하여 “며칠 있으면 국세청에서 조사가 나올 것이니 그렇게 아시오”라고 말한 경우 협박죄를 구성한다.
- ③ 협박죄의 기수는 상대방이 그에 의하여 현실적으로 공포심을 일으킬 것까지 요구하는 것은 아니며, 그와 같은 정도의 해악을 고지함으로써 상대방이 그 의미를 인식한 이상, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부와 관계없이 그로써 구성요건은 충족 된다.
- ④ 협박의 고의는 행위자가 그러한 정도의 해악을 고지한다는 것을 인식, 인용하는 것을 그 내용으로 하고 고지한 해악을 실제로 실현할 의도나 욕구는 필요로 하지 아니한다.
- ⑤ 권리행사나 직무집행의 일환으로 상대방에게 일정한 해악을 고지한 경우, 그 해악의 고지가 정당한 권리행사나 직무집행으로서 사회상규에 반하지 아니하는 때에는 협박죄가 성립하지 아니한다.

[정답] ①

[해설] 해악의 고지의 방법은 무제한하다. 언어나 문서·거동에 의하더라도 무방하며 문서인 경우 허무인 명이나 익명으로 하더라도 관계없다.

3. 채권추심 A회사의 지사장 甲은 회사로부터 자신의 횡령행위에 대한 민,형사상 책임을 추궁 당할 지경에 이르자 이를 모면하기 위하여 A회사 본사 앞으로 ‘회사의 내부비리 등을 금융감독원 등 관계 기관에 고발하겠다.’는 취지의 서면을 보내는 한편, A 회사 경영지원본부장이자 상무이사 乙에게 전화를 걸어 자신의 횡령행위를 문제삼지 말라고 요구하면서 위 서면의 내용과 같은 취지로 발언하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① A 회사에 대한 협박죄
 ② 乙에 대한 협박죄
 ③ A 회사에 대한 협박미수죄와 乙에 대한 협박죄
 ④ A 회사와 乙에 대한 협박죄
 ⑤ 무죄

[정답] ②

[해설] 법인인 A 회사는 협박죄의 객체가 될 수 없으나, 乙에게 제3자인 A 회사에 대한 해악을 고지한 행위는 乙에 대한 협박죄는 성립한다.

♣ 학습내용 정리

1. 협박죄는 사람을 협박함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 협박이란 상대방에게 해악을 고지하는 것을 말한다.
3. 해악의 고지에 있어 해악의 내용에는 제한이 없고, 본인뿐만 아니라 본인과 밀접한 관계에 있는 제3자에 대한 것도 불문한다.
4. 판례에 따라 협박죄를 위험범으로 보면 상대방에게 해악을 고지하여 상대방이 이를 인지하게 될 때 기수가 된다.

제6강 체포·감금죄, 약취·유인죄

♣ 학습목표

- 체포·감금죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 체포·감금죄의 죄수를 설명할 수 있다.
- 미성년자약취·유인죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 미성년자약취·유인죄의 가중적 구성요건을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 체포와 감금
- 약취와 유인
- 계속범
- 영리의 목적

♣ 사전테스트

1. 체포·감금죄는 계속범이다.
정답 : ○
2. 부작위에 의한 감금은 인정될 수 없다.
정답 : X
3. 성년자에 대한 약취·유인은 일반적으로 처벌되지 아니한다.
정답 : ○

♣ 돌발퀴즈

미성년자를 보호·감독하는 친권자나 감독자는 미성년자약취·유인죄의 주체가 될 수 없다.

[정답] X

[해설] 미성년자를 보호·감독하는 친권자나 감독자도 본죄의 주체가 될 수 있다.

♣ 강의내용

1. 체포·감금죄(형법 제276조 제1항)

1. 의의

사람을 체포·감금함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 계속범이다.

2. 구성요건

(1) 행위객체

사람이다. 여기서 사람이란 범인 이외의 자연인을 의미한다. 본죄의 보호법익이 잠재적 신체활동의 자유인 한, 신체활동의 자유를 향유하는 사람이면 현실적인 신체활동의 자유가 침해되었는가를 묻지 않고 본죄의 객체가 될 수 있다. 따라서 정신병자도 감금죄의 객체가 될 수 있다.

(2) 행위

체포 또는 감금이다.

(가) 체포

사람의 신체에 직접적·현실적 구속을 가하여서 행동의 자유를 빼앗는 일체의 행위이다. 체포의 수단·방법에는 제한 없다. 유형적·무형적 방법(ex. 경찰관사칭), 작위·부작위(ex. 석방해야할 의무가 있는 자가 풀어주지 않는 경우)를 불문하고, 제3자의 행위를 이용하는(간접정범) 경우도 가능하다. 반드시 신체에 대한 물리적 구속일 필요는 없다(ex. 총을 겨누고 피해자를 협박하여 동행하게 하는 경우).

여기서 체포에 해당하는가의 여부는 전체적으로 행동의 자유가 박탈되었는가를 기준으로 파악해야 한다. 따라서 부분적 자유가 있는 체포도 얼마든지 가능하다. 그러나 체포는 신체에 대한 현실적 구속이 있을 것을 요하므로 일정한 장소에 출석하도록 위협하여 출석케 하는 것은 강요죄에 해당한다.

(나) 감금

감금이란 예컨대 가옥, 방실, 차량과 같이 일정한 구획을 가진 장소에 사람을 가두어 그 장소 밖으로 벗어나지 못하게 하거나 심히 곤란하게 함으로써 신체활동의 자유를 장소적으로 제한하는 것을 말한다. 따라서 달리는 차량에서 하차를 시켜주지 않거나 사람이 지붕위에 있는데 사다리를 치워버리는 행위도 감금에 해당한다.

감금은 장소적 제한이 있다는 점과 신체에 대한 직접적인 구속을 하지 않는 점에서 체포와 구별된다. 감금의 수단·방법은 제한이 없다. 작위·부작위, 유형·무형의 수단을 불문하며, 간접정범에 의한 감금도 성립할 수 있다(ex. 허위신고를 통한 공권력에 의한 구속). 이 때 감금에 의한 자유박탈이 전면적일 필요는 없으며, 상대적 감금으로써 충분하다.

(3) 기수시기

본죄는 계속범이므로 체포·감금행위는 일정한 시간적 계속을 필요로 한다. 체포·감금의 고의 없는 일시적인 자유박탈은 폭행죄를 구성할 뿐이지만, 체포·감금의 고의로 일시적 자유박탈에 그친 경우는 본죄의 미수가 성립한다.

3. 위법성

(1) 정당행위

검사·사법경찰관의 영장에 의한 체포·구속, 현행범체포 등

(2) 피해자의 승낙에 의한 행위

체포·감금죄는 의사자유에 관한 범죄이므로 체포·감금죄에 있어서 피해자의 승낙은 구성요건해당성을 조각하는 양해가 된다.

4. 죄수

- ① 사람을 체포하여 감금한 때에는 감금죄의 포괄일죄가 된다.
- ② 체포·감금에 필수적 수단이 된 폭행·협박은 불가벌적 수반행위로 본죄에 흡수된다(대판 1982. 6.22. 82도705). 司54
- ③ 감금행위는 강간행위의 일부가 아닌 별개의 행위이고, 감금행위 자체가 강간의 수단인 폭행·협박행위를 이루고 있는 경우에는 행위의 단일성이 인정되어 양죄는 상상적 경합관계가 된다. → 조개트럭사건(대판 1983.4.26. 83도323) 司41·47·50·55
- ④ 강도·강간의 수단이 되는데 그치지 아니하고 범행이 끝난 뒤에도 계속된 경우 → 월드컵 경기장 교통사고 사건(대판 2003.1.10. 2002도4380) 辯3 司47·49·50·53·54·55 → 실체적 경합

II. 미성년자약취·유인죄(형법 제287조)

1. 의의

(1) 개념

미성년자를 약취·유인함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 계속범이다.

(2) 보호법익

피인취자(미성년자)의 자유권 및 보호자의 감독권이다(통설, 판례).

(3) 성년자에 대한 약취·유인과 구별

성년자에 대한 약취·유인은 일반적으로 처벌되지 아니한다. 다만 약취·유인의 수단이 예컨대 폭행죄·협박죄와 같이 다른 범죄를 구성하는 경우와 일정한 목적을 가지고 행해짐으로써 형법 제288조, 제289조의 범죄를 구성하는 경우에는 처벌된다.

2. 구성요건

(1) 행위주체

피해자 이외의 모든 자연인이다. 미성년자를 보호·감독하는 친권자나 감독자도 본죄의 주체가 될 수 있다.

(2) 행위객체

미성년자이다. 미성년자인 한 성별, 의사능력, 활동능력의 유무를 불문한다. 미성년자라 함은 민법을 기준으로 하여 19세 미만의 사람이다. 혼인한 미성년자도 본죄의 객체가 될 수 있다.

(3) 행위 : 약취·유인이다.

(가) 약취·유인

- ① 사람을 자유로운 생활관계 또는 보호관계로부터 자기 또는 제3자의 실력적 지배하에 옮기는 행위이다. 양자를 합쳐서 ‘인취’라고도 한다.
- ② 약취는 폭행·협박을 수단으로 한다. 폭행·협박의 정도는 미성년자를 실력적 지배 하에 둘 수 있는 정도면 충분하고 상대방의 반항을 억압할 정도일 필요는 없다.
- ③ 유인은 기망·유혹에 의한다. 기망이란 허위사실로 상대방을 착오에 빠지게 하는 것이다. 반면에 유혹이란 기망의 정도는 아니면서 감언으로 상대방을 현혹시켜 판단력을 흐리게 하는 것을 말한다. 의사능력 있는 자만이 유인의 대상이 될 수 있으므로 의사능력이 없는 유아에 대해서는 약취죄만 성립한다.

(나) 폭행·협박, 기망·유혹의 상대방

피인취자는 물론이고, 보호감독자에 대해서도 행해질 수 있다.

(다) 실력적 지배의 설정

약취·유인이 인정되기 위해서는 피인취자를 자기 또는 제3자의 실력적 지배상태에 두어야 한다. 여기서 사실적 지배라고 함은 미성년자에 대한 물리적·실력적인 지배관계를 의미한다. 따라서 미성년자를 자기의 실력적 지배 하에 두지 못하고 단순히 달아나게 하는 것만으로는 본죄가 성립하지 않는다.

그리고 미성년자를 장소적으로 이전하는 것이 본죄의 요건이 되는가와 관련해서는 보호자를 폭행·협박·기망 등으로 떠나게 하고 피해자를 자기의 실력적 지배하에 둘 수도 있기 때문에 장소적 이전은 요건이 아니다.

(4) 실행의 착수 및 기수시기

약취·유인의 고의를 가지고 약취·유인의 수단인 폭행·협박, 기망·유혹을 상대방에게 개시한 때 실행의 착수가 있다. 그리고 피인취자가 행위자 또는 제3자의 실력적 지배하에 놓임으로써 현실적으로 자유가 침해된 때 기수가 된다. 본죄는 계속범이므로 기수가 성립하기 위해서는 피인취자의 자유침해가 어느 정도 시간의 계속을 필요로 한다.

3. 위법성조각사유 : 피해자의 승낙

본죄의 보호법익은 미성년자의 자유권과 보호자의 감독권이 모두 포함된다. 따라서 승낙은 미성년자와 보호자 모두로부터 있어야 한다. 그러므로 피인취자인 미성년자의 승낙만으로는 위법성이 조각되지 않는다. 그러나 본인과 보호자 모두의 승낙이 있는 때에는 본죄는 의사자유에 관한 범죄이므로 구성요건해당성이 배제되는 양해가 된다(다수설).

III. 추행·간음 등 약취·유인죄(형법 제288조 제1항)

I. 의의

추행·간음·결혼·영리·노동력착취·성매매와 장기적출목적으로 사람을 약취 또는 유인함으로써 성립하는 범죄이다(목적범).

2. 구성요건

본죄의 객체에는 제한이 없다. 미성년자를 본죄의 목적으로 인취할 경우 본죄가 우선하여 성립한다. 영리의 목적은 행위자 또는 제3자에게 재산상의 이익을 얻게 할 목적이다. 이때 이득은 계속적·반복적일 필요는 없고, 인취행위 자체로부터 직접 얻은 이익뿐만 아니라 인취 후 피인취자가 일정한 업무에 종사하게 됨으로써 얻은 대가도 포함한다. 행위자가 이러한 목적으로 사람을 약취·유인하면 기수에 이르고, 목적의 달성 여부는 기수성립과는 무관하다.

가령 17세의 소녀를 간음할 목적으로 약취·유인하였으나 다음날 그 소녀가 탈출하여 간음하지 못한 경우 간음목적약취·유인죄가 성립한다. 또는 18세의 여자를 유흥주점에 팔 생각으로 유인하여 자기 집에 데리고 있으면서 강간한 후, 유흥주점 업주에게 넘기려다 검거된 경우 성매매목적유인죄가 성립하고 강간죄와 실체적 경합이 된다.

영리의 목적에는 노동력착취·성매매와 장기적출목적이 포함되나, 본조 제2항은 제1항에 대하여 특별관계에 있다 할 것이므로 노동력착취 등의 목적이 있는 경우에는 제2항이 우선 적용된다.

다만 본죄는 계속범이므로 기수가 되기 위해서는 피인취자를 행위자 또는 제3자의 실력적 지배하에 두고 어느 정도 시간이 지나야 함은 당연하다.

3. 세계주의

“형법 제287조부터 제292조까지 및 제294조는 대한민국 영역 밖에서 죄를 범한 외국인에게도 적용한다(형법 제296조의2).”

세계주의는 범죄지, 범죄인의 국적을 불문하고 문명에서 공통적으로 인정되는 세계적 법익을 침해하는 행위에 대하여 자국형법을 적용한다는 원칙을 말한다. 형법 제296조의2가 새로 삽입됨으로써 최소한 인신매매죄와 관련하여 범죄지, 범죄인의 국적을 불문하고 인신매매죄에 대하여 우리 형법이 적용될 수 있게 되었다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 사례에서 甲과 乙의 죄책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

사장 甲은 자신이 추진하는 사업에 반대하는 장인(丈人) A를 주주총회에 참석하지 못하게 하기 위하여 친구 乙에게 “어떻게 해서든 네 차에 A를 태워 여기저기 돌아다니면서 A가 총회장에 참석할 수 없도록 해라”고 교사하였고, 乙은 이를 승낙하였다. 乙은 사건 당일 집을 나오는 A를 협박하여 강제로 승용차에 태운 뒤 A의 하차요구에도 불구하고 몇 시간 동안 도로를 주행하다가 집에 데려다 주었다.

- ① 위 사례에서 甲은 존속감금죄의 교사범의 죄책을 진다.
- ② A가 정신병자인 경우에도 乙에게는 감금죄가 성립하는 데 지장이 없다.
- ③ 감금하기 위해 그 수단으로 행사된 협박에 대해서는 별개의 죄가 성립하지 않는다.
- ④ 만약 乙이 A를 자동차에 감금한 상태에서 A를 폭행·협박하여 금품을 강취한 후 약 1시간 동안 도로를 주행하다가 집으로 데려다 주고 도주하였다면, 乙은 감금죄와 강도죄의 상상적 경합의 죄책을 진다.
- ⑤ 만약 A가 감금상태를 벗어나기 위하여 달리던 차량을 빠져나오다가 길바닥에 떨어져 사망하였다면, 乙이 A의 사망을 예견할 수 있었던 경우 乙은 감금치사죄의 죄책을 진다.

【정답】 ④

【해설】 감금행위가 단순히 강도상해 범행의 수단이 되는 데 그치지 아니하고 강도상해의 범행이 끝난 뒤에도 계속된 경우에는 1개의 행위가 감금죄와 강도상해죄에 해당하는 경우라고 볼 수 없고, 이 경우 감금죄와 강도상해죄는 형법 제37조의 경합범 관계에 있다(대판 2003.1.10. 2002도4380).

2. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 체포·감금죄의 객체는 살아 있는 자연인만이 될 수 있다.
- ② 감금에 있어서 사람의 행동의 자유의 박탈은 반드시 전면적이어서 할 필요가 없다
- ③ 감금행위 자체가 강간의 수단인 폭행·협박행위를 이루고 있는 경우에는 행위의 단일성이 인정되어 양죄는 상상적 경합관계가 된다.
- ④ 미성년자 약취·유인죄의 성립에 있어 미성년자인 피인취자의 승낙은 본죄의 위법성을 조각하지 않는다.
- ⑤ 미성년자 약취유인죄에서 약취와 유인은 폭행, 협박, 기망 또는 유혹을 한 것으로 족하며 피인취자를 자기 또는 제3자의 사실적 지배하에 둘 필요는 없다.

【정답】 ⑤

【해설】 약취와 유인이라고 하기 위하여는 단순히 폭행, 협박, 기망 또는 유혹을 한 것만으로 족하지 않고 피인취자를 자기 또는 제3자의 사실적 지배하에 두지 않으면 안 된다.

3. 다음 약취와 유인의 죄에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?(특별법위반은 논외로 하고, 다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 17세의 소녀를 간음할 목적으로 약취·유인하였으나 다음날 그 소녀가 탈출하여 간음하지 못한 경우 간음목적약취·유인죄가 성립한다.
- ② 영리목적약취·유인죄에서 영리의 목적은 행위자 또는 제3자에게 재산상의 이익을 얻게 할 목적이다.
- ③ 18세의 여자를 유흥주점에 팔 생각으로 유인하여 자기 집에 데리고 있으면서 강간한 후, 유흥주점 업주에게 넘기려다 검거된 경우 미성년자유인죄와 강간죄의 경합범이 성립한다.
- ④ 결혼을 목적으로 여성을 납치한 경우에는 결혼목적약취죄가 성립한다.
- ⑤ 범죄지, 범죄인의 국적을 불문하고 인신매매죄에 대하여 우리 형법이 적용될 수 있다.

【정답】 ③

【해설】 유흥주점에 팔 생각으로 유인하였다면 영리목적이 인정되므로 성매매목적유인죄가 성립하고 강간죄와 실체적 경합관계에 있게 된다.

♣ 학습내용 정리

- 1. 체포·감금죄는 사람을 체포·감금함으로써 성립하는 범죄로 본죄는 계속범이다.
- 2. 체포·감금죄는 계속범이므로 체포·감금행위는 일정한 시간적 계속이 있어야 기수가 된다.
- 3. 미성년자약취·유인죄에서 미성년자라 함은 민법을 기준으로 하여 19세 미만의 사람이다.
- 4. 미성년자약취·유인죄에서 장소적 이전은 요건이 아니다.

제7강 강요죄와 강간죄

♣ 학습목표

- 강요죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 인질강요죄의 의미를 설명할 수 있다.
- 강간죄의 법리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 강요죄
- 인질강요죄
- 권리행사방해와 의무 없는 일의 강요
- 강간

♣ 사전테스트

1. 영아, 정신병자 등도 강요행위의 객체가 될 수 있다.
정답 : X
2. 인질강요죄의 제3자에는 법인, 법인격 없는 단체는 포함되나, 국가기관은 포함되지 않는다.
정답 : X
3. 강간죄의 폭행은 절대적 폭력, 강제적 폭력을 불문한다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

강간죄는 친고죄이다.

[정답] X

[해설] 본죄는 친고죄가 아니다.

♣ 강의내용

1. 강요죄(형법 제324조)

1. 개념

강요죄는 폭행 또는 협박으로 사람의 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 함으로써 성립하는 범죄이다. 강요죄는 그 성격상 의사자유를 성립요건으로 하는 다른 범죄, 예컨대 강도·공갈·강간·강제추행·체포·감금 등에 이르지 않은 전단계행위를 처벌하기 위한 의미를 가지고 있다. 따라서 강도죄·공갈죄 등이 성립하면 강요죄는 배제된다. 가령 법정에 증인으로 출석하지 않으면 구속시키겠다고 피해자를 협박하여 법정에 출석하게 하였다면 신체에 대한 현실적인 구속이 없으므로 체포죄가 아니라 강요죄에 해당한다.

2. 구성요건

(1) 행위객체

사람이다. 여기서 사람이란 의사자유를 가진 자연인이다. 다만 공포심을 느낄만한 정신적 능력 있는 자에게 국한된다. 이 때 폭행·협박을 당한 사람과 권리행사를 방해당한 사람이 동일인일 필요는 없다(이른바 삼각강요).

(2) 행위

폭행 또는 협박으로 사람의 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 하는 것이다. 따라서 본죄는 결합범이다.

(가) 폭행·협박

1) 내용

본죄에서 폭행은 광의의 폭행개념으로 사람의 의사결정 및 의사활동에 영향을 미쳐서 강제효과를 발생시킬 수 있는 직접·간접의 유형력의 행사를 의미한다(ex. 맹인의 지팡이를 빼앗거나, 가혹명도를 받기 위해 문을 폐쇄하거나, 전기·수도·가스의 공급을 끊는 경우). 한편, 본죄는 침해범이므로 협박은 해악을 고지하여 공포심을 일으켜야 한다(협의의 협박개념). 그 내용에 제한이 없고 적법·불법을 불문한다.

2) 폭행·협박의 정도

상대방의 반항을 불가능하게 할 만큼 높은 정도일 필요는 없으나 최소한 상대방의 의사결정과 의사활동에 제한을 가할 정도로 영향을 미칠 수 있어야 한다. 그러므로 장래에 닥칠 불이익을 인식하고 고통을 느낄 수 없는 영아, 정신병자 등은 강요행위의 객체가 될 수 없다.

(나) 권리행사방해와 의무 없는 일의 강요

상대방에게 폭행·협박을 하여 행사할 수 있는 권리를 행사하지 못하게 하거나(부작위), 의무 없는 일을 하게 하는 것이다(작위). 권리행사방해와 의무 없는 일의 강요는 법률행위 또는 사실행위를 불문한다.

1) 권리행사의 방해

권리의 내용은 반드시 법률상의 것이 아니라도 상관없고, 재산적 권리·비재산적 권리를 불문한다. 예컨대 정당한 도로통행이나 건물에의 출입을 방해하는 것, 차량에의 진행을 방해하는 것, 고소권자가 고소권을 행사하는 것을 방해하는 것 등이 이에 해당한다. 그러나 권리를 행사한다고 볼 수 없는 자에 대한 폭행·협박은 본죄를 구성하지 않는다.

2) 의무 없는 일의 강요

의무 없는 자에 대해 일정한 작위·부작위 또는 수인을 강요하는 모든 행위이다. 여기서 의무는 도덕상의 의무가 아니라 법률상의 의무를 말한다. 예컨대 정당한 고소를 취하하게 만드는 것, 억지로 사과광고를 내도록 하거나 회사의 중요기밀을 누설하게 하는 것, 계약서, 진정서, 사표를 강제로 쓰게 하는 것 등이 이에 해당한다. 의무인 한 공법상의 의무·사법상의 의무를 불문한다. 여기에서 ‘의무 없는 일’이란 법령, 계약 등에 기하여 발생하는 법률상 의무 없는 일을 말하므로 법률상 의무 있는 일을 하게 한 경우에는 강요죄가 성립할 여지가 없다.

(다) 실행의 착수시기와 기수시기

실행의 착수는 강요의 의사로 폭행·협박을 개시한 때이며, 기수시기는 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 강요하는 결과가 발생한 때이다. 강요죄는 결과범이므로 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 강요하는 결과가 발생하지 않은 경우는 강요미수이다.

3. 위법성조각사유 - 권리행사와 강요죄

행위자가 달성하고자 하는 목적과 수단의 관계를 고려해야 한다. 즉 정당한 목적을 위하여 사회상규상 용인될 만한 수단으로 평가된다면 강요행위의 위법성이 조각될 수 있다. 그러나 목적이 정당하더라도 투입한 수단이 상당성을 초과한 경우는 강요죄가 성립한다. ex) 상해, 방화, 인신매매에 의한 권리행사

II. 인질강요죄

1. 의의

인질강요죄는 사람을 체포·감금·약취·유인하여 인질로 삼아 제3자에 대하여 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 체포·감금죄와 강요죄 또는 약취·유인죄와 강요죄의 결합범으로서 강요죄에 대한 가중구성요건이다.

2. 구성요건

(1) 행위객체

체포·감금·인질행위의 객체인 사람과 강요행위의 객체인 사람(제3자)이다. 다만 체포·감금·인질행위의 객체인 사람은 누구든 상관없으나, 강요행위의 객체인 사람은 최소한 의사결정능력이나 의사활동능력을 지닌 사람이어야 한다.

인질과 제3자인 피강요자 사이에는 신분관계가 있을 것을 요하지 아니하므로 제3자에는 법인, 법인격 없는 단체, 국가기관도 포함된다. 따라서 항공기를 공중납치 하여 승객을 인질로 삼고, 항공기 소속 국가의 정부에 특정한 행위를 강요하는 경우에도 본죄가 성립한다.

(2) 행 위

체포·감금·약취·유인하여 이를 인질로 삼아 강요하는 것이다.

(가) 체포·감금·약취·유인

반드시 처음부터 강요의 목적으로 체포·감금·약취·유인하였을 것을 요하지 않는다. 따라서 다른 목적으로 사람을 체포·감금·약취·유인한 이후에 비로소 인질강요의 고의가 생긴 경우에도 본죄가 성립한다. 체포·감금·약취·유인의 수단에 의하지 않는 경우는 단순강요죄가 성립할 뿐이고, 본죄는 성립하지 않는다.

(나) 인질행위

인질행위라 함은 체포·감금·약취·유인된 자의 생명·신체의 안전에 대한 제3자의 우려를 이용하여 석방이나 안전보장을 권리행사방해나 의무강요의 대상으로 이용하는 것을 말한다. 인질의 수단은 생명·신체에 대한 권리를 행위자의 처분 아래에 두는 것이면 충분하고 그 방법의 구체적 내용은 불문한다.

그리고 인질행위에 있어 장소적 이전은 필요하지 않다. 따라서 테러범이 공연장을 급습하여 공연장의 관객들을 인질로 삼은 경우에도 본죄에 해당한다.

(다) 강요행위

체포·감금 또는 약취·유인된 자를 인질로 삼아 제3자의 의사활동의 자유를 침해하는 행위, 즉 권리행사의 방해와 의무 없는 행위를 강요하는 것이다. 현행법상 강요의 상대방은 제3자이므로 인질에 대한 강요는 본죄를 구성하지 않고, 단순강요죄가 성립할 뿐이다. → 인질강요죄의 강요에는 인질에 대한 강요는 포함될 수 없다.

III. 강간죄

1. 의의

본죄는 폭행 또는 협박으로 사람을 강간함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄의 보호법익은 개인의 성적 자기 결정권이다. 보호정도는 침해범으로서의 보호이다. 본죄는 친고죄나 반의사불벌죄가 아니다.

2. 구성요건

(1) 행위주체

본죄의 주체는 사람으로 제한이 없다. 사람인 이상 남녀를 불문한다.

(2) 행위객체

(가) 범위

본죄의 객체는 사람이다. 사람인 이상 남녀를 불문한다. 사람인 이상 기혼·미혼, 성년·미성년, 음행상습, 성관계, 성교능력여부를 묻지 않는다. 그리고 13세 미만의 사람을 폭행·협박을 하여 강간하면 미성년자의제강간죄가 아니라 본죄가 성립한다.

(나) 법률상의 처가 객체가 될 것인지 여부 - 긍정(판례)

판례는(대판 2013.5.16. 2012도14788,2012전도252 전원합의체) “형법이 강간죄의 객체로 규정하고 있는 ‘부녀’란 성년이든 미성년이든, 기혼이든 미혼이든 불문하며 곧 여자를 가리킨다. 이와 같이 형법은 법률상 처를 강간죄의 객체에서 제외하는 명문의 규정을 두고 있지 않으므로, 문언 해석상으로도 법률상 처가 강간죄의 객체에 포함된다고 새기는 것에 아무런 제한이 없다.”는 입장이다.

(3) 행위

폭행·협박으로 사람을 강간하는 것이다.

(가) 폭행·협박

폭행은 사람에 대한 유형력의 행사이고, 협박은 상대방에게 해악을 통고하는 것이다. 이 때 폭행은 사람에게 직접 가해져야 하지만, 협박은 제3자를 대상으로 하여도 무방하다. 제3자에 대한 폭행은 피해자인 사람에 대해서는 협박이 된다. 폭행·협박의 정도는 상대방의 반항을 완전하게 불가능하게 하는 경우뿐만 아니라 반항을 현저하게 곤란하게 하는 정도로 족하다.

폭행의 유형은 가령 마취제, 수면제의 사용, 최면술을 거는 경우와 같은 절대적 폭력과 함께 강제적 폭력으로 상대방이 반항을 포기하게 한 경우도 포함된다. 그리고 폭행·협박은 시기적으로 간음의 종료 이전에 행해져야 한다.

(나) 강간

강간은 상대방의 반항불능·현저한 반항곤란을 이용하여 사람을 간음하는 것이다.

(다) 실행의 착수시기

사람을 강간하기 위하여 폭행·협박을 개시한 때이다. 이때 실제로 그와 같은 폭행 또는 협박에 의하여 피해자의 항거가 불능하게 되거나 현저히 곤란하게 되어야만 실행의 착수가 있다고 볼 수는 없다(대판 2000.6.9. 2000도1253).

즉 피해자의 항거가 현저하게 곤란할 정도의 폭행을 가하였으나 피해자가 워낙 격렬하게 저항하는 바람에 결국 강간에 실패한 경우에도 강간의 실행의 착수는 인정된다.

3. 非親告罪

본죄는 친고죄가 아니다.

♣ 확인학습문제

1. 강요죄에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 피해자를 협박하여 그로 하여금 법률상 의무 없는 진술서를 작성하게 한 경우에는 강요죄가 성립한다.
- ② 강요죄에서 방해의 대상이 되는 타인의 권리에는 재산적 권리 뿐 아니라 비재산적 권리도 포함된다.
- ③ 강요죄의 의무에는 도덕상의 의무도 포함한다.
- ④ 정당한 목적을 위하여 사회상규상 용인될 만한 수단으로 평가된다면 강요행위의 위법성이 조각될 수 있다.
- ⑤ 법률상 의무 있는 일을 하게 한 경우에는 강요죄가 성립할 여지가 없다.

[정답] ③

[해설] 본죄에서 의무 없는 자에 대해 일정한 작위·부작위 또는 수인을 강요하는 모든 행위이다. 여기서 의무는 도덕상의 의무가 아니라 법률상의 의무를 말한다.

2. 다음 인질강요죄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 인질강요죄는 체포·감금죄와 강요죄 또는 약취·유인죄와 강요죄의 결합범이다.
- ② 인질행위에 있어 장소적 이전은 필요하지 않다.
- ③ 인질강요죄의 강요에는 인질에 대한 강요는 포함될 수 없다.
- ④ 인질과 제3자인 피강요자 사이에는 신분관계가 있을 것을 요한다.
- ⑤ 체포·감금·약취·유인의 수단에 의하지 않는 경우는 단순강요죄가 성립할 뿐이고, 인질강요죄는 성립하지 않는다.

[정답] ④

[해설] 인질과 제3자인 피강요자 사이에는 신분관계가 있을 것을 요하지 아니한다.

3. 다음 강간죄에 관한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 강간죄의 객체는 부녀로서 남자는 강간죄의 객체가 될 수 없다.
- ② 13세 미만의 사람을 폭행·협박을 하여 강간하면 미성년자의제강간죄가 아니라 강간죄가 성립한다.
- ③ 법률상 처도 강간죄의 객체에 포함된다.
- ④ 강간죄의 폭행·협박의 정도는 상대방의 반항을 완전하게 불가능하게 하는 경우뿐만 아니라 반항을 현저하게 곤란하게 하는 정도로도 족하다.
- ⑤ 강간죄의 실행의 착수시기는 강간의 의사로 폭행·협박을 개시한 때이다.

[정답] ①

[해설] 본죄의 객체는 사람이다. 사람인 이상 남녀를 불문한다.

♣ 학습내용 정리

- 1. 강요죄는 그 성격상 의사자유를 성립요건으로 하는 다른 범죄, 예컨대 강도·공갈·강간·강제추행·체포·감금 등에 이르지 않은 전단계행위를 처벌하기 위한 의미를 가지고 있다.
- 2. 인질강요죄는 사람을 체포·감금·약취·유인하여 인질로 삼아 제3자에 대하여 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 함으로써 성립하는 범죄이다.
- 3. 강간죄는 폭행 또는 협박으로 사람을 강간함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄의 보호법익은 개인의 성적 자기 결정권이다.
- 4. 강간죄의 주체는 사람으로 제한이 없다. 사람인 이상 남녀를 불문한다.

제8강 강제추행죄, 준강간·강제추행죄, 미성년자에 대한 성범죄

♣ 학습목표

- 강제추행죄를 설명할 수 있다.
- 준강간·강제추행죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 미성년자에 대한 성범죄의 법리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 강제추행
- 준강간, 준강제추행
- 의제강간, 의제강제추행
- 위계간음

♣ 사전테스트

1. 강제추행죄는 남녀 모두 행위의 주체나 객체가 될 수 있다.
정답 : O
2. 미성년자 의제강간·강제추행죄의 미수도 현행법상 처벌이 가능하다.
정답 : O
3. 미성년자·심신미약자 간음·추행죄에서 위계란 간음행위 자체에 대한 오인, 착각, 부지만을 가리키는 것은 아니다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

제3자에 의하여 항거불능상태에 빠진 상태에서 방치된 피해자 곁을 우연히 지나던 사람이 그 광경을 보고는 불현듯 간음의 의사가 생겨서 피해자를 간음한 경우 강간죄가 성립한다.

[정답] X

[해설] 행위자가 직접 폭행 등을 행사하여 간음한 경우가 아니므로 강간죄가 아니라 준강간죄가 성립한다.

♣ 강의내용

1. 강제추행죄(형법 제298조)

1. 의의

본죄는 폭행·협박으로 사람을 추행함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄의 보호법익은 사람의 성적 결정의 자유이고, 보호정도는 침해범으로서의 보호이다.

2. 구성요건

(1) 행위주체

제한이 없다. 남자는 물론 여자도 본죄의 단독정범이나 공동정범이 될 수 있다.

(2) 행위객체

여자뿐만 아니라 남자도 본죄의 대상이 된다.

(3) 행위

폭행·협박으로 추행하는 것이다.

(가) 폭행·협박

1) 폭행·협박의 정도

① 강간죄와 폭행·협박죄의 중간정도, 즉 일반인으로 하여금 항거에 곤란을 느끼게 할 정도이거나, 상대방의 의사에 임의성을 잃게 할 정도이면 되거나 또는 ② 상대방의 의사에 반하는 유형력의 행사가 있는 이상 그 힘의 대소강약을 불문한다는 것이 판례의 태도이다.

판례 춤을 추면서 피해자의 유방을 만진 사건(대판 2002.4.26. 2001도2417) 辯4 司50·52·53

강제추행죄는 상대방에 대하여 폭행 또는 협박을 가하여 항거를 곤란하게 한 뒤에 추행행위를 하는 경우뿐만 아니라 폭행행위 자체가 추행행위라고 인정되는 경우도 포함되는 것이며, 이 경우에 있어서의 폭행은 반드시 상대방의 의사를 억압할 정도의 것임을 요하지 않고 상대방의 의사에 반하는 유형력의 행사가 있는 이상 그 힘의 대소강약을 불문한다.

2) 폭행·협박의 시기

강제추행죄에 있어서 폭행 또는 협박으로 사람에게 대하여 추행을 한다함은 먼저 상대방에 대하여 폭행 또는 협박을 가하여 그 항거를 곤란하게 한 뒤에 추행행위를 하는 경우만을 말하는 것이 아니고, 폭행행위 자체가 추행행위라고 인정되는 경우도 포함되는 것이다(대판 1992.2.28. 91도 3182).

(나) 추행

추행이란 상대방의 의사에 반하여 객관적으로 일반인에게 성적 수치심·혐오감정을 불러일으키는 간음 이외의 일체의 성적 가해행위를 말한다. 추행은 행위자의 주관적 목적·경향과 관계없이 객관적으로 확정된다. 강간미수는 그 성질상 대부분의 경우 강제추행행위를 수반한다. 따라서 강간미수가 성립할 경우 법조경합에 의하여 별도로 강제추행죄가 성립할 여지는 없다.

II. 준강간·준강제추행죄(형법 제299조)

1. 의의

준강간·준강제추행죄는 사람의 심신상실 또는 항거불능상태를 이용하여 간음·추행한 경우에 성립하는 범죄이다.

2. 구성요건

(1) 행위객체

심신상실·항거불능의 상태에 있는 사람이다.

(가) 심신상실

심신상실이란 정신능력의 상실로 말미암아 정상적인 성적 자기결정을 할 수 없는 상태를 말한다. 본죄의 심신상실은 제10조의 심신상실 보다 넓은 개념이기 때문에 생물학적으로 사물변별능력이나 의사결정능력이 없는 자 뿐만 아니라, 일시적으로 깊은 의식장애에 빠진 사람(수면, 탈진, 만취상태 등)도 해당된다.

(나) 항거불능

심신상실 이외의 사유로 인하여 심리적·육체적으로 반항이 불가능하거나 현저하게 곤란한 경우로 그 원인은 불문한다. 가령 의사가 치료를 가장하여 간음하거나 포박되어 있는 사람을 간음한 경우 또는 이미 다른 사람에게 당함으로 말미암아 반항할 기력조차 없이 기진해 있는 사람의 상태를 이용하여 간음·추행한 경우가 이에 해당한다.

여기서 항거불능상태는 행위자와는 관계없이 사전에 조성되어 있어야 한다. 그러므로 행위자가 약물 등으로 피해자에게 항거불능상태를 야기시켜 간음·추행하면 본죄가 아니라 강간죄·강제추행죄가 성립한다.

(2) 행위

사람의 심신상실 또는 항거불능상태를 이용하여 간음·추행하는 것이다.

(가) 이용

심신상실·항거불능의 상태에 대한 단순한 인식이나 이것이 행위동기가 된 것만으로는 부족하며 그러한 상태 때문에 간음·추행이 가능했거나 용이하여야 함을 의미한다. 가령 제3자에 의하여 항거불능상태에 빠진 상태에서 방치된 피해자 곁을 우연히 지나던 사람이 그 광경을 보고는 불현듯 간음의 의사가 생겨서 피해자를 간음한 경우가 이에 해당한다.

여기서 심신상실 또는 항거불능상태가 행위자에 의하여 야기된 것이 아닌 한 그것이 발생한 원인이 피해자 자신에 의한 것이든 제3자에 의한 것이든 모두 불문한다.

(나) 간음·추행

강간죄와 강제추행죄의 그것과 같다.

III. 미성년자에 대한 성범죄

1. 미성년자 의제강간·강제추행죄(형법 제305조)

(1) 의의

13세 미만의 사람을 간음하거나 추행함으로써 성립하는 범죄이다.

(2) 구성요건

(가) 행위

간음·추행이다. 본죄의 성립에 있어서 폭행·협박·위계·위력 등 별도의 수단은 필요 없다. 폭행·협박을 하여 미성년자를 간음·추행한 경우에는 강간죄·강제추행죄가 성립한다. 피해자의 동의가 있는 경우에도 본죄가 성립한다. 그리고 본죄는 미수범 처벌에 관한 규정(제300조)을 준용하고 있지 않으나, 본죄는 강간죄·강제추행죄의 예에 의하므로 본죄의 미수범도 처벌된다는 데에는 학설상 異論이 없다.

판례 (대판 2007.3.15. 2006도9453) 司50·53·56

학원 승합차를 운전하던 피고인 甲이 학원 수업을 마치고 귀가하기 위하여 승합차를 탄 11세의 피해자 A가 혼자 남은 틈을 타 승합차 안에서 A를 간음하려다 미수에 그친 사안에서, 미성년자의제강간·강제추행죄를 규정한 형법 제305조가 “13세 미만의 부녀를 간음하거나 13세 미만의 사람에게 추행을 한자는 제297조, 제298조, 제301조 또는 제301조의2의 예에 의한다”로 되어 있어 강간죄와 강제추행죄의 미수범의 처벌에 관한 형법 제300조를 명시적으로 인용하고 있지 아니하나, 형법 제305조의 입법 취지는 성적으로 미성숙한 13세 미만의 미성년자를 특별히 보호하기 위한 것으로 보이는바 이러한 입법 취지에 비추어 보면 동조에서 규정한 형법 제297조와 제298조의 ‘예에 의한다’는 의미는 미성년자의제강간·강제추행죄의 처벌에 있어 그 법정형뿐만 아니라 미수범에 관하여도 강간죄와 강제추행죄의 예에 따른다는 취지로 해석되고, 이러한 해석이 형벌법규의 명확성의 원칙에 반하는 것이거나 죄형법정주의에 의하여 금지되는 확장해석이나 유추해석에 해당하는 것으로 볼 수 없다.

(나) 고의

13세 미만의 자를 간음·추행한다는 고의가 있어야 한다. 따라서 13세 미만의 자를 13세 이상의 자로 오인하고 동의를 얻어 간음·추행한 경우에는 사실의 착오로서 고의가 조각된다. 반대로 13세 이상의 자를 13세 미만의 자로 오인하고 동의를 얻어 간음·추행한 경우에는 불능범에 해당하여 본죄는 성립하지 않는다.

판례 (대판 2006.1.13. 2005도6791) 司50

[1] 형법 제305조의 미성년자의제강간제추행죄는 ‘13세 미만의 아동이 외부로부터의 부적절한 성적 자극이나 물리력의 행사가 없는 상태에서 심리적 장애 없이 성적 정체성 및 가치관을 형성할 권익’을 보호법익으로 하는 것으로서, 그 성립에 필요한 주관적 구성요건요소는 고의만으로 충분하고, 그 외에 성욕을 자극·흥분·만족시키려는 주관적 동기나 목적까지 있어야 하는 것은 아니다.

[2] 초등학교 4학년 담임교사(남자)가 교실에서 자신이 담당하는 반의 남학생의 성기를 만진 행위가 미성년자의제강간제추행죄에서 말하는 ‘추행’에 해당한다.

2. 미성년자·심신미약자 간음·추행죄(형법 제302조)

(1) 의의

미성년자 또는 심신미약자에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음 또는 추행함으로써 성립하는 범죄이다. 미성년자라 함은 제305조의 미성년자의제강간·강제추행죄와의 관계상 13세 이상 19세 미만의 자를 말한다.

(2) 위계의 의미

위계라 함은 상대방을 착오에 빠뜨려 정상적인 성적 의사결정을 그르치게 하는 행위를 말한다. 다만 행위자가 간음의 목적으로 상대방에게 오인, 착각, 부지를 일으키고 상대방의 그러한 심적 상태를 이용하여 간음의 목적을 달성하는 것을 말하고, 여기에서 오인, 착각, 부지란 간음행위 자체에 대한 오인, 착각, 부지를 말하는 것이지, 간음행위와 불가분적 관련성이 인정되지 않는 다른 조건에 관한 오인, 착각, 부지를 가리키는 것이 아니다(대판 2001.12.24. 2001도5074).

예컨대 간음행위를 단순히 건강증진을 위한 마사지라고 하면서 미성년자의 판단을 그르치게 하여 간음행위로 나갔다면 위계가 인정되어 본죄가 성립할 것이지만, 단순히 돈을 주지 않을 것임에도 돈을 준다고 속여서 미성년자를 간음한 경우에는 간음행위 자체에 대한 위계를 사용한 것이 아니므로 본죄가 성립하지 않는다.

(3) 위력의 의미

본죄에서 위력이란 피해자의 자유의사를 제압하기에 충분한 세력을 말하고, 유형적이든 무형적이든 묻지 않으므로 폭행·협박뿐 아니라 행위자의 사회적·경제적·정치적인 지위나 권세를 이용하는 것도 가능하나, 강간죄나 강제추행죄의 폭행·협박의 정도에는 이르지 아니하여야 한다. 만약 강간죄나 강제추행죄의 폭행·협박의 정도에 이르렀을 때에는 본죄가 아니라 바로 강간죄·강제추행죄가 성립한다.

♣ 확인학습문제

1. 강제추행죄에 대한 기술 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 강제추행죄의 행위수단인 폭행, 협박은 당연히 본죄에 흡수된다.
- ② 여자도 강제추행죄를 범할 수 있다.
- ③ 남자도 강제추행죄의 객체가 된다.
- ④ 강제추행죄는 상대방에 대하여 폭행 또는 협박을 가하여 항거를 곤란하게 한 뒤에 추행행위를 하는 경우에만 성립한다.
- ⑤ 추행이라 함은 객관적으로 일반인에게 성적 수치심이나 혐오감을 일으키게 하고 선량한 성적 도덕관념에 반하는 행위이다.

[정답] ④

[해설] 강제추행죄는 상대방에 대하여 폭행 또는 협박을 가하여 항거를 곤란하게 한 뒤에 추행행위를 하는 경우뿐만 아니라 폭행행위 자체가 추행행위라고 인정되는 경우도 포함되는 것이다(대법원 2002.4.26. 2001도2417).

2. 甲은 술에 취하여 안방에서 잠을 자고 있던 乙녀를 발견하고 갑자기 욕정을 일으켜 乙녀의 옆에 누워 몸을 더듬다가 바지를 벗기려는 순간 乙녀가 어렴풋이 잠에서 깨어났으나 乙녀는 자신의 애인으로 잘못 알고 불을 끄라고 말하였고, 甲이 자신을 애무할 때 누구냐고 물었으며, 甲이 여관으로 가자고 제의하자 그냥 빨리 하라고 말하였다. 판례에 의할 경우 甲의 죄책은?(주거침입죄는 논외로 함)

- ① 준강제추행죄
- ② 준강간죄
- ③ 강제추행죄
- ④ 위계에 의한 간음죄
- ⑤ 무죄

[정답] ⑤

[해설] 위의 사실 등을 고려할 때 乙녀가 심신상실이나 항거불능의 상태에 있었다고 보기 어렵다. 따라서 준강간죄나 준강제추행죄는 성립하지 않는다(대판 2000.2.25. 98도4355).

3. 甲은 2회에 걸쳐 서울 소재 某 여관 객실에서, 사고와 판단능력이 극히 낮은 정신지체 장애자인으로 심신미약상태인 피해자 乙녀에게 남자를 소개해 준다면 동녀를 유인하여 乙에게 폭행이나 협박을 전혀 사용함이 없이 乙과 성교를 하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 심신미약자간음죄
- ③ 강간죄
- ④ 강제추행죄
- ⑤ 준강간죄

[정답] ①

[해설] 피고인의 위 행위는 형법 제302조 소정의 위계에 의한 심신미약자간음죄에 있어서 위계에 해당하지 아니한다(대판 2002.7.12. 2002도2029).

♣ 학습내용 정리

1. 강제추행죄는 폭행·협박으로 사람을 추행함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 준강간·준강제추행죄는 사람의 심신상실 또는 항거불능상태를 이용하여 간음·추행한 경우에 성립하는 범죄이다.
3. 미성년자 의제강간·강제추행죄는 13세 미만의 사람을 간음하거나 추행함으로써 성립하는 범죄이다.
4. 미성년자 또는 심신미약자에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음 또는 추행함으로써 성립하는 범죄이다.

제9강 명예훼손죄(형법 제307조)

♣ 학습목표

- 명예훼손죄에서 공연성의 내용을 설명할 수 있다.
- 명예훼손죄에서 사실의 적시의 의미를 설명할 수 있다.
- 위법성조각사유인 형법 제310조의 법리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 명예훼손
- 공연성
- 사실의 적시
- 위법성조각사유로서 형법 제310조

♣ 사전테스트

1. 死者도 명예의 주체가 될 수 있다.
정답 : O
2. 공연성이란 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태이다
정답 : O
3. 공지의 사실을 적시한 경우에는 명예훼손죄가 성립할 수 없다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

형법 제310조는 형법 제307조 제1항에만 적용된다.

[정답] O

[해설] 진실한 사실을 적시할 것을 요하므로 제310조는 제307조 제1항에만 적용된다.

♣ 강의내용

I. 의의

1. 개념

명예훼손죄는 공연히 사실 또는 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손하는 범죄이다.

2. 보호법익 · 보호정도

(1) 보호법익

사람의 명예이다. 여기서 명예라 함은 사람의 인격가치 또는 행동에 대한 사회적 평가로서 외적 명예를 말한다.

(2) 보호의 정도

추상적 위험범으로서의 보호이다.

3. 명예의 향유주체

- ① 모든 자연인은 명예의 주체가 되므로 유아, 정신병자, 범죄자도 그 주체가 된다.
- ② 역사적 가치로서의 사자의 외적 명예도 보호법익이 된다. 따라서 사자도 명예의 주체가 될 수 있다.
- ③ 법인은 법에 의하여 법인격을 부여받고 있는 한 그 명예를 보호해야 할 필요가 있으며, 정당, 노동조합 등의 법인격 없는 단체도 법에 의하여 인정된 사회적 기능을 담당하고 있는 한 명예의 주체가 된다. 사교단체나 가족은 대외적인 법적 활동의 주체가 아니기 때문에 명예주체가 되지 않는다.

4. 집단명칭에 의한 명예훼손

- ① 독자적으로는 명예의 주체가 될 수 없는 집단의 구성원도 그 집단의 명칭에 의하여 명예가 훼손될 수 있는 것을 말한다.
- ② 명예훼손죄는 집합적 명사를 쓴 경우에도 그것에 의하여 그 범위에 속하는 특정인을 가리키는 것이 명백하면 이를 각자의 명예를 훼손하는 행위라고 볼 수 있다. 가령 'A 대학 교수들', 'B 법원 판사들', 'C 경찰서 경찰관들' 이라고 칭한 경우에 이에 해당한다. 다만 서울시민, 경기도민과 같이 예외를 인정하는 일반적인 평균판단으로는 족하지 않다.
- ③ 집단의 구성원의 1인 또는 수인을 지적하였지만 그것이 누구인지가 명확하지 아니하여 구성원 모두가 혐의를 받는 경우에도 명예훼손이 인정될 수 있다. ex) 장관 가운데 1명이 외도를 한다.

II, 구성요건

1. 행위의 객체

사람의 명예(외적 명예)이다.

2. 행위

공연히 사실 또는 허위의 사실을 적시하여 명예를 훼손하는 것이다.

(1) 공연성

(가) 개념

불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태이다(통설, 판례). 불특정인의 경우는 수의 다소를 묻지 않고, 다수인은 특정여부와 상관없이 단순한 복수 이상의 상당 다수를 의미한다. 다만 인식할 수 있는 상태와 관련하여 본죄는 추상적 위험범이기 때문에 불특정 또는 다수인이 구체적으로 인식할 것을 필요로 하지 않는다.

(나) 공연성의 판단기준

- ① 판례는(대판 2000.2.11. 99도4579) “명예훼손죄에 있어서 공연성은 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태를 의미하므로 비록 개별적으로 한 사람에 대하여 사실을 유포하더라도 이로부터 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성이 있다면 공연성의 요건을 충족하지만, 이와 달리 전파될 가능성이 없다면 특정한 한 사람에 대한 사실의 유포는 공연성을 결한다”고 판시하여 전파성이론을 따르고 있다.

(2) 사실의 적시

(가) 사실

사실이란 현실적으로 발생하고 증명할 수 있는 과거와 현재의 상태를 말한다. 적시된 사실은 사실의 적시를 통하여 특정인의 사회적 가치 내지 평가가 침해될 가능성이 있을 정도로 구체성을 가져야 한다. 사람의 지위·가치를 훼손할 수 있는 것이면 무엇이든 무방하다. 악사·추행에 제한되지 아니하며, 공자의 사실에 의해서도 본죄가 성립할 수 있다.

미래의 사실도 현재사실에 대한 주장을 포함하는 경우에는 본죄의 사실이 된다. 만약 허위사실을 적시한 경우에는 형이 가중된다(제307조 제2항).

(나) 사실의 적시

사실의 적시란 사람의 사회적 평가를 저하시키는데 충분한 구체적 사실을 알리는 것이다. 시기, 장소, 수단 등 상세한 부분까지 특정되어야 할 필요는 없다. 이 때 적시의 방법은 무제한하다. 문서, 도화, 신문, 잡지, 라디오, 기타 출판물에 의해도 무방하다. 다만 출판물에 의한 경우 비방의 목적이 있으면 출판물에 의한 명예훼손죄(제309조)가 성립한다. 암시·추측과 같은 우회적 표현뿐만 아니라, 전문의 사실을 전파해도 된다.

다만 그 정도에 있어서는 피해자의 성명이 명시되어야만 사실의 적시가 인정되는 것은 아니지만, 적어도 피해자는 적시하는 사실의 내용·상황에 미루어 누구인지 알 수 있을 만큼 특정되어야 한다. 따라서 증명할 수 없는 가치판단(사람을 동물에 비유하면서 욕설을 하는 것) 또는 높은 추상성을 지닌 사실(상대방을 단순히 사기꾼이라고만 표현하는 것)은 모욕죄의 대상이 될 뿐이다.

(3) 명예훼손 및 기수시기

명예훼손은 타인의 명예를 무시·공격·비난하는 일체의 손상행위를 말한다. 명예훼손죄는 추상적 위험범이므로 적시된 사실을 불특정 또는 다수인이 직접 인식할 수 있는 상태에 이르면 기수가 되며, 상대방의 현실적 인지는 필요하지 않다.

3. 고의

명예훼손죄의 고의는 사람의 명예를 훼손한다는 인식·의욕을 말한다. 미필적 고의로 충분하다. 명예훼손의 목적이나 비방의 목적이 있어야 할 필요는 없다. 그러나 사실확인을 위한 질문이나 그 질문에 대한 대답을 한 때에는 명예훼손의 고의가 인정되지 않는다(대판 1983.8.23. 83도 1017).

III. 위법성조각사유

1. 일반적 위법성조각사유 - 정당행위

- ① 검사의 기소요지진술, 증인의 증언, 변호인의 변호권행사는 법령에 의한 행위로서 위법성이 조각되지만, 허위변론은 권리남용으로 명예훼손죄를 구성한다.
- ② 언론·출판기관의 보도, 출판행위, 학술·예술작품에 대한 공정한 논평 등은 정당한 업무행위이다.
- ③ 국회의원이 국회에서 직무상 행한 발언

2. 형법 제310조의 위법성조각사유

(1) 의의

형법 제307조 제1항의 행위가 '진실한 사실'로서 오로지 '공공의 이익'에 관한 때에는 처벌하지 아니한다. 이는 개인명예의 보호와 언론의 자유라는 양 법익의 충돌을 조정하기 위한 규정이다. 따라서 제310조의 위법성조각사유가 적용되기 위해서는 ① 제307조 제1항이 적용되는 경우 ② 애당초 진실한 사실의 경우 ③ 공공성이라는 3가지 요소를 구비하여야 한다.

(2) 요건

(가) 제307조 제1항의 적용

제307조 제1항이 적용되는 사실관계의 유형

- ① 진실한 사실을 적시한 경우
- ② 허위의 사실을 진실한 사실로 오인하고 적시한 경우(판례) → 형법 제15조 제1항
- ③ 비방의 목적 없이 출판물을 이용하여 진실한 사실을 적시한 경우

(나) 진실한 사실

1) 의의

형법 제310조의 위법성조각사유가 인정되기 위해서는 진실한 사실을 적시해야 하며 적시된 사실이 진실한 것이라는 증명이 없더라도 행위자가 그 사실을 진실한 것으로 믿었고 또 그렇게 믿을 만한 상당한 이유가 있으면 족하다. 또한 내용 전체의 취지를 살펴볼 때 중요한 부분이 객관적 사실과 합치되는 사실이라는 의미에서 세부에 있어 진실과 약간 차이가 나거나 다소 과장된 표현이 있더라도 무방하다(판례).

2) 적용 범위

진실한 사실을 적시할 것을 요하므로 제310조는 제307조 제1항에만 적용된다. 그러므로 허위 사실 적시에 의한 명예훼손, 사자의 명예훼손, 출판물 등에 의한 명예훼손의 경우에는 제310조가 적용될 여지가 없다.

(다) 사실의 적시가 오로지 공공의 이익에 관한 것일 것

1) 의의

① 사실이 공공의 이익에 관한 것(객관적 요건)이고, ② 공공의 이익을 위한다는 목적(주관적 요건)을 갖고 있어야 한다.

2) 내용

① 오로지는 ‘주로’라고 해석되며 행위자의 주요한 목적이나 동기가 공공의 이익을 위한 것이라면 부수적으로 다른 사익적 목적이나 동기가 내포되어 있더라도 제310조가 적용된다(대판 2000.2.25. 98도2188). ② 공공의 이익의 범위는 널리 국가, 사회 기타 일반 다수인의 이익에 관한 것 뿐만 아니라 특정한 사회집단이나 그 구성원 전체의 관심과 이익에 관한 것도 포함된다(대판 2001.10.9. 2001도3594).

3) 판단기준

적시된 사실 자체의 내용과 성질에 비추어 객관적으로 판단하여야 한다(대판 1997.4.11. 97도88).

(3) 형법 제310조의 효과

(가) 실체법적 효과 - 위법성조각사유설

형법 제310조의 법률요건이 모두 충족되면 위법성조각사유설에 따라 위법성이 조각된다. → 형법 제310조의 규정은 인격권으로서의 개인의 명예의 보호와 헌법 제21조에 의한 정당한 표현의 자유의 보장이라는 상충되는 두 법익의 조화를 꾀한 것이라고 보아야 할 것이므로, 두 법익 간의 조화와 균형을 고려한다면 적시된 사실이 진실한 것이라는 증명이 없더라도 행위자가 진실한 것으로 믿었고 또 그렇게 믿을 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 위법성이 없다(대판 1993.6.22. 92도3160).

(나) 절차법적 효과 - 거증책임전환설

적시사실의 진실성과 공익성에 관한 거증책임을 피고인이 부담해야 하는 거증책임의 전환규정이다.

♣ 확인학습문제

1. 자신의 아들 등으로부터 폭행을 당하여 입원한 피해자의 병실로 병문안을 간 가해자의 어머니 甲이 피해자의 어머니 乙이 폭행사건에 대하여 대화하던 중 乙의 친척 등 모두 3명이 있는 자리에서 “학교에 알아보니 피해자에게 원래 정신병이 있었다고 하더라”라고 허위사실을 말할 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 진실사실 적시 명예훼손죄
- ③ 허위사실 적시 명예훼손죄

- ④ 사자명예훼손죄
- ⑤ 모욕죄

[정답] ①

[해설] 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태라고 할 수 없고, 또 그 자리에 있던 사람들의 관계 등 여러 사정에 비추어 피고인의 발언이 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성이 있다고 보기도 어려워 공연성이 없다(대판 2011.9.8. 2010도7497).

2. 다음 甲의 행위 중 명예훼손죄의 구성요건인 ‘공연성’이 인정되는 경우는?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲은 남편인 乙을 상대로 이혼소송을 하고 있던 중 소송고정에서 乙을 위하여 유리한 진술서를 작성해 준 乙의 친구인 丙에게 사실 관계를 알리는 내용의 편지를 보내면서 乙의 명예를 훼손하는 문구가 기재된 서신을 동봉하였다.
- ② 甲은 직장의 전산망에 설치된 전자게시판에 乙의 명예를 훼손하는 사실을 적시한 내용의 글을 게시하였다.
- ③ A 교파를 떠난 목사인 갑은 자신의 말을 몰래 녹음하여 이를 명예훼손죄의 증거자료로 삼을 목적으로 자신의 집으로 찾아와 거짓말을 하면서 발언을 유도한 을, 병 등 A 교파 신자 6명에게 A 교파의 지도자인 정씨 여자 문제 등 사생활에 관한 구체적 사실을 이야기하였다.
- ④ 甲이 丙으로부터 취득한 乙의 범죄경력기록을 丁에게 보여주면서 “전과자이고 나쁜 년”이라는 말을 하였다.
- ⑤ 요식업협회 조합장인 갑은 조합 이사 을의 측근이 같은 조합 이사 병에게 이사회에서 을을 불신임하게 된 사유를 설명하는 과정에서 을의 여자관계에 관한 소문을 말하였다.

[정답] ②

[해설] 직장의 전산망에 설치된 전자게시판에 타인의 명예를 훼손하는 내용의 글을 게시한 행위는 명예훼손죄를 구성한다(대판 2000.5.12, 99도5734).

3. 다음 명예훼손죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 독자적으로는 명예의 주체가 될 수 없는 가족이나 동호회 같은 집단의 구성원도 그 집단의 명칭에 의하여 명예가 훼손될 수 있다.
- ② 미래의 사실도 현재사실에 대한 주장을 포함하는 경우에는 명예훼손죄의 사실이 된다.
- ③ 명예훼손죄는 추상적 위법범이므로 적시된 사실을 불특정 또는 다수인이 직접 인식할 수 있는 상태에 이르면 기수가 되며, 상대방의 현실적 인지는 필요하지 않다.
- ④ 적시된 사실이 진실한 것이라는 증명이 없을 경우에는 행위자가 진실한 것으로 믿었고 또 그렇게 믿을 만한 상당한 이유가 있었다고 할지라도 형법 제310조가 적용될 수 없다.
- ⑤ 형법 제310조의 오로지는 ‘주로’라고 해석되며 행위자의 주요한 목적이나 동기가 공공의 이익을 위한 것이라면 부수적으로 다른 사익적 목적이나 동기가 내포되어 있더라도 제310조가 적용된다.

[정답] ④

[해설] 적시된 사실이 진실한 것이라는 증명이 없더라도 행위자가 진실한 것으로 믿었고 또 그렇게 믿을 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 위법성이 없다(대판 1993.6.22. 92도3160).

♣ 학습내용 정리

1. 명예훼손죄는 공연히 사실 또는 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손하는 범죄이다.
2. 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 사자의 명예훼손, 출판물 등에 의한 명예훼손의 경우에는 형법 제310조가 적용될 여지가 없다.
3. 형법 제310조의 법률요건이 모두 충족되면 위법성조각사유설에 따라 위법성이 조각된다.

제10강 출판물에 의한 명예훼손죄와 모욕죄

♣ 학습목표

- 사자 명예훼손죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 출판물에 의한 명예훼손죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 모욕죄에 대한 의의와 내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 사자에 대한 명예훼손
- 출판물에 의한 명예훼손
- 공연성
- 모욕

♣ 사전테스트

1. 死者도 명예의 주체가 될 수 있다.
정답 : O
2. 공연성은 출판물에 의한 명예훼손죄의 요건이다.
정답 : X
3. 공공의 이익을 가지고 출판물을 이용하여 진실한 사실을 적시한 경우에는 언제나 형법 제 310조가 적용될 수 없다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

컴퓨터 워드프로세서로 작성되어 프린트된 A4 용지 7쪽 분량의 인쇄물은 형법 제309조 제 1항의 '기타 출판물'에 해당한다.

[정답] X

[해설] 컴퓨터 워드프로세서로 작성되어 프린트된 A4 용지 7쪽 분량의 인쇄물이 형법 제 309조 제1항 소정의 '기타 출판물'에 해당하지 않는다(대판 2000.2.11. 99도3048).

♣ 강의내용

I. 死者에 대한 명예훼손죄(형법 제308조)

1. 의의

공연히 허위의 사실을 적시하여 사자의 명예를 훼손함으로써 성립하는 범죄이다. 따라서 진실한 사실을 적시한 경우에는 본죄가 성립하지 않는다. 즉 사망한 甲이 乙을 살해하였다는 사실을 새긴 비석을 도로 옆 노상에 세웠으나 실제로 甲이 乙을 살해한 사실이 있다면 본죄는 성립하지 않는다(대판 1972.9.26. 72도1798).

2. 적용범위

사자는 자연인과 관계되는 개념이므로 해산된 법인이나 소멸된 법인격 없는 단체는 본죄의 사자에 해당하지 않는다. 명예훼손행위를 할 때에 이미 사자일 것을 요하므로 명예훼손행위 후에 피해자가 사망한 경우에는 제307조의 명예훼손죄가 성립한다.

판례 (대판 1983.10.25. 83도1520) 司47

사자의 명예훼손죄는 사자에 대한 사회·역사적 평가를 보호법익으로 하는 것이므로 피고인이 공소의 甲의 사망사실을 알면서 甲은 사망한 것이 아니고 빗 때문에 도망다니며 죽은 척하는 나쁜 놈이라고 공연히 허위사실을 적시한 행위는 사자의 명예훼손죄에 해당한다.

3. 소추조건

사자에 대한 명예훼손죄는 친고죄이므로 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다(형법 제312조 제1항).

II. 출판물에 의한 명예훼손죄(형법 제309조)

1. 의의

출판물에 의한 명예훼손죄란 사람을 비방할 목적으로 신문·잡지 또는 라디오 기타 출판물에 의하여 사실 또는 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손함으로써 성립하는 범죄이다. 추상적 위험범으로서의 보호이다(다수설).

2. 구성요건

(1) 행위객체

신문, 잡지, 또는 라디오 기타 출판물이다. 비방의 목적이 있더라도 출판물 등에 의하여 명예훼손이 이루어지지 않는 경우에는 본죄는 성립하지 않는다. 형법 제309조 제1항 소정의 ‘기타 출판물’에 해당한다고 하기 위하여는 그것이 등록·출판된 제본인쇄물이나 제작물은 아니라고 할지라도 적어도 그와 같은 정도의 효용과 기능을 가지고 사실상 출판물로 유통·통용될 수 있는 외관을 가진 인쇄물로 볼 수 있어야 한다(대판 2000.2.11. 99도3048).

판례 (대판 2000.2.11. 99도3048) 辯4 司52

컴퓨터 워드프로세서로 작성되어 프린트된 A4 용지 7쪽 분량의 인쇄물이 형법 제309조 제1항 소정의 ‘기타 출판물’에 해당하지 않는다.

(2) 행위

명예훼손이며, 사실 또는 허위사실의 적시는 명예훼손행위의 수단이다.

(가) 공연성의 요부

출판물 등에 의한 명예훼손방법은 그 자체가 이미 고도의 공연성을 띠기 때문에 공연성의 본죄의 요건이 아니다.

(나) 간접정범

비방의 목적이 있는 자가 언론사에 보도자료를 제공하여 비방의 목적이 없는 언론사로 하여금 사실을 보도하게 함으로써 타인의 명예를 훼손한 경우에는 ‘어느 행위로 인하여 처벌받지 않는 자’의 행위를 이용한 경우에 해당하므로 본죄의 간접정범이 성립할 수 있다.

판례 (대판 2002.6.28. 2000도3045) **소** 47 · 52

출판물에 의한 명예훼손죄는 간접정범에 의하여 범하여질 수도 있으므로 타인을 비방할 목적으로 허위의 기사 자료를 그 정을 모르는 기자에게 제공하여 신문 등에 보도되게 한 경우에도 성립할 수 있으나 제보자가 기사의 취재·작성과 직접적인 연관이 없는 자에게 허위의 사실을 알렸을 뿐인 경우에는, 제보자가 피제보자에게 그 알리는 사실이 기사화 되도록 특별히 부탁하였다거나 피제보자가 이를 기사화 할 것이 고도로 예상되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 피제보자가 언론에 공개하거나 기자들에게 취재됨으로써 그 사실이 신문에 게재되어 일반 공중에게 배포되더라도 제보자에게 출판·배포된 기사에 관하여 출판물에 의한 명예훼손죄의 책임을 물을 수는 없다. → 비뇨기과 의사 甲이 의료기기 회사와의 분쟁을 정치적으로 해결하기 위하여 국회의원에게 허위의 사실을 제보하였을 뿐인데, 위 국회의원의 발표로 그 사실이 일간신문에 게재된 경우 출판물에 의한 명예훼손이 성립하지 아니한다.

☞ 그러나 이 사건에 대하여는 파기환송 후 원심에서 공소사실이 검찰에 의하여 변경되어 다시 기소가 이루어졌고, 의사 甲은 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄로 유죄판결을 받았다 (대판 2004.4.9. 2004도340).

(3) 기수시기

판례 (대판 2007.10.25. 2006도346)

서적·신문 등 기존의 매체에 명예훼손적 내용의 글을 게시하는 경우에 그 게시행위으로써 명예훼손의 범행은 종료하는 것이며 그 서적이나 신문을 회수하지 않는 동안 범행이 계속된다고 보지는 않는다는 점을 고려해 보면, 정보통신망을 이용한 명예훼손의 경우에, 게시행위 후에도 독자의 접근가능성이 기존의 매체에 비하여 좀 더 높다고 볼 여지가 있다 하더라도 그러한 정도의 차이만으로 정보통신망을 이용한 명예훼손의 경우에 범죄의 종료시기가 달라진다고 볼 수는 없다.

(4) 주관적 구성요건 - 비방의 목적

비방의 목적 없이 진실한 사실 또는 허위사실을 출판물 등에 게재하는 경우에는 제307조의 명예훼손죄가 성립한다.

3. 형법 제310조의 적용 여부

(1) 원칙

제310조는 제307조 제1항에 대해서만 적용되므로 제309조에는 제310조가 적용되지 않는다고 할 것이다. 즉 비방의 목적이 있는 한 공공의 이익은 없다고 해야 하므로 제309조에는 제310조가 적용되지 않는 것이다(대판 1995.6.30. 95도1010).

(2) 개별적 고찰

(가) 형법 제309조 제1항

출판물 등에 의한 명예훼손행위일지라도 적시하는 사실이 진실하고 공공의 이익을 위한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 비방의 목적이 인정되지 않으므로 제307조 제1항이 적용된다. 그러나 명백하게 비방의 목적이 있으면 진실한 사실을 출판물 등에 게재하더라도 제310조 위법성 조각사유에 해당하지 않는다.

판례 개인택시운송사업조합 이사장 선거(대판 1998.10.9. 97도158) 辯1 司55

[사실관계] 피고인 甲이 서울특별시 개인택시운송사업조합 이사장 선거에 출마하여 경쟁 후보자였던 피해자 乙과 당선 경쟁을 하면서 선거운동을 하던 중 조합원들에게 배포한 이 사건 인쇄물에서 적시한 사실은 ‘이 사건 조합의 전(前) 이사장이 대의원총회에서 불신임당하고 업무상의 비리로 인하여 구속된 사실’, ‘피해자가 조합을 상대로 소송을 제기한 사실’, ‘피해자가 전 이사장과 같은 친목회에 소속하여 있는 등 친밀한 관계를 유지하고 있었던 사실’, ‘피고인이 합동유세를 공개 제의하였는데 피해자가 반응을 보이지 않다가 선거일에 임박해서야 반박한 사실’ 등 그 중요한 부분이 객관적 사실과 합치하고, 다만 그 문맥 중에 “탄생시킨 주역”, “추종”, “저의”, “조합원을 기만하고 우롱하는 행위” 등의 다소 감정적이고 과격한 표현방법이 사용되었다.

형법 제309조 제1항 소정의 ‘사람을 비방할 목적이란 가해의 의사 내지 목적을 요하는 것으로서 공공의 이익을 위한 것과는 행위자의 주관적 의도의 방향에 있어 서로 상반되는 관계에 있다고 할 것이므로, 형법 제310조의 공공의 이익에 관한 때에는 처벌하지 아니한다는 규정은 사람을 비방할 목적이 있어야 하는 형법 제309조 제1항 소정의 행위에 대하여는 적용되지 아니하고 그 목적을 필요로 하지 않는 형법 제307조 제1항의 행위에 한하여 적용되는 것이고, 반면에 적시한 사실이 공공의 이익에 관한 것인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 비방 목적은 부인된다고 봄이 상당하므로 이와 같은 경우에는 형법 제307조 제1항 소정의 명예훼손죄의 성립 여부가 문제될 수 있고 이에 대하여는 다시 형법 제310조에 의한 위법성 조각 여부가 문제로 될 수 있다.

(나) 형법 제309조 제2항

허위의 사실을 적시한 경우이므로 공공의 이익여부 및 비방의 목적유무와 관계없이 제310조가 적용되지 않는다.

4. 반의사불벌죄

피해자의 명시적 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(형법 제312조 제2항).

III. 모욕죄

1. 의의

(1) 내용

공연히 사람을 모욕함으로써 성립하는 범죄이다.

(2) 보호법익·보호정도

보호법익은 명예훼손죄와 같이 외적명예이고, 보호정도는 추상적 위험범으로서의 보호이다.

(3) 명예훼손죄와 모욕죄의 구별기준

모욕죄의 보호법익은 명예훼손죄와 동일하게 외적 명예로 양 죄는 보호법익이 같기 때문에 (구체적)사실의 적시유무라는 행위태양에 의하여 서로 구별된다.

2. 구성요건

(1) 행위객체

살아있는 사람만이 그 대상이 되므로 사자에 대한 모욕죄는 불가능하다.

(2) 행위

(가) 공연성 - 명예훼손죄와 동일함.

(나) 모욕

사실을 적시하지 아니하고 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 표현하는 것이다(전과자, 애꾸눈 등). 추상적 사실 또는 판단의 진위여부는 불문한다. 모욕의 수단·방법은 제한 없다.

판례 (대판 2011.12.22. 2010도10130)

‘듣보잡’이라는 신조어(新造語)가 ‘듣도 보도 못한 잡것(잡놈)’이라는 의미 외에 피고인의 주장과 같이 ‘유명하지 않거나 알려지지 않은 사람’이라는 의미로 사용될 수도 있음을 고려하더라도, 피고인이 이 부분 게시 글에서 ‘듣보잡’이라는 용어를 ‘함량 미달의 듣보잡’, ‘개집으로 숨어 버렸나? 등과 같이 전자(前者)의 의미로 사용하였음이 명백한 이상 이로써 피해자의 사회적 평가를 저하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 표현한 것으로 볼 수 있다.

(3) 기수시기

본죄는 추상적 위험범이므로 공연히 모욕함으로써 기수가 된다.

3. 형법 제310조의 적용 여부

모욕죄에 형법 제310조가 적용되지 않는다는 것은 제310조 명문의 규정상 명백하다(대판 1959.12.23. 4291형상539).

4. 소추조건

모욕죄는 친고죄이므로 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다(제312조 제1항).

♣ 확인학습문제

1. 甲은 사망한 丙이 乙을 살해하였다는 사실을 새긴 비석을 도로 옆 노상에 세웠으나 실제로 丙이 乙을 살해한 사실이 있었던 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사자명예훼손죄
- ② 진실사실 적시 명예훼손죄
- ③ 허위사실 적시 명예훼손죄
- ④ 모욕죄
- ⑤ 무죄

[정답] ⑤

[해설] 사자에 대한 명예훼손죄는 공연히 허위의 사실을 적시하여 사자의 명예를 훼손함으로써 성립하는 범죄이다. 따라서 진실한 사실을 적시한 설문의 경우에는 본죄가 성립하지 않는다. 그리고 사자는 형법 제307조의 명예훼손죄의 객체가 아니다.

2. 의사 甲이 의료기기 회사와의 분쟁을 정치적으로 해결하기 위하여 국회의원에게 허위의 사실을 제보하였을 뿐인데, 위 국회의원의 발표로 그 사실이 일간신문에 게재된 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 모욕죄
- ③ 허위사실 적시 명예훼손죄
- ④ 출판물에 의한 명예훼손죄의 직접정범
- ⑤ 출판물에 의한 명예훼손죄의 간접정범

[정답] ③

[해설] 출판물에 의한 명예훼손죄의 간접정범에 대하여는 무죄판결을 받았으나, 환송심에서는 허위사실 적시 명예훼손죄로 유죄판결을 받았다.

3. 다음 모욕죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 명예훼손죄와 모욕죄의 보호법익은 다 같이 외부적 명예인 점에서는 차이가 없다.
- ② 모욕죄가 성립하기 위하여는 공연성이 인정되어야 한다.
- ③ 인터넷 게시판에서 ‘튼보잡’이란 용어를 사용한 경우 모욕행위를 한 것으로 볼 수 있다.
- ④ 모욕죄에 대하여도 형법 제310조가 적용된다.
- ⑤ 모욕죄는 친고죄이다.

[정답] ④

[해설] 모욕죄에 형법 제310조가 적용되지 않는다는 것은 제310조 명문의 규정상 명백하다(대판 1959.12.23. 4291형상539).

♣ 학습내용 정리

1. 사자에 대한 명예훼손죄는 공연히 허위의 사실을 적시하여 사자의 명예를 훼손함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 출판물에 의한 명예훼손죄란 사람을 비방할 목적으로 신문·잡지 또는 라디오 기타 출판물에 의하여 사실 또는 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손함으로써 성립하는 범죄이다.
3. 비방의 목적 없이 진실한 사실 또는 허위사실을 출판물 등에 게재하는 경우에는 제307조의 명예훼손죄가 성립한다.
4. 모욕죄는 공연히 사람을 모욕함으로써 성립하는 범죄이다.

제11강 업무방해죄(형법 제314조 제1항)

♣ 학습목표

업무방해죄의 법리를 설명할 수 있다.

업무방해죄의 업무와 공무집행방해죄의 공무의 관계를 설명할 수 있다.

컴퓨터 업무방해죄의 내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

업무방해

공무와 업무

위계 또는 위력

컴퓨터 업무방해

♣ 사전테스트

1. 의료인이나 의료법인이 아닌 자가 의료기관을 개설하여 운영하는 행위는 업무방해죄의 보호대상이 되는 '업무'에 해당하지 않는다.

정답 : ○

2. 허위사실의 유포는 위계의 예시에 불과하다.

정답 : ○

3. 업무방해의 결과발생의 염려가 없는 경우에도 업무방해죄가 성립한다.

정답 : X

♣ 돌발퀴즈

업무수행 자체가 아니라 업무의 적정성 내지 공정성이 방해된 경우에는 업무방해죄가 성립한다고 볼 수 없다.

[정답] X

[해설] 업무수행 자체가 아니라 업무의 적정성 내지 공정성이 방해된 경우에도 업무방해죄가 성립한다(대판 2010.3.25. 2009도8506).

♣ 강의내용

I. 의의

- ① 업무방해죄는 허위사실을 유포하거나 위계·위력으로 사람의 업무를 방해함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 재산죄의 성격과 함께 인격활동의 자유를 보호하는 측면도 동시에 지니는 범죄이다.
- ② 그리고 본죄의 보호법익은 사람의 업무이다. 여기서의 업무는 그 자체가 보호법익이다. 보호정도는 추상적 위험범으로서의 보호이다.

II. 구성요건

1. 행위의 객체

사람의 업무이다.

(1) 사람

자연인 이외의 법인·법인격 없는 단체도 포함된다.

(2) 업무

(가) 의의

사람이 그 사회생활상의 지위에 기하여 계속적으로 종사하는 사무이다.

(나) 내용

본죄의 업무는 반드시 직업·영업적일 필요는 없고, 업무상 과실치사상죄와는 달리 타인의 생명·신체에 위험한 사무에 제한되지 않으나, 자동차운전·수렵 등의 오락을 위한 일시적인 것은 제외된다. 경제적인 것뿐 아니라 정신적인 것도 업무에 포함되며, 보수의 유무, 영리목적의 유무, 주된 업무와 종된 업무의 구별을 불문한다.

(다) 업무의 보호가치

형법상 보호할 가치가 있는 사실상 평온하게 이루어진 사회활동도 업무로 파악되므로 형식적 적법성을 결한 사무(무효인 사무, 행정규칙을 위반한 사무)도 업무가 될 수 있다. 이 때 형법상 보호할 가치가 있는 업무인가의 여부는 그 사무가 실제 평온상태에서 일정기간 계속적으로 운영됨으로써 사회적 생활의 기반이 되고 있느냐를 기준으로 결정된다. 따라서 형법상 보호할 가치가 없는 업무는 여기서 제외된다.

판례 (대판 1991.6.28. 91도944) ㉸46·47·48

업무방해죄의 보호대상이 되는 “업무”는 타인의 위법한 행위에 의한 침해로부터 보호할 가치가 있는 것이면 되고, 그 업무의 기초가 된 계약 또는 행정행위 등이 반드시 적법하여야 하는 것은 아니다.

또한 어떤 사무나 활동 자체가 위법의 정도가 중하여 사회생활상 도저히 용인될 수 없는 정도로 반사회성을 띠는 경우에는 업무방해죄의 보호대상이 되지 않는다.

폭력조직 간부인 피고인이 직원들과 공모하여 甲이 운영하는 성매매업소 앞에 속칭 ‘병풍’을 치거나 차량을 주차해 놓는 등 위력으로써 업무를 방해하였다는 내용으로 기소된 사안에서 성매매알선 등 행위는 법에 의하여 원천적으로 금지된 행위로서 형사처벌의 대상이 되는 중대한 범죄행위일 뿐 아니라 정의관념상 용인될 수 없는 정도로 반사회성을 띠는 경우에 해당하므로, 업무방해죄의 보호대상이 되는 업무라고 볼 수 없다.

(라) 공무가 업무방해죄의 업무에 포함되는지 여부 - 공무제외설(다수설, 판례)

위력에 의한 공무집행방해죄에 대한 처벌규정이 없는 형법의 해석상 위력에 의하여 공무집행을 방해한 경우 업무방해죄로 처벌할 수 있는지와 관련하여 판례는(대판 2009.11.19. 2009도4166 전원합의체) “형법이 업무방해죄와는 별도로 공무집행방해죄를 규정하고 있는 것은 사적 업무와 공무를 구별하여 공무에 관해서는 공무원에 대한 폭행, 협박 또는 위계의 방법으로 그 집행을 방해하는 경우에 한하여 처벌하겠다는 취지라고 보아야 한다. 따라서 공무원이 직무상 수행하는 공무를 방해하는 행위에 대해서는 업무방해죄로 의율할 수는 없다고 해석함이 상당하다.”고 판시하여 이를 부정하고 있다.

2. 행위

허위 사실의 유포 기타 위계·위력으로 업무를 방해하는 것이다. 여기서 업무방해는 행위양태이고, 허위사실의 유포나 위계 또는 위력은 행위수단이다.

(1) 허위사실의 유포와 위계

- ① 허위사실의 유포라 함은 객관적 사실과 다른 내용을 불특정 다수인에게 전파하는 것을 말한다. 그리고 위계란 상대방의 착오나 부지를 이용하는 일체의 행위를 말한다. 기망은 물론이고 유혹도 포함된다. 허위사실의 유포는 위계의 예시에 불과하다.
- ② 여기서 ‘허위의 사실을 유포한다’고 함은 반드시 기본적 사실이 허위여야 하는 것은 아니고, 비록 기본적 사실은 진실이더라도 이에 허위사실을 상당 정도 부가시킴으로써 타인의 업무를 방해할 위험이 있는 경우도 포함되지만, 그 내용 전체의 취지를 살펴볼 때 중요한 부분이 객관적 사실과 합치되고 단지 세부에 있어 약간의 차이가 있거나 다소 과장된 표현이 있는 정도에 불과하여 타인의 업무를 방해할 위험이 없는 경우는 이에 해당하지 않는다(대판 2006.9.8. 2006도1580).
- ③ 다만 허위사실의 유포에 있어서는 그 행위자에게 행위 당시 자신이 유포한 사실이 허위라는 점을 적극적으로 인식하였을 것을 요한다(대판 1994.1.28. 93도1278).

(2) 위력

업무방해죄의 ‘위력’이란 사람의 자유의사를 제압·혼란케 할 만한 일체의 세력으로, 유형적이든 무형적이든 묻지 아니하므로, 폭력·협박은 물론 사회적·경제적·정치적 지위와 권세에 의한 압박 등도 이에 포함되고, 현실적으로 피해자의 자유의사가 제압될 것을 필요로 하는 것은 아니지만, 범인의 위세, 사람 수, 주위의 상황 등에 비추어 피해자의 자유의사를 제압하기 족한 세력이어야 한다(대판 2013.5.23. 2011도12440).

(3) 업무의 방해

업무방해죄의 성립에는 업무방해의 결과가 실제로 발생함을 요하지 않고 업무방해의 결과를 초래할 위험이 발생하면 족하며, 업무수행 자체가 아니라 업무의 적정성 내지 공정성이 방해된 경우에도 업무방해죄가 성립한다(대판 2010.3.25. 2009도8506).

판례 (대판 2002.3.29. 2000도3231) **辯2**

업무를 '방해한다'함은 업무의 집행 자체를 방해하는 것은 물론이고 널리 업무의 경영을 저해하는 것도 포함한다. → 다만 결과발생의 염려가 없는 경우에는 본 죄가 성립하지 않는다(대판 2007.4.27. 2006도9028).

III. 위법성

1. 자구행위

자구행위의 요건이 갖추어지지 않은 권리행사는 업무방해죄가 된다(대판 1982.6.8. 82도805).

2. 법에 의하여 허용된 쟁의행위도 위법성이 조각된다.

쟁의행위는 근로조건 개선과 임금향상을 위한다는 목적의 정당성과 폭력·파괴행위 및 사업장 등의 안전보호시설의 정상적인 유지를 방해하는 행위는 할 수 없다는 수단의 정당성이 인정되어야 정당행위가 된다(대판 1992.9.22. 92도1855).

IV. 컴퓨터 업무방해죄(형법 제314조 제2항)

1. 의의

컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해함으로써 성립하는 범죄이다.

2. 행위객체

컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록이다.

3. 행위

(1) 의의

손괴, 허위의 정보 또는 부정한 명령의 입력, 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생케 하는 것이다.

(2) 내용

① 손괴는 물리적 파괴, 멸실, 기기조작으로 입력된 데이터를 없애버리는 행위를 말하며, ② 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하는 것은 진실에 반하는 정보나 사무처리상 해서는 안 되는 정보의 입력, 기기의 기능을 마비시키는 프로그램(바이러스) 등을 입력하는 것을 말한다. 허락 없이 정보를 알아내는 것은 제316조 제2항(컴퓨터 비밀침해죄)에 의해서, 이를 통하여 재산상 이익을 취하는 것은 제347조의 2(컴퓨터등사용사기죄)에 의해서 처벌받는다.

- ③ 그리고 기타 방법이란 앞에서 본 두 가지 이외의 가해수단으로 컴퓨터에 일정한 가해를 함으로써 작동불능상태에 빠뜨리거나 사용목적에 부합하지 않도록 하는 일체의 행위를 말한다. 그렇다고 하여 고의범인 컴퓨터 업무방해죄의 행위태양에 과실에 의한 방법이 포함된다고 해석하는 것은 죄형법정주의에 반 할 수는 있는 것이므로 기타 방법에 과실로 인한 행위는 포함되지 않는다.

판례 (대판 2012.5.24. 2011도7943) 司56

주택재건축조합 조합장인 피고인이 자신에 대한 감사활동을 방해하기 위하여 조합 사무실에 있던 컴퓨터에 비밀번호를 설정하고 하드디스크를 분리·보관함으로써 조합 업무를 방해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 위와 같은 방법으로 조합의 정보처리에 관한 업무를 방해한 행위는 형법 제314조 제2항의 컴퓨터 등 장애 업무방해죄에 해당한다.

4. 기수시기

본죄는 추상적 위험범이므로 업무가 현실적으로 방해될 필요는 없고, 업무가 방해될 위험이 있으면 기수에 이른다.

판례 (대판 2009.4.9. 2008도11978) 司54·56

‘컴퓨터 등 장애 업무방해죄’가 성립하기 위해서는 가해행위 결과 정보처리장치가 그 사용목적에 부합하는 기능을 하지 못하거나 사용목적과 다른 기능을 하는 등 정보처리에 장애가 현실적으로 발생하였을 것을 요하나, 정보처리에 장애를 발생하게 하여 업무방해의 결과를 초래할 위험이 발생한 이상, 나아가 업무방해의 결과가 실제로 발생하지 않더라도 위 죄가 성립한다. 따라서 포털사이트 운영회사의 통계집계시스템 서버에 허위의 클릭정보를 전송하여 검색순위 결정 과정에서 위와 같이 전송된 허위의 클릭정보가 실제로 통계에 반영됨으로써 정보처리에 장애가 현실적으로 발생하였다면, 그로 인하여 실제로 검색순위의 변동을 초래하지는 않았다 하더라도 ‘컴퓨터 등 장애 업무방해죄’가 성립한다.

♣ 확인학습문제

1. 충북지방경찰청 민원실에서 甲 등 민원인들이 진정사건의 처리와 관련하여 지방경찰청장과의 면담 등을 요구하면서 이를 제지하는 경찰관들에게 큰소리로 욕설을 하고 행패를 부렸으나 그 정도가 폭행, 협박에는 이르지 못하고, 위력에 그친 경우 甲 등의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 폭행죄 또는 협박죄
- ② 무죄
- ③ 업무방해죄
- ④ 공무집행방해죄
- ⑤ 건조물침입죄

【정답】 ②

【해설】 판례(대판 2009.11.19. 2009도4166 전원합의체)는 업무방해죄의 업무에는 공무집행방해죄의 공무가 포함되지 않는다는 입장인바, 이에 의하면 공무집행방해죄나 업무방해죄는 성립하지 않는다. 폭행, 협박은 사용한 적이 없고, 경찰서 민원실은 민원인들이 들어 갈 수 있는 장소이므로 이 부분도 무죄이다.

2. 다음 업무방해죄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 폭력조직 간부인 피고인이 직원들과 공모하여 甲이 운영하는 성매매업소 앞에 속칭 ‘병풍’을 치거나 차량을 주차해 놓는 등 위력으로써 업무를 방해하였더라도 성매매업소 운영업주가 업무방해죄의 보호대상인 업무라고 볼 수 없다.
- ② 주한미국대사관에 비자를 신청하면서 허위의 사실을 기재하여 신청서와 이를 입증할 다른 허위자료까지 제출하고 공범에게는 미국대사관에서 문의전화가 오면 허위답변을 하도록 시킨 경우 위계에 의한 업무방해죄가 성립한다.
- ③ 업무방해죄의 보호대상이 되는 "업무"에 있어 그 업무의 기초가 된 계약 또는 행정행위 등이 반드시 적법하여야 한다
- ④ 서류배달업 회사의 직원이 회사가 배달을 의뢰받은 서류포장 속에 특정 종교를 비방하는 전단을 집어넣어 함께 배달되도록 한 경우 업무방해죄가 성립한다.
- ⑤ 사립학교의 시험출제위원이 문제를 선정하여 시험실시자에게 제출하기 전에 유출하였으나 이를 시험실시자에게 제출하지 않은 경우 업무방해죄로 처벌할 수 없다.

[정답] ③

[해설] 업무방해죄의 보호대상이 되는 "업무"라 함은 직업 또는 계속적으로 종사하는 사무나 사업을 말하는 것으로서 타인의 위법한 행위에 의한 침해로부터 보호할 가치가 있는 것이면 되고, 그 업무의 기초가 된 계약 또는 행정행위 등이 반드시 적법하여야 하는 것은 아니다(대판 1991.6.28. 91도944).

3. 주택재건축조합 조합장인 甲이 조합원들로부터 공금횡령 등의 이유로 탄핵을 당할 처지에 이르자 자신에 대한 감사활동을 방해하기 위하여 조합 사무실에 있던 컴퓨터에 비밀번호를 설정하고 하드디스크를 분리하여 사무실 금고에 보관하였는데, 조합의 감사 乙은 甲이 위 컴퓨터에 작성하여 둔 각종 자료들을 출력하여 甲에 대한 탄핵자료로 활용하려 하였으나, 甲이 위와 같이 컴퓨터에 비밀번호를 설정하고 하드디스크를 분리하여 은닉하는 바람에 탄핵자료를 수집하지 못하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 절도죄
- ③ 위력에 의한 업무방해죄
- ④ 위계에 의한 업무방해죄
- ⑤ 컴퓨터 등 장애 업무방해죄

[정답] ⑤

[해설] 위와 같은 방법으로 조합의 정보처리에 관한 업무를 방해한 행위는 형법 제314조 제2항의 컴퓨터 등 장애 업무방해죄에 해당한다(대판 2012.5.24. 2011도7943).

♣ 학습내용 정리

- 1. 업무방해죄는 허위사실을 유포하거나 위계·위력으로 사람의 업무를 방해함으로써 성립하는 범죄이다.
- 2. 자구행위의 요건이 갖추어지지 않은 권리행사는 업무방해죄가 된다
- 3. 컴퓨터 등 장애 업무방해죄는 컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해함으로써 성립하는 범죄이다.

제12강 주거침입죄(형법 제319조)

♣ 학습목표

- 주거침입죄의 의의를 설명할 수 있다.
- 주거침입죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 주거침입죄에는 어떠한 위법성조각사유가 있는지를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 주거침입
- 주거의 사실상 평온
- 위요지

♣ 사전테스트

1. 외출로 인하여 잠시 빈집에 들어간 경우는 주거침입죄가 성립하지 않는다.
정답 : X
2. 주거자의 동의는 주거침입죄의 구성요건해당성을 배제하는 양해가 된다.
정답 : O
3. 위요지에 들어가는 것만으로는 침입이라고 할 수 없다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

돌을 던지거나, 단순히 들여다보거나, 전화를 거는 경우도 침입에 해당한다.

[정답] X

[해설] 침입은 신체적 침입을 의미하므로 밖에서 돌을 던지거나, 단순히 들여다보거나, 전화를 거는 경우는 침입이 아니다.

♣ 강의내용

I. 의의

1. 개념

주거침입죄는 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입함으로써 성립하는 범죄이다.

2. 보호법익 · 보호정도

(1) 보호법익 - 사실상의 주거의 평온

주거침입죄는 사실상의 주거의 평온을 보호법익으로 하는 것이므로 그 거주자 또는 간수자가 건조물 등에 주거 또는 간수할 권리를 가지고 있는 여부는 범죄의 성립을 좌우하는 것이 아니며 점유할 권리 없는 자의 점유라 하더라도 그 주거의 평온은 보호되어야 할 것이므로 권리자가 그 권리를 실현함에 있어 법에 정하여진 절차에 의하지 아니하고 그 주거 또는 건조물에 침입하는 경우에는 주거침입죄가 성립한다(대판 1984.4.24. 83도1429).

(2) 보호정도

침해범으로서의 보호이다(다수설, 판례).

II. 구성요건

1. 행위객체

사람의 주거 · 관리하는 건조물 · 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실이다.

(1) 사람의 주거

주거란 사람이 일상생활을 위해 점거하고 침식에 사용하는 장소를 말한다. 주거의 사용은 일시적 · 영구적인 것을 불문하고(ex. 낮에만 기거하는 장소, 별장), 주거의 설비나 구조도 불문한다(ex. 천막집, 판자집, 토굴). 주거의 부속건물(ex. 정원, 복도, 계단, 차고 등), 즉 위요지나 주거용 차량도 포함된다. 가령 외출로 인하여 잠시 빈집이나 주거에 반드시 사람이 있어야 할 필요가 없다.

판례 (대판 2009.9.10. 2009도4335)

辯1 司52 · 55

[1] 주거침입죄에 있어서 주거란 단순히 가옥 자체만을 말하는 것이 아니라 그 정원 등 위요지를 포함한다. 따라서 다가구용 단독주택이나 다세대주택 · 연립주택 · 아파트 등 공동주택 안에서 공용으로 사용하는 엘리베이터, 계단과 복도는 주거로 사용하는 각 가구 또는 세대의 전용 부분에 필수적으로 부속하는 부분으로서 그 거주자들에 의하여 일상생활에서 감시 · 관리가 예정되어 있고 사실상의 주거의 평온을 보호할 필요성이 있는 부분이므로, 다가구용 단독주택이나 다세대주택 · 연립주택 · 아파트 등 공동주택의 내부에 있는 엘리베이터, 공용 계단과 복도는 특별한 사정이 없는 한 주거침입죄의 객체인 '사람의 주거'에 해당하고, 위 장소에 거주자의 명시적, 묵시적 의사에 반하여 침입하는 행위는 주거침입죄를 구성한다. [2] 피고인이 강간할 목적으로 피해자를 따라 피해자가 거주하는 아파트 내부의 엘리베이터에 탄 다음 그 안에서 폭행을 가하여 반항을 억압한 후 계단으로 끌고 가 피해자를 강간하고 상해를 입힌 사안에서, 피고인이 성폭력특례법 제3조 제1항에 정한 주거침입범의 신분을 가지게 되었다는 이유로, 주거침입을 인정하지 않고 강간상해죄만을 선고한 원심판결을 파기한 사례.

(2) 관리하는 건조물·선박이나 항공기

- ① 관리하는 사람이 사실상 지배·보존하는 것으로 인적·물적 설비에 의해 이루어진다. 예컨대 경비원을 두거나 또는 열쇠로 잠그거나 못질을 하는 경우가 이에 해당한다. 반드시 출입이 불가능하거나 곤란하게 할 설비여야 할 필요는 없다.
- ② 건조물은 주거를 제외한 일체의 건물과 그 부속물이다. ex.) 공장, 사무소, 관공서, 극장, 창고, 복도, 담배가게로 쓰이는 알미늄 샷시로 된 구조물

(3) 점유하는 방실

건조물 안에서 사실상 지배·관리하고 있는 일 구획을 말한다(ex. 점포, 사무실, 연구실, 투숙중인 호텔이나 여관의 방). 가옥의 일부분인 방을 명도받은 경우에도 점유하는 방실에 속한다.

2. 행위

(1) 침입

주거자의 의사에 반하여 행위자의 신체가 주거에 들어가는 것이다. 침입은 거동에 의한 신체적 침입이다. 주거로 들어가는 문의 시정장치를 부수거나 문을 여는 등 침입을 위한 구체적 행위를 시작하였다면 주거침입죄의 실행의 착수는 있었다고 보아야 한다(판례).

침입의 방법은 불문한다. 다만 침입은 신체적 침입을 의미하므로 밖에서 돌을 던지거나, 단순히 들여다보거나, 전화를 거는 경우는 침입이 아니다.

또한 침입은 외부로부터의 침입이어야 하므로 이미 주거 안에 적법하게 들어온 이상 그 후 침입의 의사가 생긴 경우라도 본죄는 성립할 수 없다. ex.) 친척집에 놀러 갔다가 도중에 범의가 생겨 절도를 한 경우

(2) 주거자의 의사

(가) 주거자

1) 의의

주거자란 해당 주거에 대한 출입과 체재를 결정할 수 있는 권리를 가지고 있는 사람이다. 소유자이거나 직접 점유자임을 요하지 않는다. 주거권은 적법한 점유의 개시으로써 획득되며 그 이후의 주거권은 사실상 거주하고 있으면 계속 유지되고 점유할 권리 여부는 문제되지 않는다.

2) 借家

제3자에 대한 관계에서는 물론 소유자에 대한 관계에서도 주거권은 임차인에게 있다. 따라서 임차기간이 종료한 경우라도 임차인이 동의자가 된다. 그러므로 임대차기간이 종료한 이후에 임차인이 계속 점유하고 있는 건물에 소유자가 무단으로 출입하면 주거침입죄가 성립한다. 이와는 반대로 소유자가 폐쇄한 출입구를 임차인이 뜯고 그 건물에 들어간 경우는 주거침입죄가 성립하지 않는다(대판 1985.3.26. 85도122).

3) 같은 주거에 수인이 거주할 때 - 공동주거

- ① 이때는 각자는 모두 독립된 주거의 자유를 가진다. 따라서 수인 가운데 1인의 동의를 받고 출입한 경우는 사실상 주거의 평온이 침해된 것이 아니므로 침입이 아니다.

- ② 문제가 되는 것은 거주자 1인의 승낙이 다른 거주자의 의사에 직접·간접으로 반하는 경우, 예컨대 부부의 일방이 부재중인 상황에서 다른 일방과 간음의 목적으로 주거에 들어갔을 때 주거침입죄가 성립하는지 여부이다.
- ③ 판례(대판 1984.6.26. 83도685)는 주거의 사실상 평온설을 취하면서도 다른 주거자의 의사에 반할 때에는 주거의 사실상의 평온은 깨어졌다 할 것이라고 보아 주거침입죄의 성립을 인정한다.

(나) 주거자의 의사

1) 원칙

주거자의 의사에 반할 때에만 침입이 된다. 그러나 주거자의 동의가 있는 경우에는 본죄가 성립하지 않는다. 여기서 주거자의 동의는 구성요건해당성을 배제하는 양해가 된다.

주거침입이 주거자 등의 명시적·추정적 의사에 반하느냐의 여부는 결과에서 확인된 실질적인 의사가 아니라 주거침입 자체에 대한 의사를 중시하여 판단해야 한다. 따라서 강간의 의도를 가진 범인을 남편으로 오인하여 피해자가 용변칸의 문을 열어 준 경우에는 침입 자체에 대한 피해자의 명시적·묵시적 승낙이 없어 주거침입죄가 성립한다(대판 2003.5.30. 2003도1256). → 성폭력 처벌특례법상 주거침입강간죄의 미수(용변칸 강간미수 사건)

2) 범죄목적으로 침입한 경우

타인의 주거에 범죄의 목적을 숨기고 주거권자의 명시적·추정적 승낙하에 주거 등에 들어간 경우 주거자의 진의에 반하기 때문에 주거자의 동의가 없다고 할 것이므로 본죄가 성립한다.

판례 (대판 2011.8.18. 2010도9570) **辯3** 司55

A회사의 감사인 甲은 경영진과의 불화로 회사를 퇴사한 후 30일이 지나 회사의 승낙 없이 자신이 사용하던 A회사 소유의 컴퓨터 하드디스크를 가지고 가기 위하여 일출 직후인 06:48경 A회사에 갔으나 자신의 출입카드가 정지되어 출입구가 열리지 않자 경비원으로부터 임시 출입증을 받아 감사실에 들어간 경우 甲에게는 방실침입죄가 성립한다. → 위 방실침입 행위가 정당행위에 해당하지 않는다.

3) 일반인의 침입이 허용된 공공장소에 범죄목적으로 들어간 경우 - 주거침입죄 성립

판례 초원복집사건(대판 1997.3.28. 95도2674) **司42** · 45

일반인의 침입이 허용된 음식점이라 하더라도, 영업주의 명시적 또는 추정적 의사에 반하여 들어간 것이라면 주거침입죄가 성립한다.

(3) 기수시기

신체의 전부가 아니라 일부만이 주거 안으로 들어간 경우에도 주거침입죄가 성립할 것인가가 문제되는데, 판례는 신체의 일부만 침입해도 본죄가 성립한다는 일부침입설을 취한다.

판례 얼굴만 들이민 사건(대판 1995.9.15. 94도2561) **司42** · 45 · 49

[사실관계] 甲은 1993.9.22. 00:10경 대전 중구 선화 3동에 있는 피해자(女)의 집에서 그녀를 강간하기 위하여 그 집 담 벽에 발을 딛고 창문을 열고 안으로 얼굴을 들이키는 등으로 동인의 주거에 침입하려 하였으나 동인이 소리치는 바람에 그 목적을 이루지 못하고 도주하다가 체포되었다.

[판결요지] [1] 주거침입죄는 사실상의 주거의 평온을 보호법익으로 하는 것이므로, 반드시 행위자의 신체의 전부가 범행의 목적인 타인의 주거 안으로 들어가야만 성립하는 것이 아니라 신체의 일부만 타인의 주거 안으로 들어갔다고 하더라도 거주자가 누리는 사실상의 주거의 평온을 해할 수 있는 정도에 이르렀다면 범죄구성요건을 충족하는 것이라고 보아야 하고, 따라서 주거침입죄의 범의는 반드시 신체의 전부가 타인의 주거 안으로 들어간다는 인식이 있어야만 하는 것이 아니라 신체의 일부라도 타인의 주거 안으로 들어간다는 인식이 있으면 족하다. [2] 야간에 타인의 집의 창문을 열고 집 안으로 얼굴을 들이미는 등의 행위를 하였다면 피고인이 자신의 신체의 일부가 집 안으로 들어간다는 인식하에 하였더라도 주거침입죄의 범의는 인정되고, 또한 비록 신체의 일부만이 집 안으로 들어갔다고 하더라도 사실상 주거의 평온을 해하였다면 주거침입죄는 기수에 이르렀다.

III. 위법성

1. 피해자의 승낙 또는 추정적 승낙

판례 (대판 2010.3.11. 2009도5008) **司**54

사용자인 주식회사 코스콤 이외에도 한국증권선물거래소가 공동관리하는 로비를 피고인들이 점거한 사안에서 2인 이상이 하나의 공간에서 공동생활을 하고 있는 경우에는 각자 주거의 평온을 누릴 권리가 있으므로, 사용자가 제3자와 공동으로 관리·사용하는 공간을 사용자에게 대한 쟁의행위를 이유로 관리자의 의사에 반하여 침입·점거한 경우 비록 그 공간의 점거가 사용자에게 대한 관계에서 정당한 쟁의행위로 평가될 여지가 있다 하여도 이를 공동으로 관리·사용하는 제3자의 명시적 또는 추정적인 승낙이 없는 이상 위 제3자에 대하여서까지 이를 정당행위라고 하여 주거침입의 위법성이 조각된다고 볼 수는 없다.

2. 법령에 의한 정당행위

형사소송법상 체포·구속·압수·수색·검증을 위한 경우, 민사소송법상의 강제집행을 위한 경우, 노동법상의 쟁의행위를 위한 경우는 권리남용이 아닌 한 주거침입이 아니다.

3. 현행범체포

사인이 현행범체포 또는 은닉장물의 발견을 위해 타인주거에 들어가는 것은 위법성이 조각되지 않는다(대판 1965.12.21. 65도899). **司**45

4. 사회상규에 반하지 않는 행위

- ① 술에 취하여 시비 중에 상대방의 주거에 따라 들어가서 때린 이유를 따진 경우는 위법성이 조각된다(대판 1969.9.26. 67도1089).
- ② 피고인이 동네 부녀자에게 욕설한 것을 따지기 위해 동네 부녀자 10여명과 작당하여 피해자의 집에 들어간 경우는 위법성이 조각되지 않는다(대판 1983.10.11. 83도2230).

♣ 확인학습문제

1. 주거침입죄에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 주거침입죄에서 주거란 단순히 가옥 자체만을 말하는 것이 아니라 그 정원 등 위요지를 포함한다.
- ② 다세대주택·연립주택·아파트 등 공동주택의 내부에 있는 엘리베이터, 공용 계단과 복도는 특별한 사정이 없는 한 주거침입죄의 객체인 ‘사람의 주거’에 해당한다.
- ③ 남편의 부재 중 간통의 목적으로 처의 승낙을 받고 주거에 들어간 경우와 같이 복수의 주거권자 중 한 사람이 그 주거에의 출입을 승낙하더라도, 그 승낙이 다른 주거권자의 의사에 직접·간접으로 반하는 경우 그 출입행위는 주거침입에 해당한다.
- ④ 임대차 기간이 종료된 후에는 임차인이 계속 점유하고 있는 건물에 그 소유자가 무단으로 들어가더라도 주거침입죄가 성립하지 않는다.
- ⑤ A회사의 감사인 甲이 경영진과의 불화로 회사를 퇴사한 후 30일이 지나 회사의 승낙 없이 자신이 사용하던 A회사 소유의 컴퓨터 하드디스크를 가지고 가기 위하여 일출 직후인 06:48경 A회사에 갔으나 자신의 출입카드가 정지되어 출입구가 열리지 않자 경비원으로부터 임시 출입증을 받아 감사실에 들어간 경우 甲에게는 방실침입죄가 성립한다.

[정답] ④

[해설] 이 사건 가옥을 피해자가 점유관리하고 있었다면 그 건물이 가사 피고인의 소유였다 할지라도 주거침입죄의 성립에 아무런 장애가 되지 않는다(대판 1989.9.12. 89도889).

2. 甲은 피해자 乙(女)의 집에서 그녀를 강간하기 위하여 그 집 담 벽에 발을 딛고 창문을 열고 안으로 얼굴을 들이미는 등으로 乙의 주거에 침입하려 하였으나 乙이 소리치는 바람에 그 목적을 이루지 못하고 도주하다가 체포되었다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 주거침입죄의 미수
- ② 주거침입죄
- ③ 강간죄의 미수와 주거침입죄의 미수
- ④ 강간죄의 미수와 주거침입죄
- ⑤ 무죄

[정답] ②

[해설] 비록 신체의 일부만이 집 안으로 들어갔다고 하더라도 사실상 주거의 평온을 해하였다면 주거침입죄는 기수에 이르렀다(대판 1995.9.15. 94도2561).

3. 甲이 피해자 乙(女)가 사용 중인 공중화장실의 용변칸에 노크하여 남편으로 오인한 乙이 용변칸 문을 열자 강간할 의도로 용변칸에 들어가 강간을 시도하다가 미수에 그친 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 방실침입죄
- ③ 성폭력처벌특별법상 주거침입강간죄의 미수
- ④ 강간죄의 미수
- ⑤ 방실침입죄와 강간죄의 미수

[정답] ③

【해설】 강간의 의도를 가진 범인을 남편으로 오인하여 피해자가 용변칸의 문을 열어 준 경우에는 출입 자체에 대한 피해자의 명시적·묵시적 승낙이 없어 주거침입죄가 성립한다(대판 2003.5.30. 2003도1256). → 성폭력처벌특별법상 주거침입강간죄의 미수

♣ 학습내용 정리

1. 주거침입죄는 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 침입이란 주거자의 의사에 반하여 행위자의 신체가 주거에 들어가는 것이다.
3. 주거자의 의사에 반할 때에만 침입이 된다.

제13강 친족상도례와 절도죄의 구성요건

♣ 학습목표

- 친족상도례의 내용을 설명할 수 있다.
- 재산범죄에 있어 재물의 개념을 설명할 수 있다.
- 절도죄에 있어 점유의 의미를 설명할 수 있다.
- 절취행위의 내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 친족상도례
- 금제품
- 타인의 점유와 소유
- 절취

♣ 사전테스트

1. 친족상도례에 있어 친족관계는 행위시에 존재하면 되고 그 후에 소멸되더라도 상관없다.
정답 : O
2. 금제품은 절도죄의 객체가 될 수 없다.
정답 : X
3. 대중교통 내부에서 타인의 분실한 물건을 가져간 경우 절도죄가 성립한다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

사돈지간에 사기죄를 범한 경우 친족상도례가 적용된다.

[정답] X

[해설] 사기죄의 피고인과 피해자가 사돈지간이라고 하더라도 이를 민법상 친족으로 볼 수 없다(대판 2011.4.28. 2011도2170).

♣ 강의내용

1. 친족상도례

1. 의의

친족간에 발생한 재산범죄에 대하여 친족관계의 특수성을 고려하여 처벌에서 특별히 취급하도록 한 규정들을 말한다.

2. 적용범위

(1) 형법규정

형법은 권리행사방해죄(제328조)에서 근친 간에는 형을 면제하고(제1항), 원친 간에는 친고죄(제2항)로 규정하고 있다.

준용	① 절도죄(제344조), 공갈죄(제354조), 사기죄(제354조), 횡령죄(제361조), 배임죄(제361조), 장물죄(제365조)에 준용된다. ② 재산죄 가운데 강도죄, 손괴죄, 점유강취죄와 준점유강취죄, 강제집행면탈죄에는 준용하지 않는다.
수정	제365조 제1항 : 장물범과 피해자간에 제328조 제1항, 제2항의 신분관계가 있는 경우는 동조의 규정을 준용한다. 제365조 제2항 : 장물범과 본범간에 제328조 제1항의 신분관계가 있을 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

(2) 특별법 규정

① 친족상도례에 관한 형법 규정은 특경법 제3조 제1항 위반(사기)죄에도 그대로 적용되고(대판 2000.10.13. 99오1) ② 흉기 기타 위험한 물건을 휴대하고 공갈죄를 범하여 폭처법 제3조 제1항에 의해 가중처벌 되는 경우 친족상도례 규정이 적용된다(대판 2010.7.29. 2010도5795).

3. 친족관계의 존재범위

(1) 의의

친족, 가족의 정의 및 그 범위는 민법에 따른다(민법 제767조 이하).

- ① 동거친족은 같은 주거에서 일상생활을 공동으로 하는 친족으로, 일시 숙박하는 자와 가출한 자는 제외한다.
- ② 배우자는 법률상 배우자에 한하고 배우자는 민법에 의한 법률상 개념이므로 법률혼만을 의미한다.
- ③ 직계혈족은 직계존속과 직계비속을 말하며 계모는 직계혈족은 아니지만 동거하는 경우에는 가족에 해당한다.
- ④ 사기죄의 피고인과 피해자가 사돈지간이라고 하더라도 이를 민법상 친족으로 볼 수 없다(대판 2011.4.28. 2011도2170).
- ⑤ 친족상도례를 규정한 형법 제328조 제1항에서 ‘그 배우자’는 동거가족의 배우자만을 의미하는 것이 아니라, 직계혈족, 동거친족, 동거가족 모두의 배우자를 의미하는 것으로 볼 것이다(대판 2011.5.13. 2011도1765).

(2) 인적 범위

(가) 절도죄

재산죄의 보호법익은 소유권 및 점유이므로 행위자와 재물의 소유자뿐만 아니라 점유자 사이에도 있어야 한다(대판 1980.11.11. 80도131).

(나) 횡령죄, 배임죄

횡령죄·배임죄는 신뢰관계에 대한 배반(배신설)을 본질로 하므로 위탁자도 피해자가 되어 소유자·위탁자 쌍방과 행위자가 친족관계가 있어야 친족상도례가 적용된다(대판 2008.7.4. 2008도3438)

(다) 사기죄

피기망자의 신뢰는 사기죄의 보호법익이 아니므로 피기망자는 피해자(재물교부자)가 아니라 할 것이므로 사기죄를 범한 자와 피해자와의 사이에만 친족관계가 있으면 친족상도례가 적용된다(대판 1976.4.13. 75도781).

(라) 장물죄

장물죄의 경우 장물범과 본범 사이에 직계혈족 등의 근친관계가 있다면 형을 감경 또는 면제한다(제365조 제2항). 司56

(3) 시적 범위

- ① 친족관계는 행위시에 존재하면 되고 그 후에 소멸되더라도 상관없다. 가령 남편 甲이 아내인 B의 물건을 훔친 후 이혼을 한 경우에는 이혼으로 인하여 친족관계가 소멸되더라도 친족상도례가 적용되는 것이다. 반대로 범죄 후에 비로소 친족관계가 생긴 경우에는 적용되지 않는다.
- ② 다만 혼인 외의 출생자에 대한 인지가 범행 후에 행해진 경우에는 민법 제860조의 인지의 소급효에 의하여 친족상도례가 적용된다.

II. 절도죄의 재물과 점유의 개념

1. 재물의 개념

재물이란 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력이다(민법 제98조).

(1) 유체물

유체물은 일정한 공간을 차지하고 있는 물체여야 한다. 기체, 액체, 고체를 불문한다. 그러나 채권, 기타의 권리는 유체물이 아니다.

(2) 관리할 수 있는 동력 - 권리나 정보의 재물성 여부

재물과 재산상의 이익을 구별하기 위하여 관리에는 사무적 관리는 제외된 물리적 관리만을 의미한다(통설, 판례). 따라서 권리절도는 부정된다고 할 것이므로 권리, 전파, 전화의 송수신기능, 컴퓨터 파일 등은 재물이 아니다. 따라서 타인의 일반전화를 무단사용한 경우 절도죄가 성립하지 않는다(대판 1998.6.23. 98도700).

(3) 재물의 가치성

절도죄의 객체인 재물은 반드시 객관적인 금전적 교환가치를 가질 필요는 없고 소유자·점유자가 주관적인 가치를 가지고 있는 것으로 족하고, 이 경우 주관적·경제적 가치의 유무를 판별함에 있어서는 그것이 타인에 의하여 이용되지 않는다고 하는 소극적 관계에 있어서 그 가치가 성립하더라도 관계없다(대판 2007.8.23. 2007도2595).

(4) 금제품의 재물성

금제품이란 법률에 의하여 그 소유·소지가 금지되어 있는 것인데, 이 경우에도 타인의 재물이 인정되어 재산죄의 객체가 될 것인가가 문제된다. 가령 금제품인 위조통화를 절취한 경우에도 재물성을 인정하여 절도죄가 성립할 것인지가 문제된다.

이에 대하여 판례(대판 1998.11.24. 98도2967)는 금제품의 소지를 범죄로 하는 것과 그 소지를 침해하는 것은 전혀 별개의 문제이고 금제품이라 할지라도 국가의 소유를 인정하여 절차에 따라 몰수되기까지는 그 소지를 보호해야 하므로 재물성을 인정할 수 있다는 입장이다.

2. 소유의 타인성

타인의 재물은 행위자가 아닌 다른 사람이 단독소유 또는 그와 공동소유, 총유, 합유하고 있으며, 또 점유하고 있는 재물이다. 여기서 타인이라 함은 자연인 이외에 국가, 법인, 기타 법인격 없는 단체도 포함하는 개념이다. 이때 타인의 재물이면 소유자와 점유자가 일치할 필요는 없다. 그러나 무주물이나 소유권자가 소유권을 유효하게 포기한 물건은 타인의 재물이 아니다.

3. 점유의 타인성

형법상 점유란 사회생활상 지배의사를 가지고 재물을 사실상 지배하는 행위를 말한다. 민법상의 소유권자는 아니더라도 형법상의 점유자도 타인에 포함되기 때문에 도둑이 훔친 물건을 다시 절취한 경우에도 절도죄가 성립한다(대판 1966.12.20. 66도1437).

(1) 사자의 점유

가령 甲이 피해자 乙의 집에서 함께 술을 마시다가 다툼이 일어나서 甲이 우발적으로 乙을 살해하고 난 후 乙의 재물을 취거하여 乙의 집을 나온 경우 甲의 행위에 대하여는 소위 死者의 점유를 인정할 것인가의 여부에 따라서 절도죄 혹은 점유이탈물횡령죄의 성부가 문제된다.

판례는 “피해자를 살해한 방에서 사망한 피해자 곁에 4시간 30분쯤 있다가 그곳 피해자의 자취방 벽에 걸려 있던 피해자가 소지하는 물건들을 영득의 의사로 가지고 나온 경우 피해자가 생전에 가진 점유는 사망 후에도 여전히 계속되는 것으로 보아야 한다.”(대판 1993.9.28. 93도2143)고 판시하여 생전점유계속설에 의하여 절도죄의 성립을 인정한다.

(2) 분실물에 대한 점유

- ① 원점유자가 물건의 소재를 알고 있고 다시 찾을 가능성이 있으면 원점유자의 점유가 인정된다. 그러나 재물의 원점유자가 그 소재를 모르는 경우에는 원칙적으로 점유이탈물이 된다.
- ② 다만 다른 사람의 배타적 지배범위 내에 두고 온 경우에는 관리자인 타인의 새로운 점유가 개시된다. ex.) 목욕탕 또는 당구장에 두고 온 시계

판례 (대판 2007.3.15. 2006도9338)

辯3

피씨방에 두고 간 다른 사람의 핸드폰을 취한 행위가 절도죄를 구성한다고 한 사례 - 피해자가 피씨방에 두고 간 핸드폰은 피씨방 관리자의 점유하에 있어서 제3자가 이를 취한 행위는 절도죄를 구성한다.

(3) 대중교통 내부에서 분실한 물건

대중교통 운전사가 수시로 바뀌기 때문에 운전사를 유실물의 관리자로 볼 수 없기 때문에 점유이탈물횡령죄에 해당한다(다수설, 판례).

III. 절취행위

1. 의의

타인점유의 재물에 대하여 그 점유자의 점유를 배제하고 자기 또는 제3자의 점유로 옮기는 것이다. 따라서 타인의 점유의 배제와 새로운 점유의 취득이 절취의 개념요소가 된다.

2. 점유의 배제

점유의 배제란 물건에 대한 점유자의 지배의사에 반하는 행동으로 그 물건에 대한 사실상의 지배를 제거하는 것이다. 그 수단과 방법에는 제한이 없다. 점유배제는 점유자의 의사에 반할 것을 요하므로 점유자의 동의가 있으면 점유배제는 인정되지 않는다(양해).

3. 점유의 취득

점유의 취득이란 행위자가 방해받지 않고 물건에 대한 사실상 지배를 갖는 것으로 지배의사가 있어야 한다. 행위자가 자기의 점유로 옮김으로써 새로운 점유를 취득한다.

본죄에서 절취란 타인의 점유를 배제하고 그 재물을 자기 또는 제3자의 점유로 옮기는 것이므로 재물을 취득할 때 기수가 된다(취득설 : 통설, 판례). 보다 구체적으로는 쉽게 운반이 가능한 일상용품과 같은 경우에는 손에 잡거나 주머니에 넣는 것만으로 취득을 인정할 수 있다.

반면에 쉽게 운반할 수 없는 재물은 피해자의 지배범위를 벗어나야 취득이 인정된다. ex) 쌀가마니를 운반하려고 자동차에 적재를 완료한 경우

판례 (대판 2008.10.23. 2008도6080) 辯2 司52・55

甲은 乙이 입목인 연산홍을 땅에서 완전히 캐낸 이후에 비로소 범행장소에 와서 乙과 함께 위 입목을 승용차까지 운반하였다는 것인바, 입목을 절취하기 위하여 이를 캐낸 때에는 그 시점에서 이미 소유자에 대한 점유가 침해되어 범인의 사실적 지배하에 놓이게 됨으로써 범인이 그 점유를 취득하게 되는 것이므로 이때 절도죄는 기수에 이르렀다고 할 것이고 이를 운반하거나 반출하는 등의 행위는 필요로 하지 않는다고 할 것이다.

♣ 확인학습문제

1. 형법상 친족상도례에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲이 혼인하여 따로 살고 있는 친동생 A의 집에 놀러갔다가 A의 시계를 절취한 경우 친족상도례의 규정이 적용되어 甲에 대해서는 형이 면제된다.
- ② 친족상도례를 규정한 형법 제328조 제1항에서 ‘그 배우자’는 직계혈족, 동거친족, 동거가족 모두의 배우자를 의미한다.
- ③ 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제3조 제1항 위반죄에도 형법상 친족상도례에 관한 규정이 그대로 적용된다.
- ④ 甲이 법원을 기망하여 A로부터 재물을 편취한 경우 A와 甲이 직계혈족의 관계에 있더라도 甲에 대해서 친족상도례가 적용되지 않는다.

- ⑤ 장물범과 본범간에 제328조 제1항의 근친의 신분관계가 있을 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

【정답】 ①

【해설】 甲과 A는 친족이기는 하지만, 직계혈족이 아니고 또한 동거친족도 아니므로 제328조 제2항의 친족관계에 불과하여 형면제판결이 아니라 A의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있을 뿐이다(상대적 친고죄).

2. 절도죄에 있어서의 점유에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 도둑이 훔친 물건을 다시 절취한 경우에도 절도죄가 성립한다.
- ② 물건에 대한 지배의사는 잠재적 의사로도 충분하다.
- ③ 재물의 원점유자가 그 소재를 모르는 경우에는 원칙적으로 점유이탈물이 된다.
- ④ PC방에 두고 간 다른 사람의 핸드폰을 손님인 甲이 발견하고 영득의 의사로 가져간 경우 절도죄가 성립한다.
- ⑤ 입목을 절취하기 위하여 캐낸 경우 아직 소유자의 입목에 대한 점유가 침해되는 것이 아니라 이를 운반하거나 반출한 때 비로소 그 점유가 침해된다.

【정답】 ⑤

【해설】 입목을 절취하기 위하여 캐낸 때에 소유자의 입목에 대한 점유가 침해되어 범인의 사실적 지배하에 놓이게 되므로 범인이 그 점유를 취득하고 절도죄는 기수에 이른다(대판 2008.10.23, 2008도6080).

3. 甲은 A를 살해한 후 A의 곁에서 4시간가량 있다가 A 소유의 금목걸이 1개를 발견하고 영득의 의사로 가지고 나왔다. 이러한 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 살인죄
- ③ 살인죄와 절도죄
- ④ 살인죄와 점유이탈물횡령죄
- ⑤ 강도살인죄

【정답】 ③

【해설】 판례(대판 1993.9.28. 93도2143)는 死者인 피해자가 소지했던 물건들을 영득의 의사로 가지고 나온 경우 피해자가 생전에 가진 점유는 사망 후에도 여전히 계속되는 것으로 보아야 한다고 판시하여 생전점유계속설에 의하여 절도죄의 성립을 인정한다.

♣ 학습내용 정리

- 1. 친족상도레라고 함은 친족간에 발생한 재산범죄에 대하여 친족관계의 특수성을 고려하여 처벌에서 특별히 취급하도록 한 규정을 말한다.
- 2. 절도죄는 타인이 점유하는 타인소유의 재물을 절취함으로써 성립하는 범죄이다.
- 3. 절취행위란 타인점유의 재물에 대하여 그 점유자의 점유를 배제하고 자기 또는 제3자의 점유로 옮기는 것이다.

제14강 불법영득의사

♣ 학습목표

- 불법영득의사의 법리를 설명할 수 있다.
- 사용절도와 불법영득의사의 관계를 설명할 수 있다.
- 영득행위의 위법성의 문제를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 불법영득의사
- 사용절도
- 기능가치와 사용가치
- 영득행위의 위법성

♣ 사전테스트

1. 물건이 갖고 있는 단순한 사용가치를 침해한 경우에도 불법영득의사가 인정된다.
정답 : X
2. 甲이 某 영업점 내에 있는 A 소유의 휴대전화를 허락 없이 가지고 나와 사용한 다음 약 1~2시간 후 위 영업점 정문 옆 화분에 놓아두고 간 경우 절도죄가 성립한다.
정답 : O
3. 행위자가 타인의 재물에 대하여 아무런 법적 청구권도 없었음에도 영득하였을 경우에는 당연히 불법영득의사가 인정된다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

사용절도도 절도죄로 처벌된다.

[정답] X

[해설] 사용절도는 소유자지위를 지속적으로 빼앗는 것이 아니기 때문에 법익침해상황이 없고 불법영득의사도 존재하지 않으므로 절도죄로 처벌되지 않는다.

♣ 강의내용

1. 불법영득의사의 요소

1. 의의

불법영득의사란 권리자를 배제하고(소극적 요소), 타인의 물건을 자기의 소유물인 것처럼 이용·처분하려는 의사(적극적 요소)이다. 따라서 불법영득의사는 법률상 유효하지는 않지만 외관상(형식적·법적)의 지위를 얻고자 하는 것이다.

판례 (대판 2014.2.21. 2013도14139) 司57

절도죄의 성립에 필요한 불법영득의 의사는 타인의 물건을 그 권리자를 배제하고 자기의 소유물과 같이 그 경제적 용법에 따라 이용·처분하고자 하는 의사를 말하는 것으로서, 단순히 타인의 점유만을 침해하였다고 하여 그로써 곧 절도죄가 성립하는 것은 아니나, 재물의 소유권 또는 이에 준하는 본권을 침해하는 의사가 있으면 되고 반드시 영구적으로 보유할 의사가 필요한 것은 아니며, 그것이 물건 자체를 영득할 의사인지 물건의 가치만을 영득할 의사인지를 불문한다. 따라서 어떠한 물건을 점유자의 의사에 반하여 취거하는 행위가 결과적으로 소유자의 이익으로 된다는 사정 또는 소유자의 추정적 승낙이 있다고 볼 만한 사정이 있다고 하더라도, 다른 특별한 사정이 없는 한 그러한 사유만으로 불법영득의 의사가 없다고 할 수는 없다.

[사실관계] 甲은 ① 이 사건 승용차의 소유자인 ○○캐피탈로부터 공소외인 A 명의로 위 승용차를 리스하여 운행하던 중, 사채업자 B로부터 1,300만 원을 빌리면서 위 승용차를 인도하였다. ② 위 사채업자 B는 甲이 차용금을 변제하지 못하자 위 승용차를 매도하였고 최종적으로 피해자 C가 위 승용차를 매수하여 점유하게 되었다. ③ 甲은 위 승용차를 회수하기 위해서 피해자 C와 만나기로 약속을 한 다음 약속장소에 주차되어 있던 위 승용차를 미리 가지고 있던 보조열쇠를 이용하여 임의로 가져갔다. ④ 이후 위 승용차는 공소외인 A를 통하여 약 한 달 뒤인 2012. 11. 23.경 ○○캐피탈에 반납되었다.

2. 소극적 요소 ; 소유자의 지위의 지속적 탈취

재물에 대한 권리자의 종래의 지위를 계속적으로 제거하려는 배제의사가 있어야 한다. 따라서 사용절도는 소유자지위를 지속적으로 빼앗는 것이 아니기 때문에 법익침해상황이 없고 불법영득의사도 존재하지 않으므로 절도죄로 처벌되지 않는다.

다만 예외적으로 ① 사용후 물건의 방치, ② 물건의 가치감소, ③ 소유자가 다시 새 물건을 사야 할 만큼 오랫동안 사용하면 불법영득의사가 인정된다. 가령 소유자의 승낙 없이 오토바이를 타고 가서 다른 장소에 버린 경우, 사용 후 방치인 때와 같이 불법영득의 의사가 인정되는 경우이므로 자동차등불법사용죄가 아닌 절도죄가 성립한다(대판 2002.9.6. 2002도3465). 司55

판례 (대판 2000.3.28. 2000도493) 司43·44·55

타인의 재물을 점유자의 승낙 없이 무단 사용하는 경우 그 사용으로 인하여 재물 자체가 가지는 경제적 가치가 상당한 정도로 소모되거나 또는 사용 후 그 재물을 본래의 장소가 아닌 다른 곳에 버리거나 곧 반환하지 아니하고 장시간 점유하고 있는 것과 같은 때에는 그 소유권 또는 본권을 침해할 의사가 있다고 보아 불법영득의 의사를 인정할 수 있으나, 그렇지 아니하고 그 사용으로 인한 가치의 소모가 무시할 수 있을 정도로 경미하고 또 사용 후 곧 반환한 것과 같은 때에는 그 소유권 또는 본권을 침해할 의사가 있다고 할 수 없어 불법영득의 의사를 인정할 수 없다. 피해자의 승낙 없이 혼인신고서를 작성하기 위하여 피해자의 도장을 몰래 꺼내어 사용한 후 곧바로 제자리에 갖다 놓은 경우, 도장에 대한 불법영득의 의사가 있었다고 볼 수 없다.

판례 (대판 2012.7.12. 2012도1132) 辯3

피고인이 피해자의 영업점 내에 있는 피해자 소유의 휴대전화를 허락 없이 가지고 나와 이를 이용하여 통화를 하고 문자메시지를 주고받은 다음 약 1~2시간 후 갑에게 아무런 말을 하지 않고 위 영업점 정문 옆 화분에 놓아두고 감으로써 이를 절취하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 피고인이 피해자의 휴대전화를 자신의 소유물과 같이 경제적 용법에 따라 이용하다가 본래의 장소와 다른 곳에 유기한 것이므로 피고인에게 불법영득의사가 있었다고 할 것인데도, 이와 달리 보아 무죄를 선고한 원심판결에 절도죄의 불법영득의사에 관한 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

판례 (대판 2011.8.18. 2010도9570) 辯3

甲 주식회사 감사인 피고인이 회사 경영진과의 불화로 한 달 가까이 결근하다가 회사 감사실에 침입하여 자신이 사용하던 컴퓨터에서 하드디스크를 떼어간 후 4개월 가까이 지난 시점에 반환한 사안에서, 피고인이 하드디스크를 일시 보관 후 반환하였다고 평가하기 어려워 불법영득의사를 인정할 수 있다.

3. 적극적 요소 : 소유자 지위의 향유

절취자가 소유자와 유사한 지위를 취득할 의사가 있어야 한다(이용의사). 일시적·영구적 의사를 불문한다. 타인의 재물을 절취하여도 절취자가 소유자의 지위를 누리지 않으면 재물손괴죄만 성립한다.

<이용의사가 없어 불법영득의사가 인정되지 않는 경우>

- ① 상사와의 의견 충돌 끝에 항의의 표시로 사표를 제출한 다음 평소 피고인이 전적으로 보관, 관리해 오던 이른바 비자금 관계 서류 및 금품이 든 가방을 들고 나온 경우, 불법영득의 의사가 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 서류 및 금품이 타인의 점유 하에 있던 물건이라고도 볼 수 없다(대판 1995.9.5. 94도3033). 辯3
- ② 甲이 자신이 소속한 중대에 소총 1정이 부족하자 이를 분실한 줄 알고 그 보충을 위하여 다른 부대의 소총 1정을 몰래 가져 온 사안에서 군인이 총기를 분실하고 그를 보충하기 위하여 총기를 취거한 경우에는 불법영득의 의사가 있다고 할 수 없다(대판 1977.6.7. 77도1069). 司57
- ③ 피고인이 살해된 피해자의 주머니에서 꺼낸 지갑을 살해도구로 이용한 골프채와 옷 등 다른 증거품들과 함께 자신의 차량에 싣고 가다가 쓰레기 소각장에서 태워버린 경우, 살인 범행의 증거를 인멸하기 위한 행위로서 불법영득의 의사가 있었다고 보기 어렵다(대판 2000.10.13. 2000도3655). 司57

II. 불법영득의사의 대상

1. 의의

물체 또는 물체가 가지는 가치이다(통설, 판례). 다만 영득행위의 대상을 재물의 물체 그 자체 또는 물체 속에 화체된 경제적 가치로 볼 때에도 가치의 범위를 제한할 필요가 있다. 만일 가치의 범위에 제한을 가하지 않을 경우 재물에 대한 영득행위(ex. 절도죄)와 가치에 대한 이득행위(ex. 배임죄)의 구별이 불가능해지기 때문이다.

따라서 판례는 다음과 같이 가치의 범위를 제한한다.

2. 특수한 기능가치의 경우

물체 자체는 반환한 경우에도 그 물체의 특수한 기능가치를 침해함으로써 재물의 경제적 가치를 감소시킨 경우에는 영득의사가 인정된다. 가령 타인의 충전식 교통카드를 몰래 취거하여 무단으로 사용하다가 제자리에 갖다 놓은 경우에도 그 사용으로 인하여 교통카드에 내재된 경제적 가치가 감소되었으므로 이 경우에도 불법영득의사가 인정되어 절도죄가 성립한다.

판례 예금통장 절취사건(대판 2010.5.27. 2009도9008)

司53·54·55

[사실관계] 甲은 A 건설 주식회사의 현장소장으로 근무하던 중 월급 등을 제대로 지급받지 못할 것을 염려하여 A 회사의 사무실에서 A 회사 명의의 농협 통장을 몰래 가지고 나와 예금 1,000만원을 인출한 후 다시 이 통장을 제자리에 갖다 놓는 방법으로 이를 절취하였다.

[판결요지] 예금통장은 예금채권을 표창하는 유가증권이 아니고 그 자체에 예금액 상당의 경제적 가치가 화체되어 있는 것도 아니지만, 이를 소지함으로써 예금채권의 행사자격을 증명할 수 있는 자격증권으로서 예금계약사실 뿐 아니라 예금액에 대한 증명기능이 있고 이러한 증명기능은 예금통장 자체가 가지는 경제적 가치라고 보아야 하므로, 예금통장을 사용하여 예금을 인출하게 되면 그 인출된 예금액에 대하여는 예금통장 자체의 예금액 증명기능이 상실되고 이에 따라 그 상실된 기능에 상응한 경제적 가치도 소모된다고 할 수 있다. 그렇다면 타인의 예금통장을 무단사용 하여 예금을 인출한 후 바로 예금통장을 반환하였다 하더라도 그 사용으로 인한 위와 같은 경제적 가치의 소모가 무시할 수 있을 정도로 경미한 경우가 아닌 이상, 예금통장 자체가 가지는 예금액 증명기능의 경제적 가치에 대한 불법영득의 의사를 인정할 수 있으므로 절도죄가 성립한다.

3. 사용가치의 경우

절취한 물건을 ‘사용’함으로써 다른 이익을 얻는 경우는 소유자지위를 누리는 것이 아니므로 불법영득의사가 없다. 즉 단순한 사용가치를 침해한 경우 그 물체의 경제적 가치가 감소되지 않았으므로 영득의사는 부정된다.

판례 만화천국가게 사건(대판 1999.7.9. 99도857)

司42·44

[사실관계] 甲은 서울 종로구에 있는 甲이 종업원으로 일하던 만화천국 가게에서, 가게의 주인인 乙이 자리를 비운 틈을 타서 乙이 계산대 위의 창문에 두고 간 핸드백에서 乙 소유의 엘지 신용카드 1장을 꺼내어 그 곳에서 약 50m 떨어진 신한은행 종로5가 출장소에 설치된 현금자동지급기에서 위 신용카드를 이용하여 50만 원을 현금서비스 받고, 다시 가게로 돌아와서 乙의 핸드백 안에 신용카드를 넣어 두었다.

[판결요지] 신용카드업자가 발행한 신용카드는 이를 소지함으로써 신용구매가 가능하고 금융의 편의를 받을 수 있다는 점에서 경제적 가치가 있다 하더라도, 그 자체에 경제적 가치가 화체되어 있거나 특정의 재산권을 표창하는 유가증권이라고 볼 수 없고, 단지 신용카드회원이 그 제시를 통하여 신용카드회원이라는 사실을 증명하거나 현금자동지급기 등에 주입하는 등의 방법으로 신용카드업자로부터 서비스를 받을 수 있는 증표로서의 가치를 갖는 것이어서, 이를 사용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출하였다 하더라도 신용카드 자체가 가지는 경제적 가치가 인출된 예금액만큼 소모되었다고 할 수 없으므로, 이를 일시 사용하고 곧 반환한 경우에는 불법영득의 의사가 없다.

III. 영득행위의 위법성

1. 문제점

영득은 객관적으로 위법해야 한다고 할 때 영득의 위법성의 의미는 어떻게 이해할 수 있는가? 행위자가 타인의 재물에 대하여 아무런 법적 청구권도 없었음에도 영득하였을 경우에는 당연히 영득행위의 위법성이 인정된다.

문제가 되는 것은 행위자가 피해자에 대하여 물권적·채권적 청구권을 가지고 있을 때에도 그 영득행위에 대하여 위법성을 인정할 수 있는가 하는 것이다. 가령 甲이 자신의 채무자 乙의 지갑 속에 들어 있는 현금을 채무변제조로 몰래 꺼내어 가져간 경우에도 불법영득의사가 인정될 것인가가 문제된다.

2. 학설 - 영득의 불법설

영득의 불법은 실질적으로 소유권질서와 모순·충돌되는 상태를 야기했느냐에 따라 결정해야 한다. 따라서 절취자가 반환청구권을 가지고 있는 물건의 절취는 불법영득의사가 인정되지 않아서 무죄가 된다고 한다(통설). 위의 사례에서 채권자 甲은 물론 물체인 돈 자체에 대해서는 청구권이 없지만, 빼앗은 돈의 액면가치에 대해서는 청구권이 있기 때문에 불법영득의사가 없다.

3. 수단의 불법설

영득을 결과가 아니라 수단으로서의 의미로 파악하여 수단이 불법하면 소유권 질서에 부합하더라도 영득은 불법하다. 이에 의하면 행위자에게 반환청구권이 있는 경우에도 위법성조각사유가 없는 한 절도죄가 성립한다.

판례 굴삭기 취거사건(대판 2001.10.26. 2001도4546) *

[사실관계] 피고인 甲은 현대자동차 대형영업소과장으로 근무하던 자인바, 피해자 乙이 현대자동차써비스 주식회사로부터 할부로 매입한 금 117,428,520원 상당의 이 사건 굴삭기 1대의 할부금을 연체하여 그 소유의 주택에 대하여 강제경매를 신청하였으나, 乙이 일정한 기한까지 할부대금을 지급하여 주기로 하는 내용의 각서를 작성하여 주어 위 부동산강제경매를 취하해 주었음에도 乙이 위 각서의 내용대로 이행하지 않자, 전북 진안군 부귀면 소재 공사현장에서 위 굴삭기를 추레라에 싣고 와 丙에게 매도하였다.

[판결요지] 형법상 절취란 타인이 점유하고 있는 자기 이외의 자의 소유물을 점유자의 의사에 반하여 그 점유를 배제하고 자기 또는 제3자의 점유로 옮기는 것을 말하는 것으로, 비록 약정에 기한 인도 등의 청구권이 인정된다고 하더라도, 취거 당시에 점유 이전에 관한 점유자의 명시적·묵시적인 동의가 있었던 것으로 인정되지 않는 한, 점유자의 의사에 반하여 점유를 배제하는 행위를 함으로써 절도죄는 성립하는 것이고, 그러한 경우에 특별한 사정이 없는 한 불법영득의 의사가 없었다고 할 수는 없다.

4. 결론

절취행위가 권리실현의 수단으로 사용된 경우라고 하여도 그 권리 실행의 수단 방법이 사회통념상 허용되는 정도나 범위를 넘는다면 이를 처벌할 형사정책적 필요성이 존재한다. 따라서 수단의 불법설이 타당하다. 위의 사례에서 甲에게는 불법영득의사가 인정된다.

♣ 확인학습문제

1. 불법영득의사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 타인의 은행 직불카드를 무단 사용하여 자신의 예금계좌로 돈을 이체시킨 후 곧 직불카드를 반환한 경우 절도죄가 성립하지 아니한다.
- ② 甲이 살해된 피해자의 주머니에서 꺼낸 지갑을 살해도구로 이용한 골프채와 옷 등 다른 증거품들과 함께 자신의 차량에 싣고 가다가 쓰레기 소각장에서 태워버린 경우, 불법영득의사가 있었다고 보기 어렵다.
- ③ 소유자의 승낙 없이 오토바이를 타고 가서 다른 장소에 버린 경우 불법영득의사를 인정할 수 없어 자동차등불법사용죄가 성립할 뿐이다.
- ④ 甲이 자신의 채무자 乙의 지갑 속에 들어 있는 현금을 채무변제로 몰래 꺼내어 가져간 경우에도 불법영득의사가 인정된다.
- ⑤ 타인의 충전식 교통카드를 몰래 취거하여 무단으로 사용하다가 제자리에 갖다 놓은 경우 불법영득의사가 인정되어 절도죄가 성립한다.

[정답] ③

[해설] 소유자의 승낙 없이 오토바이를 타고 가서 다른 장소에 버린 경우, 자동차등불법사용죄가 아닌 절도죄가 성립한다(대판 2002.9.6 2002도3465).

2. A 주식회사 감사인 甲은 회사 경영진과의 불화로 한 달 가까이 결근하다가 회사 감사실에 침입하여 자신이 사용하던 컴퓨터에서 하드디스크를 떼어간 후 4개월 가까이 지난 시점에 반환하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 방실침입죄
- ② 방실침입죄와 절도죄
- ③ 방실침입죄와 점유이탈물횡령죄
- ④ 절도죄
- ⑤ 무죄

[정답] ②

[해설] 甲이 하드디스크를 일시 보관 후 반환하였다고 평가하기 어려워 불법영득의사를 인정할 수 있다(대법원 2011.08.18. 선고 2010도9570). → 그리고 회사 감사실에 침입한 것이므로 방실침입죄도 성립한다.

3. 甲은 A주식회사의 현장 사무소장으로 근무하던 사람이다. 甲은 회사로부터 월급을 제대로 받지 못할지도 모른다고 염려하게 되었다. 이에 甲은 2007. 12. 11. A주식회사의 사무실에서 A주식회사 명의의 농협 통장을 몰래 가지고 나와 예금 1,000만원을 인출한 후 다시 그 통장을 제자리에 갖다 놓았다. 이에 대한 설명 중에서 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 예금통장은 예금채권을 표창하는 유가증권이 아니다.
- ② 예금통장은 이를 소지함으로써 예금채권의 행사자격을 증명할 수 있는 자격증권으로서 예금계약사실 뿐 아니라 예금액에 대한 증명기능이 있고, 이러한 증명기능은 예금통장 자체가 가지는 경제적 가치라고 보아야 한다.
- ③ 타인의 신용카드를 승낙 없이 무단 사용하여 예금을 인출하고 바로 제자리에 돌려놓은 경우에 신용카드에 대한 절도죄가 성립하지 않는다.

- ④ 타인의 예금통장을 무단 사용하여 예금을 인출한 후 바로 예금통장을 반환한 경우 그 사용으로 인한 경제적 가치의 감소가 상당한 경우 절도죄가 성립한다.
- ⑤ 피해자의 승낙 없이 혼인신고서를 작성하기 위하여 피해자의 도장을 몰래 꺼내어 사용한 후 곧바로 제자리에 갖다 놓은 경우, 도장에 대한 절도죄는 성립한다.

[정답] ⑤

[해설] 도장에 대한 불법영득의 의사가 있었다고 볼 수 없어 절도죄는 성립하지 않는다(대판 2000.3.28. 2000도493).

♣ 학습내용 정리

1. 불법영득의사란 권리자를 배제하고(소극적 요소), 타인의 물건을 자기의 소유물인 것처럼 이용·처분하려는 의사(적극적 요소)이다.
2. 불법영득의사의 대상은 물체 또는 물체가 가지는 가치이다
3. 행위자가 피해자에 대하여 물권적·채권적 청구권을 가지고 있을 때에도 그 영득행위에 대하여 위법성을 인정할 수 있다는 것이 판례의 입장이다.

제15강 특수절도죄(형법 제331조)

♣ 학습목표

- 야간주거침입절도죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 특수절도죄의 유형을 설명할 수 있다.
- 합동특수절도죄의 법리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 야간주거침입절도
- 손괴후야간주거침입특수절도
- 흥기휴대특수절도
- 합동특수절도

♣ 사전테스트

- 야간주거침입절도죄에서 야간의 의미는 천문학적으로 일몰 후 일출 전이다
정답 : O
- 형법에는 특수절도죄, 특수강도죄, 특수도주죄 등 3가지 유형의 합동범이 있다.
정답 : O
- 범행과는 전혀 무관하게 우연히 흥기를 소지하는 경우에도 흥기휴대특수절도에 해당한다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

판례는 합동범의 '합동'의 의미에 관하여 현장적 공동정범설을 취한다.

[정답] X

[해설] 판례는 현장에서 합당한 자에 대해서는 현장설의 입장을 취한다. 판례가 현장적 공동정범설을 취하는 것은 현장에 있지 아니한 다른 공범에 대하여 합동범의 공동정범을 인정할 것인가 하는 문제에 제한된다.

♣ 강의내용

1. 손괴후야간주거침입특수절도죄(형법 제331조 제1항)

1. 특수절도죄의 의의

특수절도죄는 야간에 문호 또는 장벽 기타 건조물의 일부를 손괴하고 주거 등에 침입하여 타인의 재물을 절취하거나 흥기를 휴대하거나 2인 이상이 합동하여 타인의 재물을 절취함으로써 성립하는 범죄이다.

2. 손괴후야간주거침입특수절도

- ① 야간에 주거 등에 침입하여야 하므로 주간에 문호 등을 손괴하여 침입한 경우는 본죄에 해당하지 않는다. 이때에는 주거침입죄, 손괴죄, 절도죄가 실체적 경합이 된다.
- ② 실행의 착수 및 기수시기와 관련하여 야간에 침입의 목적으로 주거 등의 일부를 손괴하기 시작했을 때 실행의 착수가 있고, 기수시기는 재물취득시이다.

판례 (대판 1986.7.8. 86도843) 辯2 司44

두 사람이 공모 합동하여 타인의 재물을 절취하려고 한 사람은 망을 보고 또 한 사람은 기구를 가지고 인쇄소 출입문의 자물쇠를 떼어 내거나 당구장 출입문의 환기창문을 열었다면 특수절도죄의 실행에 착수한 것이다.

- ③ 야간에 시정된 문을 열쇠로 열고 들어간 경우에는 손괴를 하지 않았으므로 야간주거침입절도죄만 성립한다. 그리고 본죄와 손괴죄는 법조경합의 관계에 있으므로 본죄에 해당하는 때에는 손괴죄는 별도로 성립하지 않는다.

3. 보론 - 야간주거침입절도죄(형법 제330조)

(1) 의의

본죄는 야간에 사람의 주거, 간수하는 저택, 건조물이나 선박 또는 점유하는 방실에 침입하여 절도함으로써 성립하는 절도죄에 대한 가중구성요건이다. 여기서 야간의 의미는 천문학적으로 일몰 후 일출 전이다.

판례 주간에 주거에 침입하여 야간에 절취한 사건(대판 2011.4.14. 2011도300)

司54·56

형법은 제329조에서 절도죄를 규정하고 곧바로 제330조에서 야간주거침입절도죄를 규정하고 있을 뿐, 야간절도죄에 관하여는 처벌규정을 별도로 두고 있지 아니하다. 이러한 형법 제330조의 규정형식과 그 구성요건의 문언에 비추어 보면, 형법은 야간에 이루어지는 주거침입행위의 위험성에 주목하여 그러한 행위를 수반한 절도를 야간주거침입절도죄로 중하게 처벌하고 있는 것으로 보아야 하고, 따라서 주거침입이 주간에 이루어진 경우에는 야간주거침입절도죄가 성립하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다.
→ 판례에 의하면 절도죄와 주거침입죄의 실체적 경합이 된다.

(2) 실행의 착수시기 - 주거 등에 침입했을 때이다.

판례 아파트 베란다 침범 사건(대판 2003.10.24. 2003도4417) 辯4 司46·47·49·52·57

[사실관계] 甲은 2003.3.2. 19:45경 부천시 원미구 소재 공동산 신안아파트 뒤편에 이르러 금품을 절취할 목적으로 난간을 잡고 1909동 202호 뒤편 베란다로 올라가 미리 준비한 소형손전등을 창문에 비추면서 내부를 살피던 중, 때마침 위 아파트에 근무하는 경비원인 乙에게 발각되어 그 곳 베란다에서

뛰어내려 도주하다가 체포를 면탈할 목적으로 미리 소지하고 있던 드라이버를 乙의 얼굴에 들이대면서 “너 잡지마, 잡으면 죽어”라고 말하여 이에 불응하면 乙의 신체 등에 어떠한 위해를 가할 것 같은 태도를 보여 乙을 협박하였다.

[판결요지] ① 준강도의 주체는 절도 즉 절도범인으로, 절도의 실행에 착수한 이상 미수이거나 기수이거나 불문하고, 야간에 타인의 재물을 절취할 목적으로 사람의 주거에 침입한 경우에는 주거에 침입한 단계에서 이미 형법 제330조에서 규정한 야간주거침입절도죄라는 범죄행위의 실행에 착수한 것이라고 보아야 하며, 주거침입죄의 경우 주거침입의 범의로써 예컨대, 주거로 들어가는 문의 시정장치를 부수거나 문을 여는 등 침입을 위한 구체적 행위를 시작하였다면 주거침입죄의 실행의 착수는 있었다고 보아야 한다. ② 야간에 아파트에 침입하여 물건을 훔칠 의도 하에 아파트의 베란다 철제난간까지 올라 유리창문을 열려고 시도하였다면 야간주거침입절도죄의 실행에 착수한 것으로 보아야 한다고 한 사례.

(3) 기수시기 : 재물취득시이다.

판례 (대판 1991.4.23. 91도476) 辯3 司38・45

피고인이 피해자 경영의 카페에서 야간에 그 곳 내실에 침입하여 장식장 안에 들어 있던 정기적금통장 등을 꺼내 들고 나오던 중 발각되어 돌려 준 경우 피고인은 피해자의 재물에 대한 소지(점유)를 침해하고, 일단 자신의 지배 내에 옮겼으므로 절도의 미수에 그친 것이 아니라 야간주거침입절도의 기수라고 할 것이다.

II. 흥기휴대특수절도죄(제331조 제2항 전단)

1. 흥기

사람의 살상이나 재물손괴의 목적으로 제작된 것이 아니더라도 이런 행위에 이용될 수 있는 일반적으로 위험한 물건이면 흥기에 해당한다. 액체, 기체도 포함된다.

2. 휴대

휴대란 몸 가까이 소지하는 것이다. 항상 몸에 지니고 있을 필요는 없고 행위시(실행의 착수 → 범죄의 종료)에 휴대한 것이면 족하다. 또한 처음부터 소지하지 않고 범죄현장에서 집어든 경우도 휴대에 해당한다. 그러나 휴대는 위험한 물건을 범행현장에서 그 범행에 사용하려는 의도로 소지하는 것을 말하므로 범행과는 전혀 무관하게 우연히 이를 소지하는 경우에는 휴대가 아니다.

3. 실행의 착수시기 - 주간인 경우 재물을 물색하기 시작했을 때이다.

판례 (대판 2009.12.24. 2009도9667) 辯2

형법 제331조 제2항의 (흥기휴대 또는 합동)특수절도에 있어서 주거침입은 그 구성요건이 아니므로, 절도범인이 그 범행수단으로 주거침입을 한 경우에 그 주거침입행위는 절도죄에 흡수되지 아니하고 별개로 주거침입죄를 구성하여 절도죄와는 실체적 경합의 관계에 있게 되고, 2인 이상이 합동하여 야간이 아닌 주간에 절도의 목적으로 타인의 주거에 침입하였다 하여도 아직 절취할 물건의 물색행위를 시작하기 전이라면 특수절도죄의 실행에는 착수한 것으로 볼 수 없는 것이어서 그 미수죄가 성립하지 않는다 → 주간에 피해자의 아파트 출입문 시정장치를 손괴하다가 마침 귀가하던 피해자에게 발각되어 도주한 피고인들에 대하여 형법 제331조 제2항에 정한 특수절도죄의 실행의 착수가 없었다는 이유로 합동특수절도에 대하여 무죄를 인정한 판례이다. 그러나 주거침입죄는 성립한다.

III. 합동특수절도죄(제331조 제2항 후단)

1. 의의

합동범이란 범죄참가형태의 일종으로 형법각칙에 2인 이상이 합동하여 죄를 범하도록 규정되어 있는 범죄형태를 말한다. 형법에는 특수절도죄(제331조 제2항), 특수강도죄(제334조 제2항), 특수도주죄(제146조)등 3가지가 있고, 성폭력처벌특별법에 특수강간 및 특수강제추행죄(제4조)가 있다.

2. 합동범에 있어서 ‘합동’의 의미 - 현장설(판례)

대법원은 현장에서 협동한 절도범의 죄책과 관련하여 “형법 제331조 제2항 후단에 정한 합동범으로서의 특수절도가 성립하려면 주관적 요건으로서의 공모 외에 객관적 요건으로서의 실행행위의 분담이 있어야 하고 그 실행행위에 있어서는 시간적으로나 장소적으로 합동관계가 있어야 한다.”고 판시하여 명백히 현장설의 입장을 취한다.

현장설에 의하면 가령 乙, 丙, 丁이 절도현장에서 시간적, 장소적으로 협동하여 절취행위를 한 경우 합동특수절도죄의 죄책을 진다.

판례 (대판 1996.3.22. 96도313) 司39·44

甲은 乙로부터 동생인 丙이 백지 가게수표 19장을 집에 가지고 있으며 그가 신혼여행을 떠나 집에 없다는 말을 듣고 乙과 함께 丙의 수표를 몰래 꺼내오기로 범행을 모의하고, 함께 차량을 타고 범행 장소에 도착하여 丙의 집으로 같이 들어갔다. 乙이 丙의 방안의 책상서랍에서 백지 가게수표 19장을 절취하는 동안 甲은 丙의 집 안의 가까운 곳에 대기하고 있다가 절취품을 가지고 같이 집을 나온 경우, 시간적·장소적으로 협동관계가 있었다고 볼 것이다.

3. 현장에 있지 아니한 공모자의 합동범의 공동정범 성립가능성

(1) 문제점

가령 乙, 丙, 丁이 절도현장에서 특수절도를 실행한 경우 현장에 있지는 않았으나 절취행위의 주모자인 甲을 특수절도의 공동정범으로 처벌할 수 있는가가 문제된다. 문제는 현장설과 현장적 공동정범설이 서로 상반된 입장으로 나뉘고 있다는 것이다.

(2) 학설

(가) 현장설

합동범은 공동정범에 대한 각칙상의 특별규정으로 형법 제30조의 공동정범에 관한 규정은 적용될 여지가 없으므로 현장 이외의 장소에서 가공한 자는 합동범의 공동정범이 될 수 없다(통설).

(나) 현장적 공동정범설

다른 공모자들에게 합동범이 성립하는 경우에는 현장에 가지 않더라도 합동범의 실행을 기능적으로 지배한 이상 합동범의 공동정범을 인정하는 견해이다. 이를 정리해보면,

- ① 현장성을 갖추고 기능적 행위지배도 인정되는 경우에는 당연히 합동범 그 자체가 된다. 예컨대 甲과 乙이 공동하여 A가 운영하는 보석상에서 甲이 금고문을 열고, 乙이 보석을 감정하여 값비싼 보석만을 골라서 훔쳐간 경우 甲과 乙은 모두 합동특수절도죄의 죄책을 진다. 이 경우는 현장설과 전혀 구별되지 않는다.

- ② 현장성을 갖추지는 못하였으나 기능적 행위지배도 인정되는 경우, 가령 甲이 수괴로서 모든 범죄계획 및 인원조달, 장비 등을 준비하였으나 모든 범죄가담자들의 알리바이 조작을 위하여 절도범행을 하는 현장에는 가지 않은 경우 甲은 합동특수절도죄의 공동정범이 된다.
- ③ 현장성을 갖추었지만 기능적 행위지배는 부정되는 경우에는 합동특수절도죄의 방조범이 될 뿐이다. 예컨대 甲이 乙과 丙이 절도하는 현장에서 망을 봐 주었지만 甲이 乙, 丙과 공동가공의 의사를 가지고 그렇게 한 것은 아니었던 경우이다.

(3) 판례 - 현장적 공동정범설

판례 뺑끼단란주점사건(대판 1998.5.21. 98도321 전원합의체 판결) 辯1·2 司46·47·49·51·52
· 55·57

[사실관계] 속칭 뺑끼주점의 지배인인 피고인 甲은 피해자 A로부터 신용카드를 강취하고 신용카드의 비밀번호를 알아낸 후 현금자동지급기에서 인출한 돈을 뺑끼주점의 분배관례에 따라 분배할 것을 전제로 하여 乙(뺑끼), 丙(뺑끼주점 업주) 및 丁(뺑끼)과 甲은 뺑끼주점 내에서 A를 계속 붙잡아 두면서 감시하는 동안 乙, 丙, 丁은 A의 위 신용카드를 이용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출하기로 공모하였고, 그에 따라 乙, 丙, 丁이 1997.4.18. 04:08경 서울 강남구 삼성동 소재 LG마트 편의점에서 합동하여 현금자동지급기에서 현금 4,730,000원을 절취하였다.

[판결요지] 3인 이상의 범인이 합동절도의 범행을 공모한 후 적어도 2인 이상의 범인이 범행 현장에 서 시간적, 장소적으로 협동관계를 이루어 절도의 실행행위를 분담하여 절도 범행을 한 경우에는 공동정범의 일반 이론에 비추어 그 공모에는 참여하였으나 현장에서 절도의 실행행위를 직접 분담하지 아니한 다른 범인에 대하여도 그가 현장에서 절도 범행을 실행한 위 2인 이상의 범인의 행위를 자기 의사의 수단으로 하여 합동절도의 범행을 하였다고 평가할 수 있는 정범성의 표지를 갖추고 있다고 보이는 한 그 다른 범인에 대하여 합동절도의 공동정범의 성립을 부정할 이유가 없다. 그러므로 합동절도에서도 공동정범과 교사범·종범의 구별기준은 일반원칙에 따라야 하고, 그 결과 범행현장에 존재하지 아니한 범인도 공동정범이 될 수 있으며, 반대로 상황에 따라서는 장소적으로 협동한 범인도 방조만 한 경우에는 종범으로 처벌될 수도 있다.

ㄷ 판례는 현장에서 합동한 자에 대해서는 여전히 통설과 마찬가지로 현장설의 입장을 취한다. 판례가 현장적 공동정범설을 취하는 것은 현장에 있지 아니한 다른 공범에 대하여 합동범의 공동정범을 인정할 것인가 하는 문제에 제한된다는 점을 명심해야 할 것이다.

(4) 결론

합동의 의미에 관한 현장설에 의하더라도 실행행위에 협동하지 않은 자에 대해서는 그 공동의사의 존재 여부, 행위예의 기여도 등을 따져 합동절도의 교사나 방조뿐만 아니라 합동절도의 공동정범까지도 인정할 수 있다고 보아야 한다. 따라서 현장적 공동정범설이 타당하다.

4. 교사범·방조범의 성부

정범이 합동범인 이상 현장성을 결여한 자라도 공범종속성의 원칙상 합동범에 대한 교사·방조는 가능하다(통설).

♣ 확인학습문제

1. 甲은 밤 10시 경 A 아파트 뒤편에 이르러 금품을 절취할 목적으로 난간을 잡고 1909동 202호 뒤편 베란다로 올라가 미리 준비한 소형손전등을 창문에 비추면서 내부를 살피던 중, 때마침 위 아파트에 근무하는 경비원인 乙에게 발각되어 절취행위를 하지 못하였다. 이 경우 甲의 죄책은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 절도죄의 미수
- ③ 절도죄의 미수와 주거침입죄
- ④ 야간주거침입절도죄의 미수
- ⑤ 주거침입죄의 미수

[정답] ④

[해설] 야간에 아파트에 침입하여 물건을 훔칠 의도하에 아파트의 베란다 철제난간까지 올라가 유리창문을 열려고 시도하였다면 야간주거침입절도죄의 실행에 착수한 것으로 보아야 한다(대판 2003.10.24. 2003도4417).

2. 甲은 A 회사의 물건을 훔치려고 오후 3시에 회사에 침입하여 창고에 숨어 있다가 밤 11시 경 모든 직원들이 퇴근한 이후 창고에서 나와 물품들을 절취하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 건조물침입죄와 절도죄의 실체적 경합
- ② 건조물침입죄와 절도죄의 상상적 경합
- ③ 야간주거침입절도죄
- ④ 건조물침입죄
- ⑤ 무죄

[정답] ①

[해설] 주거침입이 주간에 이루어진 경우에는 야간주거침입절도죄가 성립하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다(대판 2011.4.14. 2011도300).

3. 대법원 1998.5.21. 98도321 전원합의체 판결은 ‘3인 이상의 범인이 합동절도의 범행을 공모한 후 2인 이상의 범인이 범행현장에서 시간적, 장소적으로 협동관계를 이루어 절도의 실행행위를 분담하여 범행을 한 경우에는 그 공모에는 참여하였으나 현장에서 절도의 실행행위를 직접 분담하지 아니한 다른 범인에 대하여도 합동절도의 공동정범이 성립될 수 있다’는 취지로 판시하였다. 이 판결과 관련된 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 위 판례는 현장적 공동정범설의 입장을 취하는 것이다.
- ② 위 판례의 입장을 따를 경우 직접 실행행위에 참여하지 않고 배후에서 합동절도의 범행을 조종하는 수괴를 공동정범으로 처벌할 수 있게 된다.
- ③ 2인의 범인이 합동절도의 범행을 공모한 후 1인의 범인만이 단독으로 절도의 실행행위를 한 경우에는 위 판례의 입장을 취하더라도 합동절도가 성립할 여지가 없게 된다.
- ④ 위 판례의 입장을 비판하는 견해에 의하면 합동범을 필요적 공범 또는 공동정범의 특별한 형태로 파악하므로 합동범에 대해서는 공동정범과 공범의 규정이 모두 적용될 여지가 없다.
- ⑤ 위 판례의 입장에 의하면 행위기여도를 고려하여야 하는 것이므로 장소적으로 협동한 범인도 방조만 한 경우에는 합동절도의 종범으로 처벌된다.

[정답] ④

[해설] 합동범의 공동정범을 부정하더라도 공범종속성의 원칙상 합동범에 대한 교사범·종범의 성립은 인정된다. 즉 현장성을 결여한 자도 합동범의 교사범·종범이 될 수 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 야간주거침입절도죄는 야간에 사람의 주거, 간수하는 저택, 건조물이나 선박 또는 점유하는 방실에 침입하여 절도함으로써 성립하는 절도죄에 대한 가중구성요건이다.
2. 특수절도죄는 야간에 문호 또는 장벽 기타 건조물의 일부를 손괴하고 주거 등에 침입하여 타인의 재물을 절취하거나 흥기를 휴대하거나 2인 이상이 합동하여 타인의 재물을 절취함으로써 성립하는 범죄이다.
3. 합동범이란 범죄참가형태의 일종으로 형법각칙에 2인 이상이 합동하여 죄를 범하도록 규정되어 있는 범죄형태를 말한다.

제16강 단순강도죄(형법 제333조)

♣ 학습목표

- 강도죄에서 재물과 재산상 이익의 개념을 설명할 수 있다.
- 재물강취와 폭행, 협박의 관계를 설명할 수 있다.
- 채무면탈 목적으로 살인한 경우 어떤 범죄가 성립하는지를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 강도
- 재물과 재산상 이익
- 날치기
- 채무면탈 목적 살인

♣ 사전테스트

1. 판례에 의하면 사법상 무효인 경제적 이익도 재산적 이익이 될 수 있다.
정답 : O
2. 폭행·협박의 상대방이 반드시 재물 또는 재산상의 피해자와 일치할 필요는 없다.
정답 : O
3. 강간범이 피해자의 재물을 탈취한 경우 강도강간죄가 성립한다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

도주하는 범인이 자가용승용차를 정지시켜 운행케 한 경우에도 강도죄가 성립한다.

[정답] X

[해설] 도주하는 범인이 자가용승용차를 정지시켜 운행케 한 경우에는 대가를 지급받을 수 없는 노무의 제공은 경제적 이익이라고 할 수 없으므로 강요죄가 성립할 뿐이다.

♣ 강의내용

I. 행위객체

타인의 재물 또는 재산상 이익이다.

1. 재물

타인점유의 타인재물로서 재물의 개념은 절도죄에 있어서와 같다.

2. 재산상의 이익 - 경제적 재산설

재산상 이익이란 재물 이외에 재산적 가치가 있는 모든 이익을 말한다. 이에 대하여 판례는 재산의 법적 측면을 전혀 고려하지 않고 경제적 교환가치만으로 재산을 판단하여 사법상 무효인 경제적 이익도 재산적 이익이 될 수 있다는 경제적 재산설을 취한다.

판례 (대판 1994.2.22. 93도428)

형법 제333조 후단의 강도죄, 이른바 강제이득죄의 요건인 재산상의 이익이란 재물 이외의 재산상의 이익을 말하는 것으로서 강도죄의 성질상 그 권리의무관계의 외형상 변동의 사법상 효력의 유무는 그 범죄의 성립에 영향이 없고, 법률상 정당하게 그 이행을 청구할 수 있는 것이 아니라도 강도죄에 있어서의 재산상의 이익에 해당하는 것이며, 따라서 이와 같은 재산상의 이익은 반드시 사법상 유효한 재산상의 이득만을 의미하는 것이 아니고 외견상 재산상의 이득을 얻을 것이라고 인정할 수 있는 사실관계만 있으면 된다.

II. 행위

폭행·협박으로 타인의 재물을 강취하거나 기타 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하는 것이다.

1. 폭행·협박

(1) 폭행

사람에 대한 직접·간접의 유형력의 행사이다. 수단과 방법은 제한이 없으므로 살상행위와 같은 폭력의 행사뿐만 아니라 주류·마취제 등으로 항거불능상태를 만드는 것도 본죄의 폭행에 해당한다. 이때 폭력에는 절대적 폭력은 물론, 강제적 폭력도 포함된다.

여기서 항거불능이란 반항의 일반적 불가능성을 의미한다. 따라서 최협의의 폭행·협박이 있는 한 피해자가 필사적으로 저항해서 항거불능상태에 빠지지 않았어도 폭행은 인정된다. → 이러한 경우 강도죄의 실행의 착수 인정됨.

(2) 협박

상대방을 두렵게 하여 공포심을 갖게 할 목적으로 해악을 고지하는 행위이다. 해악의 내용에는 제한이 없다.

(3) 폭행·협박의 정도

폭행·협박은 상대방의 의사를 억압하여 반항을 불가능하게 할 정도가 되어서 그 결과 피해자가 재산을 자의로 처분할 수 없는 상태가 될 것을 요한다(최협의의 폭행·협박). 이 점에서 상대

방의 하자 있는 의사에 의하여 재산을 처분하는 정도의 폭행·협박이 있으면 즉한 공갈죄와 구별된다.

(4) 상대방

폭행·협박의 상대방이 반드시 재물 또는 재산상의 피해자와 일치할 필요는 없다. 즉 폭행·협박은 재물이나 재산상의 이익의 소유자·점유자에게 행하여지는 것이 보통이지만 제3자에 대하여 가하여져도 무방하다(통설, 판례).

2. 재물의 강취

(1) 강취

폭행·협박에 의하여 피해자의 의사에 반하여 타인의 재물을 자기 또는 제3자의 점유로 옮기는 것을 말한다. 강취는 반드시 탈취임을 요하지 않고 상대방이 재물을 교부하는 경우에도 그것이 억압된 의사의 결과이면 강취에 해당된다.

(2) 수단과 목적의 관계

강도죄의 폭행·협박은 재물을 빼앗거나 재산상의 이익을 얻기 위한 수단으로 사용되어야 한다.

(가) 시간적·장소적 직접 연관성

폭행·협박과 취거 사이에 직접적으로 시간적·장소적 연관성이 있어야 한다. 즉 폭행·협박은 재물의 강취시에 있어야 하며, 적어도 그 기수 이전에 행해져야 한다. 점유취득 후에 폭행·협박을 한 경우에는 준강도죄가 성립할 뿐이다. 재물의 취득 이전에 폭행·협박이 있었던 때에도 그 사이에 시간적 연관이 없을 경우에는 강도죄가 성립되지 않는다. ex) 폭행으로 집 열쇠를 강취하였으나 다음날 피해자의 집에 가서 그 열쇠를 이용하여 재물을 절취한 경우

(나) 강간행위 후에 강도의 고의로 부녀의 재물을 취거한 경우

이때 강도강간죄의 성립이 문제되는데, 강도강간죄는 강도범이 재물을 강취하는 기회에 부녀를 강간하는 것을 요건으로 하고 있다. 따라서 강간범이 재물을 탈취해도 강도강간죄는 성립하지 않는다(통설, 판례). 다만 재물탈취에 대해서 성립되는 범죄와 관련해서는 판례는 강도죄가 성립한다는 입장이다.

판례 (대판 2010.12.09. 2010도9630) 辯2 司55·57

강도죄는 재물탈취의 방법으로 폭행, 협박을 사용하는 행위를 처벌하는 것이므로 폭행, 협박으로 타인의 재물을 탈취한 이상 피해자가 우연히 재물탈취 사실을 알지 못하였다고 하더라도 강도죄는 성립하고, 강간범인이 부녀를 강간할 목적으로 폭행, 협박에 의하여 반항을 억압한 후 반항억압 상태가 계속 중임을 이용하여 재물을 탈취하는 경우에는 재물탈취를 위한 새로운 폭행, 협박이 없더라도 강도죄가 성립한다.

다만 판례에 의한다 할지라도 재물탈취가 강간의 폭행·협박으로 인한 지속적인 항거불능상태에서 이루어진 것이 아닌 한 절도죄가 성립할 뿐이다.

판례 (대판 1984.2.28, 84도38) 司51

강간을 당한 피해자가 도피하면서 현장에 놓아두고 간 손가방은 점유이탈물이 아니라 피해자의 지배 하에 있는 물건이라고 보아야 할 것이므로 피고인이 그 손가방 안에 들어 있는 피해자 소유의 돈을 꺼 낸 소위는 절도죄에 해당한다.

(다) 날치기의 경우

날치기 행위는 물건에 대해서만 유형력이 행사되었다고 하더라도 그 성격상 부득불 피해자의 신체에 대한 강제력과 위해가 수반될 수밖에 없다. 가령 날치기로 인하여 갑작스럽게 유형력이 가해지면서 피해자가 균형을 잃고 길바닥에 전도된다거나, 혹은 날치기범이 일단 움켜잡은 피해자의 핸드백을 피해자가 빼앗기지 않으려고 꼭 붙들고 있자 행위자가 재차 더 큰 강제력을 행사하여 빼앗아 가는 때가 그러하다.

이러한 사례에서 강도의 수단이 된 폭행이 가해졌는가 하는 판단은 결국 날치기 행위에 수반된 유형력의 행사가 상대방의 반항을 억압할 목적으로 행해졌는가의 여부에 달려있다. 따라서 전자의 사례에서는 행위자에 의한 유형력의 행사는 피해자의 반항을 억압하기 위한 것이 아니므로 강도죄의 폭행이라 할 수 없어 절도죄가 성립하지만, 후자의 사례에서는 행위자가 가한 재차의 유형력의 행사는 상대방의 반항을 억압하려는 것이므로 강도죄의 폭행에 해당한다.

가령 甲은 밤늦게 귀가하는 丙의 뒤로 몰래 접근하여 손가방을 강제로 낚아채었다. 이에 丙이 자신의 손가방을 가지고 도주하는 甲의 옷을 잡자, 甲은 체포를 면하려고 충동적으로 丙의 손을 뿌리치고 도주한 경우 이는 절도에 불과한 것으로 보아야 하고, 여기서 甲이 옷을 잡히자 체포를 면하려고 충동적으로 저항을 시도하여 잡은 손을 뿌리친 정도의 폭행을 준강도죄로 의율할 수는 없다(대판 1985.5.14, 85도619).

판례 (대판 2007.12.13. 2007도7601) 辯3 司53

소위 '날치기'와 같이 강제력을 사용하여 재물을 절취하는 행위가 때로는 피해자를 넘어뜨리거나 상해를 입게 하는 경우가 있고, 그러한 결과가 피해자의 반항 억압을 목적으로 함이 없이 점유탈취의 과정에서 우연히 가해진 경우라면 이는 강도가 아니라 절도에 불과하지만, 그 강제력의 행사가 사회통념상 객관적으로 상대방의 반항을 억압하거나 항거 불능케 할 정도의 것이라면 이는 강도죄의 폭행에 해당한다. 그러므로 날치기 수법의 점유탈취 과정에서 이를 알아채고 재물을 뺏기지 않으려는 상대방의 반항에 부딪혔음에도 계속하여 피해자를 5m 가량 끌고 가면서 억지로 재물을 빼앗고 피해자의 무릎 등에 상해를 입힌 행위는 피해자의 반항을 억압한 후 재물을 강취한 것으로서 강도에 해당한다.

(3) 재산상의 이익의 취득

(가) 재산상 이익취득의 유형

- ① 채무를 면제하게 하거나 그 이행의 연기를 승낙하게 하는 경우처럼 피해자의 일정한 처분행위에 의하여 이익을 취득하는 경우이다.
- ② 피해자의 경제적 노무에 대한 부당한 이익의 취득의 경우이다. 따라서 택시운전자를 폭행·협박하여 택시를 운행케 한 경우에는 강도죄가 성립한다. 그러나 도주하는 범인이 자가용승용차를 정지시켜 운행케 한 경우에는 대가를 지급받을 수 없는 노무의 제공은 경제적 이익이라고 할 수 없으므로 강요죄가 성립할 뿐이다.
- ③ 피해자에게 일정한 의사표시를 하게 하여 이익을 취득하는 경우이다. ex.) 소유권이전등기 또는 저당권설정등기의 취소의 의사표시를 하게 하는 경우

(나) 채무면탈을 목적으로 채권자를 살해한 경우

- ① 채무면탈이나 상속분의 이익을 얻기 위하여 또는 생명보험금을 탈 목적으로 관계당사자를 살해한 경우 단순살인죄로 볼 것인지 강도살인죄로 볼 것인지 논의가 있다. 가령 甲이 채무면탈의 목적으로 乙을 살해한 경우가 이에 해당한다.

이에 대하여 판례는 강취행위를 통하여 현실적으로 재산상 이익을 취득하거나 최소한 취득할 개연성이 있는 경우에는 강도살인죄가 성립하고, 이러한 개연성조차 없을 때는 단순살인죄가 성립한다고 판시하여 절충설의 입장을 취한다.

판례 채무면탈의 목적으로 살인한 사건(대판 2004.6.24. 2004도1098) 司47·49·55

[사실관계] 甲은 乙과 채무 변제기의 유예 여부 등을 놓고 언쟁을 벌이다가 순간적으로 乙을 살해하여 乙에 대한 채무의 지급을 면하기로 마음먹고, 마침 바닥에 떨어져 있던 망치로 乙의 뒷머리 부분을 수회 때리는 등의 방법으로 乙을 살해하였다. 甲은 살해 직후 乙이 운전하고 온 차량의 적재함에 乙의 시체를 싣고 보니 마침 그 상의 조끼에 지갑이 있는 것을 발견하고, 장차 시체가 발견될 때 乙의 신원이 밝혀지는 게 두려워 이를 숨기기 위하여 지갑을 꺼내 그 차량의 사물함에 통째로 넣어두었다가, 그로부터 15시간 가량 지난 후인 그 다음날 10:00경 범행현장에 다시 왔을 때 지갑 속에 들어 있던 돈과 乙의 바지주머니에 별도로 들어 있던 10만 원 가량의 돈을 꺼냈다가, 지갑 속의 돈은 피에 젖어 사용할 수 없을 것으로 생각하여 며칠 후 월악산 계곡에다 지갑째로 버리고, 다만 바지주머니에서 꺼낸 돈을 유류대금과 담배값 등으로 사용하였다.

[판결요지] [1] 강도살인죄가 성립하려면 먼저 강도죄의 성립이 인정되어야 하고, 강도죄가 성립하려면 불법영득(또는 불법이익)의 의사가 있어야 하며, 형법 제333조 후단 소정의 이른바 강제이익죄의 성립요건인 ‘재산상 이익의 취득’을 인정하기 위하여는 재산상 이익이 사실상 피해자에 대하여 불이익하게 범인 또는 제3자 앞으로 이전되었다고 볼 만한 상태가 이루어져야 하는데, 채무의 존재가 명백할 뿐만 아니라 채권자의 상속인이 존재하고 그 상속인에게 채권의 존재를 확인할 방법이 확보되어 있는 경우에는 비록 그 채무를 면탈할 의사로 채권자를 살해하더라도 일시적으로 채권자측의 추급을 면한 것에 불과하여 재산상 이익의 지배가 채권자측으로부터 범인 앞으로 이전되었다고 보기는 어려우므로, 이러한 경우에는 강도살인죄가 성립할 수 없다. [2] 피고인이 피해자 소유의 돈과 신용카드에 대하여 불법영득의 의사를 갖게 된 것이 살해 후 상당한 시간이 지난 후로서 살인의 범죄행위가 이미 완료된 후의 일이라면, 살해 후 상당한 시간이 지난 후에 별도의 범의에 터잡아 이루어진 재물 취거행위를 그보다 앞선 살인행위와 합쳐서 강도살인죄로 처단할 수 없다.

(4) 실행의 착수와 기수시기

본죄의 실행의 착수는 재물을 강취할 의사로 폭행·협박을 개시한 때 인정된다. 그리고 본죄의 기수시기는 폭행·협박을 수단으로 재물 또는 재산상의 이익을 취득한 때이다(취득설).

III. 권리행사와 불법영득의사

판례는 권리의 실행을 위한 경우라도 권리자가 폭행·협박으로 강취한 경우에는 강도죄가 성립한다고 한다.

판례 (대판 1995.12.12. 95도2385)

채권자로부터 채무자에 대한 외상물품 대금채권의 회수를 의뢰 받았다 하더라도, 채무자의 반항을 억압할 정도의 폭행과 협박을 가하여 재물 및 재산상 이익을 취득한 이상 이는 정당한 권리행사라고 볼 수 없음이 명백하여 강도상해죄가 성립함에는 아무런 지장이 없다.

♣ 확인학습문제

1. 甲은 乙에게 A의 재물을 절취할 것을 교사하였다. 그러나 乙은 丙과 공모하여 兇기를 휴대하고 A를 강도하기로 결의하고, 丙은 A의 집 앞에서 자동차를 세워 놓고 망을 보고, 乙은 A의 집안으로 침입하여 자고 있던 A의 머리부분을 베개로 누르던 중 A가 저항을 멈추고 사지가 늘어졌음에도 계속하여 눌러 A가 사망하였다. 그 후 乙은 귀중품을 챙긴 후 丙과 함께 도망하였다. 丙은 乙이 A를 살해하였을 것이라고 생각하지는 않았으나 兇기를 휴대하였으므로 A가 사망할 지도 모른다는 예상을 하고 있었다. 甲, 乙, 丙의 죄책은? (다툼이 있으면 판례에 의하며, 주거침입의 부분은 제외함)

- ① 甲은 강도교사죄, 乙과 丙은 강도치사죄
- ② 甲은 강도교사죄, 乙은 강도살인죄, 丙은 강도치사죄
- ③ 甲은 절도교사죄, 乙과 丙은 강도살인죄
- ④ 甲은 절도교사죄, 乙은 강도살인죄, 丙은 강도치사죄
- ⑤ 甲은 절도교사죄, 乙은 강도살인죄, 丙은 강도죄

[정답] ④

[해설] ㉠ 甲은 특수강도를 하다가 A를 살해한 것이므로 강도살인죄의 죄책을 진다. ㉡ 乙은 A에 대한 살인의 고의는 없었으나 사망의 결과에 대한 예견가능성은 가지고 있었으므로 강도치사죄(공동정범)가 성립한다. ㉢ 교사범은 교사행위를 한 범위 안에서만 죄책이 인정되는 것이므로 결국 甲은 강도살인죄가 아니라 절도죄의 교사범이 될 뿐이다.

2. 다음의 강도죄에 대한 설명으로 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲이 A녀를 강간한 후 새로이 강도의 범의를 일으켜 A의 재물을 강취한 경우 강간죄와 강도죄가 성립한다.
- ② 강도죄는 재물탈취의 방법으로 폭행, 협박을 사용하는 행위를 처벌하는 것이므로 폭행, 협박으로 타인의 재물을 탈취한 이상 피해자가 우연히 재물탈취 사실을 알지 못하였다고 하더라도 강도죄는 성립한다.
- ③ 날치기 수법의 점유탈취 과정에서 이를 알아채고 재물을 뺏기지 않으려는 상대방의 반항에 부딪혔음에도 계속하여 피해자를 끌고 가면서 억지로 재물을 빼앗은 행위는 절도에 해당한다.
- ④ 강도죄에서 재산상의 이익은 반드시 사법상 유효한 재산상의 이득만을 의미하는 것이 아니고 외견상 재산상의 이득을 얻을 것이라고 인정할 수 있는 사실관계만 있으면 된다.
- ⑤ 채무를 면탈할 의사로 채권자를 살해하였으나, 채무의 존재가 명백할 뿐만 아니라 채권자의 상속인이 존재하고 그 상속인에게 채권의 존재를 확인할 방법이 확보되어 있는 경우에는 강도살인죄가 성립하지 않는다.

[정답] ③

[해설] 날치기 수법의 점유탈취 과정에서 이를 알아채고 재물을 뺏기지 않으려는 상대방의 반항에 부딪혔음에도 계속하여 피해자를 끌고 가면서 억지로 재물을 빼앗은 행위는 피해자의 반항을 억압한 후 재물을 강취한 것으로서 강도에 해당한다(대판 2007.12.13. 2007도7601).

3. 甲이 날치기 수법으로 피해자 乙(女)이 들고 있던 가방을 탈취하면서 가방을 놓지 않고 버티는 乙을 5m 가량 끌고 감으로써 乙의 무릎 등에 상해를 입힌 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 강도치상죄

- ② 강도죄와 상해죄의 상상적 경합
- ③ 절도죄와 과실치상죄의 상상적 경합
- ④ 준강도죄와 상해죄의 상상적 경합
- ⑤ 준강도죄와 과실치상죄의 상상적 경합

[정답] ①

[해설] 날치기 수범으로 피해자가 들고 있던 가방을 탈취하면서 강제력을 행사하여 상해를 입힌 사안에서 강도치상죄의 성립을 인정한 사례(대판 2007.12.13. 2007도7601).

♣ 학습내용 정리

1. 강도죄는 폭행 또는 협박으로 타인의 재물을 강취하거나 기타 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 취득케 함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 강취는 반드시 탈취임을 요하지 않고 상대방이 재물을 교부하는 경우에도 그것이 억압된 의사의 결과이면 강취에 해당된다.
3. 판례는 권리의 실행을 위한 경우라도 권리자가 폭행·협박으로 강취한 경우에는 강도죄가 성립한다고 한다.

제17강 준강도죄(형법 제335조)

♣ 학습목표

- 준강도죄에서 행위의 주체의 개념을 설명할 수 있다.
- 준강도죄의 기수와 미수의 구별기준을 설명할 수 있다.
- 준강도죄의 공동정범의 성립요건을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 준강도
- 절도의 기회
- 준강도의 미수
- 준강도죄의 공동정범

♣ 사전테스트

1. 준강도죄의 행위주체는 절도범이다.
정답 : O
2. 절도가 체포를 면탈할 목적으로 경찰관에게 폭행·협박을 가한 때에도 준강도가 된다.
정답 : O
3. 준강도의 목적으로 예비행위를 하는 경우 강도예비죄를 인정할 수 있다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

절도가 현장에서 추적당한 경우 거리가 멀리 떨어진 장소에서 폭행을 가한 때에는 준강도가 성립하지 않는다.

[정답] X

[해설] 준강도의 폭행·협박은 절도현장 또는 직접 그 부근에서 행해져야 한다. 다만 현장에서 추적당한 경우에는 거리가 멀리 떨어진 때에도 장소적 근접성을 인정할 수 있다

♣ 강의내용

1. 행위주체

1. 준강도죄의 의의

준강도죄는 절도가 재물을 취득한 후 재물탈환의 항거, 체포면탈 또는 죄적인멸을 위해 폭행·협박을 함으로써 성립하는 범죄로서 독자적 변형구성요건이다. 준강도죄를 강도죄와 같이 처벌하는 이유는 폭행·협박과 재물의 절취가 결합되어 그 불법내용을 강도죄와 같이 평가할 수 있기 때문이다. 본죄의 보호법익은 재산권 및 자유권이며 보호의 정도는 침해범으로서의 보호이다.

2. 행위주체

(1) 절도

본죄의 주체는 절도범이다. 여기서 절도는 단순절도, 야간주거침입절도, 특수절도, 상습절도를 포함하는 개념이다. 절도의 실행에 착수한 이상 기수·미수를 불문한다(통설, 판례: 대판 2003.10.24. 2003도4417).

절도가 적어도 실행의 착수에 이르러야 하므로 절도가 예비·음모의 단계에서 폭행·협박을 한 때에는 본죄가 성립하지 않는다. 따라서 절도가 타인의 주거에 침입하자마자 때마침 방에서 나오던 집주인에게 발각되어 체포를 면탈할 목적으로 폭행·협박을 가한 경우 ① 주간인 경우에는 절도의 실행의 착수가 없으므로 준강도는 성립하지 않지만(주거침입죄와 폭행죄의 실제적 경합) ② 야간인 경우에는 절도의 실행의 착수가 있으므로 준강도(미수)가 성립한다.

그리고 절도는 절도죄의 정범만을 의미하므로 절도죄의 공범(교사, 방조)이 폭행·협박을 한 경우에는 본죄는 성립하지 않고, 절도죄의 공범이 될 뿐이다.

(2) 승계적 공동정범에 의한 준강도죄의 성부

폭행·협박에만 가담하고, 절도에 가담하지 않은 자가 승계적 공동정범에 의하여 본죄의 주체가 될 수 있는가와 관련하여 승계적 공동정범에 대하여는 소극설(통설, 판례)이 타당하므로 폭행·협박에 가담한 자는 폭행죄·협박죄의 공동정범이 될 뿐이다. 다만 폭처법 제2조 제2항에 의하여 가중하여 처벌된다.

(3) 준강도예비죄의 인정 여부

가령 행위자가 특수절도의 의사로 흉기를 휴대하고 범행대상물을 물색하다가 발각되어 경찰관에게 검거되었을 경우, 흉기를 휴대하였다는 사실로부터 행위자가 재물을 절취하다 발각되면 체포면탈 등의 목적으로 폭행·협박을 하겠다는 의욕, 즉 준강도의 목적을 가지고 있었음을 추론할 수 있다. 이때 준강도의 목적으로 절도를 예비한 행위를 (준)강도예비·음모죄로 처벌할 수 있는가가 문제된다.

그러나 폭행·협박을 하여 재물을 강취할 목적과 재물을 절취하다 발각되면 체포면탈 등을 위해 폭행·협박을 하겠다는 준강도의 목적과는 구별되어야 할 것이므로 강도예비·음모죄가 성립하기 위해서는 예비·음모 행위자에게 미필적으로라도 ‘강도’를 할 목적이 있음이 인정되어야 할 것이다. 결론적으로 준강도의 목적으로 예비행위를 하여도 강도예비죄를 인정할 수는 없다(대판 2006.9.14. 2004도6432).

II. 행위 - 폭행·협박이다.

1. 폭행·협박의 정도

본죄의 폭행·협박은 강도죄의 경우와 마찬가지로 상대방의 반항을 억압할 정도가 되어야 한다. 이 때 폭행·협박은 일반적·객관적으로 상대방의 반항을 억압하는 수단으로 가능하다고 인정되면 족하며, 현실적으로 반항을 억압하였을 것을 요하지 않는다(대판 1981.3.24. 81도409).

당연히 폭행·협박을 행사해야 하므로 가령 乙이 지하철에서 X의 지갑을 절취하기 위하여 X의 주머니를 더듬던 중 맞은편에 앉아있던 Y가 “강도야”하고 소리치자 체포를 면탈하기 위하여 도망친 경우 체포면탈의 목적을 위한 폭행·협박의 행사가 없으므로 乙은 준강도가 될 수 없고, 단지 절도미수죄의 죄책만을 질뿐이다.

(2) 폭행·협박의 상대방

폭행·협박의 상대방은 재물의 소유자·점유자 이외에 목적충족의 방해가 되는 제3자도 그 대상이 될 수 있다. 따라서 절도가 체포를 면탈할 목적으로 경찰관에게 폭행·협박을 가한 때에도 준강도죄가 된다(대판 1992.7.28. 92도917).

(3) 절도의 기회

폭행·협박은 절도의 기회에 행한 것이어야 한다. 이것은 준강도죄가 강도죄와 동일하게 평가되기 위한 조건이 된다. 여기서 절도의 기회는 절도의 실행의 착수 후 절취행위의 종료까지 시간적·장소적 근접성이 있는 범위를 의미한다.

(가) 시간적 근접성

절도의 실행에 착수한 이후부터 절도의 종료 직후까지이다(통설, 판례).

(나) 장소적 근접성

폭행·협박은 절도현장 또는 직접 그 부근에서 행해져야 한다. 다만 현장에서 추적당한 경우에는 거리가 떨어진 때에도 장소적 근접성을 인정할 수 있다(다수설, 판례).

판례 2km를 추적한 사건(대판 1982.7.13. 82도1352)

司48

[사실관계] 피해자 A는 피고인 甲 및 공범 乙이 자기 집에서 물건을 훔쳐 나갔다는 연락을 받고 도주로를 따라 추적하자 범인들이 이를 보고 도주하므로 1킬로미터 가량 추적하여 乙을 체포하여 같이 추적하여 온 동리 사람들에게 인계하고 1킬로미터를 더 추적하여 甲을 체포하여 가지고 간 나무몽둥이로 甲을 1회 구타하자 甲이 몽둥이를 빼앗아 피해자 A를 구타하여 상해를 가하고 도주하였다.

[판결요지] 절도범행의 종료 후 얼마 되지 아니한 단계이고 안전지대로 이탈하지 못하고 피해자측에 의하여 체포될 가능성이 남아있는 단계에서 추적당하여 체포되려 하자 구타한 경우에는 절도행위와 그 체포를 면탈하기 위한 구타행위와의 사이에 시간상 및 거리상 극히 근접한 관계에 있다 할 것이므로 준강도죄가 성립한다.

※ 공범인 乙에 대한 준강도상해죄의 공동정범의 성부 - 예견가능성이 없음을 이유로 부정(합동특수 절도만 성립)

(4) 미수의 결정기준

(가) 문제점

준강도죄는 절도가 절도의 기회에 체포면탈 등의 목적으로 폭행·협박을 하였을 경우에 성립하는바, 가령 甲이 야간에 乙의 집에 들어갔으나 재물을 물색하기도 전에 발각되자 도주를 하다

가 자신을 추격하는 乙에게 폭행을 가한 사례에서 甲은 야간주거침입절도가 미수인 상태, 즉 절도의 기회에 체포면탈의 목적으로 자신을 추격하는 乙에게 폭행을 가하였는바, 이는 전혀 재물을 탈취하지 못한 상태에서 이루어진 것이다.

그런데 형법 제335조 준강도죄는 절도죄와 폭행죄·협박죄의 결합범이기 때문에 준강도죄의 미수가 폭행·협박의 기수·미수를 기준으로 하는지, 아니면 절취행위의 기수·미수를 기준으로 하는지에 대해서는 견해가 대립한다.

(나) 판례 - 절취행위기준설

판례 양주병 절취사건(대판 2004.11.18. 2004도5074 전원합의체)

辯4 司47·48·50·53

[사실관계] 甲이 乙과 합동하여 양주를 절취할 목적으로 장소를 물색하던 중, 5층 건물 중 2층 A가 운영하는 주점에 이르러, 乙은 1층과 2층 계단 사이에서 甲과 무전기로 연락을 취하면서 망을 보고, 甲은 주점의 잠금장치를 뜯고 침입하여 위 주점 내 진열장에 있던 양주 45병 시가 1,622,000원 상당을 미리 준비한 바구니 3개에 담고 있던 중, 계단에서 서성거리고 있던 乙을 수상히 여기고 위 주점 종업원 B가 주점으로 돌아오려는 소리를 듣고서 양주를 그대로 둔 채 출입문을 열고 나오다가 B 등이 甲을 붙잡자, 체포를 면탈할 목적으로 甲의 목을 잡고 있던 B의 오른손을 깨무는 등 폭행을 가하였다.

[판결요지] <다수의견> 피해자에 대한 폭행·협박을 수단으로 하여 재물을 탈취하고자 하였으나 그 목적을 이루지 못한 자가 강도미수죄로 처벌되는 것과 마찬가지로, 절도미수범인이 폭행·협박을 가한 경우에도 강도미수에 준하여 처벌하는 것이 합리적이라 할 것이다. 만일 강도죄에 있어서는 재물을 강취하여야 기수가 됨에도 불구하고 준강도의 경우에는 폭행·협박을 기준으로 기수와 미수를 결정하게 되면 재물을 절취하지 못한 채 폭행·협박만 가한 경우에도 준강도죄의 기수로 처벌받게 됨으로써 강도미수죄와의 불균형이 초래된다. 위와 같은 준강도죄의 입법취지, 강도죄와의 균형 등을 종합적으로 고려해 보면, 준강도죄의 기수 여부는 절도행위의 기수 여부를 기준으로 하여 판단하여야 한다고 봄이 상당하다. 이와 달리 절도미수범이 체포를 면탈하기 위하여 폭행을 가한 경우에 준강도미수로 볼 수 없다고 한 대판 1964.11.20. 64도504 판결, 대판 1969.10.23. 69도1353 판결 등은 위의 법리에 저촉되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

절취행위기준설에 의하면 절취행위가 미수에 그쳤으나 폭행·협박행위는 기수에 이르렀다면 이는 준강도죄의 미수가 될 것이고, 반대로 절취행위는 기수에 달하였지만 폭행·협박행위는 미수에 그쳤다면 이는 준강도죄의 기수가 될 것이다.

3. 주관적 구성요건

고의 및 불법영득의사와 재물탈환의 항거, 죄적인멸, 체포면탈의 목적이 있어야 한다. 따라서 절도가 발각되자 체포면탈 등의 목적이 아니라 강취의 목적으로 폭행·협박을 하여 재물을 탈취한 경우에는 강도죄가 성립한다.

III. 준강도죄와 공범

1. 문제점

가령 甲과 乙이 절도를 공모하여 특수절도를 하다가 범행이 발각되자 乙이 체포를 면탈하기 위하여 폭행을 가한 경우 乙에게 준강도죄가 성립함은 분명하다. 그런데 절도의 공동정범 가운데 1인이 절도의 공모를 초과하여 본죄를 범한 경우에 다른 공범자, 즉 위의 사례에서 폭행에 가담하지 않은 甲에게도 본죄의 성립을 인정할 수 있는가가 문제된다.

2. 판례

판례(대판 1982.7.13. 82도1352)는 “합동하여 절도를 한 경우 범인 중 1인이 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 하여 상해를 가한 때에는 나머지 범인도 이를 예기하지 못한 것으로 볼 수 없으면 준강도상해죄의 죄책을 면할 수 없다”고 판시하여 다른 공범자에게 폭행·협박의 예견가능성이 존재하면 본죄의 공동정범이 성립된다는 입장이다. 다만 판례에 의하여도 예견가능성이 존재하지 않는 경우에는 특수절도죄만이 성립한다.

IV. 보론 - 처벌

1. 전 2조의 예에 의한다.

강도죄 또는 특수강도죄와 같이 취급한다. 또한 강도상해·치상죄 및 강도강간죄의 규정도 적용된다. 그러므로 절도가 체포를 면탈하거나 죄적을 인멸할 목적으로 사람을 살해한 때에도 강도살인죄가 성립한다.

2. 특수강도인가의 판단

폭행·협박의 태양에 따라 판단한다. 따라서 절도범이 처음에는 흉기를 휴대하지 않았으나 체포를 면탈할 목적으로 폭행·협박을 가할 때에 비로소 흉기를 휴대 사용하게 된 경우에는 특수준강도죄가 성립한다(대판 1973.11.13. 73도1553 전원합의체).

♣ 확인학습문제

1. 다음 준강도죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 절도가 체포를 면탈하거나 죄적을 인멸할 목적으로 사람을 살해한 때에는 준강도죄와 살인죄가 성립한다.
- ② 甲은 심야에 인적이 드문 도로가에서 주차된 자동차의 문을 열고 그 안의 물건을 훔칠 의도로 범행 대상을 물색하다가 체포되었다. 그런데 그 당시 甲은 절도 범행이 발각되었을 경우 체포를 면탈하는데 도움이 될 수 있을 것이라는 생각에서 흉기를 휴대하고 있었다. 이 경우 甲에게는 강도예비죄가 성립하지 않는다.
- ③ 준강도죄의 입법취지, 강도죄와의 균형 등을 종합적으로 고려해 보아 준강도죄의 기수 여부는 절취행위의 기수 여부를 기준으로 하여 판단하여야 한다.
- ④ 준강도죄의 성립에 필요한 수단으로서의 폭행이나 협박의 정도는 상대방의 반항을 억압하는 수단으로서 일반적, 객관적으로 가능하다고 인정되는 정도의 것이면 되고 현실적으로 반항을 억압하였음을 필요로 하는 것은 아니다.
- ⑤ 甲이 지나가는 행인을 재물을 훔쳐서 도주하다가 순찰 중인 경찰관 A가 자신을 추격하자 체포를 면하기 위하여 A에게 폭행을 가한 경우 준강도죄와 공무집행방해죄가 성립한다.

[정답] ①

[해설] 강도살인죄의 주체인 강도는 준강도죄의 범인을 포함한다고 할 것이어서 절도가 체포를 면탈하거나 죄적을 인멸할 목적으로 사람을 살해한 때에도 강도살인죄가 성립한다(대판 1987.9.22. 87도1592).

2. A는 甲 및 공범 乙이 자기 집에서 물건을 훔쳐 나왔다는 연락을 받고 도주로를 따라 추격하자 범인들이 이를 보고 도주하므로 1킬로미터 가량 추격하여 乙을 체포하여 같이 추격하여 온 동리 사람들에게 인계하고 1킬로미터를 더 추격하여 甲을 체포하여 가지고 간 나무몽둥이로 甲을 1회 구타하자 甲이 몽둥이를 빼앗아 피해자 A를 구타하여 상해를 가하고 도주하였다. 이 경우 甲과 乙의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲과 乙은 강도치상죄의 공동정범
- ② 甲 : 강도치상죄, 乙 : 특수절도죄
- ③ 甲과 乙은 특수절도죄
- ④ 甲 : 강도치상죄, 乙 : 준강도죄
- ⑤ 甲과 乙은 준강도죄의 공동정범

[정답] ②

[해설] 甲은 (준)강도치상죄가 되고, 乙은 폭행에 대한 예견가능성을 인정할 수 없으므로 특수절도죄가 된다.

3. 甲이 A의 재물을 훔치려고 하였으나 실패하고 도망을 가다가 추적해 오는 A를 각목으로 때려서 추적을 단념하게 하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 절도죄의 미수와 폭행죄
- ② 절도죄의 미수와 특수폭행죄
- ③ 준강도죄의 미수와 특수폭행죄
- ④ 준강도죄의 미수
- ⑤ 특수준강도죄의 미수

[정답] ⑤

[해설] 절도가 미수에 그친 상태에서 체포면탈의 목적으로 폭행을 가한 것이므로 준강도미수가 되고, 폭행할 때 위험한 물건을 사용하였으므로 특수준강도죄의 미수가 된다.

♣ 학습내용 정리

1. 준강도죄는 절도가 재물을 취득한 후 재물탈환의 항거, 체포면탈 또는 죄적인멸을 위해 폭행·협박을 함으로써 성립하는 범죄로서 독자적 변형구성요건이다.
2. 준강도죄의 주관적 구성요건으로서 폭행, 협박에 대한 고의 및 불법영득의사와 재물탈환의 항거, 죄적인멸, 체포면탈의 목적이 있어야 한다.
3. 판례는 특수절도의 다른 공범자에게 폭행·협박의 예견가능성이 존재하면 준강도죄의 공동정범이 성립된다는 입장이다.
4. 절도범이 처음에는 흥기를 휴대하지 않았으나 체포를 면탈할 목적으로 폭행·협박을 가할 때에 비로소 흥기를 휴대 사용하게 된 경우에는 특수준강도죄가 성립한다.

제18강 강도죄의 특수유형

♣ 학습목표

- 인질강도죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 특수강도죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 강도강간죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 인질강도
- 야간주거침입특수강도
- 흥기휴대 특수강도
- 합동특수강도
- 강도강간

♣ 사전테스트

1. 재물 또는 재산상 이익과 무관한 요구를 한 때에도 인질강도죄가 성립한다.
정답 : X
2. 주거침입만 한 경우에도 야간주거침입특수강도의 실행의 착수를 인정하는 판례도 있다.
정답 : O
3. 특수강도가 강간한 때에는 성폭력처벌특례법 제4조 제1항에 의하여 가중처벌된다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

강도강간죄의 강도에는 준강도나 인질강도는 포함되지 않는다.

[정답] X

[해설] 강도강간죄의강도에는 준강도, 인질강도, 해상강도, 강도상해가 포함된 개념이다.

♣ 강의내용

I. 인질강도죄(형법 제336조)

1. 의의

본죄는 사람을 체포·감금, 약취·유인하여 그 석방대가로 재물을 취득함으로써 성립하는 범죄로 체포·감금죄나 약취·유인죄와 공갈죄의 결합범이다. 인질강요죄에 대해서 적용되는 해방감경규정은 본죄에 대해서는 적용되지 않는다.

2. 행위객체 및 행위

본죄에 있어서 ‘사람’은 반드시 미성년자일 필요는 없으며, 인질과 재물취득행위의 피해자 역시 일치할 필요가 없다. ‘인질로 삼는다’는 것은 체포·감금, 약취·유인된 사람을 불모로 하여 그 석방 내지 생명, 신체 등에 대한 안전을 재물 내지 재산상 이익을 요구하는 수단으로 삼은 것을 뜻한다. 재물 또는 재산상 이익과 무관한 요구를 한 때에는 인질강요죄가 성립한다.

3. 실행의 착수 및 기수시기

① 실행의 착수시기는 본죄의 고의로 체포·감금, 약취·유인행위를 개시한 때라는 견해와 석방이나 안전보장의 대가로 재물 또는 재산상의 이익을 요구한 때라는 견해가 대립하는 바, 본죄는 처음부터 재물 또는 재산상의 이익을 요구할 의사로 체포·감금·약취·유인하는 것을 요하지 아니하므로 후설이 타당하다. ② 본죄의 기수시기는 재물을 취득한 때이다.

4. 가중처벌

미성년자 약취·유인죄를 범한 자가 본죄를 범한 경우에는 특가법 제5조의2 제2항 1호에 의하여 가중처벌 된다. 이 법률에 의하면 미성년자를 약취·유인한 자가 이를 인질로 삼아 재물이나 재산상 이익을 취득한 경우뿐만 아니라 단순히 요구한 경우에도 형법상 인질강도죄와 달리 미수가 아니라 기수이다.

II. 특수강도죄(형법 제334조)

1. 성격

행위의 위험성으로 인한 형법 제333조 강도죄의 가중구성요건이다.

2. 실행의 착수시기

(1) 문제점

야간주거침입강도죄의 경우에도 야간주거침입절도죄와 마찬가지로 주거침입이 있으면 실행의 착수가 있는지가 문제된다. 강도죄에서는 절도죄와는 달리 폭행·협박도 그 수단이 되기 때문에 발생하는 문제이다.

(2) 주거침입시절

본죄는 야간주거침입절도죄와 마찬가지로 주거침입죄와 강도죄의 결합범이므로 주거침입시에 실행의 착수가 인정된다.

판례 (대판 1992.7.28. 92도917) 司47·51·52·55

형법 제334조 제1항 소정의 야간주거침입강도죄는 주거침입과 강도의 결합범으로서 시간적으로 주거침입행위가 선행되므로 주거침입을 한 때에 본죄의 실행에 착수한 것으로 볼 것인바, 같은 조 제2항 소정의 흉기휴대 합동강도죄에 있어서도 그 강도행위가 야간에 주거에 침입하여 이루어지는 경우에는 주거침입을 한 때에 실행에 착수한 것으로 보는 것이 타당하다.

(3) 폭행·협박시설

야간주거침입강도의 경우 실행의 착수시기는 폭행·협박을 개시한 때라는 견해이다.

판례 (대판 1991.11.22. 91도2296) 司52·55

강도의 범의로 야간에 칼을 휴대한 채 타인의 주거에 침입하여 집안의 동정을 살피다가 피해자를 발견하고 갑자기 욕정을 일으켜 칼로 협박하여 강간한 경우, 야간에 흉기를 휴대한 채 타인의 주거에 침입하여 집안의 동정을 살피는 것만으로는 특수강도의 실행에 착수한 것이라고 할 수 없으므로 위의 특수강도에 착수하기도 전에 저질러진 위와 같은 강간행위가 구 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의6 제1항 소정의 특수강도강간죄에 해당한다고 할 수 없다.

[사실관계] 甲이 야간에 타인의 재물을 강취하기로 마음먹고 흉기인 칼을 휴대한 채 시정되어 있지 않은 乙의 집 현관문을 열고 마루까지 침입하여 동정을 살피던 중 마침 혼자서 집을 보던 乙의 손녀(14세)가 화장실에서 용변을 보고 나오는 것을 발견하고 갑자기 욕정을 일으켜 칼을 위 손녀의 목에 들이 대고 방안으로 끌고 들어가 밀어 넘어뜨려 반항을 억압한 다음 강제로 1회 간음하여 동 피해자를 강간하였다.

(4) 결론

- ① 주거침입시를 실행의 착수시기로 보게 되면 야간주거침입절도죄와 야간주거침입강도죄의 구별이 행위자의 주관적 의사에 따라 결정되기 때문에 양자의 구별이 애매해지게 된다. 따라서 본죄의 실행의 착수시기는 폭행·협박시로 보는 것이 타당하다.
- ② 다만 노상에서 이루어진 특수강도의 경우에 대한 판례의 태도는 명확하지 않다. 통설은 이 경우 특수강도죄의 실행의 착수시기를 폭행·협박시로 보는바, 노상에서 이루어진 특수강도에 대하여 주거침입행위를 상정할 수는 없으므로 이때에는 특수강도의 고의에 의한 폭행·협박시에 실행의 착수를 인정해야 할 것이다. 가령 甲과 乙이 공모하여 丙의 재물을 강취하기로 하고 甲이 현장에서 망을 보고 있는 사이 乙이 丙을 폭행·협박하다가 경찰관에게 체포된 경우 어느 한 공동정범이 실행에 착수한 때에는 모든 공동정범에 대하여 실행의 착수가 인정되므로 乙은 물론 甲에게도 특수강도죄의 실행의 착수가 인정된다. 司52

3. 죄수

판례 (대판 2012.12.27. 2012도12777)

강도상해죄에 있어서의 강도는 형법 제334조 제1항 특수강도도 포함된다고 보아야 한다. 그런데 형법 제334조 제1항 특수강도죄는 ‘주거침입’이라는 요건을 포함하고 있으므로 형법 제334조 제1항 특수강도죄가 성립할 경우 ‘주거침입죄’는 별도로 처벌할 수 없고, 형법 제334조 제1항 특수강도에 의한 강도상해가 성립할 경우에도 별도로 ‘주거침입죄’를 처벌할 수 없다고 보아야 할 것이다.

4. 강도상해·강도치상죄, 강도살인·강도치사죄

<강도살인·상해죄를 인정한 판례>

- ① 강도범행 직후 신고를 받고 출동한 경찰관이 위 범행 현장으로부터 약 150m 지점에서, 화물차를 타고 도주하는 피고인을 발견하고 순찰차로 추적하여 격투 끝에 피고인을 붙잡았으나, 피고인이 너무 힘이 세고 반항이 심하여 수갑도 채우지 못한 채 피고인을 순찰차에 억지로 밀어 넣고서 파출소로 연행하고자 하였는데, 그 순간 피고인이 체포를 면하기 위하여 소지하고 있던 과도로써 옆에 앉아 있던 경찰관을 찔러 사망케 하였다면 피고인의 위 살인행위는 강도행위와 시간상 및 거리상 극히 근접하여 사회통념상 범죄행위가 완료되지 아니한 상태에서 이루어진 것이라고 보이므로(위 살인행위 당시에 피고인이 체포되어 신체가 완전히 구속된 상태였다고 볼 수 없다), 원심이 피고인을 강도살인죄로 적용하여 처벌한 것은 옳다(대판 1996.7.12. 96도1108). 49·50
- ② 형법 제337조의 강도상해죄는 강도범인이 강도의 기회에 상해행위를 함으로써 성립하므로 강도범행의 실행 중이거나 실행 직후 또는 실행의 범의를 포기한 직후로서 사회통념상 범죄행위가 완료되지 아니하였다고 볼 수 있는 단계에서 상해가 행하여짐을 요건으로 한다. 그러나 반드시 강도범행의 수단으로 한 폭행에 의하여 상해를 입힐 것을 요하는 것은 아니고 상해행위가 강도가 기수에 이르기 전에 행하여져야만 하는 것은 아니므로, 강도범행 이후에도 피해자를 계속 끌고 다니거나 차량에 태우고 함께 이동하는 등으로 강도범행으로 인한 피해자의 심리적 저항불능 상태가 해소되지 않은 상태에서 강도범인의 상해행위가 있었다면 강취행위와 상해행위 사이에 다소의 시간적·공간적 간격이 있었다는 것만으로는 강도상해죄의 성립에 영향이 없다(대판 2014.9.26. 2014도9567).

III. 강도강간죄(형법 제339조)

1. 법적 성격

강도가 강간함으로써 성립하는 강도죄의 가중구성요건이다. 이때 강도에는 준강도, 인질강도, 해상강도, 강도상해가 포함된 개념이다. 다만 특수강도가 강간한 때에는 성폭력처벌특례법 제4조 제1항에 의하여 가중처벌 된다.

2. 행위주체

(1) 강도범이다.

강도의 실행에 착수한 이상 기수·미수를 불문한다. 강간행위가 종료하기 전에 강도한 경우에는 강도의 기회라고 볼 수 있기 때문에 강도강간죄가 성립한다.

판례 (대판 1988.9.9. 88도1240) 辯2 司52

강도강간죄는 강도라는 신분을 가진 범인이 강간죄를 범하였을 때 성립하는 범죄이고 따라서 강간범이 강간행위 후에 강도의 범의를 일으켜 그 부녀의 재물을 강취하는 경우에는 강도강간죄가 아니라 강도죄와 강간죄의 경합범이 성립될 수 있을 뿐이나, 강간범이 강간행위 종료전 즉 그 실행행위의 계속 중에 강도의 행위를 할 경우에는 이때에 바로 강도의 신분을 취득하는 것이므로 이후에 그 자리에서 강간행위를 계속하는 때에는 강도가 부녀를 강간한 때에 해당하여 형법 제339조 소정의 강도강간죄를 구성한다.

판례 (대판 2010.7.15. 2010도3594) 辯2 司54·55

형법 제334조(특수강도) 등의 죄를 범한 자가 「형법」 제297조(강간) 등의 죄를 범한 경우에 이를 특수강도강간 등의 죄로 가중하여 처벌하는 것이므로, 다른 특별한 사정이 없는 한 특수강간범이 강간

행위 종료 전에 특수강도의 행위를 한 이후에 그 자리에서 강간행위를 계속하는 때에도 특수강도가 부녀를 강간한 때에 해당하여 구「성폭력특례법」 제5조 제2항에 정한 특수강도강간죄로 의율할 수 있다.

【동일취지 판결】 야간에 甲의 주거에 침입하여 드라이버를 들이대며 협박하여 甲의 반항을 억압한 상태에서 강간행위의 실행 도중 범행현장에 있던 乙 소유의 핸드백을 가져간 피고인의 행위는 포괄하여 성폭력처벌특례법위반(특수강도강간등)죄에 해당한다(대판 2010.12.9. 2010도9630).

(2) 그러나 강간행위가 종료된 후 강도한 경우에는 강간죄와 강도죄의 경합범이 된다.

판례 (대판 2002.2.8. 2001도6425) 司52

강간범이 강간행위 후에 강도의 범의를 일으켜 그 부녀의 재물을 강취하는 경우에는 형법상 강도강간죄가 아니라 강간죄와 강도죄의 경합범이 성립될 수 있을 뿐인바, 성폭력특례법 제3조 제2항은 형법 제334조(특수강도) 등의 죄를 범한 자가 형법 제297조(강간) 등의 죄를 범한 경우에 이를 특수강도강간 등의 죄로 가중하여 처벌하고 있으므로, 다른 특별한 사정이 없는 한 강간범이 강간의 범행 후에 특수강도의 범의를 일으켜 그 부녀의 재물을 강취한 경우에는 이를 성폭력특례법 제3조 제2항 소정의 특수강도강간죄로 의율할 수 없다.

3. 행위

강도의 기회에 사람을 강간하는 것이다. 강도의 기회에 강간이 행해지면 족하고, 강취의 전후는 불문한다. 강간시의 폭행·협박이 동시에 재물강취의 수단이 된 경우라도 본죄가 성립한다. 그러나 강간 후 비로소 재물강취의 고의가 생겼다면 강간죄와 강도죄의 경합범이 된다. 강도강간의 미수는 강간행위의 기수·미수에 따라 정해진다.

4. 죄수

강도가 강간하다가 과실로 상해한 경우 상해가 강도행위에서 비롯되었으면 강도강간죄와 강도치상죄의 상상적 경합이고, 상해가 강간행위에서 비롯되었으면 강도강간죄와 강간치상죄의 상상적 경합이 된다.

판례 (대판 1988.6.28. 88도820) 辯2 司50·51·54·57

강도가 재물강취의 뜻을 재물의 부재로 이루지 못한 채 미수에 그쳤으나 그 자리에서 항거불능의 상태에 빠진 피해자를 간음할 것을 결의하고 실행에 착수했으나 역시 미수에 그쳤더라도 반항을 억압하기 위한 폭행으로 피해자에게 상해를 입힌 경우에는 강도강간미수죄와 강도치상죄가 성립되고 이는 1개의 행위가 2개의 죄명에 해당되어 상상적 경합관계가 성립된다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 강도죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 강도범행 직후 신고를 받고 출동한 경찰관이 위 범행 현장으로부터 약 150m 지점에서, 화물차를 타고 도주하는 피고인을 발견하고 순찰차로 추적하여 격투 끝에 피고인을 붙잡았으나, 피고인이 너무 힘이 세고 반항이 심하여 수갑도 채우지 못한 채 피고인을 순찰차에 억지로 밀어 넣고서 파출소로 연행하고자 하였는데, 그 순간 피고인이 체포를 면하기 위하여 소지하고 있던 과도로 옆에 앉아 있던 경찰관을 찔러 사망케 한 경우, 강도죄와 살인죄의 실체적 경합범에 해당된다.
- ② 인질강도죄는 체포·감금죄나 약취·유인죄와 공갈죄의 결합범이다.

제19강 사기죄의 행위객체와 기망

♣ 학습목표

- 사기죄의 객체인 재물과 재산상 이익의 의미를 말할 수 있다.
- 사기죄에서 기망의 내용을 설명할 수 있다.
- 부작위에 의한 기망에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 기망
- 용도사기와 동기의 착오
- 부작위에 의한 기망
- 거스름돈 사기

♣ 사전테스트

- 타인에게 입질한 자기의 재물을 기망하여 교부받은 경우 사기죄가 성립한다.
정답 : X
- 상관행상 일반적으로 인정되는 범위 내의 과장광고는 기망이 되지 않는다.
정답 : O
- 사기죄에 있어 기망은 부작위에 의한 기망도 가능하다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

환자가 치료비채무의 이행을 모면하기 위하여 거짓말을 하고 병원을 빠져 나와 도주한 경우 사기죄가 성립한다.

[정답] X

[해설] 그것만으로서 피고인이 위 치료비의 지급채무를 면탈받은 것은 아니라 할 것이므로 사기죄가 될 수 없다(대판 1970.9.22. 70도1615)

♣ 강의내용

1. 행위의 객체

1. 사기죄의 구성요건

사기죄의 객관적 구성요건은 ① 기망행위, ② 상대방이 착오에 빠질 것, ③ 상대방의 재물교부 내지 처분행위, ④ 재물 또는 재산상의 이익의 취득, ⑤ 상대방에게 재산상의 손해의 발생 등이다.

2. 행위객체

행위객체 : 재물 또는 재산상 이익이다.

(1) 재물 : 타인이 점유하는 타인소유의 재물이다.

타인이 점유하는 자기 소유의 재물을 기망으로 교부받은 경우 재물의 타인성이 부정되므로 사기죄가 성립할 수 없다. 예컨대 타인에게 입질한 자기의 재물을 기망하여 교부받아 도로 찾아온 행위에 대해서는 사기죄가 성립하지 않는다.

(2) 재산상 이익

- ① 재산상 이익은 적극적 이익이건, 소극적 이익이건 불문한다. 여기서 적극적 이익은 연대보증인이 되게 하는 것, 노무제공, 연고권취득, 채권자를 속여 채권의 추심승낙을 받아 이를 추심취득한 경우 등이며, 소극적 이익은 채무면제나 이른바 대환 같은 채무변제의 유예 등을 말한다. 또한 일시적 이익, 영구적 이익을 불문한다. 이 때 이익취득이 사법상 유효하지 않아도 상관없다. 외관상 재산상 이익을 취득하였다는 사실관계가 있으면 족하다.

판례 (대판 2012.9.27. 2011도282)

경제적 이익을 기대할 수 있는 자금운용의 권한 내지 지위의 획득도 그 자체로 경제적 가치가 있는 것으로 평가할 수 있다면 사기죄의 객체인 재산상의 이익에 포함된다.

- ② 재산상 이익의 대상은 재산권이어야 하므로 기망에 의하여 재산을 취득한 경우에도 그것이 재산상 이익이 아니면 사기죄가 성립하지 않는다.

판례 (대판 1997.3.28. 96도2625)

司52

보험가입사실증명원은 교통사고를 일으킨 차가 교통사고처리특례법 제4조에서 정한 취지의 보험에 가입하였음을 보험회사가 증명하는 내용의 문서일 뿐이고 거기에 재물이나 재산상의 이익의 처분에 관한 사항을 포함하고 있는 것은 아니므로 사기죄의 객체가 되지 아니한다.

- ③ 재산상 이익은 구체적 이익이어야 한다. 따라서 구체적 이익의 취득이 아닌 경우에는 사기죄를 구성하지 않는다.

판례 (대판 1970.9.22. 70도1615)

司45

치료비채무의 이행을 모면하기 위하여 피고인이 거짓말을 하고 입원환자(처)와 함께 병원을 빠져 나와 도주하였다 하여도 그것 만으로서는 피고인이 위 치료비의 지급채무를 면탈 받은 것은 아니라 할 것이므로 사기죄가 될 수 없다.

II. 기망의 대상

1. 기망행위의 의의

기망이란 허위의 의사표시에 의하여 타인을 착오에 빠뜨리는 일체의 행위이다. 즉 기망은 널리 재산상의 거래행위에 있어서 서로 지켜야 할 신의와 성실의 의무를 저버리는 모든 적극적 및 소극적 행위로서 사람으로 하여금 착오를 일으키게 하는 것이다(대판 2002.2.5. 2001도5789).

2. 기망의 대상

(1) 사실

사실이란 구체적 증명이 가능한 과거 또는 현재의 상태로서 재산적 처분행위에 대한 판단의 기초가 된다. 여기서 사실은 동기, 목적, 전문지식에 속하는 심리적·내부적 사실(ex. 지불의사)이나 외부적 사실(ex. 지불능력)을 불문한다.

(2) 과장광고

상관행상 일반적으로 인정되는 범위 내의 과장광고는 사회적으로 용인될 수 있는 상술로서 기망이 되지 않는다. 그러나 거래상 중요한 사항에 관한 구체적인 사실을 거래상의 신의성실원칙에 반하는 비난받을 정도의 방법으로 허위광고를 하는 것은 기망행위가 된다.

(3) 차용금 사기(용도사기)의 문제

금원을 차용하면서 차용금의 용도를 기망한 경우인데, 동기의 착오도 착오의 대상에 포함되는가의 문제에 있어서 착오가 반드시 법률행위내용의 중요부분에 대한 것임을 요하지 않고 법률행위의 내용으로 표시되지 아니한 의사결정의 동기에 관하여 착오를 일으킨 경우인 동기의 착오로도 족하다고 한다는 것이 통설과 판례의 태도이다.

판례 차용금융도 사기사건(대판 1996.2.27. 95도2828) *

[판결요지] 사기죄의 실행행위로서 기망은 반드시 법률행위의 중요부분에 관한 허위표시임을 요하지 아니하고 상대방을 착오에 빠지게 하여 행위자가 희망하는 재산적 처분행위를 하도록 하기 위한 판단의 기초가 되는 사실에 관한 것이면 족한 것이므로 용도를 속이고 돈을 빌린 경우에 있어서 만일 진정한 용도를 고지하였다면 상대방이 돈을 빌려주지 않았을 것이라는 관계가 있는 때에는 사기죄의 실행행위인 기망은 있는 것으로 보아야 한다.

3. 수단·방법

무제한하다. 작위에 의한 명시적·묵시적 기망뿐만 아니라, 부작위에 의한 기망도 가능하다. 여기서 명시적·묵시적 기망행위는 언어나 문서에 의하여 적극적으로 기망하는 경우이다. 묵시적 기망은 일정한 동작(거동)에 의하여 허위의 주장을 하는 경우이다.

III. 부작위에 의한 기망

1. 의의

상대방이 행위자와 관계없이 이미 스스로 착오에 빠져 있는 상태를 이용하고자 진실한 사실을 고지하지 않는 경우에만 부작위에 의한 기망이 된다.

2. 성립요건

판례는 거래의 상대방이 일정한 사정에 관한 고지를 받았더라면 당해 거래에 임하지 아니하였을 것이라는 관계가 인정되는 경우에는 그 거래로 인하여 재물을 수취하는 자에게는 신의성실의 원칙상 사전에 상대방에게 그와 같은 사정을 고지할 의무가 있다 할 것이고, 그럼에도 불구하고 이를 고지하지 아니한 것은 고지할 사실을 묵비함으로써 상대방을 기망한 것이 되어 사기죄를 구성한다는 입장이다.

판례 (대판 2014.2.27. 2011도48)

소극적 행위로서의 부작위에 의한 기망은 법률상 고지의무 있는 사람이 일정한 사실에 관하여 상대방이 착오에 빠져 있음을 알면서도 그 사실을 고지하지 아니함을 말하는 것으로서, 일반거래의 경험칙상 상대방이 그 사실을 알았다더라면 당해 법률행위를 하지 아니하였을 것이 명백한 경우에는 신의칙에 비추어 그 사실을 고지할 법률상 의무가 인정된다고 할 것이나, 이와 달리 법률관계에 아무런 영향도 미칠 수 없어 상대방의 권리 실현 또는 계약 목적 달성에 장애가 되지 아니하는 사유까지 고지할 의무가 있다고는 볼 수 없다.

판례 (대판 1986.9.9. 86도956) 司42·44

부동산매매에 있어서 매매목적물에 관하여 소유권귀속에 관한 분쟁이 있어 재심소송이 계속 중에 있는 경우 매도인 이 매수인에게 소송계속 사실을 숨기고 매도하여 대금을 교부받았다면 이는 사기죄를 구성한다.

판례 (대판 1998.12.8. 98도3263) 辯1 司43·56

임대인이 임대차계약을 체결하면서 임차인에게 임대목적물이 경매진행중인 사실을 알리지 아니한 경우, 임차인이 등기부를 확인 또는 열람하는 것이 가능하더라도 신의칙에 비추어 그 사실을 고지할 법률상 의무가 인정되는 것이므로 사기죄가 성립한다.

3. 문제가 되는 경우

(1) 거스름돈사기

(가) 문제점

과분의 매매잔금이 교부되었으나 그 나머지를 돌려주지 않은 경우 어떤 범죄가 성립할 것인지가 문제된다. 이는 소위 ‘거스름돈 사기’의 경우로 금전을 수령할 때 과분의 매매잔금이 교부된다는 사실을 알았을 경우 이를 상대방에게 고지해야 할 고지의무가 인정되어 부작위에 의한 사기죄가 성립될 것인가가 문제의 핵심이 된다.

(나) 판례의 태도

판례는 과다한 거스름돈을 교부하는 현장에서 그 착오를 알고도 그대로 받은 경우에는 수령인에게 법률상의 고지의무가 있다고 보아 부작위에 의한 사기죄가 성립하고, 교부 및 수령 후에 그 착오를 알게 되었다면 고지의무의 불이행이라는 부작위는 편취의 수단으로서의 의미가 없으므로 점유이탈물횡령죄만이 성립한다는 견해를 취한다.

[사실관계] A 아파트 소유자 乙은 甲과 매매계약을 맺고 아파트를 매수인 甲에게 매도를 하려는 바, 이 사건 당일 乙이 甲에게 매매잔금을 지급할 때에 乙의 착오로 1,000만원권 자기앞수표 1장을 추가로 지급하게 되었다. 甲은 그 사실을 모른 채 자기앞수표를 수령하였고, 나중에서야 매매잔금이 더 수령되었음을 알게 되었으나 이를 돌려주지는 아니하였다.

[판결요지] 매수인이 매도인에게 매매잔금을 지급함에 있어 착오에 빠져 지급해야 할 금액을 초과하는 돈을 교부하는 경우, ① 매도인이 사실대로 고지하였다면 매수인이 그와 같이 초과하여 교부하지 아니하였을 것임은 경험칙상 명백하므로, 매도인이 매매잔금을 교부받기 전 또는 교부받던 중에 그 사실을 알게 되었을 경우에는 특별한 사정이 없는 한 매도인으로서 매수인에게 사실대로 고지하여 매수인의 그 착오를 제거하여야 할 신의칙상 의무를 지므로 그 의무를 이행하지 아니하고 매수인이 건네주는 돈을 그대로 수령한 경우에는 사기죄에 해당될 것이지만, ② 그 사실을 미리 알지 못하고 매매잔금을 건네주고 받는 행위를 끝마친 후에야 비로소 알게 되었을 경우에는 주고받는 행위는 이미 종료되어 버린 후이므로 매수인의 착오 상태를 제거하기 위하여 그 사실을 고지하여야 할 법률상 의무의 불이행은 더 이상 그 초과된 금액 편취의 수단으로서의 의미는 없으므로, 교부하는 돈을 그대로 받은 그 행위는 점유이탈물횡령죄가 될 수 있음은 별론으로 하고 사기죄를 구성할 수는 없다.

(2) 금전 차용행위

(가) 처음부터 변제의사가 없는 경우

금전을 차용하려고 할 때 변제의사가 있음을 묵시적으로 표현한 것이라고 보아 묵시적 기망행위로 보아야 할 것이다. 판례(대판 1998.12.9. 98도3282) 역시 “수표나 어음이 지급기일에 결제되지 않으리라는 점을 예견하였거나 지급기일에 지급될 수 있다는 확신이 없으면서도 그러한 내용을 수취인에게 고지하지 아니하고 이를 속여서 할인을 받으면 사기죄가 성립한다.”는 입장이다.

(나) 후에 변제하겠다는 의사가 있는 경우

금전차용당시에 변제 능력이 없음을 고지하지 않았더라도 후에 변제능력을 갖추어 변제하겠다는 의사가 있었다면 이때에는 묵시적 기망도 인정되지 않고, 신의칙에 의한 고지의무가 있다고 볼 수도 없기 때문에 부작위에 의한 기망도 인정되지 않는다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 사기죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사기죄의 객체인 재물은 타인이 점유하는 타인소유의 재물이어야 한다.
- ② 경제적 이익을 기대할 수 있는 자금운용의 권한 내지 지위를 획득하는 것도 사기죄의 객체인 재산상 이익에 포함된다.
- ③ 거래상 중요한 사항에 관한 구체적인 사실을 거래상의 신의성실원칙에 반하는 비난받을 정도의 방법으로 허위광고를 하는 것은 기망행위가 된다.
- ④ 용도를 속이고 돈을 빌린 경우와 같은 동기의 착오는 사기죄의 실행행위인 기망에 해당하지 않는다.
- ⑤ 기망에 의하여 재산을 취득한 경우에도 그것이 재산상 이익이 아니면 사기죄가 성립하지 않는다.

【해설】 용도를 속이고 돈을 빌린 경우에 있어서 만일 진정한 용도를 고지하였더라면 상대가 돈을 빌려 주지 않았을 것이라는 관계에 있는 때에는 사기죄의 실행행위인 기망은 있는 것으로 보아야 한다(대판 1996.2.27. 95도2828).

- ① 수표나 어음이 지급기일에 결제되지 않으리라는 점을 예견하였으면서도 그러한 내용을 수취인에게 고지하지 아니하고 이를 속여서 할인을 받으면 사기죄가 성립한다.
- ② 명시적·묵시적 기망행위는 언어나 문서에 의하여 적극적으로 기망하는 경우이다. 묵시적 기망은 일정한 동작(거동)에 의하여 허위의 주장을 하는 경우이다.
- ③ 일반거래의 경험칙상 상대방이 그 사실을 알았다라면 당해 법률행위를 하지 않았을 것이 명백한 경우에는 신의칙에 비추어 그 사실을 고지할 법률상 의무가 인정된다.
- ④ 매매목적물의 소유권 귀속에 관한 재심소송계속 사실을 숨기고 매도하여 대금을 교부받은 경우 사기죄가 성립한다.
- ⑤ 임대인이 임대차계약을 체결하면서 임차인에게 임대목적물이 경매진행중인 사실을 알리지 아니한 경우, 임차인이 등기부를 확인 또는 열람하는 것이 가능한 것이므로 사기죄가 성립한다고 볼 수 없다.

3. A 아파트 소유자 乙은 甲과 매매계약을 맺고 아파트를 매수인 甲에게 매도를 하려는 바, 乙이 甲에게 매매잔금을 지급할 때에 乙의 착오로 1,000만원권 자기앞수표 1장을 추가로 지급하게 되었다. 甲은 그 사실을 모른 채 자기앞수표를 수령하였고, 나중에야 매매잔금이 더 수령되었음을 알게 되었으나 이를 돌려주지는 아니하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- 【해설】 과분의 거스름돈을 교부하는 현장에서 그 착오를 알고도 그대로 받은 경우에는 부작위에 의한 사기죄가 성립하고, 교부 및 수령 후에 그 착오를 알게 되었다면 점유이탈물횡령죄만이 성립한다(대판 2004.5.27. 2003도4531).

1. 사기죄의 행위객체는 재물 또는 재산상 이익이다.
2. 사기죄의 요건으로서의 기망은 널리 재산상의 거래관계에 있어 서로 지켜야 할 신의와 성실의 의무를 저버리는 모든 적극적 또는 소극적 행위를 말하는 것이다.
3. 상대방이 행위자와 관계없이 이미 스스로 착오에 빠져 있는 상태를 이용하고자 진실한 사실을 고지하지 않는 경우에만 부작위에 의한 기망이 된다.

제20강 착오의 유발과 소송사기

♣ 학습목표

- 사기죄에서 기망의 정도에 대하여 설명할 수 있다.
- 소송사기의 법리를 설명할 수 있다.
- 소송사기의 실행의 착수시기를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 기망의 정도
- 소송사기
- 소송사기의 실행의 착수시기
- 소송사기의 기수시기

♣ 사전테스트

1. 기망에 의한 착오가 있는 경우에도 그로 인하여 거래의 목적을 달성하는데 지장이 없는 경우에는 사기죄의 기망이 있다고 할 수 없다.
정답 : ○
2. 보험사기에서 보험금의 지급을 청구한 때 실행의 착수가 인정된다.
정답 : ○
3. 착오에 빠진 원인 중 피기망자 측의 과실이 있는 경우에는 사기죄가 성립하지 않는다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

사기죄에서 피기망자는 재산상의 피해자와 반드시 일치해야 한다.

[정답] X

[해설] 피기망자는 재산상의 피해자와 반드시 일치해야 할 필요는 없다.

♣ 강의내용

Ⅰ. 착오의 유발

1. 기망의 정도

(1) 의의

단순히 상대방에게 착오를 일으키게 한 것만으로는 기망이 아니고, 적어도 그것이 거래관계에 있어서 신의칙에 반하는 정도에 이르러야 한다. 따라서 기망에 의한 착오가 있는 경우에도 그로 인하여 거래의 목적을 달성하는데 지장이 없는 경우에는 사기죄의 기망이 있다고 할 수 없다.

(2) 내용

- ① 예컨대 甲이 절도범인으로부터 그 정을 알면서 자기앞수표를 취득하여 이를 음식대금으로 지급하고 거스름돈을 받은 경우 장물취득죄 외에 사기죄는 성립하지 아니한다.
- ② 또는 절취한 丙의 손가방 안에 들어 있는 자기앞수표 10만원권 1장을 발견한 乙은 그 자기앞수표를 5만원 상당의 생필품대금으로 교부하고, 5만원을 거스름돈으로 받은 경우 乙에게는 절도죄만 성립하고, 사기죄는 성립하지 아니한다.
- ③ 왜냐하면 자기앞수표는 그 액면금을 즉시 지급받을 수 있는 등 현금에 대신하는 기능을 가지고 거래상 현금과 동일하게 취급되고 있는 점에서 금전의 경우와 동일하게 보아야 하므로 (대판 2000.3.10. 98도2579) 자기앞수표를 음식대금으로 지급하거나 생필품대금으로 지급한 경우 이를 선의로 취득한 자는 어떠한 불이익도 당하지 아니하므로 거래의 목적을 달성하는데 어떠한 지장이 있을 수 없어서 사기죄의 기망을 인정할 수 없기 때문이다.

판례 (대판 1990.11.13. 90도1961) *

명의수탁자가 신탁받은 부동산을 매각한 경우에도 매수인은 유효하게 소유권을 취득하므로 매수인에 대한 관계에서 사기죄가 성립하지 않는다.

판례 (대판 2012.1.26. 2011도15179) 司57

부동산의 이중매매에 있어서 매도인이 제1의 매매계약을 일방적으로 해제할 수 없는 처지에 있었다는 사정만으로는, 바로 제2의 매매계약의 효력이나 그 매매계약에 따르는 채무이행, 또는 제2의 매수인의 매매목적물에 대한 권리의 실현에 장애가 된다고도 볼 수 없는 것이므로 매도인이 제2의 매수인에게 그와 같은 사정을 고지하지 아니하였다고 하여 제2의 매수인을 기망한 것이라고 할 수 없다.

2. 사기죄의 실행의 착수시기

- ① 실행의 착수시기는 사기의 고의로 기망행위를 개시한 때이다. 이 때 기망행위로 인하여 상대방이 착오에 빠졌는지의 여부는 의미가 없다. 단순히 기망을 위한 수단을 준비하는 정도로는 아직 실행의 착수가 인정되지 않는다.
- ② 예컨대 화재보험금을 편취하기 위하여 피보험대상물인 자기 집에 방화하는 경우나 상해보험금을 수령하기 위하여 자해행위를 하는 경우는 아직 사기의 예비단계에 불과하다. 보험금은 지급을 청구한 때 실행의 착수가 인정된다. 辯4

판례 (대판 2013.11.14. 2013도7494)

타인의 사망을 보험사고로 하는 생명보험계약을 체결함에 있어 제3자가 피보험자인 것처럼 가장하여 체결하는 등으로 그 유효 요건이 갖추어지지 못한 경우에도, 그 보험계약 체결 당시에 이미 보험사고가 발생하였음에도 이를 숨겼다거나 보험사고의 구체적 발생 가능성을 예견할 만한 사정을 인식하고 있었던 경우 또는 고의로 보험사고를 일으키려는 의도를 가지고 보험계약을 체결한 경우와 같이 보험사고의 우연성과 같은 보험의 본질을 해칠 정도라고 볼 수 있는 특별한 사정이 없는 한, 그와 같이 하자 있는 보험계약을 체결한 행위만으로는 미필적으로라도 보험금을 편취하려는 의사에 의한 기망행위의 실행에 착수한 것으로 볼 것은 아니다. 그러므로 그와 같이 기망행위의 실행의 착수로 인정할 수 없는 경우에 피보험자 본인임을 가장하는 등으로 보험계약을 체결한 행위는 단지 장차의 보험금 편취를 위한 예비행위에 지나지 않는다.

3. 착오의 유발

(1) 의의

행위자의 기망으로 인하여 피기망자에게 착오가 유발되어야 한다. 즉 행위자가 고지한 내용이 객관적 사실과 부합하지 않음에도 불구하고 피기망자는 객관적 사실인 것으로 오인해야 한다.

(2) 기망의 상대방 - 피기망자

기망의 상대방은 착오에 빠질 수 있는 능력이 있는 타인으로서 사기광고와 같은 불특정인도 그 대상이 된다. 그리고 피기망자는 재산적 처분능력이 있는 자이어야 하므로 유아·심신상실자는 제외된다. 다만 기계에 대한 기망과 관련하여 기계는 주어진 사실에 따라 피동적으로 작동할 뿐이고 착오에 빠질 수 없기 때문에 기망행위의 대상이 될 수 없다. 따라서 기계에 대한 기망은 있을 수 없다. → 타인의 일반전화를 무단 이용하여 전화통화를 한 경우, 사기죄가 성립하지 않는다(대판 1999.6.25. 98도3891).

그리고 착오에 빠진 원인 중에 피기망자 측의 과실이 있는 경우에도 사기죄가 성립한다(대판 2009.6.23. 2008도1697). 司52:55

II. 소송사기의 성립요건

1. 의의

피기망자는 재산상의 피해자와 반드시 일치해야 할 필요는 없다(삼각사기). 그 전형적인 예가 바로 소송사기의 경우이다. 소송사기는 법원에 허위의 사실을 주장하거나 허위의 증거를 제출함으로써 법원을 기망하여 승소판결을 받는 경우를 말한다. 이 경우 피해자는 소송의 상대방이지만 피기망자는 법원이 된다. 결국 소송사기에 있어서 피기망자는 법원이고 피해자는 소송의 상대방이므로 전형적인 삼각사기의 일종이다.

2. 행위주체

원고뿐만 아니라 피고도 가능하다. 예컨대 허위내용의 서류를 작성하여 증거로 제출하는 등 적극적인 사술을 사용하여 응소함으로써 자신의 재산상의 의무이행을 면하게 된 경우에도 사기죄가 성립한다(판례).

판례 (대판 1987.9.22, 87도1090)

司38·41·44

적극적 소송당사자인 원고가 아니라 방어적인 위치에 있는 피고라 하더라도 허위내용의 서류를 작성하여 이를 증거로 제출하거나 위증을 시키는 등의 적극적인 방법으로 법원을 기망하여 착오에 빠지게

한 결과 승소확정판결을 받음으로써 자기의 재산상의 의무이행을 면하게 된 경우에는 그 재산가액 상당에 대하여 사기죄가 성립한다.

3. 기망행위 - 적극적 사술의 사용

소송사기가 인정되기 위해서는 소송에서 주장하는 권리가 없다는 사실을 알면서도 적극적인 사술을 사용하여 허위의 주장과 입증으로 법원을 기망한다는 인식을 가지고 있어야 한다(대판 1988.9.20. 87도964). 따라서 허위의 채권으로 지급명령을 신청하여 가집행선고부지급명령을 발부 받아서 채권압류 및 전부명령을 받은 경우에도 사기죄가 성립한다.

판례 (대판 2011.9.8. 2011도7262)

소송사기는 법원을 기망하여 제3자의 재물을 편취할 것을 기도하는 것을 내용으로 하는 것으로서, 사기죄로 인정하기 위하여는 제소 당시 그 주장과 같은 권리가 존재하지 않는다는 것만으로는 부족하고, 그 주장의 권리가 존재하지 않는 사실을 잘 알고 있으면서도 허위의 주장과 입증으로 법원을 기망한다는 인식을 요한다. 그러나 허위의 내용으로 소송을 제기하여 법원을 기망한다는 고의가 있는 경우에 법원을 기망하는 것은 반드시 허위의 증거를 이용하지 않더라도 당사자의 주장이 법원을 기망하기에 충분한 것이라면 기망수단이 된다.

4. 처분행위 - 사자 혹은 허무인을 상대로 한 경우

(1) 문제점

소송사기에 있어서 피기망자인 법원의 재판은 피해자의 처분행위에 갈음하는 내용과 효력이 있는 것이어야 하고 그렇지 않으면 사기죄가 성립하지 않는다. 다만 문제가 되는 것은 사자 혹은 허무인을 상대로 하여 소를 제기하여 승소판결을 받은 경우에도 재산적 처분행위를 인정하여 사기죄의 성립을 인정할 것인가이다.

(2) 판례 - 무죄설

소송사기에 있어서 피기망자인 법원의 재판은 피해자의 처분행위에 갈음하는 내용과 효력이 있는 것이어야 하고 그렇지 않으면 사기죄가 성립하지 않는다. 따라서 사자나 허무인에 대해서는 판결의 내용에 따른 효력이 발생하지 않으므로 사기죄가 성립하지 않는다.

판례 (대판 2002.1.11, 2000도1881) 辯4 司41・44・46・49・57

피고인의 제소가 사망한 자를 상대로 한 것이라면 이와 같은 사망한 자에 대한 판결은 그 내용에 따른 효력이 생기지 아니하여 상속인에게 그 효력이 미치지 아니하고 따라서 사기죄를 구성한다고 할 수 없다.

판례 (대판 1992.12.11, 92도743) 司42

실재하고 있지 아니한 자에 대하여 판결이 선고되더라도 그 판결은 피해자의 처분행위에 갈음하는 내용과 효력을 인정할 수 없고, 따라서 착오에 의한 재물의 교부행위를 상정할 수 없는 것이므로 사기죄의 성립을 시인할 수 없다.

III. 소송사기의 실행의 착수시기

1. 원고인 경우

사기의 고의로 訴를 제기했을 때이다.

2. 피고인 경우

응소했을 때이다.

판례 (대판 1998.2.27, 97도2786)

司41·44

방어적인 위치에 있는 피고라 하더라도 적극적인 방법으로 법원을 기망할 의사를 가지고 허위내용의 서류를 증거로 제출하거나 그에 따른 주장을 담은 답변서나 준비서면을 제출한 경우에 사기죄의 실행의 착수가 있다.

3. 기수시기

소송사기의 경우 그 기수시기는 소송의 승소판결이 확정된 때이다.

판례 (대판 2006.4.7. 2005도9858. 전원합의체판결) 司49·50·54

피고인 또는 그와 공모한 자가 자신이 토지의 소유자라고 허위의 주장을 하면서 소유권보존등기 명의자를 상대로 보존등기의 말소를 구하는 소송을 제기한 경우 그 소송에서 위 토지가 피고인 또는 그와 공모한 자의 소유임을 인정하여 보존등기 말소를 명하는 내용의 승소확정판결을 받는다면, 이에 더 잡아 언제든지 단독으로 상대방의 소유권보존등기를 말소시킨 후 위 판결을 부동산등기법 제130조 제2호 소정의 소유권을 증명하는 판결로 하여 자기 앞으로의 소유권보존등기를 신청하여 그 등기를 마칠 수 있게 되므로, 이는 법원을 기망하여 유리한 판결을 얻음으로써 ‘대상 토지의 소유권에 대한 방해를 제거하고 그 소유명의를 얻을 수 있는 지위’라는 재산상 이익을 취득한 것이어서 사기죄에 해당하고, 그 경우 기수 시기는 위 판결이 확정된 때이다. → 사기죄의 기수를 인정함.

4. 관련 판례

판례 (대판 1982.10.26. 82도1529)

辯3 司43

가압류·가처분은 강제집행의 보전방법에 불과하고 그 기초가 되는 허위의 채권에 의하여 실제로 청구의 의사표시를 한 것이라고 할 수 없으므로 소의 제기 없이 가압류신청을 한 것만으로는 사기죄의 실행에 착수한 것이라고 할 수 없다.

판례 (대판 1999.4.9. 99도364) 司42·43·46·51

가계수표발행인이 자기가 발행한 가계수표를 타인이 교부받아 소지하고 있는 사실을 알면서도, 또한 그 수표가 적법히 지급 제시되어 수표상의 소구의무를 부담하고 있음에도 불구하고 허위의 분실사유를 들어 공시최고 신청을 하고 이에 따라 법원으로부터 제권판결을 받음으로써 수표상의 채무를 면하여 그 수표금 상당의 재산상 이익을 취득하였다면 이러한 행위는 사기죄에 해당한다.

♣ 확인학습문제

1. 甲은 A 토지에 대하여 자신이 토지의 소유자라고 허위의 주장을 하면서 소유권보존등기 명의자 乙을 상대로 보존등기의 말소를 구하는 소송을 제기하여 승소의 확정판결을 받았다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 공무집행방해죄
- ② 사기죄의 불능미수
- ③ 사기죄의 미수
- ④ 사기죄
- ⑤ 무죄

[정답] ④

[해설] 이는 법원을 기망하여 유리한 판결을 얻음으로써 ‘대상 토지의 소유권에 대한 방해’를 제거하고 그 소유명의를 얻을 수 있는 지위’라는 재산상 이익을 취득한 것이고, 그 경우 기수시기는 위 판결이 확정된 때이다(대판 2006.4.7. 2005도9858 전원합의체).

2. 甲이 A회사에는 상조회가 구성되어 있지 아니함에도 자동차사고 발생시 사고로 인한 손해를 보상하여 주기로 하는 상조회가 설치되어 있다 하여 A 회사와 그 회사 상조회에 대하여 연대하여 금 12,100,000원의 지급을 구하는 소장을 수원지방법원에 제출하여 위 법원을 기망하여 승소판결을 선고받아 위 금액을 편취하려 한 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 사기죄
- ③ 사기죄의 미수
- ④ 사기죄의 불능미수
- ⑤ 공무집행방해죄

[정답] ①

[해설] 실재하고 있지 아니한 자에 대하여 판결이 선고되더라도 그 판결은 피해자의 처분행위에 갈음하는 내용과 효력을 인정할 수 없고, 따라서 착오에 의한 재물의 교부행위를 상정할 수 없는 것이므로 사기죄의 성립을 시인할 수 없다(대판 1992.12.11. 92도743).

3. 다음 중 기수, 미수를 불문하고 사기죄가 성립하는 경우가 아닌 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 자신이 발행한 가계수표를 타인이 소지하고 있는 것을 알면서 허위의 분실사유를 들어 공시최고 신청을 하여 법원으로부터 제권판결을 받은 경우
- ② 방어적인 위치에 있는 피고가 응소하여 적극적인 방법으로 법원을 기망하여 착오에 빠지게 한 결과 승소확정판결을 받은 경우
- ③ 허위채권으로 가압류를 신청한 경우
- ④ 법원에 허위사실을 주장하여 법원을 기망하고 승소판결을 받은 경우
- ⑤ 화재보험에 가입하고 자신의 집에 불을 지른 다음 보험금의 지급을 청구한 경우

[정답] ③

[해설] 訴의 제기 없이 가압류신청을 한 것만으로는 사기죄의 실행에 착수한 것이라고 할 수 없다(대판 1982.10.26. 82도1529).

♣ 학습내용 정리

1. 사기죄의 기망은 단순히 상대방에게 착오를 일으키게 한 것만으로는 기망이 아니고, 적어도 그것이 거래관계에 있어서 신의칙에 반하는 정도에 이르러야 한다.
2. 사자나 허무인에 대해서는 판결의 내용에 따른 효력이 발생하지 아니하므로 설사 승소의 확정판결을 받더라도 사기죄가 성립하지 않는다.
3. 소송사기의 경우 그 기수시기는 소송의 승소판결이 확정된 때이다.

제21강 재산적 처분행위와 재산상 손해발생

♣ 학습목표

- 사기죄에서 재산적 처분행위에 대하여 설명할 수 있다.
- 재산상 손해발생이 사기죄의 성립요건이 되는지를 설명할 수 있다.
- 불법원인급여와 사기죄의 법리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 재산적 처분행위
- 재산상 손해발생
- 재산상 손해발생의 위험성
- 불법원인급여와 사기죄

♣ 사전테스트

1. 처분행위는 부작위에 의해서도 이루어질 수 있다.
정답 : O
2. 구청에서 소독하러 나왔다고 기망하고 주거에 들어가서 몰래 재물을 훔친 경우 사기죄가 성립한다.
정답 : X
3. 처분행위가 성립하기 위해서는 처분행위자와 피기망자는 동일인이어야 하지만, 처분행위자와 피해자는 일치할 필요가 없다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

절도물인 줄 모르고 구입한 경우에도 사기죄가 성립할 수 있다.

[정답] O

[해설] 절도물인 줄 모르고 구입한 경우와 같이 재산상태가 악화되었다고 볼 수 있는 재산 가치에 대한 구체적 위험만으로도 재산상의 손해를 인정할 수 있다.

♣ 강의내용

1. 재산적 처분행위

1. 의의

사기죄가 성립하기 위해서는 피기망자의 재산처분행위가 존재하여야 한다. 여기서 재산처분행위란 비록 하자가 있는 것이긴 하지만 자유의사로 직접 재산손해를 초래하는 작위행위를 하거나 또는 방치하는 행위(부작위)를 하는 것을 말한다.

2. 재산처분행위의 태양

처분행위는 재물사기죄의 경우에는 재물에 대한 사실상의 점유이전을 뜻하는 교부행위, 이득사기죄의 경우에는 처분행위가 있어야 한다.

그리고 재산처분행위는 모든 형태의 작위행위로 이루어질 수 있으며, 작위행위는 법률행위(ex. 계약체결)나 사실행위(ex. 물건의 인도, 노동의 제공)를 포괄한다. 법률행위인 경우에는 유효·무효 또는 취소여부를 묻지 않는다. 또한 처분행위는 부작위에 의해서도 이루어질 수 있다. 즉 기망당한 자가 할 수 있는 것을 하지 않고 내버려두는 방치행위로서도 가능하다(ex. 청구권의 불행사).

3. 처분행위의 내용 - 재산손해발생의 직접성

재산처분행위는 피기망자 스스로 직접 재산손해를 발생시키는 것이어야 한다(처분효과의 직접성). 그러므로 처분행위가 직접 재물의 교부를 야기한 때, 즉 행위자의 다른 추가적 행위가 없어도 손해가 발생한 경우에 인정된다. 만일 재산처분행위와 손해발생 사이에 제3의 행위가 개입된 간접적인 경우에는 외견상 재산처분행위가 있어도 절도죄(책략절도)가 성립한다. ex) 구청에서 소독하러 나왔다고 기망하여 주거에 들어가서 몰래 재물을 훔친 경우, 백화점 옷 코너에서 구입을 가장하여 옷을 갈아입은 후 주인이 한 눈을 파는 사이 몰래 도망가는 경우

판례 (대판 1994.8.12. 94도1487)

辯2 司44

피고인이 피해자 경영의 금방에서 마치 귀금속을 구입할 것처럼 가장하여 피해자로부터 순금목걸이 등을 건네받은 다음 화장실에 갔다 오겠다는 핑계를 대고 도주한 것이라면 위 순금목걸이 등은 도주하기 전까지는 아직 피해자의 점유 하에 있었다고 할 것이므로 이를 절도죄로 의율 차단한 것은 정당하다.

4. 처분행위자

처분행위가 성립하기 위해서는 처분행위자와 피기망자는 동일인이어야 하지만, 처분행위자와 피해자는 일치할 필요가 없다(삼각사기). 다만 삼각사기에서 기망당해 재산을 처분한 사람은 그로 인해 피해를 입는 사람(재산피해자)에 대한 관계에서 재산처분권이 있어야 한다.

판례 (대판 1994.10.11. 94도1575)

辯1 司46

사기죄가 성립되려면 피기망자와 재산상의 피해자가 같은 사람이 아닌 경우에는 피기망자가 피해자를 위하여 그 재산을 처분할 수 있는 권능을 갖거나 그 지위에 있어야 하지만, 여기에서 피해자를 위하여 재산을 처분할 수 있는 권능이나 지위라 함은 반드시 사법상의 위임이나 대리권의 범위와 일치하여야 하는 것은 아니고 피해자의 의사에 기하여 재산을 처분할 수 있는 서류 등이 교부된 경우에는 피기망자의 처분행위가 설사 피해자의 진정한 의도와 어긋나는 경우라고 할지라도 위와 같은 권능을 갖거나 그 지위에 있는 것으로 보아야 한다.

II. 재산상 손해발생

1. 현실적 손해발생 요부

사기죄가 성립하기 위해서는 기망당한 자의 재산처분행위로 자기 또는 제3자에게 손해가 발생해야 하는가가 문제되는바, 판례는 손해불요설을 취한다. 가령 피해자에게 상당한 대가를 제공한 경우 손해불요설에 의하면 피해자에게 상당한 대가를 제공한다고 하더라도 사기죄가 된다.

판례 (대판 2005.4.29. 2002도7262) **司52**

사기죄는 상대방을 기망하여 하자 있는 상대방의 의사에 의하여 재물을 교부받음으로써 성립하는 것이므로 분석회계에 의한 재무제표 등으로 금융기관을 기망하여 대출을 받았다면 사기죄는 성립하고, 변제의사와 변제능력의 유무 그리고 충분한 담보가 제공되었다거나 피해자의 전체 재산상에 손해가 없고, 사후에 대출금이 상환되었다고 하더라도 사기죄의 성립에는 영향이 없다.

판례 (대판 1983.4.26. 82도3088) *

금융기관의 대출이나 신용보증기금의 신용보증서 발급이 기망행위에 의하여 이루어진 이상 그로써 곧 사기죄는 성립하는 것이고, 담보권을 취득했다 하더라도 담보권이 손해를 정산하지 못한다.

2. 재산상 손해발생의 위험

손해발생의 위험도 재산상의 손해로 인정될 수 있는가 하는 것이 문제된다. 예컨대 절도물인 줄 모르고 구입한 경우, 지불능력 없는 자와 금전대여계약을 체결한 경우와 같이 재산상태가 악화되었다고 볼 수 있는 재산가치에 대한 구체적 위험만으로도 재산상의 손해를 인정할 수 있다.

3. 손해의 발생시기 - 기수시기의 문제

(1) 원칙

재산상의 손해가 발생한 때 또는 손해발생의 구체적 위험이 있는 때가 사기죄의 기수시기가 된다. 반드시 행위자가 불법한 이익을 취득하였을 것을 요하지 않는다.

(2) 동산사기

동산사기는 인도·교부시에 기수가 된다. 다만 사기죄에 있어서 재물의 교부가 있었다고 하기 위하여 반드시 재물의 현실적인 인도가 필요한 것은 아니며, 재물이 범인의 사실상의 지배 아래에 들어가 그의 자유로운 처분이 가능한 상태에 놓인 경우에도 재물의 교부가 인정된다(대판 2003.5.16. 2001도1825). **司46**

(3) 부동산사기

부동산사기의 기수시기는 부동산에 대한 권리이전의 의사표시가 있는 것으로 족하지 않고, 현실적으로 점유의 이전이 있거나 소유권이전등기가 경료된 때이다. 권리이전의 의사표시만으로는 기망행위로 인한 재산상 손해가 발생하였다고 볼 수 없기 때문이다.

4. 재산상 이익의 취득

재산상 이익이란 일체의 재산상태를 보다 유리하게 형성하는 것, 즉 재산의 경제적 가치의 증가를 말한다. 사기죄에 있어서 재산상 이익, 즉 편취액은 그 대가가 일부 지급된 경우에도 피해

자로부터 교부된 재물의 가치로부터 그 대가를 공제한 차액이 아니라 교부받은 재물 전부가 된다(대판 2000.7.7. 2000도1899).

<재산상 이익의 취득을 인정한 판례>

- ① 부동산가압류결정을 받아 부동산에 관한 가압류집행까지 마친 자가 그 가압류를 해제하면 소유자는 가압류의 부담이 없는 부동산을 소유하는 이익을 얻게 되므로, 가압류를 해제하는 것 역시 사기죄에서 말하는 재산적 처분행위에 해당하고, 그 이후 가압류의 피보전채권이 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다고 하더라도 가압류의 해제로 인한 재산상의 이익이 없었다고 할 수 없다(대판 2007.9.20. 2007도5507). 司52·56
- ② 채무자의 기망행위로 인하여 채권자가 채무를 확정적으로 소멸 내지 면제시키는 특약 등 처분행위를 한 경우에는 채무의 면제라고 하는 재산상 이익에 관한 사기죄가 성립하고, 후에 재산적 처분행위가 사기를 이유로 민법에 따라 취소될 수 있다고 하여 달리 볼 것은 아니다. 그러므로 피고인이 피해자들을 기망하여 부동산을 매도하면서 매매대금 중 일부를 피해자들의 피고인에 대한 기존 채권과 상계하는 방법으로 지급받아 채무 소멸의 재산상 이익을 취득하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 피고인이 상계에 의하여 기존 채무가 소멸되는 재산상 이익을 취득하였다고 보아 사기죄를 인정한 원심판단은 정당하다(대판 2012.4.13. 2012도1101). 司57

5. 제3자를 위한 영득행위

형법 제347조 제2항은 제3자를 위한 사기 영득행위를 명문으로 규정하고 있다.

판례 (대판 2009.1.30. 2008도9985) 辯1 司53·55

[1] 범인이 기망행위에 의해 스스로 재물을 취득하지 않고 제3자로 하여금 재물의 교부를 받게 한 경우에 사기죄가 성립하려면, 그 제3자가 범인과 사이에 정을 모르는 도구 또는 범인의 이익을 위해 행동하는 대리인의 관계에 있거나, 그렇지 않다면 적어도 불법영득의사와의 관련상 범인에게 그 제3자로 하여금 재물을 취득하게 할 의사가 있어야 한다. 위와 같은 의사는 반드시 적극적 의욕이나 확정적 인식이어야 하는 것은 아니고 미필적 인식이 있으면 충분하며, 그 의사가 있는지 여부는 범인과 그 제3자 및 피해자 사이의 관계, 기망행위 혹은 편취행위의 동기, 경위와 수단·방법, 그 행위의 내용과 태양 및 당시의 거래관행 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다. 한편, 재물 편취를 내용으로 하는 사기죄에 있어서는 기망으로 인한 재물교부가 있으면 그 자체로써 피해자의 재산 침해가 되어 곧 사기죄는 성립하는 것이고, 그로 인한 이익이 결과적으로 누구에게 귀속하는지는 사기죄의 성부에 아무런 영향이 없다. [2] 甲이 乙에게 이중매도한 택지분양권을 순차 매수한 丙·丁에게 이중매도 사실을 숨긴 채 자신의 명의로 형식적인 매매계약서를 작성해 준 사안에서, 甲이 직접 매매대금을 수령하지 않았더라도 丙·丁에 대한 사기죄가 성립한다.

III. 불법원인급여와 사기죄

1. 문제점

예컨대 도박자금이나 통화위조자금을 편취하거나 공무원에게 뇌물로 공여할 재물을 편취한 경우 또는 윤락여성이 정교의 대가로 매음료를 받고도 정교를 거절한 경우와 같은 불법원인급여와 사기죄의 문제는 사람을 기망하여 반환청구권이 없는 불법한 급여를 하게 한 경우에도 재산상 손해발생을 인정하여 사기죄의 성립을 인정할 것인가의 문제이다.

2. 학설의 태도 - 긍정설

사람을 기망하여 불법원인급여를 하게 한 때에는 불법원인이 수익자에게만 있는 경우에 해당하여 민법 제746조 단서에 의해 급여자가 목적물의 반환을 청구할 수 있을 뿐만 아니라 교부된 재물 자체에는 불법성이 없기 때문에 법적 보호밖에 있다고 할 수 없고 기망행위에 의해 피해자의 경제적 가치에 손해를 입힌 것은 부정할 수 없으므로 사기죄가 성립한다.

3. 판례 - 긍정설

판례 도박자금 편취사건(대판 2006.11.23. 2006도6795)

辯2 司51

[판결요지] 민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다고 할 것인바(대판 1995.9.15. 95도707), 피고인이 피해자로부터 도박자금으로 사용하기 위하여 금원을 차용하였다라도 사기죄의 성립에는 영향이 없다.

[판례해설] 대법원은 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여를 하게 하였다는 점을 판결요지에서 제시하면서도 이 경우 민법 제746조에 의하여 급여자에게 반환청구권의 행사를 부정함으로써 동조 단서의 적용을 배제하고 있다. 다만 대법원은 경제적 재산설에 의하여 사기죄의 성립을 인정하고 있다. 그러나 수익자에게 편취행위가 명백히 인정되는 만큼 민법 제746조 단서를 적용하여 반환청구를 허용함으로써 사기죄의 성립을 인정하는 방법이 무방하다고 생각된다. 이러한 취지는 아래에서 언급되는 민사하급심에서도 그 취지가 자세하게 나타나 있다.

판례 매음료 면탈사건(대판 2001.10.23. 2001도2991)

司45 · 52

일반적으로 부녀와의 성행위 자체는 경제적으로 평가할 수 없고, 부녀가 상대방으로부터 금품이나 재산상 이익을 받을 것을 약속하고 성행위를 하는 약속 자체는 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위로서 무효이나, 사기죄의 객체가 되는 재산상의 이익이 반드시 사법(私法)상 보호되는 경제적 이익만을 의미하지 아니하고, 부녀가 금품 등을 받을 것을 전제로 성행위를 하는 경우 그 행위의 대가는 사기죄의 객체인 경제적 이익에 해당하므로, 부녀를 기망하여 성행위 대가의 지급을 면하는 경우 사기죄가 성립한다.

4. 결론

민법은 제746조에서 불법원인급여의 반환청구를 원칙적으로 금지하고 있다. 그러나 동조 단서에서는 불법원인이 수익자에게만 있는 경우에는 예외적으로 반환청구를 허용하고 있다. 이때 민법이 예외적으로 반환청구를 인정하여 정의를 실현시키고자 하는 취지를 충분히 고려하여 제746조 단서는 불법원인이 급여자에게는 전혀 없고 수익자에게만 있는 경우뿐만 아니라 급여자에게 다소 불법성이 있다고 하여도 그것이 미미한 정도에 그친 때에도 적용하는 것이 바람직하다. 결론적으로 긍정설이 타당하고, 불법원인급여에 대해서도 사기죄가 성립한다.

예컨대 甲이 乙에게 乙과 원한관계에 있는 丙을 납치하여 살해할 준비를 하는 비용을 달라고 거짓말을 하여 금품을 교부받았을 경우 이는 불법원인이 수익자인 甲에게만 있는 경우이므로 급여자인 乙은 자신이 甲에게 제공한 금품에 대하여 반환청구권을 상실하지 않는다. 따라서 甲은 사기죄의 죄책을 진다.

♣ 확인학습문제

1. 다음의 사기죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사기죄의 성립요건으로서 재산상 손해의 발생이 필요한가에 대하여 판례는 이를 부정한다.
- ② 출판사 경영자가 출고현황표를 조작하는 방법으로 실제출판부수를 속여 작가에게 인세의 일부만을 지급한 경우 부작위에 의한 처분행위가 인정되므로 사기죄가 성립한다.
- ③ 기망행위를 통해 스스로 재물을 취득하지 않고 제3자에게 재물을 교부받게 한 경우에도 사기죄가 성립한다.
- ④ 사기죄에 있어서 그 대가가 일부 지급된 경우 그 편취액은 피해자로부터 교부받은 재물 전부가 아니라 교부된 재물의 가치로부터 그 대가를 공제한 차액이다.
- ⑤ 금품 등을 받을 것을 전제로 성행위에 응한 부녀를 기망하여 성행위 대가의 지급을 면한 경우 사기죄가 성립한다.

[정답] ④

[해설] 편취액은 그 대가가 일부 지급된 경우에도 피해자로부터 교부된 재물의 가치로부터 그 대가를 공제한 차액이 아니라 교부받은 재물 전부가 된다(대판 2000.7.7. 2000도1899).

2. 대출자격요건을 갖추지 못한 甲은 A 은행 대출담당 직원 乙을 기망하여 거액의 대출을 받았으나 A 은행으로서는 대출금에 상당하는 담보권을 甲으로부터 설정받았다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 사기죄
- ③ 사기죄의 미수
- ④ 사기죄의 불능미수
- ⑤ 업무방해죄

[정답] ②

[해설] 금융기관의 대출이나 신용보증기금의 신용보증서 발급이 기망행위에 의하여 이루어진 이상 그로써 곧 사기죄는 성립하는 것이고, 담보권의 설정이 있었다 하여 결론을 달리하는 바는 아니다(대판 1983.4.26. 82도3088).

3. 甲이 실제로는 살인할 의도가 전혀 없으면서도 乙에게 乙과 원한관계에 있는 丙을 납치하여 죽여주겠으니 살해할 준비를 하는 비용을 달라고 기망을 하여 금품을 교부받았을 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 사기죄의 미수
- ③ 사기죄
- ④ 공갈죄
- ⑤ 살인예비죄

[정답] ③

[해설] 민법 제746조의 불법원인급여에 해당하여 급여자가 수익자에 대한 반환청구권을 행사할 수 없다고 하더라도, 수익자가 기망을 통하여 급여자로 하여금 불법원인급여에 해당하는 재물을 제공하도록 하였다면 사기죄가 성립한다(대판 2006.11.23. 2006도6795).

♣ 학습내용 정리

1. 사기죄가 성립하기 위해서는 피기망자의 재산처분행위가 존재하여야 한다.
2. 삼각사기에서 기망당해 재산을 처분한 사람은 그로 인해 피해를 입는 사람(재산피해자)에 대한 관계에서 재산처분권이 있어야 한다.
3. 재산상태가 악화되었다고 볼 수 있는 재산가치에 대한 구체적 위험만으로도 재산상의 손해를 인정할 수 있다.
4. 형법 제347조 제2항은 제3자를 위한 사기 영득행위를 명문으로 규정하고 있다.

제23강 신용카드범죄

♣ 학습목표

자기명의의 신용카드를 부정사용한 행위의 죄책을 설명할 수 있다.

탈취한 타인명의의 신용카드를 부정사용한 행위의 법리를 설명할 수 있다.

타인의 신용카드를 편취하여 이를 부정사용한 행위를 죄책을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

자기명의의 신용카드

타인명의의 신용카드

신용카드부정사용

신용카드에 대한 탈취죄와 편취죄

♣ 사전테스트

1. 타인의 신용카드를 절취하여 물건을 구입한 경우에도 신용카드부정사용죄가 성립한다.

정답 : O

2. 신용카드를 절취한 후 이를 사용한 경우 신용카드의 부정사용행위는 절도범행의 불가벌적 사후행위가 된다.

정답 : X

3. 타인을 기망하여 그의 신용카드를 취득한 다음 그 카드를 사용하여 현금을 인출한 경우 별도로 절도죄는 성립하지 않지만, 횡령죄가 성립한다.

정답 : X

♣ 돌발퀴즈

절취한 타인의 신용카드의 현금카드기능을 사용하여 예금을 인출한 경우 신용카드부정사용죄가 성립한다.

[정답] X

[해설] 신용카드의 본래의 용법인 신용공여기능에 따른 사용이 아니므로 본죄의 성립이 부정된다(대판 2003.11.14. 2003도3977).

♣ 강의내용

I. 자기명의 신용카드와 관련된 범죄

대금결제의 의사나 능력이 없음에도 불구하고 신용카드를 발급 받아 물품을 구입하고 현금자동인출기에서 현금을 인출한 경우의 죄책이 문제된다.

1. 신용카드부정사용죄의 성부

자기의 신용카드의 경우 위조, 변조 또는 그에 따른 사용행위가 아니라면 본죄는 성립하지 않는다(여신전문금융업법 제70조 제1항). 司52

2. 결제의사 없이 물품을 구입하거나 현금을 인출한 행위 - 사기죄의 포괄일죄

판례 (대판 1996.4.9. 95도2466) 司44·45·50·52

피고인이 카드사용으로 인한 대금 결제의 의사와 능력이 없으면서도 있는 것 같이 가장하여 카드회사를 기망하고, 카드회사는 이에 착오를 일으켜 일정 한도 내에서 카드사용을 허용해 줌으로써 피고인은 기망 당한 카드회사의 신용공여라는 하자 있는 의사표시에 편승하여 자동지급기를 통한 현금대출도 받고, 가맹점을 통한 물품구입대금 대출도 받아 카드발급회사로 하여금 같은 액수 상당의 피해를 입게 함으로써, 카드사용으로 인한 일련의 편취행위가 포괄적으로 이루어지는 것이다. 따라서 카드사용으로 인한 카드회사의 손해는 그것이 자동지급기에 의한 인출행위이든 가맹점을 통한 물품 구입 행위이든 불문하고 모두가 피해자인 카드회사의 기망 당한 의사 표시에 따른 카드발급에 터 잡아 이루어지는 사기의 포괄일죄이다.

II. 탈취한 타인의 신용카드로 현금을 인출한 행위

1. 타인의 신용카드를 절취, 강취 횡령한 후 현금자동인출기에서 현금을 인출한 경우

(1) 신용카드부정사용죄(여신전문금융업법 제70조 제1항)의 성부

(가) 타인의 신용카드로 현금자동지급기를 통하여 현금서비스를 받은 경우

신용카드를 현금인출기에 주입하고 비밀번호를 조작하여 현금서비스를 제공받는 일련의 행위도 타인의 신용카드의 본래 용도에 따른 사용이므로 본죄가 성립한다(대판 1995.7.28. 95도997).

(나) 타인의 신용카드의 현금카드기능을 사용하여 예금을 인출한 경우

가령 甲이 乙의 신용카드를 절취한 다음 乙의 예금계좌에서 예금을 인출한 경우와 같이 신용카드를 절취한 자가 현금카드기능이 부가된 신용카드로 예금을 인출한 경우 신용카드의 '현금인출기능'만을 사용한 경우에도 '신용기능'을 부정하게 사용한 것으로 이해하여 신용카드부정사용죄가 성립할 것인가가 문제된다.

이에 대하여 판례(대판 2003.11.13. 2003도3977)는 단순한 현금인출을 위한 카드는 신용카드업자의 신용업무와는 관계없는 예금잔고 내에서의 현금인출기능만을 가진 것으로 신용카드의 본래적 용도에 해당한다고 할 수 없어서 신용카드의 부정사용에 포함시킬 수 없으므로 은행잔고 내에서의 단순한 현금인출행위의 경우에는 본죄의 성립이 부정된다는 입장이다.

(다) 타인의 신용카드를 무단으로 사용하여 현금을 인출하고 곧바로 돌려준 경우

신용카드부정사용죄가 성립한다는 것이 판례(대판 1999.7.9. 99도857)의 태도이다. 물론 신용카드 자체에 대해서는 불법영득의사가 없다고 보아 절도죄의 성립이 부정된다.

(2) 현금을 인출한 행위에 대한 죄책 - 절도죄 성립

절취한 신용카드를 이용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출한 경우, 현금자동지급기 관리자의 의사에 반하여 그의 지배를 배제하고 그 현금을 자기의 지배하에 옮겨 놓는 것이 되어 절도죄를 구성한다(대판 2008.6.12. 2008도2440). 辯4 司57

판례 (대판 2002.7.12. 2002도2134) 辯1 · 4 司46 · 50 · 55

타인의 명의를 모용하여 발급받은 신용카드를 사용하여 현금자동지급기에서 현금대출을 받는 행위는 카드회사에 의하여 미리 포괄적으로 허용된 행위가 아니라, 현금자동지급기의 관리자의 의사에 반하여 그의 지배를 배제한 채 그 현금을 자기의 지배 하에 옮겨 놓는 행위로서 절도죄에 해당한다고 봄이 상당하다.

판례 강취한 카드로 현금을 인출한 사건(대판 2007.5.10. 2007도1375) 辯4 司51 · 55

강도죄는 공갈죄와는 달리 피해자의 반항을 억압할 정도로 강력한 정도의 폭행·협박을 수단으로 재물을 탈취해야 성립하는 것이므로 피해자로부터 현금카드를 강취하였다고 인정되는 경우에는 피해자로부터 현금카드의 사용에 관한 승낙의 의사표시가 있었다고 볼 여지가 없다. 따라서 강취한 현금카드를 사용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출한 행위는 피해자의 승낙에 기한 것이라고 할 수 없으므로, 현금자동지급기 관리자의 의사에 반하여 그의 지배를 배제하고 그 현금을 자기의 지배하에 옮겨놓는 것이 되어서 강도죄와는 별도로 절도죄를 구성한다고 할 것이다.

(3) 죄수

(가) 절도와 신용카드부정사용죄

신용카드를 절취한 후 이를 사용한 경우 신용카드의 부정사용행위는 새로운 법익의 침해로 보아야 하고 그 법익침해가 절도범행보다 큰 것이 대부분이므로 위와 같은 부정사용행위가 절도범행의 불가벌적 사후행위가 되는 것은 아니다(대판 1996.7.12. 96도1181). 司52 · 54

(나) 신용카드부정사용죄의 포괄일죄

피고인이 동일한 신용카드를 수 차례에 걸쳐 부정사용한 행위는 포괄하여 일죄에 해당한다(대판 1996.7.12. 96도1181).

2. 타인의 신용카드를 절취, 강취, 횡령하여 물건을 구입한 경우

(1) 신용카드부정사용죄 성부

신용카드부정사용죄(여신전문금융업법 제70조 제1항)가 성립한다(통설, 판례).

(2) 신용카드만을 제시한 경우

판례 (대판 2008.2.14. 2007도8767) 司52 · 56

신용카드를 절취한 사람이 대금을 결제하기 위하여 신용카드를 제시하고 카드회사의 승인까지 받았다고 하더라도 매출전표에 서명한 사실이 없고 도난카드임이 밝혀져 최종적으로 매출취소로 거래가 종결되었다면, 신용카드 부정사용의 (불가벌적)미수행위에 불과하다.

(3) 사기죄의 성부

판례 (대판 1997. 1. 21. 96도2715) 司50・52・56

강취한 신용카드를 가지고 자신이 그 신용카드의 정당한 소지인인양 가맹점의 점주를 속이고 그에 속은 점주로부터 주류 등을 제공받아 이를 취득한 것이라면 신용카드부정사용죄와 별도로 사기죄가 성립한다.

(4) 신용카드부정사용죄와 사기죄의 관계

매출전표에 서명하여 교부하는 행위는 양죄의 보호법익이나 행위태양이 전혀 다르므로 실제적 경합관계가 된다(대판 1996.7.12. 96도1181). 司52

(5) 사문서위조 및 동행사죄의 성부

위 매출표의 서명 및 교부가 별도로 사문서위조 및 동행사의 죄의 구성요건을 충족한다고 하여도 이 사문서위조 및 동행사의 죄는 위 신용카드부정사용죄에 흡수되어 신용카드부정사용죄의 1죄만이 성립한다(대판 1992.6.9. 92도77). 辯4 司54

3. 타인의 명의를 모용하여 신용카드를 발급받은 다음 현금자동지급기에서 현금을 인출하거나 ARS 전화서비스 등으로 신용대출을 받은 경우

판례 ARS 전화서비스 대출사건(대판 2006.7.27. 2006도3126) 辯1・4 司55・56

[판결요지] [1] 피고인이 타인(이혼한 妻)의 명의를 모용하여 신용카드를 발급받은 경우, 비록 카드회사가 피고인으로부터 기망을 당한 나머지 피고인에게 피모용자 명의로 발급된 신용카드를 교부하고, 사실상 피고인이 지정한 비밀번호를 입력하여 현금자동지급기에 의한 현금대출(현금서비스)을 받을 수 있도록 하였다 할지라도, 카드회사의 내심의 의사는 물론 표시된 의사도 어디까지나 카드명의인인 피모용자에게 이를 허용하는 데 있을 뿐 피고인에게 이를 허용한 것은 아니라는 점에서, 피고인이 타인의 명의를 모용하여 발급받은 신용카드를 사용하여 현금자동지급기에서 현금대출을 받는 행위는 카드회사에 의하여 미리 포괄적으로 허용된 행위가 아니라, 현금자동지급기의 관리자의 의사에 반하여 그의 지배를 배제한 채 그 현금을 자기의 지배 하에 옮겨 놓는 행위로서 절도죄에 해당한다.

[2] 타인의 명의를 모용하여 발급받은 신용카드의 번호와 그 비밀번호를 이용하여 ARS 전화서비스나 인터넷 등을 통하여 신용대출을 받는 방법으로 재산상 이익을 취득하는 행위 역시 미리 포괄적으로 허용된 행위가 아닌 이상, 컴퓨터 등 정보처리장치에 권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상 이익을 취득하는 행위로서 컴퓨터 등 사용사기죄에 해당한다.

[3] 타인의 명의를 모용하여 발급받은 신용카드를 이용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출한 행위와 ARS 전화서비스 등으로 신용대출을 받은 행위를 포괄적으로 카드회사에 대한 사기죄가 된다고 판단한 원심판결을 파기한 사례.

III. 편취한 타인의 신용카드로 현금을 인출한 행위

1. 신용카드부정사용죄의 성부

기망, 갈취 등의 행위로 취득한 타인의 신용카드를 사용한 경우에는 여신전문금융업법 제70조 제1항 4호에서 신용카드 강취 등의 행위를 명백히 규정하고 있으므로 이들 행위도 당연히 신용카드부정사용죄를 구성한다.

2. 인출한 현금에 대한 절도죄의 성부

(1) 문제점

타인을 기망 또는 강박함으로써 타인의 신용카드를 편취하여 사기행위나 공갈행위를 한 다음 그 신용카드를 사용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출한 경우 신용카드에 대한 범죄가 편취죄이므로 비록 하자있는 의사표시이기는 하지만 피해자의 유효한 승낙에 기한 현금인출행위이므로 이것을 과연 절취행위라고 보아 별도로 절도죄가 성립하는지가 문제된다.

(2) 판례 - 부정설

판례 '가루로 만들어 버리겠다' 사건(대판 1996.9.20. 95도1728)

辯1·4 司43·46·50·55·56

예금주인 현금카드 소유자를 협박하여 그 카드를 갈취하였고, 하자있는 의사표시이기는 하지만 피해자의 승낙에 의하여 현금카드를 사용할 권한을 부여받아 이를 이용하여 현금을 인출한 이상, 피해자가 그 승낙의 의사표시를 취소하기까지는 현금카드를 적법, 유효하게 사용할 수 있고, 은행의 경우에도 피해자의 지급정지 신청이 없는 한 피해자의 의사에 따라 그의 계산으로 적법하게 예금을 지급할 수밖에 없는 것이므로, 피고인이 피해자로부터 현금카드를 사용한 예금인출의 승낙을 받고 현금카드를 교부받은 행위와 이를 사용하여 현금자동지급기에서 예금을 여러 번 인출한 행위들은 모두 피해자의 예금을 갈취하고자 하는 피고인의 단일하고 계속된 범의 아래에서 이루어진 일련의 행위로서 포괄하여 하나의 공갈죄를 구성한다고 볼 것이지, 현금지급기에서 피해자의 예금을 취득한 행위를 현금지급기 관리자의 의사에 반하여 그가 점유하고 있는 현금을 절취한 것이라 하여 이를 현금카드 갈취행위와 분리하여 따로 절도죄로 처단할 수는 없다.

판례 (대판 2005.9.30, 2005도5869)

司52

피고인이 현금카드의 소유자로부터 현금카드를 편취하여 예금인출의 승낙을 받고 현금카드를 교부받아 이를 이용하여 현금을 인출한 사안에서, 피고인의 현금 인출행위가 현금지급기 관리자의 의사에 반하여 그가 점유하고 있는 현금을 절취한 것에 해당한다거나 피고인이 인출된 현금의 보관자의 지위에 있는 것이 아니라는 이유로 절취의 주위적 공소사실과 횡령의 예비적 공소사실 모두에 대하여 무죄를 선고한 원심의 판단을 수긍한 사례.

3. 타인의 신용카드를 기망, 갈취하여 물품을 구입한 경우

신용카드를 편취할 때 이미 물품구입에 대한 피해자의 승낙이 있었으므로 물품구입행위는 피해자의 하자 있는 의사표시에 기한 편취행위에 포함된다고 보아야 한다. 이때에는 현금인출의 경우와 마찬가지로 사기죄나 공갈죄의 포괄일죄의 성부가 문제된다.

♣ 확인학습문제

1. 다음의 신용카드범죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 신용카드를 절취한 사람이 물품 대금의 결제를 위해 신용카드를 제시하고 카드회사의 승인까지 받았다고 하더라도 매출전표에 서명한 사실이 없고 도난카드임이 밝혀져 최종적으로 매출취소로 거래가 종결되었다면, 신용카드 부정사용의 불가벌적 미수행위에 불과하다.
- ② 타인의 명의를 모용하여 발급받은 신용카드의 번호와 그 비밀번호를 이용하여 ARS 전화서비스나 인터넷 등을 통하여 신용대출을 받는 방법으로 재산상 이익을 취득하는 행위는 컴퓨터 등 사용사기죄에 해당한다.
- ③ 타인의 명의를 모용하여 발급받은 신용카드를 이용하여 현금자동지급기에서 현금대출을 받는 경우에는 절도죄가 성립하지 않는다.

- ④ 타인의 신용카드를 임의로 가지고 가 현금자동지급기에서 현금서비스를 받은 후 곧바로 반환한 경우라도 신용카드부정사용죄는 성립한다.
- ⑤ 절취한 타인의 신용카드로 여러 가맹점에서 수차례 물품을 구입한 경우 신용카드부정사용죄 부분은 포괄하여 일죄가 된다.

【정답】 ③

【해설】 위의 행위는 현금자동지급기의 관리자의 의사에 반하여 그의 지배를 배제한 채 그 현금을 자기의 지배하에 옮겨 놓는 행위로 절도죄에 해당한다(대판 2002.7.12. 2002도2134).

2. 甲이 乙에게 폭행을 행사하여 乙의 신용카드를 강탈한 다음 이 카드를 사용하여 현금자동인출기에서 현금을 인출하였을 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 강도죄, 절도죄, 신용카드부정사용죄의 상상적 경합
- ② 강도죄, 절도죄, 신용카드부정사용죄의 실체적 경합
- ③ 강도죄, 절도죄의 실체적 경합
- ④ 강도죄, 절도죄의 상상적 경합
- ⑤ 강도죄

【정답】 ②

【해설】 신용카드에 대한 강도죄, 인출한 현금에 대한 절도죄, 그리고 신용카드부정사용죄의 실체적 경합이 된다(대판 2007.5.10. 2007도1375).

3. 甲이 A에게 협박을 가하여 A의 신용카드를 빼앗은 다음 현금자동인출기에서 금 100만원을 인출하여 사용하였을 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의하고, 신용카드부정사용죄는 논외임)

- ① 무죄
- ② 공갈죄와 절도죄의 실체적 경합
- ③ 공갈죄와 절도죄의 상상적 경합
- ④ 공갈죄
- ⑤ 절도죄

【정답】 ④

【해설】 위의 행위들은 모두 피해자의 예금을 갈취하고자 하는 피고인의 단일하고 계속된 범의 아래에서 이루어진 일련의 행위로서 포괄하여 하나의 공갈죄를 구성한다(대판 1996.9.20. 95도1728).

♣ 학습내용 정리

1. 대금결제 의사나 능력이 없음에도 불구하고 신용카드를 발급 받아 물품을 구입하고 현금 자동인출기에서 현금을 인출한 경우 사기죄의 포괄일죄이다.
2. 절취하거나 강취한 타인의 신용카드로 현금자동지급기에서 현금을 인출한 행위는 별도로 절도죄를 구성한다.
3. 타인의 신용카드를 편취하여 현금을 인출한 행위는 별도로 절도죄를 구성하지 않는다.

제24강 컴퓨터사용사기죄(형법 제347조의2)

♣ 학습목표

컴퓨터등사용사기죄의 행위객체와 행위에 대하여 설명할 수 있다.
위임범위를 초과하여 현금을 인출한 행위의 죄책을 설명할 수 있다.
컴퓨터등사용사기죄와 친족상도례와의 관계를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

컴퓨터등사용사기죄
불법계좌이체
재산상 이익과 장물
친족상도례

♣ 사전테스트

1. 불가벌적 사후행위가 인정되려면 사후행위는 최소한 어떤 범죄의 구성요건에 해당하는 행위여야 한다.
정답 : O
2. 절취한 타인의 신용카드를 이용하여 현금지급기에서 계좌이체를 한 행위 역시 절취행위에 해당한다.
정답 : X
3. 컴퓨터등사용사기죄에 대하여는 친족상도례가 적용되지 않는다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

권한 없이 인터넷뱅킹으로 타인의 예금계좌에서 자신의 예금계좌로 돈을 이체한 후 그 중 일부를 인출한 경우 그 돈은 장물이 된다.

[정답] X

[해설] 컴퓨터등사용사기죄에 의하여 취득한 예금채권은 재물이 아니라 재산상 이익이므로 장물이 될 수 없다(대판 2004.4.16. 2004도353).

♣ 강의내용

1. 행위객체 및 행위

1. 컴퓨터등사용사기죄의 의의

컴퓨터 등 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 권한없이 정보를 입력, 변경하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상 이익을 취득하거나 또는 제3자로 하여금 취득하게 함으로써 성립하는 범죄이다.

순수한 이득죄이고, 재산을 보호법익으로 하지만 재산상 중요한 정보처리과정에 대한 침해를 금지한다는 점에서 일반 사기죄와 구별된다.

2. 행위의 객체 및 행위

(1) 행위객체

재산상 이익이다. 그러나 컴퓨터를 부정조작한 재산침해의 대상에서 구태여 재물을 제외할 이유가 없기 때문에 재물도 본죄의 객체가 된다고 보아야 한다.

(2) 행위

컴퓨터 등 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 권한 없이 정보를 입력, 변경하여 정보처리를 하게 하는 것이다.

- ① 허위정보의 입력이란 사실관계와 일치하지 않는 자료를 입력하는 것을 말한다. 예컨대 사실과 다른 입금기록을 새로 입력한다거나 다른 사람의 구좌에 있는 예금을 단말기조작으로 자신의 구좌로 입금시키는 행위를 말한다.
- ② 부정한 명령의 입력이란 부정하게 프로그램을 변경하여 조작하는 것을 말한다. 예컨대 자신의 예금을 부정하게 증액시키는 처리를 할 프로그램을 만들어서 입력시키는 것과 같은 프로그램조작이 여기에 해당한다.
- ③ 권한 없이 정보를 입력·변경한다 함은 타인의 진정한 정보를 권한 없는 자가 본인의 승낙 없이 사용하는 것을 말한다. 즉 진실한 자료의 권한 없는 사용을 말한다. 예컨대 타인의 신용카드를 습득하여 비밀번호를 알아내고 현금자동지급기로부터 예금을 인출하는 경우가 이에 해당한다.

판례 인터넷뱅킹 계좌이체사건(대판 2004.4.16. 2004도353) 辯3 司49·50·53

[사실관계] 甲은 권한 없이 신진기획(주)의 ID와 패스워드를 입력하여 인터넷뱅킹에 접속한 다음 위 회사의 예금계좌로부터 자신의 예금계좌로 함께 180,500,000원을 이체한 다음 자신의 현금카드를 사용하여 현금자동지급기에서 현금 6,000만원을 인출하였다. 甲은 이 돈을 채무변제조로 乙에게 교부하였는데, 乙은 이 돈의 출처를 소상히 알고 있었다.

[판결요지] [1] 형법 제41장의 장물에 관한 죄에 있어서의 ‘장물’이라 함은 재산범죄로 인하여 취득한 물건 그 자체를 말하므로, 재산범죄를 저지른 이후에 별도의 재산범죄의 구성요건에 해당하는 사후행위가 있었다면 비록 그 행위가 불가벌적 사후행위로서 처벌의 대상이 되지 않는다 할지라도 그 사후행위로 인하여 취득한 물건은 재산범죄로 인하여 취득한 물건으로서 장물이 될 수 있다.

[2] 컴퓨터등사용사기죄의 범행으로 예금채권을 취득한 다음 자기의 현금카드를 사용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출한 경우, 현금카드 사용권한있는 자의 정당한 사용에 의한 것으로서 현금자동지급기 관리자의 의사에 반하거나 기망행위 및 그에 따른 처분행위도 없었으므로, 별도로 절도죄나 사기죄의 구성요건에 해당하지 않는다 할 것이고, 그 결과 그 인출된 현금은 재산범죄에 의하여 취득한 재물이 아니므로 장물이 될 수 없다.

[3] 甲이 권한 없이 인터넷뱅킹으로 타인의 예금계좌에서 자신의 예금계좌로 돈을 이체한 후 그 중 일부를 인출하여 그 정을 아는 乙에게 교부한 경우, 甲이 컴퓨터등사용사기죄에 의하여 취득한 예금채권은 재물이 아니라 재산상 이익이므로, 그가 자신의 예금계좌에서 돈을 인출하였더라도 장물을 금융기관에 예치하였다가 인출한 것으로 볼 수 없다는 이유로 乙의 장물취득죄의 성립을 부정한 사례.

[판례해설] [1. 甲의 죄책] 甲에게 컴퓨터사용사기죄가 성립함은 명백하다. 이때 甲이 현금을 인출한 행위는 컴퓨터사용사기죄의 불가벌적 사후행위에 해당하지 않는다. 왜냐하면 컴퓨터등사용사기죄를 범한 자가 자기의 현금카드를 사용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출한 경우라 할지라도 이는 현금카드 사용권한있는 자의 정당한 사용에 의한 것으로서 별도로 절도죄나 사기죄의 구성요건에 해당하지 않기 때문이다.¹⁾ [2. 乙의 죄책] 대선판례에 의하면 재산범죄의 불가벌적 사후행위로 인하여 취득한 물건은 재산범죄로 인하여 취득한 물건으로서 장물이 될 수 있다. 그러나 甲에게 별도로 절도죄나 사기죄의 구성요건해당성이 인정되지 않는다. 따라서 그 인출된 현금은 재산범죄에 의하여 취득한 재물이 아니므로 장물이 될 수 없다. 또한 甲이 컴퓨터등사용사기죄에 의하여 취득한 예금채권은 재물이 아니라 재산상 이익이므로, 그가 자신의 예금계좌에서 6,000만 원을 인출하였더라도 장물을 금융기관에 예치하였다가 인출한 것으로 볼 수 없다. 따라서 乙에게는 장물취득죄가 성립하지 않는다.

판례 (대판 2008. 6.12. 2008도2440) 司52·56

절취한 타인의 신용카드를 이용하여 현금지급기에서 계좌이체를 한 행위는 컴퓨터등사용사기죄에서 컴퓨터 등 정보처리장치에 권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 한 행위에 해당함은 별론으로 하고 이를 절취행위라고 볼 수는 없고, 한편 위 계좌이체 후 현금지급기에서 현금을 인출한 행위는 자신의 신용카드나 현금카드를 이용한 것이어서 이러한 현금인출이 현금지급기 관리자의 의사에 반한다고 볼 수 없어 절취행위에 해당하지 않으므로 절도죄를 구성하지 않는다.

(3) 정보처리

허위정보 또는 부정한 명령의 입력으로 컴퓨터 등을 실행하여 진실에 반하는 기록을 만드는 것을 말한다.

판례 (대판 2014.3.13. 2013도16099)

형법 제347조의2에서 ‘정보처리’는 사기죄에서 피해자의 처분행위에 상응하므로 입력된 허위의 정보 등에 의하여 계산이나 데이터의 처리가 이루어짐으로써 직접적으로 재산처분의 결과를 초래하여야 하고, 행위자나 제3자의 ‘재산상 이익 취득’은 사람의 처분행위가 개재됨이 없이 컴퓨터 등에 의한 정보처리 과정에서 이루어져야 한다.

II. 위임범위를 초과해서 현금을 인출한 사건 - 컴퓨터사용사기죄의 성부

■ 사례연습 ■

甲은 10:00경 충주시 옥행동에 있는 충주농업 목행지점에서 같은동에 있는 ‘사이버 25시 피씨방’에 게임을 하러 온 피해자 A로부터 그 소유의 농협현금카드를 20,000원을 인출해 오라는 부탁과 함께 현금카드를 건네받게 되자 이를 기화로, 위 지점에 설치되어 있는 현금자동인출기에 위 현금카드를 넣고 권한 없이 인출금액을 50,000원으로 입력하여 그 금액을 인출한 후 그 중 20,000원만 피해자에게 건네주어 30,000원 상당의 재산상 이익을 취득하였다. 甲의 형사책임은?

1) 불가벌적 사후행위가 인정되려면 사후행위는 최소한 어떤 범죄의 구성요건에 해당하는 행위여야 한다.

예금주인 현금카드 소유자로부터 일정한 금액의 현금을 인출해 오라는 부탁을 받으면서 이와 함께 현금카드를 건네받은 것을 기회로 그 위임을 받은 금액을 초과하여 현금을 인출하는 방법으로 그 차액 상당을 위법하게 이득할 의사로 현금자동지급기에 그 초과된 금액이 인출되도록 입력하여 그 초과된 금액의 현금을 인출한 경우에는, 그 인출된 현금에 대한 점유를 취득함으로써 이 때에 그 인출한 현금 총액 중 인출을 위임받은 금액을 넘는 부분의 비율에 상당하는 재산상 이익을 취득한 것으로 볼 수 있으므로, 이러한 행위는 그 차액 상당액에 관하여 형법 제347조의2에 규정된 컴퓨터등 정보처리장치에 권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득하는 행위로서 컴퓨터등사용사기죄에 해당된다.

1. 문제점

컴퓨터사용사기죄가 성립하기 위해서는 권한 없이 진실한 정보를 입력하여 재산상 이익을 취득하여야 한다. 그런데 설문에서 甲은 위임범위를 초과하여 A의 현금카드를 진실한 정보인 A의 비밀번호를 입력하여 현금을 인출하여 이를 영득하였는바, 이 행위가 ① 권한 없이 진실한 정보를 입력하여 ② 재산상 이익을 취득한 행위에 해당하여야만 甲이 컴퓨터사용사기죄의 죄책을 지는바, 이 문제를 검토해 본다.

2. 권한 없이 진실한 정보를 입력한 경우에 해당하는가 여부

‘권한 없이’의 좁은 의미는 권한이 아예 없는 경우를 의미한다. 그러나 판례는 통상적으로 위탁된 권한을 초월하여 위탁자명의로의 사문서를 작성하거나 위임의 취지에 위배하여 문서를 작성하는 행위도 권한 없이 문서를 작성하는 경우로서 사문서위조로 파악한다.

이에 근거한다면 2만원의 인출을 위임받은 甲이 5만원의 현금을 인출한 것은 위임범위를 엄청나게 초과한 경우라고 할 수도 있다. 따라서 甲의 행위는 권한 없이 진실한 정보를 입력하여 현금을 인출한 것이다.

3. 권한을 초과하여 인출한 현금의 성격

판례는 통상적으로 현금카드를 인출한 현금을 ‘재물’이라고 하였지만, 통설은 컴퓨터사용사기죄의 성립에 있어서 재산상태를 더 유리하게 하는 경우이면 모두 여기에 속하기 때문에 입법취지로 보아 재물(현금)도 재산상의 이익에 포함된다는 입장을 취하여 왔다.

그런데 판례는 설문과 동일한 사건에서 “그 인출한 현금 총액 중 인출을 위임받은 금액을 넘는 부분의 비율에 상당하는 재산상 이익을 취득한 것으로 볼 수 있다”고 판시한 바 있다.

따라서 현금카드를 탈취하여 현금을 인출한 경우처럼 애당초 인출권한이 없었던 경우와는 달리 위임범위를 초과하여 현금을 인출한 경우에는 인출된 현금을 ‘재산상 이익’으로 파악하는 것이 통설과 판례의 일치된 견해이고, 또한 타당하다.

4. 결론

甲이 A의 현금카드를 위임된 금액을 초과하여 현금을 인출한 다음 그 차액을 영득한 행위는 권한 없이 정보처리장치에 진실한 정보를 입력하여 그 차액 상당액에 관하여 재산상 이익을 취득한 경우로서 형법 제347조의2 컴퓨터등사용사기에 해당된다.

III. 기수시기와 친족상도례

1. 기수시기

판례 (대판 2006.9.14, 2006도4127) 辯1 司49・55

금융기관 직원이 전산단말기를 이용하여 다른 공범들이 지정한 특정계좌에 돈이 입금된 것처럼 허위의 정보를 입력하는 방법으로 위 계좌로 입금되도록 한 경우, 이러한 입금절차를 완료함으로써 장차 그 계좌에서 이를 인출하여 갈 수 있는 재산상 이익을 취득하였으므로 형법 제347조의2에서 정하는 컴퓨터 등 사용사기죄는 기수에 이르렀고, 그 후 그러한 입금이 취소되어 현실적으로 인출되지 못하였다고 하더라도 이미 성립한 컴퓨터 등 사용사기죄에 어떤 영향이 있다고 할 수는 없다.

판례 (대판 2006.1.26. 2005도8507) 司55

금융기관 직원이 범죄의 목적으로 전산단말기를 이용하여 다른 공범들이 지정한 특정계좌에 무자원 송금의 방식으로 거액을 입금한 것은 형법 제347조의2에서 정하는 컴퓨터 등 사용사기죄에서의 ‘권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 한 경우’에 해당한다고 할 것이고, 이는 그 직원이 평상시 금융기관의 여·수신업무를 처리할 권한이 있었다고 하여도 마찬가지이다.

2. 컴퓨터사용사기죄와 친족상도례와의 관계

판례 할아버지 예금통장으로 계좌이체 한 사건(대판 2007.3.15. 2006도2704) 司50・51・53・56

[사실관계] 피고인 甲이 절취한 친할아버지 A의 소유 고흥 농업협동조합 예금통장을 현금자동지급기에 넣고 조작하는 방법으로 A 명의의 위 농업협동조합 계좌의 예금 잔고 중 57만 원을 피고인 명의 국민은행 계좌로 이체한 사건에서 검사는 컴퓨터등사용사기 범행 부분의 피해자를 고흥 농업협동조합이라고 특정하여 공소를 제기하였다.

[판결요지] [1] 컴퓨터 등 정보처리장치를 통하여 이루어지는 금융기관 사이의 전자식 자금이체거래는 금융기관 사이의 환거래관계를 매개로 하여 금융기관 사이나 금융기관을 이용하는 고객 사이에서 현실적인 자금의 수수 없이 지급·수령을 실현하는 거래방식인바, ① 권한없이 컴퓨터 등 정보처리장치를 이용하여 예금계좌 명의인이 거래하는 금융기관의 계좌 예금 잔고 중 일부를 자신이 거래하는 다른 금융기관에 개설된 그 명의 계좌로 이체한 경우, 예금계좌 명의인의 거래 금융기관에 대한 예금반환 채권은 이러한 행위로 인하여 영향을 받을 이유가 없는 것이므로, 거래 금융기관으로서는 예금계좌 명의인에 대한 예금반환 채무를 여전히 부담하면서도 환거래관계상 다른 금융기관에 대하여 자금이체로 인한 이체자금 상당액 결제채무를 추가 부담하게 됨으로써 이체된 예금 상당액의 채무를 이중으로 지급해야 할 위험에 처하게 된다. 따라서 ② 친척 소유 예금통장을 절취한 자가 그 친척 거래 금융기관에 설치된 현금자동지급기에 예금통장을 넣고 조작하는 방법으로 친척 명의 계좌의 예금 잔고를 자신이 거래하는 다른 금융기관에 개설된 자기 계좌로 이체한 경우, 그 범행으로 인한 피해자는 이체된 예금 상당액의 채무를 이중으로 지급해야 할 위험에 처하게 되는 그 친척 거래 금융기관이라 할 것이므로, 위와 같은 경우에는 친족 사이의 범행을 전제로 하는 친족상도례를 적용할 수 없다.

[2] 손자가 할아버지 소유 농업협동조합 예금통장을 절취하여 이를 현금자동지급기에 넣고 조작하는 방법으로 예금 잔고를 자신의 거래 은행 계좌로 이체한 사안에서, 위 농업협동조합이 컴퓨터 등 사용사기 범행 부분의 피해자라는 이유로 친족상도례를 적용할 수 없다고 한 사례.

♣ **확인학습문제**

1. 다음의 컴퓨터등사용사기죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 금융기관 직원이 범죄의 목적으로 전산단말기를 이용하여 특정계좌에 거액을 무자원 송금한 경우, 컴퓨터등사용사기죄에 해당한다.
- ② 위임범위를 초과하여 현금을 인출한 경우에는 인출된 현금을 '재산상 이익'에 포함된다고 해석할 수 있다.
- ③ 불가벌적 사후행위로 인하여 취득한 물건은 장물이 될 수 없다.
- ④ 컴퓨터등사용사기의 범행으로 예금채권을 취득한 다음 자기의 현금카드를 사용하여 현금자동지급기에서 현금을 인출한 행위는 별도로 절도죄의 구성요건에 해당하지 않는다.
- ⑤ 금융기관 직원이 전산단말기를 이용하여 다른 공범들이 지정한 특정계좌에 돈이 입금된 것처럼 허위의 정보를 입력하는 방법으로 위 계좌로 입금되도록 한 경우, 컴퓨터등사용사기죄는 기수에 이르렀다.

[정답] ③

[해설] 어떤 행위가 주된 범죄의 불가벌적 사후행위로서 처벌의 대상이 되지 않는다 할지라도 그 사후행위로 인하여 취득한 물건은 재산범죄로 인하여 취득한 물건으로서 장물이 될 수 있다(대판 2004.4.16. 2004도353).

2. 사이버 25시 PC방에서 알바를 하고 있던 甲은 손님인 乙로부터 현금 2만원을 인출해 오라는 부탁을 받으면서 그로부터 현금카드를 건네받았는데, 甲은 현금 5만원을 인출하여 3만원은 자신이 취득하고, 2만원만 乙에게 교부하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 절도죄
- ② 컴퓨터등사용사기죄
- ③ 절도죄와 컴퓨터등사용사기죄의 실체적 경합
- ④ 절도죄와 컴퓨터등사용사기죄의 상상적 경합
- ⑤ 사기죄

[정답] ②

[해설] 이러한 행위는 그 차액 상당액에 관하여 '컴퓨터 등 정보처리장치에 권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득'하는 행위로서 컴퓨터 등 사용사기죄에 해당된다(대판 2006.3.24. 2005도3516).

3. 甲은 자신의 할아버지 乙 소유의 농업협동조합 예금통장을 절취하여 이를 현금자동지급기에 넣고 조작하는 방법으로 예금 잔고를 자신의 거래 은행 계좌로 이체하였다. 위의 사례에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 예금통장에 대하여는 절도죄가 성립한다.
- ② 절도죄에 대해서는 친족상도례가 적용된다.
- ③ 계좌이체행위에 대하여는 컴퓨터등사용사기죄가 성립한다.
- ④ 컴퓨터등사용사기죄에 대해서는 친족상도례가 적용되지 않는다.
- ⑤ 절도죄와 컴퓨터등사용사기죄는 상상적 경합관계에 있다.

[정답] ⑤

[해설] 2개의 행위에 의한 2개의 범죄이므로 실체적 경합관계에 있다.

♣ 학습내용 정리

1. 컴퓨터등사용사기죄는 컴퓨터 등 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 권한없이 정보를 입력, 변경하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상 이익을 취득하거나 또는 제3자로 하여금 취득하게 함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 컴퓨터등사용사기죄는 순수한 이득죄이다.
3. 컴퓨터등사용사기죄는 재산을 보호법익으로 하지만 재산상 중요한 정보처리과정에 대한 침해 금지한다는 점에서 일반 사기죄와 구별된다.

제25강 공갈죄(형법 제350조)

♣ 학습목표

- 공갈죄의 행위객체에 대하여 설명할 수 있다.
- 공갈행위가 무슨 의미인지 설명할 수 있다.
- 권리행사와 공갈죄의 성부는 어떤 관계에 있는지를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 공갈
- 재산적 처분행위
- 재산상 손해발생
- 권리행사와 공갈죄

♣ 사전테스트

1. 일반적으로 부녀와의 정교 그 자체는 이를 경제적으로 평가할 수 없는 것이므로 부녀를 공갈하여 정교를 맺었다고 하여도 공갈죄가 성립하지 않는다.
정답 : ○
2. 공갈죄에서 부작위에 의한 처분행위도 가능하다.
정답 : ○
3. 공갈죄는 강도죄에 흡수되지 않고 별도의 범죄를 구성한다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

피공갈자와 재산피해자는 언제나 같은 사람이어야 한다.

[정답] X

[해설] 피공갈자와 재산처분행위자는 같은 사람이어야 하지만, 피공갈자와 재산피해자, 공갈행위자와 재산이득자는 같을 필요가 없다(삼각공갈).

♣ 강의내용

I. 공갈죄의 행위객체

재물 또는 재산상의 이익으로서 사기죄와 동일하다. 예컨대 부녀와의 정교는 재산상의 이익이라 할 수 없으므로 부녀를 공갈하여 성행위를 한 경우에는 강간죄 또는 강요죄는 성립할 수 있어도 공갈죄는 성립할 수 없다. 다만 판례는 매음을 전제로 성행위를 한 후 폭행·협박으로 매음료를 지불하지 않았을 때에는 재산상 이익을 취득한 것으로 보아 공갈죄가 성립가능하다는 입장이다(경제적 재산설).

판례 (대판 1982.2.8. 82도2714) 司51

공갈죄는 재산범으로서 그 객체인 재산상 이익은 경제적 이익이 있는 것을 말하는 것인바, 일반적으로 부녀와의 정교 그 자체는 이를 경제적으로 평가할 수 없는 것이므로 부녀를 공갈하여 정교를 맺었다고 하여도 특단의 사정이 없는 한 이로써 재산상 이익을 갈취한 것이라고 볼 수는 없는 것이며, 부녀가 주점접대부라 할지라도 피고인과 매음을 전제로 정교를 맺은 것이 아닌 이상 피고인이 매음대가의 지급을 면하였다고 볼 여지가 없으니 공갈죄가 성립하지 아니한다. → 이 경우 이론상 강요죄의 성립은 가능하다.

[사실관계] 원심은 피고인 甲이 가짜 기자회견을 하면서 싸롱객실에서 나체쇼를 한 피해자 乙녀를 고발할 것처럼 데리고 나와 여관으로 유인한 다음, 겁에 질려있는 그녀의 상태를 이용하여 동침하면서 1회 성교하여 그녀의 정조대가에 상당하는 재산상 이익을 갈취하였다는 공소사실에 대하여 여자의 정조 그 자체는 경제적 이익이 아니라는 이유로 무죄를 선고하였다.

판례 (대판 2012.08.30. 2012도6157) 司55

[1] 공갈죄의 대상이 되는 재물은 타인의 재물을 의미하므로, 사람을 공갈하여 자기의 재물을 교부받는 경우에는 공갈죄가 성립하지 아니한다. 그리고 타인의 재물인지는 민법, 상법, 기타의 실체법에 의하여 결정되는데, 금전을 도난당한 경우 절도범이 절취한 금전만 소지하고 있는 때 등과 같이 구체적으로 절취된 금전을 특정할 수 있어 객관적으로 다른 금전 등과 구분됨이 명백한 예외적인 경우에는 절도 피해자에 대한 관계에서 그 금전이 절도범인 타인의 재물이라고 할 수 없다.

[2] 甲이 乙의 돈을 절취한 다음 다른 금전과 섞거나 교환하지 않고 쇼핑백 등에 넣어 자신의 집에 숨겨두었는데, 피고인이 乙의 지시로 丙과 함께 甲에게 겁을 주어 위 돈을 교부받아 갈취하였다고 하여 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동공갈)으로 기소된 사안에서, 위 금전을 타인인 甲의 재물이라고 할 수 없어 공갈죄가 성립된다고 볼 수 없다. → 다만 甲이 돈을 교부받으려고 죽인다고 A를 협박한 행위가 사회통념상 정당한 행위라고 보이지 아니하므로 甲의 행위는 형법 제283조 제1항 협박죄를 구성할 여지는 있다.

II. 행위 : 공갈이다.

1. 공갈

공갈이라 함은 재물 또는 재산상 이익을 교부 또는 공여하도록 타인에게 폭행·협박을 수단으로 일정한 해악을 고지하여 상대방의 공포를 야기하는 행위를 말한다.

공갈죄는 피공갈자의 재산처분을 강요하는 데 본질이 있으므로 본죄의 폭행·협박은 타인의 의사나 행동의 자유를 제한하는 정도로 충분하고, 반드시 강도죄의 폭행·협박과 같은 정도로 상대방의 반항을 억압할 정도를 요하지 않는다. 만약 상대방의 반항을 억압할 정도이면 강도죄

가 성립한다. 따라서 공갈죄에 있어서 폭행·협박과 강도죄에 있어서 폭행·협박은 질적 차이가 아닌 양적 차이만을 갖는다고 할 수 있다.

그리고 공갈죄의 수단으로 한 폭행·협박은 공갈죄에 흡수될 뿐 별도로 폭행죄·협박죄를 구성하지 않으므로, 폭행죄·협박죄에 대한 피해자의 고소가 취소되었다 하여 공갈죄로 처벌하는데 아무런 장애가 되지 아니한다(대판 1996.9.24. 96도2151). 司46

(판례) (대판 2013.4.11. 2010도13774) 司56

강요죄나 공갈죄의 수단인 협박은 사람의 의사결정의 자유를 제한하거나 의사실행의 자유를 방해할 정도로 겁을 먹게 할 만한 해악을 고지하는 것을 말하는데, 해악의 고지는 반드시 명시적인 방법이 아니더라도 말이나 행동을 통해서 상대방으로 하여금 어떠한 해악에 이르게 할 것이라는 인식을 갖게 하는 것이면 족하고, 피공갈자 이외의 제3자를 통해서 간접적으로 할 수도 있다.

2. 처분행위

공갈죄는 피공갈자의 하자 있는 의사표시에 따른 재산처분행위가 본질적 요소가 되기 때문에 공갈죄가 성립하기 위해서는 피공갈자의 재물을 교부하거나 재산상의 이익을 공여하는 재산처분행위가 있어야 한다.

한편, 공갈의 상대방과 관련하여서 피공갈자와 재산처분행위자는 같은 사람이어야 하지만, 피공갈자와 재산피해자, 공갈행위자와 재산이득자는 같을 필요가 없다(삼각공갈). 이때 재산처분자는 사기죄에서와 마찬가지로 피해자의 재산을 처분할 수 있는 지위에 있어야 한다.

(판례) (대판 2005.9.29. 2005도4) 司57

공갈죄에 있어서 공갈의 상대방은 재산상의 피해자와 동일함을 요하지는 아니하나, 공갈의 목적이 된 재물 기타 재산상의 이익을 처분할 수 있는 사실상 또는 법률상의 권한을 갖거나 그러한 지위에 있음을 요한다.

(판례) (대판 1960.2.29. 4292형상997) 司57

공갈죄의 본질은 피공갈자의 외포로 인한 하자있는 동의를 이용하는 재물의 영득행위라고 해석하여야 할 것이므로 그 영득행위의 형식에 있어서 피공갈자가 자의로 재물을 제공한 경우뿐만 아니라 피공갈자가 외포하여 묵인함을 이용하여 공갈자가 직접 재물을 탈취한 경우에도 공갈죄로 봄이 타당하다.

(판례) (대판 2012.1.27. 2011도16044) *

[1] 재산상 이익의 취득으로 인한 공갈죄가 성립하려면 폭행 또는 협박과 같은 공갈행위로 인하여 피공갈자가 재산상 이익을 공여하는 처분행위가 있어야 한다. 물론 그러한 처분행위는 반드시 작위에 한하지 아니하고 부작위로도 족하여서, 피공갈자가 외포심을 일으켜 묵인하고 있는 동안에 공갈자가 직접 재산상의 이익을 탈취한 경우에도 공갈죄가 성립할 수 있다. 그러나 폭행의 상대방이 위와 같은 의미에서의 처분행위를 한 바 없고, 단지 행위자가 법적으로 의무 있는 재산상 이익의 공여를 면하기 위하여 상대방을 폭행하고 현장에서 도주함으로써 상대방이 행위자로부터 원래라면 얻을 수 있었던 재산상 이익의 실현에 장애가 발생한 것에 불과하다면, 그 행위자에게 공갈죄의 죄책을 물을 수 없다. [2] 피고인이 피해자가 운전하는 택시를 타고 간 후 최초의 장소에 이르러 택시요금의 지급을 면할 목적으로 다른 장소에 가자고 하였다면서 택시에서 내린 다음 택시요금 지급을 요구하는 피해자를 때리고 달아나자, 피해자가 피고인이 말한 다른 장소까지 쫓아가 기다리다 그곳에서 피고인을 발견하고 택시요금 지급을 요구하였는데 피고인이 다시 피해자의 얼굴 등을 주먹으로 때리고 달아난 사안에서, 피해자가 피고인에게 계속해서 택시요금의 지급을 요구하였으나 피고인이 이를 면하고자 피해자를 폭행하고 달아났을 뿐, 피해자가 폭행을 당하여 외포심을 일으켜 수동적·소극적으로라도 피고인이 택시요금 지급을 면하는 것

을 용인하여 이익을 공여하는 처분행위를 하였다고 할 수 없는데도, 이와 달리 보아 공갈죄를 인정한 원심판결에 법리오해 등 위법이 있다.

3. 재산상의 손해

공갈죄가 성립하려면 재산상의 손해가 발생하여야 한다(다수설). 이 때 실행의 착수시기는 갈취의 의사로 폭행·협박이 개시된 때이며, 기수시기는 재산상 손해가 발생한 때이다.

그리고 피공갈자의 하자 있는 의사에 기하여 이루어지는 재물의 교부 자체가 공갈죄에서의 재산상 손해에 해당하므로, 반드시 피해자의 전체 재산의 감소가 요구되는 것은 아니다(대판 2013.4.11. 2010도13774).

판례 (대판 1992.9.14. 92도1506) **司**49·57

부동산에 대한 공갈죄에 있어서는 부동산에 대한 소유권이전등기를 경료받거나 인도를 받은 때에 기수가 되고, 소유권이전등기에 필요한 서류를 교부받은 때에 기수로 되어 그 범행이 완료되는 것은 아니다.

판례 (대판 1985.9.24. 85도1687) **司**57

피해자들을 공갈하여 피해자들로 하여금 지정한 예금구좌에 돈을 입금케한 이상, 위 돈은 범인이 자유로이 처분할 수 있는 상태에 놓인 것으로서 공갈죄는 이미 기수에 이르렀다 할 것이다.

III. 권리행사와 공갈죄의 성부

1. 문제점

공갈행위자가 자신의 정당한 권리를 실행하기 위해 공갈행위를 한 경우에도 불법영득의사를 인정하여 공갈죄가 성립할 수 있는가 하는 것이 쟁점이 된다.

2. 학설

(1) 폭행죄·협박죄설

이 경우 불법영득의사는 부정되고, 다만 이때에도 정당한 권리를 행사하는 수단은 폭행죄, 협박죄 또는 강요죄에 해당되며, 자구행위나 정당행위에 의하여 위법성조각이 될 가능성이 있다.

(2) 공갈죄설

공갈행위자가 자신의 정당한 권리를 실행하기 위해 공갈행위를 한 경우에도 불법영득의사를 인정할 수 있고, 다만 정당행위나 자구행위를 근거로 공갈행위의 위법성이 부정될 수 있다.

3. 판례 - 공갈죄설

판례 (대판 1987.10.26. 87도1656) **辯**1

외상대금채권회수의 의뢰를 받고 피해자에게 욕설을 하고 눈을 치켜뜨고 죽어볼래 하면서 2-3분간 먹살을 잡고 흔드는 등 겁을 먹게 하여 피해자로 하여금 원금을 교부하게 하였다면, 피고인의 위 소위는 공갈죄를 구성하는 것으로 이 행위가 단순히 채권회수를 위한 권리행사로 사회통념상 용인된 행위라고는 할 수 없다.

4. 결론

폭행이나 협박이 권리실현의 수단으로 사용된 경우라고 하여도 그것이 권리행사를 빙자하여 상대방을 겁을 먹게 하였고 그 권리 실행의 수단 방법이 사회통념상 허용되는 정도나 범위를 넘는다면 이를 처벌할 형사정책적 필요성이 존재한다고 해야 한다. 공갈죄설이 타당하다.

IV. 보론 - 죄수

- ① 1개의 공갈행위로 같은 피해자로부터 수회에 걸쳐 재물의 교부를 받아 재산상의 이익을 취득한 때는 포괄일죄가 된다.
- ② 동일인에 대하여 수개의 공갈행위를 한 경우에는 수개의 공갈죄의 실체적 경합이 된다(대판 1958.4.11. 4290형상360).
- ③ 공갈죄는 강도죄에 흡수된다.
- ④ 공무원이 직무집행의 의사 없이 직무집행을 빙자하여 재물을 건네받은 경우에는 공갈죄만 성립한다. 이 경우 뇌물교부자는 폭행·협박으로 인해 교부하였을 뿐이기 때문에 뇌물공여죄는 성립하지 않는다(대판 1994.12.22. 94도2528).
- ⑤ 공무원이 직무행위의 의사로 타인을 폭행·협박하여 재물을 교부받은 경우 공갈죄와 수뢰죄의 상상적 경합이 성립한다.

♣ 확인학습문제

1. 甲의 친구인 A는 甲의 사무실에 놀러왔다가 사무실에 있는 금고가 열려져 있고, 그 안에 돈다발이 있는 것을 보고는 甲의 소유인 현금 2,000만원을 훔쳐갔다. A는 甲의 돈을 훔친 다음 다른 금전과 섞거나 교환하지 않고 이 돈을 모두 그대로 사과상자에 넣어 자신의 집에 숨겨두었다. 이 사실을 알게 된 甲은 A를 찾아가서 A를 죽인다고 겁을 주어 사과상자에 들어 있던 절취된 돈을 교부받았다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 절도죄
- ③ 공갈죄
- ④ 협박죄
- ⑤ 강도죄

[정답] ④

[해설] 공갈죄의 대상이 되는 재물은 타인의 재물을 의미하므로 사람을 공갈하여 자기의 재물을 교부받는 경우에는 공갈죄가 성립하지 아니한다(대판 2012.8.30. 2012도6157). → 다만 甲이 돈을 교부받으려고 죽인다고 A를 협박한 행위가 사회통념상 정당한 행위라고 보이지 아니하므로 甲의 행위는 형법 제283조 제1항 협박죄를 구성한다.

2. 다음 공갈죄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 부동산에 대한 공갈죄는 그 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료받거나 또는 인도를 받은 때에 기수가 된다.
- ② 동일인에 대하여 수개의 공갈행위를 한 경우에는 수개의 공갈죄의 실체적 경합이 된다.

- ③ 피해자들을 공갈하여 피해자들로 하여금 지정한 예금구좌에 돈을 입금케 하였으나 그 돈을 아직 인출하지 못한 경우 공갈죄가 기수에 이르렀다고 볼 수 없다.
- ④ 공무원이 직무행위의 의사로 타인을 폭행,협박하여 재물을 교부받은 경우 공갈죄와 수뢰죄의 상상적 경합이 성립한다.
- ⑤ 폭행죄·협박죄에 대한 피해자의 고소가 취소되었다 하여 공갈죄로 처벌하는 데에 아무런 장애가 되지 아니한다.

[정답] ③

[해설] 피해자들을 공갈하여 피해자들로 하여금 지정한 예금구좌에 돈을 입금케한 이상, 위 돈은 범인이 자유로히 처분할 수 있는 상태에 놓인 것으로서 공갈죄는 이미 기수에 이르렀다 할 것이다(대판 1985.9.24. 85도1687).

3. 甲이 乙로부터 A에 대한 외상대금채권회수의 의뢰를 받고 이를 승낙한 다음 위 외상대금을 받아 주기 위하여 A에게 乙의 채무를 당장 갚고 나서 영업을 하라고 요구하고, 이를 갚기 전에는 영업을 할 수 없다 하면서 욕을 하고 눈을 치켜뜨고 죽어볼래 하면서 A의 먹살을 2, 3분 잡아 흔드는 등 겁을 먹게 하여 A의 영업을 방해하면서 금원을 교부받은 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 폭행죄와 협박죄
- ② 공갈죄와 업무방해죄
- ③ 폭행죄와 협박죄와 업무방해죄
- ④ 공갈죄
- ⑤ 무죄

[정답] ②

[해설] 甲의 위 所爲는 공갈죄를 구성하는 것으로 이 행위가 단순히 채권회수를 위한 권리 행사로서 사회통념상 용인된 행위라고는 할 수 없다(대판 1987.10.26. 87도1656). → A의 영업을 방해하였으므로 업무방해죄도 성립한다.

♣ 학습내용 정리

1. 공갈이라 함은 재물 또는 재산상 이익을 교부 또는 공여하도록 타인에게 폭행·협박을 수단으로 일정한 해악을 고지하여 상대방의 공포를 야기하는 행위를 말한다.
2. 재산상 이익의 취득으로 인한 공갈죄가 성립하려면 폭행 또는 협박과 같은 공갈행위로 인하여 피공갈자가 재산상 이익을 공여하는 처분행위가 있어야 한다.
3. 판례에 의하면 공갈행위자가 자신의 정당한 권리를 실행하기 위해 공갈행위를 한 경우에도 불법영득의사를 인정할 수 있고, 다만 정당행위나 자구행위를 근거로 공갈행위의 위법성이 부정될 수 있다.

제26강 횡령죄의 행위주체

♣ 학습목표

- 횡령죄의 의의를 설명할 수 있다.
- 횡령죄에서 보관의 의미를 설명할 수 있다.
- 불법원인급여와 횡령죄의 성부에 대한 법리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 횡령
- 재물의 보관
- 위탁관계에 의한 보관
- 불법원인급여와 횡령죄

♣ 사전테스트

1. 횡령죄와 배임죄는 타인의 신임관계를 배반한다는 점에서 동일한 성질을 가진다.
정답 : O
2. 횡령죄의 보관은 절도의 점유개념과 동일하다.
정답 : X
3. 절도·강도·사기·공갈에 의해 점유하게 된 재물에 대해서는 사실상의 위탁관계를 인정할 수 없으므로 횡령죄가 성립할 여지는 없다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

판례는 횡령죄를 침해범으로 파악한다.

[정답] X

[해설] 판례는 횡령죄를 위태범(위험범)으로 파악한다.

♣ 강의내용

1. 횡령죄(형법 제355조 제1항)의 행위주체 - 보관

1. 횡령죄의 의의

(1) 개념

타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 반환을 거부함으로써 성립하는 범죄이다.

(2) 보호법익 및 보호정도

보호법익은 소유권이며, 보호정도를 판례는 위태범(위험범)으로 파악한다.

(3) 배임죄와의 구별

횡령죄와 배임죄는 타인의 신임관계를 배반한다는 점에서 동일한 성질을 가진다. 그러나 배임죄는 기존의 신임관계를 전제로 하여 이를 침해하는 일체의 행위를 벌하는 것이고, 횡령죄는 본인과 행위자 사이의 신임관계를 전제하고 있으나, 다만 자기가 보관하는 타인의 재물을 영득하는 경우에 성립한다는 제한이 있으므로 횡령죄는 배임죄와 특별관계에 있다. 또한 횡령죄는 재물에 대한 위탁관계를 기초로 한 순수한 재물죄이고, 배임죄는 재산상의 이익을 침해하는 이득죄라는 점에서도 차이가 난다.

2. 행위주체

위탁관계에 의하여 타인의 재물을 보관하는 자이다(진정신분범, 의무범).

(1) 보관

보관이라 함은 점유 또는 소지와 같은 의미로 형법상의 점유개념이다. 그러나 횡령죄의 보관은 사실상의 지배뿐만 아니라 법률상의 지배관계까지 포함하는 점에서 사실상의 재물지배만을 의미하는 절도의 점유개념보다 넓다.

(2) 보관자의 구체적 범위

(가) 동산의 보관

동산의 경우 위탁관계로 재물을 사실상 점유하는 경우 보관이 인정된다.

<동산의 보관을 인정한 판례>

- ① 타인의 금전을 위탁받아 보관하는 자가 보관방법으로 금융기관에 자신의 명의로 예치한 경우 금융기관으로서는 특별한 사정이 없는 한 실명확인한 한 예금명의자만을 예금주로 인정할 수밖에 없으므로 수탁자 명의의 예금에 입금된 금전은 수탁자만이 법률상 지배·처분할 수 있을 뿐이고 위탁자로서는 위 예금의 예금주가 자신이라고 주장할 수는 없으나, 그렇다고 하여 보관을 위탁받은 위 금전이 수탁자 소유로 된대거나 위탁자가 위 금전의 반환을 구할 수 없는 것은 아니므로 수탁자가 이를 함부로 인출하여 소비하거나 또는 위탁자로부터 반환요구를 받았음에도 이를 영득할 의사로 반환을 거부하는 경우에는 횡령죄가 성립한다(대판 2000.8.18. 2000도1856). ㉮50
- ② 학교법인 이사장인 피고인이, 학교법인이 설치·운영하는 대학 산학협력단이 용도를 특정하여 교부 받은 국고보조금 중 3억 원을 대학 교비계좌로 송금하여 교직원 급여 등으로 사용하여 횡령하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 피고인이 대학과 산학협력단 운영에 직·간접적으로 영향력을 행사하

였고, 대학 교비나 산학협력단 자금에 관하여 입출금을 지시하기도 하였던 점 등을 종합할 때 자금에 관하여 사실상 보관자의 지위에 있었다(대판 2011.10.13. 2009도13751). 司54·55

(나) 부동산의 보관

부동산에 있어서 타인의 재물을 보관하는 자의 지위는 동산의 경우와는 달리 부동산에 대한 점유의 여부가 아니라 그 부동산을 제3자에게 유효하게 처분할 수 있는 권능의 유무에 따라 결정하여야 한다.

판례 (대판 2000.4.11. 2000도565) 司46·55

부동산에 관한 횡령죄에 있어서 타인의 재물을 보관하는 자의 지위는 동산의 경우와는 달리 부동산에 대한 점유의 여부가 아니라 부동산을 제3자에게 유효하게 처분할 수 있는 권능의 유무에 따라 결정하여야 하므로, 부동산을 공동으로 상속한 자들 중 1인이 부동산을 혼자 점유하던 중 다른 공동상속인의 상속지분을 임의로 처분하여도 그에게는 그 처분권능이 없어 횡령죄가 성립하지 아니한다.

[사실관계] 피해자 A와 B의 계모인 甲은 A와 B의 친부인 자신의 남편 乙로부터 A, B와 공동으로 상속한 건물에 거주·관리하면서 살다가 이를 乙에게 매도하였다.

II. 위탁관계에 의한 보관

1. 의의

횡령죄는 신임관계에 위배하여 타인의 재물을 영득한다는 배신성에 그 본질이 있으므로 보관은 위탁관계에 의한 것임을 요한다(통설). 따라서 타인의 점유를 떠나 우연히 자기의 점유에 귀속하게 된 재물을 영득한 경우에는 위탁관계가 인정될 수 없으므로 점유이탈물횡령죄가 성립한다.

2. 위탁관계의 발생근거

(1) 원칙

계약(사용대차, 임대차, 위임, 임차, 고용 등)과 같이 위탁자 본인의 의사에 의하여 발생하는 경우가 일반적이지만, 법정대리권, 사무관리, 후견과 같이 본인의 의사와는 무관하게 법률규정에 따른 법률상 원인에 의하여 발생하는 경우도 존재한다. 더 나아가 기타 신의성실의 원칙, 조리에 의해서도 위탁관계가 발생할 수 있다(대판 2006.1.12. 2005도7610).

위탁관계는 객관적으로 존재하는 사실상의 관계이면 충분하다. 따라서 소유자의 의사와 관계없이 법률의 규정에 의한 사무관리에 의해서도 위탁관계가 인정될 수 있고, 또한 위탁관계가 법률상 무효·취소된 때에도 이미 인도된 재물의 점유에 대해 사실상의 위탁관계는 인정된다.

판례 (대판 2010.12.9. 2010도891) 辯3 司45·48·53·54

어떤 예금계좌에 돈이 착오로 잘못 송금되어 입금된 경우에는 그 예금주와 송금인 사이에 신의칙상 보관관계가 성립한다고 할 것이므로 피고인이 송금 절차의 착오로 인하여 피고인 명의의 은행 계좌에 입금된 돈을 임의로 인출하여 소비한 행위는 횡령 죄에 해당하고, 이는 송금인과 피고인 사이에 별다른 거래관계가 없다고 하더라도 마찬가지이다.

채권양도인이 양도 통지 전에 채무자로부터 채권을 추심하여 금전을 수령한 경우 양도인이 수령한 금전은 양도인과 양수인 사이에서 양수인의 소유에 속하고 양도인은 이를 양수인을 위하여 보관하는 관계에 있다고 보아야 할 것이므로 양도인이 위 금전을 임의로 소비한 경우 횡령죄가 성립한다(대판 1999.4.15. 97도666 전원합의체).

(2) 부정되는 경우

절도·강도·사기·공갈에 의해 점유하게 된 재물에 대해서는 사실상의 위탁관계를 인정할 수 없으므로 횡령죄가 성립할 여지는 없다. 따라서 가령 절도범이 피해자로부터 도품에 대한 반환요구를 받고 이를 거절하더라도 절도죄 이외에 횡령죄는 성립하지 않는다.

[사실관계] 甲은 토지 브로커들과 공모공동 하여 乙에게 경기도 평택읍 임야 592평방미터는 丙의 소유인데 乙이 불법으로 등기를 경료 한 것이므로 위 임야를 丙에게 넘겨주지 않으면 형사처벌을 받게 할 것이라는 등의 협박을 가하여 乙을 외포케 하여 甲 명의로 위 임야의 일부에 관한 소유권이전등기를 넘겨받은 후 이를 丁에게 매도처분 하였다.

[판결요지] 횡령죄는 불법영득의 의사 없이 목적물의 점유를 시작한 경우라야 하고 타인을 공갈하여 재물을 교부케 한 경우에는 공갈죄를 구성하는 외에 그것을 소비하고 타에 처분하였다 하더라도 횡령죄를 구성하지는 않는다.

III. 불법원인급여와 횡령죄

1. 문제점

횡령죄에서 “보관”은 위탁관계에 기한 재물의 점유를 말하며, 그것은 위탁자에 대한 관계에서는 신뢰관계의 기초로서의 의미를 갖는다. 따라서 위탁관계가 불법인 경우에 횡령죄의 성부는 불법원인위탁물의 소유권이 누구에게 귀속되는지의 여부와 불법원인수탁이 횡령죄의 기초로 되는 위탁에 의한 점유에 해당되는지가 기준이 된다. 전자는 민법에 의하여 판단되어야 할 문제이지만, 후자는 형법적 판단의 문제인 것이다.

그렇다면 가령 공무원에게 증뢰하도록 위탁받은 재물이나 도박판에서 빌린 도박자금과 같은 불법원인급여물은 민법 제746조에 의하여 그 위탁관계가 불법하여 위탁자가 수탁자에 대하여 반환청구를 할 수 없는바, 이때 수탁자가 불법원인급여물을 착복한 경우에도 횡령죄가 성립하는가 하는 것이 문제된다.

2. 학설 - 부정설

㉠ 불법원인급여의 경우 보호받을 만한 위탁관계가 없고 ㉡ 위탁물의 소유권은 수탁자에게 귀속하므로 타인의 재물이 아니며 ㉢ 민법상 반환의무 없는 자에게 형법이 반환을 강제하는 것은 법질서의 통일성을 깨뜨리게 되므로 횡령죄가 부인된다는 견해이다(다수설, 판례).

3. 판례 - 부정설

판례 주택조합자금횡령사건(대판 1988.9.20. 86도628)

辯1·3 司48·55

[사실관계] 서울시 중계동 새마을 연립주택조합의 조합장인 피고인 甲이 자신의 집에서 도봉구청 도
시정비국장에게 공여한다는 명목으로 조합공금에서 인출한 금 1,000,000원 중 금 500,000원을 피고인
의 생활비 등에 임의 소비하고, 위 도봉구청 녹지와 직원들에게 공여한다는 명목으로 조합 공금에서 인
출한 금 500,000원 중 금 230,000원을 甲의 생활비 등에 임의소비하였다.

[판결요지] 민법 제746조에 불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이
익의 반환을 청구하지 못한다고 규정한 뜻은 급여를 한 사람은 그 원인행위가 법률상 무효임을 내세워
상대방에게 부당이득반환청구를 할 수 없고, 또 급여한 물건의 소유권이 자기에게 있다고 하여 소유권
에 기한 반환청구도 할 수 없어서 결국 급여한 물건의 소유권은 급여를 받은 상대방에게 귀속된다는 것
이므로 조합장이 조합으로부터 공무원에게 뇌물로 전달하여 달라고 금원을 교부받은 것은 불법원인으로
인하여 지급 받은 것으로서 이를 뇌물로 전달하지 않고 타에 소비하였다고 해서 타인의 재물을 보관 중
횡령하였다고 볼 수는 없다.

4. 결론

횡령죄의 성립요건으로서는 ‘재물의 타인성’과 ‘신임관계에 의한 위탁’이 그 본질적 요소가 되
는바, 불법원인급여의 경우 소유권은 수탁자에 있으므로 재물의 타인성은 부정되며, 형법은 불
법한 위탁관계 또는 민법에서 보호하지 않는 위탁관계까지 보호한다고 할 수 없으므로 횡령죄
의 성립을 부정하는 부정설이 타당하다.

5. 관련문제 - 수익자의 불법이 현저하게 큰 불법원인급여의 경우

불법원인급여의 경우 횡령죄의 성립을 부정하는 것이 통설과 판례의 태도이지만 수익자에게
만 불법이 있거나 또는 급여자와 비교하여 수익자의 불법이 현저하게 큰 경우에는 민법 제746
조 단서에 의하여 예외적으로 급여자에게 반환청구권을 인정한다고 보아 급여자에게 소유권이
귀속된다고 할 것이므로 횡령죄가 성립한다는 것이 다수설과 판례의 입장이다.

판례 윤락녀화대 임의소비사건(대판 1999.9.17. 98도2036) 司51

[판결요지] [1] 민법 제746조에 의하면, 불법의 원인으로 인한 급여가 있고, 그 불법원인이 급여자에
게 있는 경우에는 수익자에게 불법원인이 있는지 여부, 수익자의 불법원인의 정도, 그 불법성이 급여자
의 그것보다 큰지 여부를 막론하고 급여자는 불법원인급여의 반환을 구할 수 없는 것이 원칙이나, 수익
자의 불법성이 급여자의 그것보다 현저히 큰 데 반하여 급여자의 불법성은 미약한 경우에도 급여자의
반환청구가 허용되지 않는다면 공평에 반하고 신의성실의 원칙에도 어긋나므로, 이러한 경우에는 민법
제746조 본문의 적용이 배제되어 급여자의 반환청구는 허용된다.

[2] 포주가 윤락녀와 사이에 윤락녀가 받은 화대를 포주가 보관하였다가 절반씩 분배하기로 약정하고
도 보관중인 화대를 임의로 소비한 경우, 포주와 윤락녀의 사회적 지위, 약정에 이르게 된 경위와 약정
의 구체적 내용, 급여의 성격 등을 종합해 볼 때 포주의 불법성이 윤락녀의 불법성보다 현저히 크므로
화대의 소유권이 여전히 윤락녀에게 속한다는 이유로 횡령죄를 구성한다고 본 사례. → 판례는 문제된
매음료를 민법 제746조 본문의 적용 대상이 아니라, 불법원인이 오로지 수익자에게만 있는 경우에 그
이익의 반환을 청구할 수 있도록 규정한 제746조 단서의 적용대상으로 판단한 것이다.

♣ 확인학습문제

1. 甲이 A 회사의 직원이 착오로 甲 명의 은행 계좌에 잘못 송금한 돈을 임의로 인출하여 사용한 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 횡령죄
- ③ 배임죄
- ④ 사기죄
- ⑤ 업무방해죄

[정답] ②

[해설] 착오로 송금되어 입금된 돈을 임의로 인출하여 소비한 행위는 송금인과 피고인 사이에 별다른 거래관계가 없는 경우에도 횡령죄에 해당한다(대판 2010.12.9. 2010도891).

2. 다음 횡령죄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 부동산을 공동으로 상속한 자들 중 1인이 부동산을 혼자 점유하던 중 다른 공동상속인의 상속지분을 임의로 처분한 경우 횡령죄가 성립한다.
- ② 제3자에 대한 뇌물공여의 목적으로 전달하여 달라고 교부받은 돈을 전달하지 않고 임의로 소비하였다고 하더라도 횡령죄가 성립하지 않는다.
- ③ 횡령죄에서 재물 보관에 관한 위탁관계는 사실상의 관계에 있으면 충분하다.
- ④ 절도범이 피해자로부터 도품에 대한 반환요구를 받고 이를 거절하더라도 절도죄 이외에 횡령죄는 성립하지 않는다.
- ⑤ 부동산에 있어서 타인의 재물을 보관하는 자의 지위는 그 부동산을 제3자에게 유효하게 처분할 수 있는 권능의 유무에 따라 결정하여야 한다.

[정답] ①

[해설] 부동산을 공동으로 상속한 자들 중 1인이 부동산을 혼자 점유하던 중 다른 공동상속인의 상속지분을 임의로 처분하여도 그에게는 그 처분권능이 없어 횡령죄가 성립하지 아니한다(대판 2000. 4. 11, 2000도565).

3. 윤락업소 사장인 포주 甲은 가정형편이 극히 어려운 유부녀 A(28세)를 설득하여 성매매를 하도록 하였다. 甲과 A는 매음료를 절반씩 나누어 갖기로 약정을 하였으나, 甲은 A가 6개월 동안 받은 화대 4천만 원을 보관하던 중 A의 몫 2천만 원을 반환하지 않고 전액 소비하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사기죄
- ② 배임죄
- ③ 횡령죄
- ④ 공갈죄
- ⑤ 무죄

[정답] ③

[해설] 포주가 윤락녀와 사이에 윤락녀가 받은 화대를 포주가 보관하였다가 분배하기로 약정하고도 보관중인 화대를 임의로 소비한 경우, 포주의 불법성이 윤락녀의 불법성보다 현저히 크다는 이유로 횡령죄를 구성한다(대판 1999.9.17. 98도2036).

♣ 학습내용 정리

1. 횡령죄는 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 반환을 거부함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 횡령죄에서 “보관”은 위탁관계에 기한 재물의 점유를 말하며, 그것은 위탁자에 대한 관계에서는 신뢰관계의 기초로서의 의미를 갖는다.
3. 횡령죄는 신임관계에 위배하여 타인의 재물을 영득한다는 배신성에 그 본질이 있으므로 보관은 위탁관계에 의한 것임을 요한다.
4. 불법원인급여의 경우 보호받을 만한 위탁관계가 없고, 위탁물의 소유권은 수탁자에게 귀속하므로 타인의 재물이 아니다.

제27강 횡령죄의 행위객체

♣ 학습목표

- 횡령죄에서 재물의 타인성의 의미를 설명할 수 있다.
- 담보물권과 횡령죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 금전위탁물을 소비한 경우의 죄책을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 재물의 타인성
- 담보물권
- 양도담보
- 목적, 용도가 정해져 위탁된 금전

♣ 사전테스트

1. 채권 기타 권리 그 자체는 횡령죄의 객체가 될 수 없다.
정답 : O
2. 공동소유물도 횡령죄에 있어 타인의 재산이다.
정답 : O
3. 채무자가 양도담보가 설정된 목적물을 임의로 처분하면 횡령죄가 성립한다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

익명조합의 영업자가 영업이익금 등을 임의로 소비하였다면 횡령죄가 성립한다.

[정답] X

[해설] 조합 또는 내적 조합과 달리 익명조합의 경우에는 익명조합원이 영업을 위하여 출자한 금전 기타의 재산은 상대방인 영업자의 재산이 되므로 영업자는 타인의 재물을 보관하는 자의 지위에 있지 않고, 횡령죄가 성립할 수는 없다(대판 2011.11.24. 2010도5014).

♣ 강의내용

I. 행위의 객체 - 타인의 재물

1. 재물

본죄의 객체는 재물에 한하고, 재산상의 이익은 제외되므로 채권 기타 권리 그 자체는 횡령죄의 객체가 될 수 없다. → 상법상 주식은 자본구성의 단위 또는 주주의 지위(주주권)를 의미하고, 주주권을 표창하는 유가증권인 주권과는 구분이 되는바, 주권은 유가증권으로서 재물에 해당되므로 횡령죄의 객체가 될 수 있으나, 자본의 구성단위 또는 주주권을 의미하는 주식은 재물이 아니므로 횡령죄의 객체가 될 수 없다(대판 2005.2.18. 2002도2822).

2. 타인의 재물

(1) 재물의 타인성의 판단

재물의 소유권이 행위자 이외의 타인에 속하는 경우이다. 여기서 타인이란 자연인·법인·법인격 없는 단체 또는 조합을 포함한다. 따라서 공동소유물도 타인의 재산이다. 소유권의 귀속은 민법에 의하여 결정된다.

판례 (대판 2011.11.24. 2010도5014)

[1] 조합재산은 조합원의 합유에 속하므로 조합원 중 한 사람이 조합재산 처분으로 얻은 대금을 임의로 소비하였다면 횡령죄의 죄책을 면할 수 없고, 이러한 법리는 내부적으로는 조합관계에 있지만 대외적으로는 조합관계가 드러나지 않는 이른바 내적 조합의 경우에도 마찬가지이다.

[2] 조합 또는 내적 조합과 달리 익명조합의 경우에는 익명조합원이 영업을 위하여 출자한 금전 기타의 재산은 상대방인 영업자의 재산이 되므로 영업자는 타인의 재물을 보관하는 자의 지위에 있지 않고, 따라서 영업자가 영업이익금 등을 임의로 소비하였다면 횡령죄가 성립할 수는 없다.

(2) 1인 주주회사

주식회사의 주식이 사실상 1인의 주주에 귀속하는 1인회사의 경우에도 회사와 주주는 별개의 인격체로서 1인회사의 재산이 곧바로 그 1인 주주의 소유라고 볼 수 없으므로, 그 회사 소유의 금원을 업무상 보관 중 임의로 소비하면 횡령죄를 구성한다(대판 1999.7.09. 99도1040).

II. 담보물권과 횡령죄

1. 담보부·유보부 소유권 유형 - 부동산과 등기·등록 가능한 동산의 경우

(1) 원칙

가등기담보법에 의하여 양도담보, 대물반환의 예약, 환매 등 명목여하를 불문하고(제2조 1호), 채권자가 소유권이전등기를 하거나 담보가등기에 기하여 소유권이전본등기를 하더라도 이로써 소유권을 취득하는 것이 아니라 담보물권을 취득할 뿐이고, 청산금을 채무자에게 지급한 때에 소유권을 취득한다고 규정하고 있다(제4조). 따라서 양도담보·매도담보의 채권자는 청산기간이 경과한 후에 청산을 하여야만 비로소 담보목적물의 소유권을 취득할 수 있고, 그 때까지는 채무자가 여전히 소유권자가 된다.

(2) 채무자

채무자가 ‘변제기 전’ 또는 ‘청산금지급 전’에 목적부동산을 임의로 처분하는 행위는 자기소유물 처분행위에 불과하므로 횡령죄가 성립하는 것이 아니라 배임죄의 성부가 문제된다.

판례 (대판 1997.6.24. 96도1218) 司41·46

배임죄에 있어서 손해란 현실적인 손해가 발생한 경우뿐만 아니라 재산상의 위험이 발생한 경우도 포함되므로, 자신의 채권자와 부동산양도담보설정계약을 체결한 피고인이 그 소유권이전등기 경료 전에 임의로 기존의 근저당권자인 제3자에게 지상권설정등기를 경료하여 준 경우, 그 지상권 설정이 새로운 채무부담행위에 기한 것이 아니라 기존의 지당권자가 가지는 채권을 지당권과 함께 담보하는 의미밖에 없다고 하더라도 이로써 양도담보권자의 채권에 대한 담보능력 감소의 위험이 발생한 이상 배임죄를 구성한다.

(3) 채권자

(가) 변제기 도과 전

판례는 “채권의 담보를 목적으로 부동산의 소유권이전등기를 마친 채권자는 채무자가 변제기 일까지 그 채무를 변제하면 채무자에게 그 소유명의를 환원하여 주기 위하여 그 소유권이전등기를 이행할 의무가 있으므로 이 경우 배임죄가 성립한다.”고 하여 배임죄의 성립을 인정한다(대판 1992. 7.14, 92도753). 司46

(나) 변제기 도과 후

변제기 후에 등기명의인인 채권자가 목적부동산을 임의로 처분하는 것은 채무자 소유의 부동산이라고 하더라도 채권자의 담보권 실행행위이므로 불법영득의사를 인정할 수 없어서 횡령죄 내지는 배임죄는 성립하지 않는다.

2. 담보부·유보부 소유권 유형 - 동산

(1) 원칙

동산에 대해서는 가등기담보법의 직접적인 적용이 없으므로 민법상 법률관계에 관하여 신탁적 소유권이전설 등의 학설에 따라서 형법상 법률관계도 달라진다.

(2) 채무자

사법상 판례의 입장인 신탁적 소유권이전설에 의하면 대내적 관계에서는 여전히 채무자가 소유자가 되므로 채무자가 목적물을 임의로 처분하면 배임죄가 성립한다.

판례 (대판 1989.7.25. 89도350) 辯1 司34·43

금전채권을 담보하기 위하여 채무자 소유의 동산에 관하여 이른바 약한 의미의 양도담보가 설정되어 채무자가 그 동산을 점유하는 경우, 동산의 소유권은 신탁적으로 채권자에게 이전됨에 불과하여 채권자와 채무자간의 대내적 관계에서 채무자는 의연 소유권을 보유하게 되나 채권자인 양도담보권자가 담보의 목적을 달성할 수 있도록 이를 보관할 의무를 지게 되어 부당히 이를 처분하거나 멸실, 훼손 기타담보가치를 감소케 하는 행위가 금지된다 할 것이므로 채무자인 양도담보설정자는 채권자에 대하여 채권담보의 약정에 따른 그의 사무를 처리하는 자의 지위에 있게 된다 할 것이고, 위 채무자가 양도담보된 동산을 처분하는 등 부당히 그 담보가치를 감소시키는 행위를 한 경우에는 형법상 배임죄가 성립된다.

(3) 채권자

신탁적 소유권이전설을 따를 경우 점유개정이 있는 한 채권자는 목적물을 직접 점유하고 있지 않고 대내적 관계에서 채무자가 여전히 소유권자가 되므로 채권자가 목적물을 처분할 수 있는 여지는 없다. 만약 채권자가 목적물을 임의로 가져가서 처분하면 절도죄가 성립한다. 판례는 점유개정의 방법에 의한 양도담보부 금전소비대차계약의 채권자가 변제기일 후 채무자의 의사에 반하여 담보 목적물을 가져간 경우 절도죄의 성립을 인정한다.

판례 (대판 2005.6.24. 2005도2861) 辯4 司52

피해자와 사이에 피해자 소유인 채석장비들에 관하여 점유개정의 방법에 의한 양도담보부 금전소비대차계약을 체결하였는데 피해자가 변제기일이 지나도 채무를 변제하지 아니하자 채권자 회사의 직원들인 피고인들이 합동하여 피해자의 의사에 반하여 채석장비들을 임의로 분해하여 가지고 간 경우 영득의사는 있었다고 보아야 한다. → 비록 약정에 기한 인도 등의 청구권이 인정된다고 하더라도, 취거 당시에 점유 이전에 관한 점유자의 명시적·묵시적인 동의가 있었던 것으로 인정되지 않는 한, 점유자의 의사에 반하여 점유를 배제하는 행위를 함으로써 절도죄는 성립하는 것이다.

(4) 동산의 이중양도담보

채무자 甲이 자신 소유의 동산을 乙에게 양도담보로 제공하고 점유개정의 방법으로 점유하고 있다가 다시 이를 丙에게 양도담보로 제공하고 점유개정의 방법으로 점유하고 있었다. 甲은 최종적으로 이 동산을 丁에게 매각처분하여 현실인도하였다.

(가) 제1 양도담보권자 乙에 대한 죄책

1) 제2 양도담보권자 丙에게 이중양도담보를 설정한 행위

제2 양도담보권자는 제1의 담보권자인 피해자에 대하여 배타적으로 자기의 담보권을 주장할 수 없으므로 위와 같이 이중으로 양도담보제공이 된 것만으로는 제1의 양도담보권자에게 담보권의 상실이나 담보가치의 감소 등 손해가 발생한 것으로 볼 수 없으니 배임죄를 구성하지 않는다(대판 1990.2.13. 89도1931).

2) 제3자 丁에게 이를 현실인도하여 매각한 행위

판례의 태도인 신탁적 소유권이전설에 의하면 乙에 대하여 배임죄가 성립한다.

(나) 제2 양도담보권자에 대한 죄책 - 배임죄 불성립

판례 성형사출기 이중양도담보 사건(대판 2004.6.25. 2004도1751) 辯4 司49·50

금전채무를 담보하기 위하여 채무자가 그 소유의 동산을 채권자에게 양도하되 점유개정에 의하여 채무자가 이를 계속 점유하기로 한 경우 특별한 사정이 없는 한 동산의 소유권은 신탁적으로 이전됨에 불과하여 채권자와 채무자 사이의 대내적 관계에서 채무자는 의연히 소유권을 보유하나 대외적인 관계에 있어서 채무자는 동산의 소유권을 이미 채권자에게 양도한 무권리자가 되는 것이어서 다시 다른 채권자와 사이에 양도담보 설정계약을 체결하고 점유개정의 방법으로 인도를 하더라도 선의취득이 인정되지 않는 한 나중에 설정계약을 체결한 채권자는 양도담보권을 취득할 수 없는데, 현실의 인도가 아닌 점유개정으로선 선의취득이 인정되지 아니하므로, 결국 위의 채권자는 양도담보권을 취득할 수 없고, 따라서 이와 같이 채무자가 그 소유의 동산에 대하여 점유개정의 방식으로 채권자들에게 이중의 양도담보 설정계약을 체결한 후 양도담보 설정자가 목적물을 임의로 제3자에게 처분하였다면 양도담보권자라 할 수 없는 위의 채권자에 대한 관계에서는, 설정자인 채무자가 타인의 사무를 처리하는 자에 해당한다고 할 수 없어 배임죄가 성립하지 않는다.

이때 후양수인 丙이 목적물을 임의로 가져다가 처분하면 丙에게는 절도죄가 성립한다.

판례 (대판 2007.2.22. 2006도8649) 辯4

[1] 점유개정의 방법으로 동산에 대한 이종의 양도담보설정계약이 체결된 경우, 뒤에 설정계약을 체결한 이종양수 채권자가 양도담보권을 취득할 수 있는지 여부(소극) [2] 돈사에서 대량으로 사육되는 돼지에 대한 이종의 양도담보설정계약이 체결된 경우 뒤에 양도담보설정계약을 체결한 이종양수 채권자가 임의로 돼지를 반출한 행위가 절도죄를 구성한다.

III. 위탁물이 금전인 경우

1. 목적·용도를 정하여 위탁된 금전

가령 환전하여 달라는 부탁과 함께 교부받은 돈을 그 목적과 용도에 사용하지 않고 수탁자가 자신의 승용차를 구입하는 데 임의로 사용한 경우와 같이 일정한 목적과 용도를 정하여 위탁된 금전을 수탁자가 임의로 다른 용도로 사용한 경우 판례는 횡령죄의 성립을 인정한다.

판례 (대판 1997.9.26. 97도1520) 辯1 司49

환전하여 달라는 부탁과 함께 교부받은 돈을 그 목적과 용도에 사용하지 않고 마음대로 피고인의 위탁자에 대한 채권에 상계충당 함은 당초 위탁한 취지에 반하는 것으로서 횡령죄를 구성한다고 볼 것이고 위탁자에 대한 채권의 존재는 횡령죄의 성립에 영향을 미치는 것이 아니며, 또한 상계할 수 있는 반대채권이 있어 그에 상계충당 하였다는 것만으로는 용도 내지 목적을 특정하여 위탁한 돈의 반환을 거절할 정당한 사유가 되지 못한다.

2. 위탁매매

위탁매매인(수탁자)이 그 대금을 임의소비한 때에는 횡령죄가 성립한다.

판례 (대판 1990.8.28. 90도1019) 辯1 司34·46

피고인이 피해자로부터 피해자 소유의 다이아반지 1개를 팔아 달라는 부탁을 받고 교부받아 이를 판매한 대금을 보관 중 임의소비한 경우 피고인에게 불법영득의 의사가 있었다고 보아야 할 것이므로 피고인의 행위는 횡령죄를 구성한다.

3. 금전의 수수를 수반하는 사무처리를 위임받은 경우

목적·용도를 정하여 위탁된 금전의 문제가 동일하게 발생한다.

판례 (대판 1998.4.10. 97도3057) 司48

금전수수를 수반하는 사무의 처리를 위임받은 자가 그 행위에 기하여 위임자를 위하여 제3자로부터 수령한 금전은 그 목적이나 용도를 한정하여 위탁된 금전과 마찬가지로 특별한 사정이 없는 한 그 수령과 동시에 위임자의 소유에 속하는 것이고, 위임을 받은 자는 이를 위임자를 위하여 보관하는 관계에 있다. 위탁자로부터 당좌수표 할인을 의뢰받은 피고인이 제3자를 기망하여 당좌수표를 할인받은 다음 그 할인금을 임의 소비한 경우, 제3자에 대한 사기죄와 별도로 위탁자에 대한 횡령죄가 성립한다.

♣ **확인학습문제**

1. 다음 횡령죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 채무자가 '변제기 전' 또는 '청산금지급 전'에 목적부동산을 임의로 처분하는 행위는 횡령죄의 성부가 문제되는 경우이다.
- ② 주권은 횡령죄의 객체가 될 수 있으나, 주식은 횡령죄의 객체가 될 수 없다.
- ③ 위탁매매인이 위탁매매대금을 임의소비한 때에는 횡령죄가 성립한다.
- ④ 대외적인 관계에 있어서 동산에 양도담보를 설정한 채무자는 담보목적물을 점유개정의 방법으로 점유하고 있더라도 동산의 소유권을 이미 채권자에게 양도한 무권리자가 된다.
- ⑤ 1인 주주가 그 회사 소유의 금원을 업무상 보관 중 임의로 소비하면 횡령죄를 구성한다.

[정답] ①

[해설] 채무자가 '변제기 전' 또는 '청산금지급 전'에 목적부동산을 임의로 처분하는 행위는 자기소유물 처분행위에 불과하므로 횡령죄가 아니라 배임죄의 성부가 문제된다.

2. 채무자 甲은 자신 소유의 고가의 조선시대 병풍을 乙에게 양도담보로 제공하고 점유개정의 방법으로 점유하고 있다가 다시 이를 丙에게 양도담보로 제공하고 점유개정의 방법으로 점유하고 있었다. 돈이 궁해진 甲은 최종적으로 이 동산을 丁에게 매각처분하여 현실인도 하였다. 위의 사례에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 丙의 양도담보권자인 丙은 처음의 담보권자인 乙에 대하여 배타적으로 자기의 담보권을 주장할 수 없다.
- ② 甲이 乙에게 양도담보를 설정한 동산을 다시 丙에게 양도담보를 설정한 행위는 배임죄에 해당하지 않는다.
- ③ 甲이 丁에게 위의 병풍을 현실인도 하여 매각한 행위는 乙에 대하여 배임죄를 구성한다.
- ④ 甲이 丁에게 위의 병풍을 현실인도 하여 매각한 행위는 丙에 대한 배임죄에 해당한다.
- ⑤ 만약 丙의 양도담보권자인 丙이 위의 병풍을 임의로 가져다가 처분하면 丙에게는 절도죄가 성립한다.

[정답] ④

[해설] 양도담보권자라 할 수 없는 丙의 채권자 丙에 대한 관계에서는 설정자인 채무자 甲은 타인의 사무를 처리하는 자에 해당한다고 할 수 없어 배임죄가 성립하지 않는다(대판 2004.6.25. 2004도1751).

3. 甲은 乙로부터 액면금 20,000,000원인 당좌수표 1장의 할인을 의뢰받고, 사채업자 丙을 기망하여 위 수표를 선이자를 공제한 금 18,500,000원에 할인받아 보관하던 중 이를 임의로 소비하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사기죄와 횡령죄의 상상적 경합
- ② 사기죄와 횡령죄의 실체적 경합
- ③ 사기죄와 배임죄의 상상적 경합
- ④ 사기죄와 배임죄의 실체적 경합
- ⑤ 사기죄

[정답] ②

【해설】 위탁자로부터 당좌수표 할인을 의뢰받은 피고인이 제3자를 기망하여 당좌수표를 할인받은 다음 그 할인금을 임의소비한 경우, 제3자에 대한 사기죄와 별도로 위탁자에 대한 횡령죄가 성립한다(대판 1998.4.10. 97도3057).

♣ 학습내용 정리

1. 횡령죄의 객체는 자기가 보관하는 타인의 재물이고, 여기서 타인이란 자연인·법인·법인격 없는 단체 또는 조합을 포함한다.
2. 재물의 타인성을 결정함에 있어 소유권의 귀속은 민법에 의하여 결정된다.
3. 가등기담보법에 의하면 양도담보, 대물반환의 예약, 환매 등 명목여하를 불문하고, 채권자가 청산기간이 경과한 후에 청산을 하기 전까지는 채무자가 목적부동산의 소유권자가 된다.

제28강 명의신탁 받은 부동산과 횡령죄

♣ 학습목표

- 2자간 명의신탁의 내용을 설명할 수 있다.
- 중간생략형 명의신탁의 법리를 설명할 수 있다.
- 계약명의신탁의 유형과 그 의미내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 2자간 명의신탁
- 중간생략형 명의신탁
- 계약명의신탁
- 자동차 명의신탁

♣ 사전테스트

1. 2자간 명의신탁에 있어 명의신탁약정은 무효이고, 그에 기한 물권변동도 무효가 된다.
정답 : O
2. 부동산의 수탁자가 신탁자의 승낙 없이 매각처분함으로써 횡령죄가 성립하는 경우에는 매수인이 그 정을 알고 있었다면 횡령죄의 공동정범이 된다.
정답 : X
3. 계약명의신탁에 있어 부동산 매도인이 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못한 경우 수탁자 명의의 소유권이전등기는 무효가 된다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

계약명의신탁에 있어 수탁자는 신탁자에 대하여 부당이득반환의무를 부담한다.

[정답] O

[해설] 신탁자가 수탁자에게 제공한 매매대금 등의 급부는 법률상 원인이 없게 되고 수탁자는 신탁자의 손해 아래 매매대금 등을 수령하여 부동산의 소유권을 취득한 셈이 되므로 그 이익을 부당이득으로 신탁자에게 반환하여야 한다.

♣ 강의내용

I. 2자간 명의신탁

1. 원칙 및 문제점

부동산소유자(신탁자)가 수탁자와 명의신탁약정을 하고 수탁자명의로 부동산등기를 한 2자간 명의신탁 즉, 명의신탁이 신탁자와 수탁자의 2인으로 이루어지는 경우이다. 이 때 명의신탁약정은 무효이고 그에 기한 물권변동도 무효에 해당한다. 이에 수탁자의 죄책이 문제된다.

2. 학설 - 횡령죄 성립설

- ① 명의신탁의 사법상 무효와 형사처벌은 불법원인급여와 같은 전면적 불법에 해당하는 것이 아니라 행정목적 달성을 위한 제한적인 행정법적 불법성을 갖는데 지나지 않으므로 명의신탁부동산의 소유권은 당연히 명의신탁자에게 남아 있게 된다.
- ② 명의수탁자는 비록 사법상 무효인 등기의 명의인에 지나지 않지만 대외적으로 얼마든지 그 부동산을 유효하게 처분할 수 있는 지위에 있기 때문에 사실상의 위탁관계는 존재한다 할 것이므로 횡령죄에서 말하는 '보관자'의 지위를 가지고 있다.

3. 판례 - 횡령죄 성립설

판례 (대판 1999.10.12. 99도3170) 辯3 司42

신탁자가 그 소유명의로 되어 있던 부동산을 수탁자에게 명의신탁하였는데 수탁자가 임의로 부동산에 관하여 근저당권을 설정하였다면 신탁자에 대한 횡령죄가 성립하고 그 명의신탁이 부동산실권리자명의 등기에관한법을 시행 이후에 이루어진 것이라고 하여 달리 볼 것은 아니다.

II. 중간생략형 명의신탁

1. 원칙 및 문제점

명의신탁자가 원권리자로부터 부동산을 취득하면서 수탁자에게 직접 소유권을 이전한 3자간 명의신탁 즉, 명의신탁자가 매도인과 매매계약을 체결하고 등기는 명의수탁자인 제3자 앞으로 경료하는 중간생략 명의신탁의 경우이다. 이 경우에 명의신탁약정과 소유권이전등기가 무효이므로 부동산소유권은 매도인에게 복귀하여 매도인은 여전히 소유자가 된다. 따라서 수탁자는 소유자가 될 수 없는바, 이때 수탁자에 대하여 횡령죄가 성립하는가에 대해서는 견해가 대립한다.

2. 학설 - 매도인에 대한 횡령죄설

신탁자와 수탁자간의 명의신탁약정은 무효이고, 소유권은 여전히 원소유자인 매도인에게 있으므로 명의수탁자가 매도인에 대하여 갖는 관계에서 횡령죄가 성립한다.

3. 판례 - 신탁자에 대한 횡령죄설

판례 중간생략형 명의신탁사건(대판 2001.11.27. 2000도3463) 辯4 司44 · 46 · 48 · 56

[사실관계] 乙과의 명의신탁약정에 따라 乙이 丙으로부터 매수한 공주시 소재 토지를 甲 앞으로 막바로 소유권이전등기를 하여 보관하던 중, ① 위 토지의 일부인 70평에 대한 토지수용보상금 19,370,000원 중 5,370,000원을 임의로 소비하여 횡령하고, ② 乙로부터 위 토지의 소유명의를 돌려달

라는 요구를 받고 이를 거부하여 시가 금 1억 원 상당의 위 토지를 횡령하였다. → ①+② 사안 모두에 대하여 횡령죄가 성립하여 경합관계에 있다.

[판결요지] 부동산을 그 소유자로부터 매수한 자가 그의 명의로 소유권이전등기를 하지 아니하고 제3자와 맺은 명의신탁약정에 따라 매도인으로부터 바로 그 제3자에게 중간생략의 소유권이전등기를 경료한 경우, 그 제3자가 그와 같은 명의신탁 약정에 따라 그 명의로 신탁된 부동산을 임의로 처분하였다면 신탁자에 대한 횡령죄가 성립하고, 그 명의신탁이 부동산실권리자명의등기에관한법을 시행 전에 이루어졌고 같은 법이 정한 유예기간 이내에 실명등기를 하지 아니함으로써 그 명의신탁약정 및 이에 따라 행하여진 등기에 의한 물권변동이 무효로 된 후에 처분이 이루어졌다고 하여 달리 볼 것은 아니다.

4. 결론

매도인은 소유권이전의사로 대금을 지급받고 소유권이전등기를 하였으므로 피해자가 될 수도 없고, 명의수탁자에게 매도인의 재물을 보관하는 자의 지위도 인정되지 않는다. 그러나 매매대금을 지급하고 부동산을 취득하지 못한 손해를 입은 자는 결국 신탁자이므로 신탁자가 피해자가 된다. 결국 신탁자에 대해서 횡령죄가 성립한다는 판례가 타당하다.

III. 계약명의신탁

1. 의의

계약명의신탁이란 신탁자가 수탁자와 명의신탁약정을 맺고 신탁자의 위임에 따라 수탁자가 매매계약의 당사자가 되어 매도인과 매매계약을 체결한 후 그 등기를 수탁자 앞으로 이전하는 형식의 명의신탁이다. 다른 유형의 명의신탁에서는 매매계약 체결 등 부동산을 취득하는 과정은 신탁자가 행하면서 단지 등기명의만을 수탁자 앞으로 해놓는 것인데 비하여, 계약명의신탁은 신탁자가 계약당사자가 아니고, 수탁자가 직접 자신의 명의로 계약을 체결한다는 점에서 근본적인 차이가 있다. 매도인이 악의인 경우와 선의인 경우에 있어서 해석의 차이가 나타난다.

2. 매도인이 명의신탁사실을 알고 있는 경우

판례 매도인이 악의인 계약명의신탁사건(대판 2012.11.29. 2011도7361) 辯4 司55·57

[1] 이른바 계약명의신탁 방식으로 명의수탁자가 당사자가 되어 명의신탁 약정이 있다는 사실을 알고 있는 소유자와 부동산에 관한 매매계약을 체결하고 그 명의로 소유권이전등기를 마친 경우, 명의수탁자가 명의신탁자나 매도인에 대한 관계에서 ‘타인의 재물을 보관하는 자’ 또는 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있지 아니한다.

[2] 명의신탁자와 명의수탁자가 이른바 계약명의신탁 약정을 맺고 명의수탁자가 당사자가 되어 명의신탁 약정이 있다는 사실을 알고 있는 소유자와 부동산에 관한 매매계약을 체결한 후 그 매매계약에 따라 당해 부동산의 소유권이전등기를 명의수탁자 명의로 마친 경우에는 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 제4조 제2항 본문에 의하여 수탁자 명의의 소유권이전등기는 무효이고 당해 부동산의 소유권은 매도인이 그대로 보유하게 되므로 명의수탁자는 부동산 취득을 위한 계약의 당사자도 아닌 명의신탁자에 대한 관계에서 ㉠ 횡령죄에서의 ‘타인의 재물을 보관하는 자’의 지위에 있다고 볼 수 없고, ㉡ 또한 명의수탁자가 명의신탁자에 대하여 매매대금 등을 부당이득으로서 반환할 의무를 부담한다고 하더라도 이를 두고 배임죄에서의 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 보기도 어렵다.

한편 위 경우 명의수탁자는 매도인에 대하여 소유권이전등기말소 의무를 부담하게 되나, 위 소유권이전등기는 처음부터 원인무효여서 명의수탁자는 매도인이 소유권에 기한 방해배제청구로 그 말소를 구하는 것에 대하여 상대방으로서 응할 처지에 있음에 불과하고, 그가 제3자와 사이에 한 처분행위가 부동산실명법 제4조 제3항에 따라 유효하게 될 가능성이 있다고 하더라도 이는 거래의 상대방인 제3자를 보

호하기 위하여 명의신탁약정의 무효에 대한 예외를 설정한 취지일 뿐 매도인과 명의수탁자 사이에 위 처분행위를 유효하게 만드는 어떠한 신임관계가 존재함을 전제한 것이라고는 볼 수 없으므로 그 말소등 기의무의 존재나 명의수탁자에 의한 유효한 처분가능성을 들어 명의수탁자가 매도인에 대한 관계에서 횡령죄에서의 '타인의 재물을 보관하는 자' 또는 배임죄에서의 '타인의 사무를 처리하는 자'의 지위에 있다고 볼 수 없다.

3. 매도인이 명의신탁사실을 알지 못하는 경우

(1) 원칙 및 문제점

- ① 매도인이 명의신탁 약정이 있다는 사실을 알지 못한 경우에는 부동산실명법 제4조 제2항 단서에 의하여 그 물건변동은 유효하므로 수탁자 명의의 소유권이전등기는 확정적으로 유효하다. 그 결과 수탁자는 매도인뿐만 아니라 신탁자를 포함한 모든 사람에 대하여 그 소유권을 주장할 수 있다. 따라서 수탁자는 횡령죄에서 말하는 타인의 재물을 보관하는 자라고 볼 수 없다.
- ② 한편, 명의신탁약정이 무효이므로 신탁자는 수탁자에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기청구를 할 수 없음은 물론이다.
- ③ 다만 신탁자가 수탁자에게 제공한 매매대금 등의 급부는 법률상 원인이 없게 되고 수탁자는 신탁자의 손해 아래 매매대금 등을 수령하여 부동산의 소유권을 취득한 셈이 되므로 그 이익을 부당이득으로 신탁자에게 반환하여야 한다. 이 때 수탁자가 부동산을 영득하는 경우 어떠한 형사책임을 인정할 것인가가 문제된다.

(2) 판례 - 무죄설

판례 횡령죄가 성립하지 않는 것에 대한 논거(대판 2000.3.24. 98도4347)

辯1·4 司45

[판결요지] 부동산실권리자명의등기에관한법률의 규정에 의하면, 신탁자와 수탁자가 명의신탁 약정을 맺고, 이에 따라 수탁자가 당사자가 되어 명의신탁 약정이 있다는 사실을 알지 못하는 소유자와 사이에서 부동산에 관한 매매계약을 체결한 후 그 매매계약에 기하여 당해 부동산의 소유권이전등기를 수탁자 명의로 경료한 경우에는, 그 소유권이전등기에 의한 당해 부동산에 관한 물건변동은 유효하고, 한편 신탁자와 수탁자 사이의 명의신탁 약정은 무효이므로, 결국 수탁자는 전소유자인 매도인 뿐만 아니라 신탁자에 대한 관계에서도 유효하게 당해 부동산의 소유권을 취득한 것으로 보아야 할 것이고, 따라서 그 수탁자는 타인의 재물을 보관하는 자라고 볼 수 없다.

판례 (업무상)배임죄가 성립하지 않는 것에 대한 논거(대판 2004.4.27. 2003도6994)

辯4 司47

[사실관계] 회사의 총괄이사인 피고인 甲이 그 대표이사인 乙의 지시에 따라 甲 명의로 이 사건 아파트에 관한 분양권 매수계약을 체결하고 그 분양권을 취득하여 보관하던 중 甲이 피해 회사를 퇴사하게 되었음에도 불구하고 위 분양권 관련 서류를 반환하는 등의 업무상 임무를 이행하지 아니하고 오히려 甲 명의로 소유권이전등기를 경료함으로써 위 분양권 매매대금 8천만 원 상당의 재산상 이익을 취득하고, 피해 회사에 동액 상당의 손해를 가하였다.

[판결요지] 신탁자와 수탁자가 명의신탁약정을 맺고, 그에 따라 수탁자가 당사자가 되어 명의신탁약정이 있다는 사실을 알지 못하는 소유자와 사이에서 부동산에 관한 매매계약을 체결한 계약명의신탁에 있어서 수탁자는 신탁자에 대한 관계에서도 신탁 부동산의 소유권을 완전히 취득하고 단지 신탁자에 대하여 명의신탁약정의 무효로 인한 부당이득반환의무를 부담할 뿐인바, 그와 같은 부당이득반환의무는 명의신탁약정의 무효로 인하여 수탁자가 신탁자에 대하여 부담하는 통상의 채무에 불과할 뿐 아니라, 신탁자와 수탁자 간의 명의신탁약정이 무효인 이상, 특별한 사정이 없는 한 신탁자와 수탁자 간에 명의신탁약정과 함께 이루어진 부동산 매입의 위임 약정 역시 무효라고 볼 것이어서 수탁자를 신탁자와의

신임관계에 기하여 신탁자를 위하여 신탁 부동산을 관리하면서 신탁자의 허락 없이는 이를 처분하여서는 아니 되는 의무를 부담하는 등으로 신탁자의 재산을 보전·관리하는 지위에 있는 자에 해당한다고 볼 수 없어 수탁자는 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있지 않다.

4. 매수인(제3취득자)의 장물취득죄와 횡령죄 공범의 성부

(1) 횡령죄의 공동정범

부동산의 수탁자가 신탁자의 승낙 없이 매각처분함으로써 횡령죄가 성립하는 경우에는 매수인이 그 정을 알고 있었다 하더라도 수탁자와 짜고 불법영득할 것을 공모한 것이 아닌 한 횡령죄의 공동정범이 되지 아니 한다(대판 1971.1.26. 70도2173). 辯3

(2) 장물취득죄

신탁행위에서 수탁자가 외부관계에 대하여 소유자로 간주되므로 이를 취득한 제3자는 수탁자가 신탁자의 승낙 없이 매각하는 정을 알고 있는 여부에 불구하고 장물취득죄가 성립하지 아니 한다(대판 1979.11.27. 79도2410).

IV. 보론 - 자동차 명의신탁의 문제

판례 (대판 2013.2.28. 2012도15303) 司56

피고인 甲이 자신의 명의로 등록된 자동차를 사실혼 관계에 있던 乙에게 증여하여 乙만이 이를 운행·관리하여 오다가 서로 별거하면서 재산분할 내지 위자료 명목으로 乙이 소유하기로 하였는데, 甲이 이를 임의로 운전해 간 사안에서, 자동차 등록명의와 관계없이 피고인과 갑과 乙 사이에서는 乙을 소유자로 보아야 한다는 이유로 절도죄를 인정한 원심판단을 정당하다.

판례 (대판 2012.4.26. 2010도11771) 辯3·4 司55

[1] 당사자 사이에 자동차의 소유권을 등록명의자 아닌 자가 보유하기로 약정한 경우, 약정 당사자 사이의 내부관계에서는 등록명의자 아닌 자가 소유권을 보유하게 된다고 하더라도 제3자에 대한 관계에서는 어디까지나 등록명의자가 자동차의 소유자라고 할 것이다.

[2] 피고인이 자신의 모(母) 甲 명의로 구입·등록하여 甲에게 명의신탁한 자동차를 乙에게 담보로 제공한 후 乙 몰래 가져가 절취하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 乙에 대한 관계에서 자동차의 소유자는 甲이고 피고인은 소유자가 아니므로 乙이 점유하고 있는 자동차를 임의로 가져간 이상 절도죄가 성립한다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례.

♣ 확인학습문제

1. 다음 횡령죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 2자간 명의신탁의 경우 자신에게 명의수탁 된 부동산을 제3자에게 처분한 명의수탁자에게는 횡령죄가 성립한다.
- ② 甲이 자신의 명의로 등록된 자동차를 사실혼 관계에 있던 乙에게 증여하여 乙만이 이를 운행·관리하여 오다가 서로 별거하면서 재산분할 내지 위자료 명목으로 乙이 소유하기로 하였는데, 甲이 이를 임의로 운전해 간 경우 횡령죄가 성립한다.

- ③ 중간생략형 명의신탁의 경우 명의수탁자는 부동산 명의신탁자에 대하여 횡령죄가 된다.
- ④ 계약명의신탁에서 매도인이 명의신탁 약정이 있다는 사실을 알지 못한 경우에는 수탁자는 횡령죄에서 말하는 타인의 재물을 보관하는 자라고 볼 수 없다.
- ⑤ 명의신탁 된 부동산을 취득한 제3자에게는 장물취득죄가 성립하지 않는다.

【정답】 ②

【해설】 甲과 乙 내부관계에 있어서는 등록명의자 아닌 乙이 자동차의 소유권을 보유하게 되는 것이므로 절도죄가 성립한다(대판 2013.2.28. 2012도15303).

2. 甲은 자신의 직장상사인 乙의 간곡한 부탁으로 乙과 명의신탁약정을 맺고 부동산 실거래자를 자처하면서 丙 명의로 된 부동산에 관하여 매매계약을 체결하고 甲의 명의로 소유권이 전등기를 마쳤으나, 얼마 후 甲은 이 부동산을 A에게 매도하였다. 그런데 부동산 매도인 丙은 甲과 乙 사이에 명의신탁약정이 있다는 사실을 잘 알고 있었다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의하고, 특별법위반은 논외임)

- ① 무죄
- ② 매도인 丙에 대한 횡령죄
- ③ 매도인 丙에 대한 배임죄
- ④ 명의신탁자 乙에 대한 횡령죄
- ⑤ 명의신탁자 乙에 대한 배임죄

【정답】 ①

【해설】 명의수탁자 甲은 명의신탁자 乙이나 매도인 丙에 대한 관계에서 ‘타인의 재물을 보관하는 자’ 또는 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있지 아니하므로 배임죄나 횡령죄가 성립하지 않는다(대판 2012.11.29. 2011도7361).

3. 甲은 자신의 어머니 乙 명의로 구입·등록하여 乙에게 명의신탁한 자동차에 대하여 甲과 乙 사이에 자동차의 소유권을 甲이 보유하기로 약정을 맺었다. 그 후 甲은 이 자동차를 丙에게 담보로 제공하였는데, 甲은 丙 몰래 이 자동차를 미리 소지하고 있던 여벌의 자동차키를 사용하여 가져갔다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 횡령죄
- ③ 배임죄
- ④ 권리행사방해죄
- ⑤ 절도죄

【정답】 ⑤

【해설】 제3자인 丙에 대한 관계에서 자동차의 소유자는 등록명의자인 乙이므로 丙이 점유하고 있는 자동차를 임의로 가져간 이상 절도죄가 성립한다(대판 2012.4.26. 2010도11771).

♣ 학습내용 정리

1. 부동산실명법에 의하여도 중중소유재산의 명의신탁이나 배우자명의의 명의신탁과 같은 유효한 명의신탁의 경우에는 횡령죄가 성립한다(제8조).
2. 부동산소유자(신탁자)가 수탁자와 명의신탁약정을 하고 수탁자명의로 부동산등기를 한 2자간 명의신탁의 경우 명의신탁약정은 무효이고 그에 기한 물권변동도 무효에 해당한다.
3. 계약명의신탁에 있어서 매도인이 선의인 경우에는 수탁자는 유효하게 신탁부동산에 대한 소유권을 취득하게 되는데, 법이 유효하게 소유권취득을 인정한 소유자의 적법한 권리행사에 대해 가벌성을 인정하는 것은 타당하지 않다. 무죄를 인정하는 판례는 타당하다.

제29강 횡령행위와 불법영득의사

♣ 학습목표

- 횡령죄에서 횡령행위의 의미를 설명할 수 있다.
- 횡령죄의 불법영득의사를 내용을 설명할 수 있다.
- 업무상 횡령죄와 점유이탈물횡령죄의 의미내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 횡령행위
- 불법영득의사
- 업무상 횡령
- 점유이탈물횡령

♣ 사전테스트

1. 법률행위가 당연무효 일 경우에는 횡령죄가 성립하지 아니한다.
정답 : X
2. 횡령죄는 불법영득의사가 객관적으로 외부에 표현된 때 기수가 된다.
정답 : O
3. 타인의 재물을 보관하는 자의 반환거부행위가 횡령행위와 같다고 볼 수 있을 정도이면 반환의 거부행위는 횡령죄를 구성한다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

단순한 내심의 의사만으로도 횡령행위가 있었다고 할 수 있다.

[정답] X

[해설] 단순한 내심의 의사만으로는 횡령행위가 있었다고 할 수 없고, 영득의 의사가 외부에 인식될 수 있는 객관적 행위가 있을 때 횡령죄가 성립한다(대판 1993.3.9. 92도2999).

♣ 강의내용

I. 횡령행위

횡령죄의 행위는 횡령 또는 반환을 거부하는 것이다.

1. 횡령

횡령이란 불법영득의사를 객관적·외부적으로 표출하는 행위로 부작위에 의해서도 가능하다. 횡령은 소비·은닉·반출·점유의 부인 또는 착복과 같은 사실행위는 물론이고, 매매·교환·입질 또는 저당권설정이나 가등기와 같은 담보제공·증여·대여와 같은 법률행위도 포함한다. 그리고 법률행위의 유효·무효·취소 여부는 횡령죄의 성립에 지장이 없으므로 법률행위가 당연히 무효일 경우에도 횡령죄가 성립한다.

판례 공장기계 저당권설정사건(대판 2002.11.13. 2002도2219) *

[사실관계] 甲은 조카 A의 명의로 충남 예산군 소재 이천도에타일공장 및 그 부지 등을 소유자 주식회사 외환은행으로부터 성업공사의 공매를 통하여 427,100,000원에 매수하여 A의 명의로 소유권이전등기를 경료한 후 공장 및 기계를 인수하면서 피해자 乙이 외환은행으로부터 매수한 자동포장기 외 24개 품목의 기계도 함께 인도받아 乙을 위하여 보관하면서 그 기계들을 사용하여 명신세라믹이라는 상호로 공장을 실질적으로 운영하던 중, 충청은행 광천지점에서 지점장에게 위 공장의 기계 전부가 甲의 소유인 것처럼 공장 및 기계 일체를 담보로 한 대출신청을 하여 乙 소유 기계 중 14점의 기계에 관하여 충청은행을 채권자로 하는 근저당권설정계약을 체결하고 근저당권설정등기를 경료해 주었다.

[판결요지] 횡령죄는 다른 사람의 재물에 관한 소유권 등 본권을 그 보호법익으로 하고 본권이 침해될 위험성이 있으면 그 침해의 결과가 발생되지 아니하더라도 성립하는 이른바 위태범이므로, 다른 사람의 재물을 보관하는 사람이 그 사람의 동의없이 함부로 이를 담보로 제공하는 행위는 불법영득의사를 표현하는 횡령행위로서 사법(私法)상 그 담보제공행위가 무효이거나 그 재물에 대한 소유권이 침해되는 결과가 발생하는지 여부에 관계없이 횡령죄를 구성한다.

<횡령행위를 인정한 경우>

- ① 주식회사는 주주와 독립된 별개의 권리주체로서 이해가 반드시 일치하는 것은 아니므로, 주주나 대표이사 또는 그에 준하여 회사 자금의 보관이나 운용에 관한 사실상의 사무를 처리하는 자가 회사 소유 재산을 제3자의 자금 조달을 위하여 담보로 제공하는 등 사적인 용도로 임의 처분하였다면 그 처분에 관하여 주주총회나 이사회 결의가 있었는지 여부와는 관계없이 횡령죄의 죄책을 면할 수는 없다(대판 2011.3. 24. 2010도17396). 辯3
- ② 감정평가법인 지사에서 근무하는 감정평가사들이 접대비 명목 등으로 임의로 나누어 사용할 목적으로 감정평가법인을 위하여 보관 중이던 돈의 일부를 비자금으로 조성한 사안에서, 피고인들이 위 지사를 독립채산제로 운영하기로 했다고 하더라도 그것은 지사가 처리한 감정평가업무로 인한 경제적 이익의 분배에 관하여 그와 같이 약정을 한 것에 불과한 것이므로 피고인들이 사용한 지사의 자금이 법률상으로는 위 법인의 자금이 아니라고 할 수는 없다는 점 등에 비추어, 위 비자금 조성행위는 업무상횡령죄에 해당한다(대판 2010.5.13. 2009도1373). 司55
- ③ 마을 이장인 피고인이 경로당 화장실 개·보수 공사를 위하여 업무상 보관 중이던 공사비를 그 용도 외 에 다른 용도로 사용한 이상 횡령죄는 성립하고, 피고인이 과거 마을을 위하여 개인 돈을 지출하였다고 하여 이에 충당할 수는 없다(대판 2010.09.30. 2010도7012). 司55

2. 반환거부

반환거부란 불법영득의사로서 소유자의 반환요청에 대하여 소유자의 권리를 배제하는 의사표시를 하는 것이다. 여기서 반환의 거부가 횡령죄를 구성하려면 타인의 재물을 보관하는 자가 단순히 그 반환을 거부한 사실만으로는 부족하고 그 반환거부 이유와 주관적인 의사들을 종합하여 반환거부행위가 횡령행위와 같다고 볼 수 있을 정도이어야 한다. 따라서 비록 그 반환을 거부하였다고 하더라도 그 반환거부에 정당한 사유가 있어 이를 반환하지 아니하였다면 불법영득의 의사가 있다고 할 수 없다(대판 1998.7.10. 98도126).

3. 기수시기

불법영득의사가 객관적으로 외부에 표현된 때 기수가 된다(표현설). 이에 따르면 매매계약을 체결하거나 매매의 의사를 표시하는 청약에 의해서도 횡령은 이미 기수가 된다. 다만 부동산의 물권변동은 등기에 의하여 이루어지므로 그 부동산에 관하여 소유권이전등기를 경료받거나 또는 인도를 받은 때에 기수가 된다.

판례 (대판 1993.3.9. 92도2999)

횡령죄의 구성요건으로서의 횡령행위란 불법영득의사를 실현하는 일체의 행위를 말하고, 횡령죄에 있어서의 행위자는 이미 타인의 재물을 점유하고 있으므로 점유를 자기를 위한 점유로 변경하는 의사를 일으키면 곧 영득의 의사가 있었다고 할 수 있지만, 단순한 내심의 의사만으로는 횡령행위가 있었다고 할 수 없고 영득의 의사가 외부에 인식될 수 있는 객관적 행위가 있을 때 횡령죄가 성립한다.

4. 미수

횡령죄의 기수시기에 관한 표현설을 취하면 행위자가 처음부터 타인의 재물을 보관하고 있고, 불법영득의사가 객관적으로 외부에 표현되면 횡령은 이미 기수가 되므로 미수는 실제적으로 생략할 수 없다. 다만 아래 판례는 예외적으로 횡령미수를 인정한 판례이다.

판례 (대판 2012.8.17. 2011도9113) 辯3 司57

동업자 甲과 A의 합유물인 수목을 가식(假植)·관리 해오던 甲이 수목을 횡령할 의도로 A의 허락없이 제3자와 수목에 관한 매매계약을 체결하고 계약금만을 지급받은 상태에서, 이를 알게 된 A에 의해 수목에 관한 분리, 보관, 반출, 명인방법 등의 현실적·구체적인 일체의 조치가 저지된 경우 횡령죄의 미수가 성립한다.

II. 불법영득의사

1. 내용

타인의 재물을 보관하는 사람이 자기 또는 제3자의 이익을 꾀할 목적으로 업무상의 임무에 위배하여 보관하는 타인의 재물을 자기의 소유인 경우와 같이 사실상 또는 법률상 처분하는 의사를 말하고, 사후에 이를 반환하거나 변상, 보전하는 의사가 있다 하더라도 불법영득의 의사를 인정함에는 지장이 없다.

이때 반드시 자기 스스로 영득하여야만 횡령죄가 성립되는 것은 아니다(대판 2006.11.10. 2004도5167). 司53 → 제3자를 위한 횡령행위도 인정되는 것이다.

<불법영득의사를 인정한 경우>

- ① 법인의 구성원이 업무수행에 있어서 관계 법령을 위반함으로써 형사재판을 받게 된 경우 그의 개인적인 변호사비용을 법인자금으로 지급하는 것은 횡령에 해당하고 그 변호사 비용을 법인이 부담하는 것이 관례라고 하여도 그러한 행위가 사회상규에 어긋나지 않는다고 할 만큼 사회적으로 용인되어 보편화된 관례라고 할 수 없다(대판 2003.5.30. 2002도235). ㉮50
- ② 회사의 대표이사가 자신이 당사자일 뿐만 아니라 자신의 경영권을 방어하기 위한 목적으로 신주를 발행하는 과정에서 저지른 배임행위에 대한 소송을 수행하면서 그 변호사 비용을 회사의 자금으로 지급한 사안에서, 업무상횡령죄의 성립을 인정한 사례(대판 2008.6.26. 2007도9679). ㉮51
- ③ 회사의 대표이사가 보관 중인 회사 재산을 처분하여 그 대금을 정치자금으로 기부한 경우 ㉮ 그것이 회사의 이익을 도모할 목적으로 합리적인 범위 내에서 이루어졌다면 그 이사에게 횡령죄에 있어서 요구되는 불법영득의 의사가 있다고 할 수 없을 것이나, 그것이 회사의 이익을 도모할 목적보다는 ㉮ 후보자 개인의 이익을 도모할 목적이나 기타 다른 목적으로 행하여졌다면 그 이사는 회사에 대하여 횡령죄의 죄책을 면하지 못한다(대판 2005.5.26. 2003도5519). ㉮55
- ④ 대기업 회장이 모회사와 계열회사가 보관중인 용도가 특정되어 있지 않았던 자금을 임의로 다른 회사에 대여한 경우에 불법영득의사가 인정된다(대판 2006.11.10 2004도5167).

<불법영득의사를 부정한 경우>

- ① 분쟁에 대한 실질적인 이해관계는 단체에게 있으나 법적인 이유로 그 대표자의 지위에 있는 개인이 소송 기타 법적 절차의 당사자가 되었다거나 대표자로서 단체를 위해 적법하게 행한 직무행위 또는 대표자의 지위에 있음으로 말미암아 의무적으로 행한 행위 등과 관련하여 분쟁이 발생한 경우와 같이, 당해 법적 분쟁이 단체와 업무적인 관련이 깊고 당시의 제반 사정에 비추어 단체의 이익을 위하여 소송을 수행하거나 고소에 대응하여야 할 특별한 필요성이 있는 경우에 한하여 단체의 비용으로 변호사 선임료를 지출할 수 있다(대판 2006.10.26, 2006도6280). ㉮49・55
- ② 회사에 대하여 개인적인 채권을 가지고 있는 대표이사가 이사회 의 승인 등의 절차 없이 그와 같이 자신의 회사에 대한 채권을 변제하였더라도 이는 대표이사의 권한 내에서 한 회사채무의 이행행위로서 유효하며, 따라서 그에게는 불법영득의 의사가 인정되지 아니하여 횡령죄의 죄책을 물을 수 없다(대판 2002.7.26. 2001도5459). ㉮57

2. 타인소유・자기점유물을 기망행위로 영득한 경우

타인소유・자기점유물을 기망행위로 영득한 경우 사기죄의 객체는 타인소유・타인점유물이고, 또한 피기망자에 의한 재산처분행위도 없으므로 횡령죄만이 성립한다.

판례 (대판 1980.12.9, 80도1177) ㉮34・35・46・55

자기가 점유하는 타인의 재물을 횡령하기 위하여 기망수단을 쓴 경우에는 피기망자에 의한 재산처분행위가 없으므로 일반적으로 횡령죄만 성립되고 사기죄는 성립되지 아니한다.

[사실관계] 甲은 1978.4.2경 피해자 乙로부터 동인 소유의 임야 2필의 매각처분을 위임받은 다음 위 임야를 丙에게 대금 600,000원에 매도하였음에도 불구하고 乙에게 돈 300,000원에 처분하였다고 거짓 말을 하여 乙을 기망하고 이를 믿은 乙에게 돈 300,000원만을 교부하고 나머지 돈 300,000원을 교부하지 아니하고 나머지는 임의로 소비하였다.

III. 업무상 횡령죄와 점유이탈물횡령죄

1. 업무상 횡령죄(형법 제356조)

본죄는 위탁관계가 업무로 되어 있기 때문에 형벌이 가중되는 횡령죄의 가중적 구성요건이다. 여기서 업무가 꼭 직업 또는 영업이어야 할 필요는 없고, 판례에 따른 사실상의 것도 포함된다. 자기를 위한 업무, 타인을 위한 업무, 그리고 주된 업무, 부수적 업무를 불문한다. 면허가 없는 절차상 불법이 있더라도 업무 자체가 위법하지 않으면 여기의 업무에 해당한다.

판례 (대판 2011.10.13. 2009도13751) 司54

업무상횡령죄에서 ‘업무’는 법령, 계약에 의한 것뿐만 아니라 관례를 좇거나 사실상의 것이거나를 묻지 않고 같은 행위를 반복할 지위에 따른 사무를 가리키며, 횡령죄에서 재물 보관에 관한 위탁관계는 사실상의 관계에 있으면 충분하다.

판례 (대판 1982.1.12. 80도1970)

피고인이 등기부상으로 공소와 회사의 대표이사를 사임한 후에도 계속하여 사실상 대표이사 업무를 행하여 왔고 회사원들도 피고인을 대표이사의 일을 하는 사람으로 상대해 왔다면 피고인은 위 회사 소유 금전을 보관할 업무상의 지위에 있었다고 할 것이다.

2. 점유이탈물횡령죄(형법 제360조)

(1) 의의

점유이탈물횡령죄는 유실물·표류물·매장물 또는 그밖에 소유자가 점유권을 상실한 재물을 횡령함으로써 성립하는 범죄이다.

(2) 특징

점유침해가 없다는 점에서 절도죄와 구별되고, 소유자와 위탁관계에 의한 보관이 없다는 점에서 횡령죄 또는 업무상 횡령죄와 성질을 달리한다. 특히 소유권만을 침해하는 가장 단순한 재산범죄라는 점에서 독립된 별개의 범죄라고 보아야 한다.

(3) 행위객체

- ① 유실물·표류물·매장물 기타 점유이탈물이다. 유실물·표류물·매장물은 점유이탈물의 예시에 불과하다.
- ② 점유이탈물은 점유자의 의사와 상관없이 그 점유를 떠난 물건을 말한다. 이 때 누구의 점유에도 속하지 않는 물건뿐만 아니라 타인이 실수로 놓고 간 물건과 같이 점유자의 착오에 의한 것도 포함된다. 타인의 점유를 이탈한 물건인가의 여부에 따라 본죄와 절도죄가 구별된다. 원점유자가 물건의 소재를 알고 있고 다시 찾을 가능성이 있는 경우에는 점유를 이탈한 것이 아니므로 절도죄의 객체가 된다.

♣ 확인학습문제

1. 횡령죄의 불법영득의사를 인정한 경우가 아닌 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 법인의 구성원이 업무수행에 있어 관계 법령을 위반함으로써 형사재판을 받게 된 경우 그의 개인적인 변호사비용을 법인자금으로 지급하는 행위
- ② 회사의 대표이사가 자신이 당사자일 뿐만 아니라 자신의 경영권을 방어하기 위한 목적으로 신주를 발행하는 과정에서 저지른 배임행위에 대한 소송을 수행하면서 그 변호사 비용을 회사의 자금으로 지급한 행위
- ③ 회사의 대표이사가 보관 중인 회사 재산을 처분하여 그 대금을 정치자금으로 기부하였는데, 그것이 후보자 개인의 이익을 도모할 목적이거나 기타 다른 목적으로 행하여진 경우
- ④ 회사에 대하여 개인적인 채권을 가지고 있는 대표이사가 회사를 위하여 보관하고 있는 회사 소유의 금전으로 자신의 채권 변제에 충당하는 행위
- ⑤ 대기업 회장이 모회사와 계열회사가 보관중인 용도가 특정되어 있지 않았던 자금을 임의로 다른 회사에 대여한 행위

[정답] ④

[해설] 회사에 대하여 개인적인 채권을 가지고 있는 대표이사가 이사회 등의 절차 없이 그와 같이 자신의 회사에 대한 채권을 변제하였더라도 이는 대표이사의 권한 내에서 한 회사채무의 이행행위로서 유효하며, 따라서 그에게는 불법영득의 의사가 인정되지 아니하여 횡령죄의 죄책을 물을 수 없다(대판 2002.7.26. 2001도5459). 司57

2. 다음의 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 법률행위의 유효·무효·취소 여부는 횡령죄의 성립에 지장이 없다.
- ② 횡령죄의 성립에 반드시 자기 스스로 영득할 것을 요하지 않는다.
- ③ 횡령한 재물을 사후에 반환하거나 변상, 보전하는 의사가 있었다면 불법영득의 의사를 인정할 수 없다.
- ④ 업무상횡령죄에서 ‘업무’는 법령, 계약에 의한 것뿐만 아니라 관례를 좇거나 사실상의 것이거나를 묻지 않는다.
- ⑤ 원점유자가 물건의 소재를 알고 있고 다시 찾을 가능성이 있는 경우에는 점유를 이탈한 것이 아니므로 절도죄의 객체가 된다.

[정답] ③

[해설] 횡령한 재물을 사후에 반환하거나 변상, 보전하는 의사가 있다 하더라도 불법영득의 의사를 인정함에는 지장이 없다.

3. 甲은 乙로부터 동인 소유의 임야 2필의 매각처분을 위임받은 다음 위 임야를 丙에게 대금 6천만원에 매도하였음에도 불구하고 乙에게 돈 3천만원에 처분하였다고 거짓말을 하여 乙을 기망하고 이를 믿은 乙에게 돈 3천만원만을 교부하고 나머지 돈 3천만원을 교부하지 아니하고 나머지는 임의로 소비하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 횡령죄
- ③ 사기죄
- ④ 배임죄
- ⑤ 절도죄

【정답】 ②

【해설】 자기가 점유하는 타인의 재물을 횡령하기 위하여 기망수단을 쓴 경우에는 피기망자에 의한 재산처분행위가 없으므로 일반적으로 횡령죄만 성립되고 사기죄는 성립되지 아니한다(대판 1980.12.9. 80도1177).

♣ 학습내용 정리

1. 횡령죄의 행위는 횡령 또는 반환을 거부하는 것이다. 여기서 횡령이란 불법영득의사를 객관적·외부적으로 표출하는 행위로 부작위에 의해서도 가능하다.
2. 업무상 횡령죄는 위탁관계가 업무로 되어 있기 때문에 형벌이 가중되는 횡령죄의 가중적 구성요건이다.
3. 점유이탈물횡령죄는 유실물·표류물·매장물 또는 그밖에 소유자가 점유권을 상실한 재물을 횡령함으로써 성립하는 범죄이다.

제30강 배임죄(형법 제355조 제2항)

♣ 학습목표

배임죄의 의의를 설명할 수 있다.

배임죄의 행위주체에 대하여 설명할 수 있다.

배임행위의 내용을 설명할 수 있다.

배임죄에서 재산상 손해발생과 재산상 이익의 취득의 의미를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

배임

타인의 사무처리자

채권적 급부의무

자기의 사무

♣ 사전테스트

1. 배임죄는 그 성격에 있어 재물과 재산상 이익을 내용으로 하는 범죄이다.

정답 : X

2. 행위자와 본인 사이의 신뢰관계에 위반하여 재산을 침해하는 데 배임죄의 본질이 있다.

정답 : O

3. 재산상 손해발생의 위험조차 초래되지 아니한 경우에는 배임죄가 성립하지 아니 한다.

정답 : O

♣ 돌발퀴즈

공무원은 배임죄의 주체가 될 수 없다.

[정답] X

[해설] 공무원이 임무에 위배되는 행위로써 제3자로 하여금 재산상 이익을 취득하게 하여 국가에 손해를 가한 경우, 업무상배임죄가 성립한다(대판 2013.9.27. 2013도6835).

♣ 강의내용

Ⅰ. 행위주체 - 타인의 사무처리자

1. 배임죄의 의의

(1) 성격

타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배되는 행위를 하여 스스로 재산상 이익을 취득하거나 또는 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가하는 것을 내용으로 하는 범죄이다. 본죄는 그 성격에 있어서 재산상 이익만을 내용으로 하는 범죄이다.

(2) 보호정도

판례는 위태범으로 본다(대판 1975.12.23. 74도2215).

(3) 본질

행위자와 본인 사이의 신뢰관계에 위반하여 재산을 침해하는 데 배임죄의 본질이 있고(이른바 '배신설'), 이 점에서는 횡령죄와 본질을 같이 한다. 다만 횡령죄와 배임죄는 행위객체(재물 또는 재산상 이익)에서 차이가 있는 일반법과 특별법의 관계에 있다.

2. 행위주체

타인의 사무를 처리하는 자이다(진정신분범).

(1) 의의

(가) 개념

타인의 사무를 처리하는 자란 타인과의 대내적 신임관계에 의하여 맡겨진 사무를 그 타인을 위하여 신의성실의 원칙에 비추어 처리해야 할 의무를 지는 자이다. 반드시 제3자에 대한 대외 관계에서 그 사무에 관한 권한이 존재할 것을 요하지 않으며, 또 그 사무가 포괄적 위탁사무일 것을 요하는 것도 아니다.

(나) 범위

타인이란 행위자 이외의 모든 자연인, 법인, 법인격 없는 단체를 의미한다.

판례 (대판 1983.12.13. 83도2330) 司44

소위 1인 회사에 있어서도 행위의 주체와 그 본인은 분명히 별개의 인격이며, 그 본인인 주식회사에 재산상 손해가 발생하였을 때 배임죄는 기수가 되는 것이므로 궁극적으로 그 손해가 주주의 손해가 된다 하더라도 이미 성립한 죄에는 아무 소장이 없다.

(다) 배임죄에 있어서 배임행위자의 거래상대방이 공범이 될 수 있는 요건

판례 (대판 2005.10.28. 2005도4915) 辯4 司51 · 55 · 56

거래상대방의 대향적 행위의 존재를 필요로 하는 유형의 배임죄에 있어서 거래상대방을 배임의 실행 행위자와 공동정범으로 인정하기 위하여는 실행행위자의 행위가 피해자 본인에 대한 배임행위에 해당한다는 것을 알면서도 소극적으로 그 배임행위에 편승하여 이익을 취득한 것만으로는 부족하고, 실행행위

자의 배임행위를 교사하거나 또는 배임행위의 전 과정에 관여하는 등으로 배임행위에 적극 가담할 것을 필요로 한다.

(라) 공무원이 배임죄의 주체가 될 수 있는지 여부 - 긍정

판례 (대판 2013.9.27. 2013도6835)

공무원이 그 임무에 위배되는 행위로써 제3자로 하여금 재산상의 이익을 취득하게 하여 국가에 손해를 가한 경우에 업무상배임죄가 성립한다.

(2) 사무처리의 근거

- ① 타인의 사무를 처리하는 자가 되려면 타인과 사무처리자 사이에 일정한 신임관계가 있어야 한다. 이 때 타인의 사무를 처리하는 근거는 양자 사이에 법령(ex. 친권자·후견인·파산관재인·집행관·회사대표자 등), 계약(ex. 위임·고용·임차계약 등) 또는 대리권의 수여와 같은 법률행위에 의해서 발생한다.
- ② 또한 타인의 재산사무를 처리하는 신임관계는 신의성실의 원칙에 의하여도 발생하므로 사실상의 신임관계가 존재하면 관습·사무관리도 사무처리의 근거가 될 수 있다. 따라서 사무처리의 근거가 된 법률행위가 무효이거나 사무를 처리할 법적 권한이 소멸한 경우라 할지라도 맡았던 사무를 인계하기까지 사실상의 신임관계가 인정될 수 있다. 예컨대 대리권 소멸 후나 해임 이후에 후임자가 업무를 인수하기 전에 한 사무처리가 여기에 해당한다.
- ③ 사무처리의 근거가 된 법률행위가 공서양속에 반하는 등(민법 제103조) 명백하게 법적인 금지로 인하여 무효인 경우에는 처음부터 신임관계를 인정할 수 없으므로 배임죄가 성립하지 않는다.

판례 (대판 1986.9.9. 86도1382)

司47

내연의 처와의 불륜관계를 지속하는 대가로서 부동산에 관한 소유권이전등기를 경료해 주기로 약정한 경우 비록 위 등기의무를 이행하지 않는다 하더라도 배임죄를 구성하지 않는다.

(3) 타인의 사무

처리하는 사무는 타인의 사무이어야 한다. 타인의 사무인 동시에 자기사무의 성질을 가지고 있는 경우에도 전자가 전형적·본질적 내용을 이룰 때에는 타인의 사무를 처리하는 자가 된다. 예컨대 부동산의 이중매매·이중저당에서는 매도인이나 저당권설정자에게 선매수인에 대한 매도절차이행이나 선저당권자에 대한 저당권실행확보가 본질적으로 중요하기 때문에 타인의 사무로 보아야 한다.

판례 (대판 2009.5.28. 2009도2086)

배임죄에 있어서 타인의 사무라 함은 신임관계에 기초를 둔 타인의 재산의 보호 내지 관리의무가 있을 것을 그 본질적 내용으로 하는 것으로, 타인의 재산관리에 관한 사무를 대행하는 경우, 예컨대 위임, 고용 등의 계약상 타인의 재산의 관리·보전의 임무를 부담하는데 본인을 위하여 일정한 권한을 행사하는 경우, 등기협력의무와 같이 매매, 담보권설정 등 자기의 거래를 완성하기 위한 자기의 사무인 동시에 상대방의 재산보전에 협력할 의무가 있는 경우 따위를 말한다. → 아파트 건축공사의 시행사가 수분양자들에게 소유권 이전 등기절차를 이행하지 않은 채 분양계약서에 기재된 대출한도금액을 초과한 근저당권설정등기를 경료한 사안에서, 수분양자들에 대한 배임죄의 성립을 인정한 사례.

(4) 채권적 급부의무의 타인의 사무성

타인의 사무는 타인의 재산상의 이익을 보호해야 할 신의칙의 의무가 포함된 어느 정도 정형성을 갖춘 사무여야 하므로 타인에 대한 단순히 계약이행상의 일반적인 채권적 급부의무는 상대방의 재산상의 이익을 보호해야 할 본질적인 내용이 아니므로 타인의 사무가 아니다.

판례 (대판 1984.12.26. 84도2127) 司44

배임죄에서 “타인의 사무처리”로 오인되려면, 타인의 재산관리에 관한 사무의 전부 또는 일부를 타인을 위하여 대행하는 경우와 타인의 재산보전행위에 협력하는 경우라야만 되는 것이고, 단순히 타인에 대하여 채무를 부담함에 불과한 경우에는 본인의 사무로 인정될지언정 타인의 사무처리에 해당한다 할 수는 없다.

II. 배임행위

배임행위로 재산상 이익을 취득하여 본인에게 손해를 발생시킨 경우이다.

1. 배임행위의 개념

배임행위라 함은 사무처리자로서의 임무에 위배하여 본인과 의 신임관계를 파괴하는 일체의 행위이다. 임무에 위배하는 행위라 함은 처리하는 사무의 내용, 성질 등 구체적 상황에 비추어 법률의 규정, 계약의 내용 혹은 신의칙상 당연히 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대하는 행위를 함으로써 본인과 사이의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함하고, 그러한 행위가 법률상 유효인가, 무효인가 여부는 따져볼 필요가 없다.

따라서 배임행위는 권한남용·법률상의 의무위반, 법률행위·사실행위, 작위·부작위를 불문한다.

판례 (대판 1999.3.12. 98도4704) 司46·49·51

기업의 영업비밀을 사외로 유출하지 않을 것을 서약한 회사의 직원이 경제적인 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 피해자와의 신임관계를 저버리는 행위로서 업무상배임죄를 구성한다.

<배임행위를 인정한 경우>

- ① 배임죄의 성립에 있어서 행위자가 가사 본인을 위한다는 의사를 가지고 행위를 하였다고 하더라도 그 목적과 취지가 법령이나 사회상규에 위반된 위법한 행위로서 용인할 수 없는 경우에는 그 행위의 결과가 일부 본인을 위하는 측면이 있다고 하더라도 이는 본인과 의 신임관계를 저버리는 행위로서 배임죄의 성립을 인정함에 영향이 없다(대판 2002.7.22. 2002도1696). 司45·49
- ② 토지에 식재된 수목은 특별한 사정이 없는 한 그 토지의 부합물에 해당하여 그 토지에 설정된 근저당권의 효력이 미치므로, 근저당권설정자가 그 근저당권의 목적이 되는 토지에 식재된 수목을 처분하는 등으로 부당히 그 담보가치를 감소시키는 행위를 한 경우에는 배임죄가 성립하게 된다(대판 2007.1.11. 2006도4215).

<배임행위를 부정한 경우>

- ① 대표이사가 개인의 차용금 채무에 관하여 개인 명의로 작성하여 교부한 차용증에 추가로 회사의 법인 인감을 날인하였다고 하더라도 대표이사로서 행한 적법한 대표행위라고 할 수 없으므로 회사가 위 차용증에 기한 차용금 채무를 부담하게 되는 것이 아님은 물론이고, 나아가 금원의 대여자는 위와 같은 행위가 적법한 대표행위가 아님을 알았거나 알 수 있었다 할 것이어서 회사가 대여자에 대하여 사용자책임이나 법인의 불법행위 등에 따른 손해배상의무도 부담할 여지가 없으므로, 결국 회

사에 재산상 손해가 발생하였다거나 재산상 실해 발생의 위험이 초래되었다고 볼 수 없으므로 업무상 배임죄는 성립하지 않는다(대판 2004.4.9. 2004도771). 司5257

- ② 거래처의 기존대출금에 대한 연체이자에 충당하기 위하여 위 거래처가 신규대출을 받은 것처럼 서류상 정리한 부분은 조합의 대출금원장 등에는 형식적으로 대출금이 거래처에게 교부된 것처럼 되어 있으나 실질적으로는 위 거래처에게 대출금이 새로 교부된 것이 아니므로 그로 인하여 조합 측에 어떤 새로운 손해가 발생하는 것은 아니라고 할 것이어서 업무상배임죄가 성립된다고 볼 수 없다(대판 1997.9.26. 97도1469). 司57

III. 재산상 손해발생과 재산상 이익의 취득

1. 재산상의 손해

- ① 본인의 전체의 재산가치가 감소되는 것을 말한다. 관리자의 의무위반으로 본인의 재산증식이 없게 된 경우인 소극적 손해도 손해개념에 포함된다. 재산상 손해의 유무에 대한 판단은 본인의 전재산상태와의 관계에서 법률적 판단에 의하지 아니하고 경제적 관점에서 파악하여야 한다.
- ② 이 때 현실적으로 손해가 발생한 경우뿐만 아니라 가치의 감소라고 볼 수 있는 재산상의 위험이 발생한 경우도 포함한다. 따라서 법률적 판단에 의하여 당해 배임행위가 무효라 하더라도 경제적 관점에서 파악하여 배임행위로 인하여 본인에게 현실적인 손해를 가하였거나 재산상 실해발생의 위험을 초래한 경우에는 재산상의 손해를 가한 때에 해당한다. 다만 재산상 손해발생의 위험조차 초래되지 아니한 경우에는 배임죄가 성립하지 아니 한다(대판 2011.7.14. 2011도3180).

판례 (대판 2009.10.29. 2007도6772)

업무상배임죄에서 본인에게 손해를 가한 때라 함은 총체적으로 보아 본인의 재산상태에 손해를 가한 경우를 말하고, 실해 발생의 위험을 초래케 한 경우도 포함하는 것이므로 손해액이 구체적으로 명백하게 산정되지 않았더라도 업무상배임죄의 성립에는 영향이 없다. → A, B가 공모하여 甲 회사의 영업비밀인 회로도 등의 기술정보들을 유출한 사안에서, 유출된 기술정보들이 가지는 액수 미상의 시장교환가격 상당의 손해가 발생하였다고 보아 업무상배임죄의 죄책을 인정한 사례.

2. 자기 또는 제3자의 재산상 이익취득

설령 본인에게 재산상 손해가 발생해도 관리인 자신 또는 제3자가 재산상 이익을 얻지 않으면 배임행위가 성립하지 않는다. 재산상 이익의 취득이란 전체 재산상태가 보다 유리하게 형성되는 것을 말한다. 여기서 제3자라 함은 사무처리자 또는 본인을 제외한 자를 말한다. 배임죄에서 재산상 이익의 취득은 반드시 피해자의 처분행위에 기인할 필요는 없다.

배임죄는 본인에게 재산상의 손해를 가하는 외에 배임행위로 인하여 행위자 스스로 또는 제3자로 하여금 재산상의 이익을 취득할 것을 요건으로 하므로, 본인에게 손해를 가하였다고 할지라도 재산상 이익을 행위자 또는 제3자가 취득한 사실이 없다면 배임죄가 성립하지 않는다(대판 2009.12.24. 2007도2484).

3. 실행의 착수 및 기수시기

실행의 착수시기는 배임의 고의로 배임행위를 개시한 때이다. 배임행위를 개시했으나 본인에게 재산상 손해가 발생하지 않은 경우는 배임죄의 미수에 불과하다.

배임죄는 재산상 손해가 발생하거나 손해의 위험이 발생한 경우 기수가 된다(통설, 판례).

♣ 확인학습문제

1. 다음 배임죄에 대한 판례의 태도 중 잘못된 것은?

- ① 본인에게 손해를 가하였다고 할지라도 재산상 이익을 행위자 또는 제3자가 취득한 사실이 없다면 배임죄가 성립하지 않는다.
- ② 근저당권설정자가 그 근저당권의 목적이 되는 토지에 식재된 수목을 처분하는 등으로 부당히 그 담보가치를 감소시키는 행위를 한 경우 배임죄가 성립한다.
- ③ 행위자가 본인을 위한다는 의사를 가지고 행위를 하였고 그 행위의 결과가 일부 본인을 위하는 측면이 있었다면 설사 그 목적과 취지가 법령이나 사회상규에 위반된 위법한 행위로서 용인할 수 없는 경우라도 배임죄가 성립하지 않는다.
- ④ 단순히 타인에 대하여 채무를 부담함에 불과한 경우에는 본인의 사무로 인정될지언정 타인의 사무처리에 해당한다 할 수 없다.
- ⑤ 기업의 영업비밀을 유출하지 않을 것을 서약한 직원이 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출한 행위는 업무상배임죄에 해당한다.

【정답】 ③

【해설】 배임죄의 성립에 있어 행위자가 가사 본인을 위한다는 의사를 가지고 행위를 하였고 하더라도 그 목적과 취지가 법령이나 사회상규에 위반된 위법한 행위로서 용인할 수 없는 경우에는 그 행위의 결과가 일부 본인을 위하는 측면이 있다고 하더라도 배임죄의 성립을 인정함에 영향이 없다(대판 2002.7.22. 2002도1696).

2. 다음 배임죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 배임행위를 개시했으나 본인에게 재산상 손해가 발생하지 않은 경우는 배임죄의 미수에 불과하다.
- ② 판례는 배임죄를 위태범으로 본다.
- ③ 타인의 재산사무를 처리하는 신임관계는 신의성실의 원칙에 의하여도 발생할 수 있다.
- ④ 타인의 사무인 동시에 자기사무의 성질을 가지고 있는 경우에도 전자가 전형적·본질적 내용을 이룰 때에는 타인의 사무를 처리하는 자가 된다.
- ⑤ 대표이사가 개인의 차용금 채무에 관하여 개인 명의로 작성하여 교부한 차용증에 추가로 회사의 법인 인감을 날인한 경우 업무상배임가 성립한다.

【정답】 ⑤

【해설】 이는 대표이사로서 행한 적법한 대표행위라고 할 수 없으므로 회사가 위 차용증에 기한 차용금 채무를 부담하게 되는 것이 아니어서 업무상 배임죄가 성립하지 않는다(대법원 2004.04.09. 선고 2004도771).

3. 법률상의 훗가 있는 甲은 내연의 처 乙과의 불륜관계를 지속하는 대가로 부동산에 관한 소유권이전등기를 乙에게 경료해 주기로 약정하였으나 끝내 이를 이행하지 않았을 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 배임죄
- ③ 사기죄
- ④ 횡령죄
- ⑤ 권리행사방해죄

【정답】 ①

【해설】 위 부동산 증여계약은 선량한 풍속과 사회질서에 반하는 것으로 무효이어서 동인이 타인의 사무를 처리하는 자에 해당한다고 볼 수 없어 비록 위 등기의무를 이행하지 않는다 하더라도 배임죄를 구성하지 않는다(대판 1986.9.9. 86도1382).

♣ 학습내용 정리

1. 배임행위라 함은 사무처리자로서의 임무에 위배하여 본인과 의 신임관계를 파괴하는 일체의 행위이다.
2. 재산상 손해발생은 본인의 전체의 재산가치가 감소되는 것을 말한다.
3. 배임죄에서 재산상 이익의 취득은 반드시 피해자의 처분행위에 기인할 필요는 없다.
4. 배임죄의 실행의 착수시기는 배임의 고의로 배임행위를 개시한 때이다. 그리고 재산상 손해가 발생하거나 손해의 위험이 발생한 경우 기수가 된다.

제31강 부동산과 동산의 이중매매

♣ 학습목표

- 부동산 이중매매의 법리를 설명할 수 있다.
- 부동산의 이중저당의 내용을 설명할 수 있다.
- 동산이중매매에 대하여 설명할 수 있다.
- 업무상 배임죄의 내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 부동산 이중매매
- 부동산의 이중저당
- 동산이중매매
- 업무상 배임죄

♣ 사전테스트

1. 매도인의 등기협력의무는 곧 배임죄에 있어 타인의 사무가 된다.
정답 : ○
2. 매도인이 다시 후매수인과 매매계약을 체결하고 중도금까지 받은 때 배임죄의 실행의 착수가 인정된다.
정답 : ○
3. 이중매매 된 부동산을 매수한 악의의 후매수인에 대하여는 장물취득죄가 성립한다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

매도한 부동산에 대하여 가등기를 경료한 경우에는 배임죄가 성립하지 않는다.

[정답] X

[해설] 매도한 부동산에 대하여 가등기(대판 1985.10.8. 83도1375)를 경료한 경우에도 배임죄가 성립한다.

♣ 강의내용

1. 부동산의 이중매매

1. 의의

매도인이 선매수인에게 자기의 부동산을 매도하였으나 이전등기를 아직 경료해 주지 않은 상태에서 이를 후매수인에게 다시 매도하고 후매수인에게 소유권이전등기를 경료해 준 경우이다.

2. 관련문제

(1) 횡령죄의 성부

부동산 물권변동에 관해 등기주의(형식주의)를 취한 현행 민법에서는 소유권이전등기가 경료되기까지는 부동산은 매도인의 소유이므로 횡령죄는 성립되지 않는다.

(2) 사기죄의 성부

(가) 사기죄가 부정되는 경우

- ① 후매수인은 유효하게 소유권을 취득하므로 거래에 있어서 신의칙에 반할 정도의 기망이 있었다고 할 수 없어 후매수인에 대한 사기죄는 성립하지 않는다.
- ② 또한 이를 선매수인에 대한 삼각사기로 볼 경우 후매수인에게는 피해자의 재산을 처분할 수 있는 법적 권한 내지 사실상의 지위에 있다고 볼 수 없으므로 후매수인은 선매수인의 재산 처분권자라고 볼 수 없고, 따라서 선매수인에 대한 사기죄도 성립되지 않는다.

(나) 사기죄가 성립하는 경우

후매수인에 대한 사기죄의 성부와 관련하여 판례(대판 1991.12.24. 91도2698)에 따르면 부동산의 이중매매에 있어서 후매수인에게 당초부터 소유권을 이전하여 줄 의사가 없었음에도 있는 듯이 속이거나 매매목적물에 관하여 이미 제3자의 신청에 의하여 처분금지가처분결정이 된 경우 등과 같이 계약을 이행함에 있어서 법률상의 제한이 있음에도 이를 고지하지 아니하고 매매계약을 체결하는 경우 등에만 후매수인에 대한 사기죄가 성립된다.

3. 부동산매매

(1) 매도인의 의무

매도인이 등기이전에 협력하지 않으면 매수인의 소유권취득은 불가능하므로 매도인의 등기협력의무는 매수인의 재산보호를 본질적 내용으로 하는 타인의 사무가 된다.

(2) 등기협력의무의 발생시기 - 중도금교부시

중도금을 수령하면 해제가 불가능하므로(민법 제565조 제1항) 타인의 사무로서의 등기협력의무가 발생한다.

판례 (대판 1986.7.8. 85도1873) ㉮57

이중매매에 있어서 매도인이 매수인의 사무를 처리하는 자로서 배임죄의 주체가 되기 위하여는 매도인이 계약금을 받은 것만으로는 부족하고 적어도 중도금을 받는 등 매도인이 더 이상 임의로 계약을 해할 수 없는 상태에 이르러야 한다.

(3) 실행의 착수시기

매도인이 다시 제3자와 매매계약을 체결하고 중도금까지 받은 때이다.

판례 (대판 1983.10.11. 83도2057) 司48

매도인이 부동산을 제1차 매수인에게 매도하고 계약금과 중도금까지 수령한 이상 특단의 약정이 없는 한 잔금수령과 동시에 매수인 명의로의 소유권이전등기에 협력할 임무가 있고 이 임무는 주로 위 매수인을 위하여 부담하는 임무라 할 것이므로, 위 매매계약이 적법하게 해제되지 않은 이상 매도인이 다시 제3자와 사이에 매매계약을 체결하고 계약금과 중도금까지 수령한 것은 제1차 매수인에 대한 소유권이전등기 협력 임무의 위배와 밀접한 행위로서 배임죄의 실행착수라고 보아야 할 것이다.

판례 (대판 2003.3.25. 2002도7134) 辯1 司46·53·55

피고인이 제1차 매수인으로부터 계약금 및 중도금 명목의 금원을 교부받은 후 제2차 매수인에게 부동산을 매도하기로 하고 계약금만을 지급 받은 뒤 더 이상의 계약 이행에 나아가지 않았다면 배임죄의 실행의 착수가 있었다고 볼 수 없다.

(4) 기수시기

제3자(후매수인)에게 소유권이전등기를 경료해 준 때이다.

판례 (대판 1984.11.27. 83도1946) 辯3·4

부동산의 매도인이 매수인 앞으로의 소유권이전등기에 협력할 의무가 있음에도 불구하고 같은 부동산을 위 매수인 이외의 자에게 2중으로 매도하여 그 소유권이전등기를 마친 경우에는 1차 매수인에 대한 소유권이전등기임무는 이행불능이 되고 이로써 1차 매수인에게 그 부동산의 소유권을 취득할 수 없는 손해가 발생하는 것이므로 부동산의 2중매매에 있어서 배임죄의 기수시기는 2차 매수인 앞으로 소유권이전등기를 마친 때라고 할 것이다.

(5) 악의의 이중매수인의 책임

① 이중매매 된 부동산은 재산범죄로 인하여 영득한 재물이 아니므로 후매수인에 대하여 장물취득죄는 성립할 여지가 없다. ② 다만 구체적인 행위사태에 따라서 배임죄의 교사범 또는 공동정범이 성립한다.

판례 (대판 1975.6.10. 74도2455) 司56

이미 타인에게 매도되었으나 소유권이전등기가 경료되지 아니하고 있는 부동산을 이중으로 매수 기타 양수하는 자에 대하여 배임죄의 죄책을 묻기 위하여는 이중으로 양수하는 자가 단지 그 부동산이 이미 타인에게 매도되었음을 알고 이중으로 양수하는 것만으로는 부족하고 먼저 매수한 자를 해할 목적으로 양도를 교사하거나 기타 방법으로 양도행위에 적극 가담한 경우에 한하여 양도인의 배임행위에 대한 공범이 성립된다.

II. 동산의 이중매매

판례 동산이중매매와 배임죄의 성부(대판 2011.1.20. 2008도10479 전원합의체) 辯1·4 司53·54·55
·56·57

[사실관계] 甲은 자신소유의 인쇄기 한대를 고양시 덕양구에 있는 乙의 회사에 보관해 놓고 2005년4월께 피해자 丙에게 1억3,500만원에 팔기로 계약했다. 이후 甲은 丙에게 계약금 등을 주면 잔금을 내기 전에 인쇄기를 미리 주겠다고 약속하고 세 차례에 걸쳐 총 4,300여만원을 받았다. 하지만 甲은 인쇄기를 넘기지 않고 오히려 인쇄기를 보관하고 있던 乙과 같은해 7월 인쇄기 매매계약을 체결해 배임 혐의

로 기소됐다. 1,2심은 모두 "甲이 丙에게 잔금 지급전에도 인채기를 주겠다고 한 것은 丙의 편의를 봐주기 위해 호의적으로 한 말에 불과해 甲에게는 인채기를 선이행해야 할 의무가 없다"면서 "인채기를 丙에게 인도해야 할 의무는 민사상의 채무에 불과할 뿐 타인의 사무라고 볼 수 없어 甲이 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없다"며 甲에게 무죄를 선고했다.

[판결요지] [다수의견] 당사자 일방이 재산을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생기는 계약의 경우(민법 제563조), 쌍방이 그 계약의 내용에 좇은 이행을 하여야 할 채무는 특별한 사정이 없는 한 '자기의 사무'에 해당하는 것이 원칙이다. 매매의 목적이 동산일 경우, 매도인은 매수인에게 계약에 정한 바에 따라 그 목적이 동산을 인도함으로써 계약의 이행을 완료하게 되고 그때 매수인은 매매목적물에 대한 권리를 취득하게 되는 것이므로, 매도인에게 자기의 사무인 동산인도채무 외에 별도로 매수인의 재산의 보호 내지 관리 행위에 협력할 의무가 있다고 할 수 없다. 동산매매계약에서의 매도인은 매수인에 대하여 그의 사무를 처리하는 지위에 있지 아니하므로, 매도인이 목적물을 매수인에게 인도하지 아니하고 이를 타에 처분하였다 하더라도 형법상 배임죄가 성립하는 것은 아니다.

[소수의견] "계약 당사자 사이에 중도금이 수수되는 등 계약이 일정 단계 이상으로 진행된 경우에는 동산의 이중매매 행위도 부동산 이중매매 등과 마찬가지로 배임죄로 처벌할 수 있다. 즉 계약상 채무의 이행이 자기 사무의 처리라는 성격과 동시에 타인의 재산 관리·보전에 협력하는 의미를 지니고 있는 경우에 그 채무자는 타인의 사무를 처리하는 자에 해당하므로 거래관계에서 발생하는 당사자 간의 신임관계는 형벌법규에 의한 제재를 통해 보호할 가치가 있는 법익이라는 점에서 배임죄 처벌의 당위성을 발견할 수 있다."

III. 이중저당

1. 내용

甲이 乙에게 자기 부동산에 1번 저당권을 설정해 주기로 약정한 후 아직 그 등기가 되지 않은 상태에서 丙에게 다시 저당권을 설정해 주고 丙에게 1번 저당권 설정등기를 마친 경우이다. 이중매매와 달리 저당권은 얼마든지 설정가능하므로 이중저당은 민법상 유효하다고 할 것이나, 선순위저당권자이어야 할 乙이 후순위저당권자로 밀림으로써 충분히 변제를 받지 못할 가능성으로 인하여 재산손해발생의 위험이 존재한다.

이 경우 저당권설정등기에 협력해야 할 의무는 타인의 재산보호를 본질적 내용으로 하는 타인의 사무이므로 배임죄가 성립한다.

판례 (대판 1993.9.28. 93도2206)

배임죄에 있어서 피해자와 주택에 대한 전세권설정계약을 맺고 전세금의 중도금까지 지급 받고도 임의로 타에 근저당권설정등기를 경료해 줌으로써 전세금반환채무에 대한 담보능력 상실의 위험이 발생되었다고 보인다면 위 등기 경료행위는 배임죄를 구성한다.

2. 가등기, 근저당설정등기, 전세권등기

부동산을 이중으로 매매한 경우뿐만 아니라 매도한 부동산에 대하여 가등기(대판 1985.10.8. 83도1375)나 근저당설정등기(대판 1990.10.16. 90도1702)를 경료하거나 전세권등기(대판 1969.9.30. 69도1001)를 경료한 경우에도 배임죄가 성립한다.

판례 (대판 2008.7.10. 2008도3766) 司52·54

매도인이 부동산을 제3자에게 이중매매하고 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기를 마쳐 준 경우, 배임죄를 구성하는지 여부(적극) - 부동산의 매도인으로서 매수인에 대하여 그 앞으로의 소유권이전등

기절차에 협력할 의무 있는 자가 그 임무에 위배하여 같은 부동산을 매수인 이외의 제3자에게 이중으로 매도하고 제3자 앞으로 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기를 마쳐 주었다면, 이는 매수인에게 손해 발생의 위험을 초래하는 행위로서 배임죄를 구성한다.

IV. 보론 - 업무상 배임죄(형법 제356조)

1. 성격

타인의 사무를 처리하는 것이 업무인 사람이 배임죄를 행한 경우 가중처벌하는 가중구성요건(부진정신분범)이다. 본죄는 타인의 사무를 처리하는 자와 업무자라는 두 가지 신분을 요구하는 이중의 신분범이다.

2. 업무의 근거

배임죄의 주체로서 ‘타인의 사무를 처리하는 자’란 타인과의 대내관계에 있어서 신의성실의 원칙에 비추어 그 사무를 처리할 신임관계가 존재한다고 인정되는 자를 의미하고, 반드시 제3자에 대한 대외관계에서 그 사무에 관한 대리권이 존재할 것을 요하지 않으며, 업무상 배임죄에 있어서의 업무의 근거는 법령, 계약, 관습의 어느 것에 의하건 묻지 않고, 사실상의 것도 포함한다.

업무상 배임행위가 기수가 된 이후에 타인이 이에 가담한 경우에는 업무상 배임죄의 공동정범이 될 수 없다.

판례 (대판 2003.10.30. 2003도4382) 辯1·4 司46

[1] 업무상배임죄의 실행으로 인하여 이익을 얻게 되는 수익자 또는 그와 밀접한 관련이 있는 제3자를 배임의 실행행위자와 공동정범으로 인정하기 위하여는 실행행위자의 행위가 피해자 본인에 대한 배임행위에 해당한다는 것을 알면서도 소극적으로 그 배임행위에 편승하여 이익을 취득한 것만으로는 부족하고, 실행행위자의 배임행위를 교사하거나 또는 배임행위의 전 과정에 관여하는 등으로 배임행위에 적극 가담할 것을 필요로 한다. [2] 회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출한 때 업무상배임죄의 기수에 이르렀다고 할 것이고, 그 이후에 위 직원과 접촉하여 영업비밀을 취득하려고 한 자는 업무상배임죄의 공동정범이 될 수 없다.

[사실관계] 甲은 삼성전자를 퇴직한 후에 삼성전자의 영업비밀과 관련된 벤처기업에 취업할 경우 업무에 활용할 목적으로, 삼성전자의 영업비밀을 CD-R과 디스켓에 저장한 후 CD-R을 반출하여 집으로 가져왔고, 그 후 휴대폰 기술개발업체인 벨웨이브의 대표이사인 乙을 만나 벨웨이브에 취업하고 싶다고 하면서 삼성전자의 영업비밀에 관한 자료를 집에 보관하고 있다고 말하였는데, 乙은 알았다고 하면서 甲의 요구를 받아들여 연봉 6,500만원 외에 벨웨이브의 주식 3만 주를 주기로 약정하였고, 그 후 삼성전자에 사직서를 제출하면서 위 디스켓마저 집으로 가져와 보관하고 있다가 벨웨이브에 취업한 다음 甲은 CD-R과 디스켓에 들어 있는 영업비밀을 벨웨이브의 서버컴퓨터에 제공하였다.

♣ 확인학습문제

1. 다음 부동산 이중매매에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 선매수인으로부터 중도금을 수령하면 타인의 사무로서의 등기협력의무가 발생한다.
- ② 후매수인으로부터 계약금을 지급받은 경우 배임죄의 실행의 착수가 있다.
- ③ 후매수인에게 소유권이전등기를 경료해 준 때 배임죄는 기수가 된다.
- ④ 부동산 매도인은 후매수인에 대하여 사기죄의 죄책을 지지 않는다.
- ⑤ 부동산 매도인에게 횡령죄는 성립되지 않는다.

[정답] ②

[해설] 부동산의 이중양도에 있어서 매도인이 제2차 매수인(후매수인)으로부터 계약금만을 지급받고 중도금을 수령한 바 없다면 배임죄의 실행의 착수가 있었다고 볼 수 없다(대판 2003.3.25. 2002도7134).

2. 甲은 자신의 명품시계를 A에게 대금을 받고 매도하였으나, 아직 A에게 시계를 인도하기 전에 B가 자신이 돈을 2배 더 주겠으니 자신에게 팔라는 제의를 받고는 주저 없이 대금을 받고 이 시계를 B에게 인도, 교부하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사기죄
- ② 배임죄
- ③ 무죄
- ④ 횡령죄
- ⑤ 권리행사방해죄

[정답] ③

[해설] 매매의 목적물이 동산일 경우, 매도인은 자기의 사무인 동산인도채무 외에 별도로 매수인의 재산의 보호 내지 관리 행위에 협력할 의무가 있다고 할 수 없어 배임죄가 성립하지 않는다(대판 2011.1.20. 2008도10479 전원합의체).

3. 甲은 자신이 근무하던 A회사를 퇴직하면서 A회사의 영업비밀과 관련된 벤처기업에 취업할 경우 업무에 활용할 목적으로 A회사의 영업비밀을 메모리 카드에 저장한 후 메모리 카드를 반출하여 집으로 가져왔다. 그 후 甲은 그간의 잘 사정을 알고 있는 B 벤처기업의 대표이사인 乙을 만나 고액의 연봉을 조건으로 B 회사에 입사하기로 합의를 하였고, 甲은 입사 후 메모리 카드에 들어 있는 영업비밀을 B 회사의 서버컴퓨터에 제공하였다. 이 경우 甲과 乙의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의하고, 특별법은 논외임)

- ① 甲과 乙은 업무상 배임죄의 공동정범
- ② 甲 : 업무상 배임죄, 乙 : 배임죄
- ③ 甲과 乙은 배임죄의 공동정범
- ④ 甲 : 업무상 배임죄, 乙 : 무죄
- ⑤ 甲 : 업무상 배임죄, 乙 : 업무상 배임죄의 교사범

[정답] ④

[해설] 회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출한 때 업무상배임죄의 기수에 이르렀다고 할 것이고, 그 이후에 위 직원

과 접촉하여 영업비밀을 취득하려고 한 자는 업무상배임죄의 공동정범이 될 수 없다(대판 2003.10.30. 2003도4382).

♣ 학습내용 정리

1. 부동산의 이중매매는 매도인이 선매수인에게 자기의 부동산을 매도하였으나 이전등기를 아직 경료해 주지 않은 상태에서 이를 후매수인에게 다시 매도하고 후매수인에게 소유권이전등기를 경료해 준 경우이다.
2. 동산이중매매에 있어 매도인이 목적물을 매수인에게 인도하지 아니하고 이를 타에 처분하였다 하더라도 형법상 배임죄가 성립하는 것은 아니다.
3. 업무상 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 것이 업무인 사람이 배임죄를 행한 경우 가중처벌 하는 가중구성요건(부진정신분범)이다.

제32강 장물죄(형법 제362조)

♣ 학습목표

- 장물죄의 의의와 행위주체에 대하여 설명할 수 있다.
- 장물죄의 행위객체인 장물에 대하여 설명할 수 있다.
- 환전통화의 장물성에 대한 판례의 태도에 대하여 설명할 수 있다.
- 장물죄의 행위태양에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 대체장물
- 환전통화의 장물성
- 장물취득
- 장물알선

♣ 사전테스트

1. 순수이득죄인 배임죄와 비영득죄인 손괴죄는 장물죄의 본범이 될 수 없다.
정답 : O
2. 친족상도례가 적용되는 경우에는 장물성은 부정된다.
정답 : X
3. 뇌물, 도박판돈과 같이 비재산죄로 인하여 취득한 재물도 장물이 될 수 있다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

장물죄는 재산범죄의 본범에 대한 사후방조범이 된다.

[정답] X

[해설] 장물죄는 비록 본범비호적인 성격을 가지고 있으나 어디까지나 독립된 범죄이고 본범에 대한 사후방조범이 되는 것이 아니다.

♣ 강의내용

I. 행위주체

1. 장물죄의 의의

장물을 취득·양도·운반·보관하거나 또는 이를 알선하는 내용의 범죄이다. 장물이 발생한 원인이 되는 재산범죄를 본범이라고 한다. 따라서 본범은 장물죄에 시간적으로 선행한다. 장물죄는 비록 본범비호적인 성격을 가지고 있으나 어디까지나 독립된 범죄이고 본범에 대한 사후방조범이 되는 것이 아니다.

2. 행위주체

- ① 본범의 정범, 공동정범, 합동범을 제외한 모든 자이다. 본범의 정범은 장물죄의 주체가 될 수 없으므로 본범의 정범의 장물행위는 본범의 불가벌적 사후행위가 아니라 처음부터 구성요건해당성이 인정되지 않는다. 다만 판례는 불가벌적 사후행위로 본다. 간접정범도 본범의 정범에 포함된다(대판 1986.9.9. 86도1273).
- ② 그러나 본범의 교사범·방조범은 장물범이 될 수 있다. 이때 본범에 대한 공범과 장물죄는 죄수론상 실체적 경합관계에 있다. → 횡령 교사를 한 후 그 횡령한 물건을 취득한 때에는 횡령교사죄와 장물취득죄의 경합범이 성립된다(대판 1969.6.24. 69도692). 司56

II. 행위객체 - 장물

1. 장물의 개념

장물은 선행한 재산범죄로 영득한 재물이다.

2. 장물의 요건

(1) 재물성

장물죄의 객체는 원칙적으로 재물에 국한된다. 재물인 이상 동산이나 부동산을 불문한다. 권리나 가치와 같은 재산상 이익은 장물죄의 객체가 되지 않는다. 다만 권리나 가치가 문서(물건)로 화체된 경우(ex. 유가증권 등)는 여기서의 재물이 된다. 그리고 관리할 수 있는 동력도 형법이 재물로 간주하는 한 비록 장물죄에 제346조 동력에 관한 준용규정이 없더라도 장물이 될 수 있다(대판 1972.6.13. 72도971). 司57

(2) 본범의 성질

장물은 재산범죄에 의하여 영득한 재물이어야 한다.

- ① 뇌물, 도박판돈과 같이 비재산죄로 인하여 취득한 재물은 장물이 아니다.
- ② 장물죄의 본범은 절도·강도·사기·공갈·횡령죄이다. 그리고 장물죄도 재산죄이므로 장물죄의 본범이 될 수 있다. 배임수증재죄에서 그 행위객체가 재물인 때에는 장물죄의 본범이 될 수 있다. 그러나 순수이득죄인 배임죄와 비영득죄인 손괴죄는 장물죄의 본범이 될 수 없다.

- ③ 재산범죄에 의하여 영득한 재물만이 장물이 될 수 있으므로 범죄에 의하여 작성된 물건이나 재산범죄의 수단으로 사용된 재물도 장물이 될 수 없다. 부동산 이종매매에 제공된 부동산이 그 예이다.

판례 (대판 1983.11.8. 82도2119)

司46·53

양도담보로 제공한 후 다시 타에 양도한 물건은 배임행위에 제공한 물건이지 배임행위로 인하여 영득한 물건 자체는 아니므로 장물이라고 볼 수 없다.

(3) 장물성의 상실

재산범죄에 의하여 영득한 재물이 모두 장물이 되는 것이 아니라 재물이 위법한 점유상태에 있는 때에만 장물이 될 수 있다. 따라서 본범 또는 제3자가 장물에 대하여 하자 없는 소유권을 취득한 때에는 장물성을 상실하게 되어 장물죄는 성립하지 않는다.

- ① 명의신탁 부동산처럼 본범이 대외관계에서 소유자로서 처분권한을 가지고 처분한 경우(대판 1979.11.27. 79도2410)
- ② 민법 제249조에 의하여 제3자가 선의취득한 재물은 장물이 아니다. 다만 목적물이 도품이나 유실물일 때에는 도난 또는 유실한 날로부터 2년간 장물성이 소멸되지 않는다.

(4) 본범의 실현정도

장물죄가 성립하기 위해서 본범의 행위는 적어도 구성요건에 해당하고 위법해야 한다. 따라서 본범이 책임무능력자인 경우에도 장물죄는 성립한다. 또한 본범에게 처벌조건이나 소추조건은 요하지 않으므로 본범에 대한 공소시효가 완성된 경우, 친족상도례가 적용되는 경우 장물성은 인정된다.

(5) 재물의 동일성

장물은 본범으로부터 취득한 원래의 재물이거나 적어도 그것과 물질적 동일성이 인정되는 것 이어야 한다. 원형을 어느 정도 변형하였더라도 그 동일성을 잃지 않는 한 장물성이 인정된다.
ex.) 귀금속을 금괴로 변형한 경우, 도별한 원목을 제재·반출한 경우

(가) 대체장물(장물의 대가물)의 장물성

- ① 장물이란 재산범죄로 인하여 취득한 물건 그 자체를 말하는 것에는 의문이 없으나, 그 장물의 처분대가인 대체장물을 장물로 볼 수 있는가와 관련하여 장물의 매각대금, 장물과 교환한 재물은 물론, 장물인 돈으로 매입한 재물과 같은 대체장물은 모두 장물이 될 수 없다.
- ② 다만 절취한 재물을 처분하는 경우 민법 제250조의 해석상 별도로 사기죄가 성립하므로 도품의 처분에 의하여 받은 돈은 사기죄의 장물이 될 수 있다.

(나) 환전통화의 장물성

1) 문제점

가령 甲이 절취한 100만원권 자기앞수표를 금융기관에 예금하였다가 1만원권으로 전액 인출하여 그 정을 아는 乙에게 채무변제로 교부한 경우 장물성이 여전히 유지되는 지가 문제되는 바, 만약 이를 긍정한다면 그 정을 알고 이 돈을 수령한 乙은 장물죄의 죄책을 지게 될 것이다. 이는 장물의 처분대가 또는 교환물의 한 예로서 장물인 통화를 환전하여 받은 현금, 장물인 수표로 지급받은 현금, 나아가 장물인 통화 또는 수표를 예금하였다가 인출한 현금의 경우를 모두 포괄하는 문제이다.

2) 판례 - 긍정설

통화를 환전한 통화나 수표를 지급제시하거나 교부하고 지급받은 현금에 대하여 장물의 동일성이 유지되는 것으로 보는바, 통화는 물건의 영득보다는 가치취득, 즉 금액에 중심을 두고 널리 대체성이 인정된다는 점을 논거로 장물성을 인정한다.

판례 (대판 2000.3.10, 98도2579)

司44·53·56

장물이라 함은 재산범죄로 인하여 취득한 물건 그 자체를 말하고, 그 장물의 처분대가는 장물성을 상실하는 것이지만, 금전은 고도의 대체성을 가지고 있어 다른 종류의 통화와 쉽게 교환할 수 있고, 그 금전 자체는 별다른 의미가 없고 금액에 의하여 표시되는 금전적 가치가 거래상 의미를 가지고 유통되고 있는 점에 비추어 볼 때, 장물인 현금을 금융기관에 예금의 형태로 보관하였다가 이를 반환받기 위하여 동일한 액수의 현금을 인출한 경우에 예금계약의 성질상 인출된 현금은 당초의 현금과 물리적인 동일성은 상실되었지만 액수에 의하여 표시되는 금전적 가치에는 아무런 변동이 없으므로 장물로서의 성질은 그대로 유지된다고 봄이 상당하고, 자기앞수표도 그 액면금을 즉시 지급받을 수 있는 등 현금에 대신하는 기능을 가지고 거래상 현금과 동일하게 취급되고 있는 점에서 금전의 경우와 동일하게 보아야 한다.

[사실관계] 모 주식회사 영업3팀 과장인 A는 자신이 감원 대상이라는 것을 알고서 이에 반발하여, 거래처로부터 물품대금 명목으로 교부받아 보관 중이던 약속어음 8매 액면 합계 8억 여 원을 영득할 의사로, 이를 할인 의뢰할 권한이 없음에도 B에게 할인을 의뢰하여 교부받은 금전을 자신 명의의 예금계좌에 예치하였다가 그 대부분을 현금으로 인출하였다가 피고인 甲에게 그와 같이 취득 보관 중이던 현금 중 금 9,500만원을 보관하여 달라는 부탁을 하였고, 甲은 이를 교부받아 자신의 집에 보관하고, A로부터 총 2,000만원을 자신의 집에서 교부받아 취득하였다. → 장물보관죄와 장물취득죄의 실체적 경합

III. 행위

장물을 취득·양도·운반·보관 또는 이러한 행위를 알선하는 것이다.

1. 취득

판례 (대판 2010.12.9 2010도6256)

辯1·3·4 司54·56

[1] 사기죄의 객체는 타인이 점유하는 ‘타인의’ 재물 또는 재산상의 이익이므로, 피해자와의 관계에서 살펴보면 그것이 피해자 소유의 재물인지 아니면 피해자가 보유하는 재산상의 이익인지에 따라 ‘재물’이 객체인지 아니면 ‘재산상의 이익’이 객체인지 구별하여야 하는 것으로서, 이 사건과 같이 피해자가 본범의 기망행위에 속아 현금을 피고인 명의의 은행 예금계좌로 송금하였다면, 이는 재물에 해당하는 현금을 교부하는 방법이 예금계좌로 송금하는 형식으로 이루어진 것에 불과하여, 피해자의 은행에 대한 예금채권은 당초 발생하지 않는다.

[2] 장물취득죄에서 ‘취득’이라 함은 장물의 점유를 이전받음으로써 그 장물에 대하여 사실상 처분권을 획득하는 것을 의미하는데, 이 사건의 경우 본범의 사기행위는 피고인이 예금계좌를 개설하여 본범에게 양도한 방조행위가 가공되어 본범에게 편취금이 귀속되는 과정 없이 피고인이 피해자로부터 피고인의 예금계좌로 돈을 송금받아 취득함으로써 종료되는 것이고, 그 후 피고인이 자신의 예금계좌에서 위 돈을 인출하였다 하더라도 이는 예금명의자로서 은행에 예금반환을 청구한 결과일 뿐 본범으로부터 위 돈에 대한 점유를 이전받아 사실상 처분권을 획득한 것은 아니므로, 피고인의 위와 같은 인출행위를 장물취득죄로 벌할 수는 없다.

[사실관계] 甲은 사기 범행에 이용되리라는 사정을 알고서도 자신의 명의로 새마을금고 예금계좌를 개설하여 乙에게 이를 양도함으로써 乙이 丙을 속여 丙으로 하여금 1,000만 원을 위 계좌로 송금하게 한 사기 범행을 방조한 피고인 甲이 위 계좌로 송금된 돈 중 140만 원을 인출하여 乙이 편취한 장물을 취득하였다.

2. 양도

취득한 장물을 제3자에게 수여하는 것이다. 장물양도는 유상·무상을 불문한다.

3. 운반

판례 (대판 1999.3.26. 98도3030)

司43·46

피고인이 본범이 절취한 차량이라는 점을 알면서도 본범 등으로부터 그들이 위 차량을 이용하여 강도를 하려 함에 있어 차량을 운전해 달라는 부탁을 받고 위 차량을 운전해 준 경우, 피고인은 강도예비와 아울러 장물운반의 고의를 가지고 위와 같은 행위를 하였다고 봄이 상당하다.

4. 보관

위탁을 받고 장물을 자기점유에 두는 것이다. 장물인 줄 모르고 보관했다가 사후에 장물인 줄 알고도 계속 보관하면 그 사실을 안 때부터 장물보관죄가 성립한다. 이 경우 점유할 권한이 있는 때에는 이를 계속하여 보관하더라도 장물보관죄가 성립하지 않는다(판례).

판례 (대판 1986.1.21. 85도2472)

司44·45·56

피고인이 채권의 담보로서 이 사건 수표들을 교부받았다가 장물 인정을 알게 되었음에도 이를 보관한 행위처럼 장물인 점을 모르고 장물을 보관하였다가 그 후에 장물인 점을 알게 된 경우 그 점을 알고서도 이를 계속하여 보관하는 행위는 장물죄를 구성하는 것이나 이 경우에도 점유할 권한이 있는 때에는 이를 계속하여 보관하더라도 장물보관죄가 성립하지 않는다.

5. 알선

알선은 장물의 취득·양도·운반 또는 보관을 매개하거나 주선하는 행위로, 알선의 방법은 제한 없이 본범 또는 장물취득자와의 합의 또는 추정적 승낙 하에서 이루어져야 한다.

판례 (대판 2009.4.23. 2009도1203)

辯2 司53·56

[1] 형법 제362조 제2항에 정한 장물알선죄에서 '알선'이란 장물을 취득·양도·운반·보관하려는 당사자 사이에 서서 이를 중개하거나 편의를 도모하는 것을 의미한다. 따라서 장물인 점을 알면서, 장물을 취득·양도·운반·보관하려는 당사자 사이에 서서 서로를 연결하여 장물의 취득·양도·운반·보관행위를 중개하거나 편의를 도모하였다면, 그 알선에 의하여 당사자 사이에 실제로 장물의 취득·양도·운반·보관에 관한 계약이 성립하지 아니하였거나 장물의 점유가 현실적으로 이전되지 아니한 경우라도 장물알선죄가 성립한다. [2] 장물인 귀금속의 매도를 부탁받은 피고인이 그 귀금속이 장물임을 알면서도 매매를 중개하고 매수인에게 이를 전달하려다가 매수인을 만나기도 전에 체포되었다 하더라도, 위 귀금속의 매매를 중개함으로써 장물알선죄가 성립한다.

♣ 확인학습문제

1. 乙은 절취한 100만원권 자기앞수표를 금융기관에 예금하였다가 1만원권으로 전액 인출한 다음 이 돈으로 스마트폰 1대를 구입한 후 그간의 모든 정을 아는 자신의 여자친구 甲에게 위의 스마트폰은 선물로 주고, 나머지 현금은 용돈으로 쓰라며 교부한 경우 이를 수령한 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 스마트폰과 현금에 대한 장물취득죄
- ③ 현금에 대한 장물취득죄

- ④ 스마트폰에 대한 장물취득죄
- ⑤ 스마트폰과 현금에 대한 장물보관죄

【정답】 ③

【해설】 스마트폰은 대체장물이므로 장물성이 상실되어 장물죄는 성립하지 않는다. 그러나 판례는 환전통화의 장물성을 인정하므로 인출한 현금에 대해서는 장물취득죄가 성립한다.

2. 甲은 사기 범행에 이용되리라는 사정을 알고서도 자신의 명의로 은행 예금계좌를 개설하여 乙에게 이를 양도하였다. 그 후 乙이 丙을 기망하여 丙으로 하여금 1,000만 원을 위 계좌로 송금하게 하였는데, 乙 몰래 직불카드를 하나 더 발급받은 甲은 위 계좌로 송금된 돈 중 140만 원을 인출, 취득하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사기방조죄
- ② 사기방조죄와 장물취득죄
- ③ 사기방조죄와 횡령죄
- ④ 장물취득죄
- ⑤ 무죄

【정답】 ①

【해설】 甲은 본범으로부터 위 돈에 대한 점유를 이전받아 사실상 처분권을 획득한 것은 아니므로 甲의 위의 인출행위를 장물취득죄로 벌할 수는 없다(대법원 2010.12.9. 2010도6256).

3. 다음 장물죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 횡령 교사를 한 후 그 횡령한 물건을 취득한 때에는 횡령교사죄와 장물취득죄의 경합범이 성립된다.
- ② 장물죄의 행위주체는 본범의 정범, 공동정범, 합동범을 제외한 모든 자이다.
- ③ 본범 이외의 자가 본범이 절취한 차량이라는 정을 알면서 본범의 강도행위를 위해 그 차량을 운전해 준 경우, 강도예비죄와 함께 장물운반죄가 성립한다.
- ④ 관리할 수 있는 동력도 비록 장물죄에 형법 제346조 동력에 관한 준용규정이 없더라도 장물이 될 수 있다
- ⑤ 장물인 귀금속의 매도를 부탁받은 甲이 그 귀금속의 매매를 중개하고 매수인에게 이를 전달하려다가 매수인을 만나기도 전에 체포되었다면 장물알선죄가 성립하지 않는다.

【정답】 ⑤

【해설】 장물인 귀금속의 매도를 부탁받은 피고인이 그 귀금속이 장물임을 알면서도 매매를 중개하고 매수인에게 이를 전달하려다가 매수인을 만나기도 전에 체포되었다 하더라도, 위 귀금속의 매매를 중개함으로써 장물알선죄가 성립한다(대판 2009.4.23. 2009도1203).

♣ 학습내용 정리

1. 장물죄는 장물을 취득·양도·운반·보관하거나 또는 이를 알선하는 내용의 범죄이다. 장물이 발생한 원인이 되는 재산범죄를 본범이라고 한다.
2. 장물은 본범으로부터 취득한 원래의 재물이거나 적어도 그것과 물질적 동일성이 인정되는 것이어야 한다.
3. 장물취득은 장물에 대한 점유를 이전 받음으로써 사실상의 처분권을 인수한다는 두 가지 요소를 갖추어야 한다.
4. 장물알선은 장물의 취득·양도·운반 또는 보관을 매개하거나 주선하는 행위로, 알선의 방법은 제한이 없이 본범 또는 장물취득자와의 합의 또는 추정적 승낙 하에서 이루어져야 한다.

제33강 방화죄

♣ 학습목표

- 현주건조물방화죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 방화죄의 죄수에 대하여 설명할 수 있다.
- 일반건조물, 일반물건방화죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 연소죄의 내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 현주건조물방화
- 일반건조물방화
- 일반물건방화
- 연소죄

♣ 사전테스트

1. 현주건조물방화죄는 추상적 위험범이므로 본죄의 미수범은 처벌하지 않는다.
정답 : X
2. 가족이 함께 살고 있는 집에 방화한 때에도 현주건조물방화죄가 성립한다.
정답 : O
3. 건조물의 부속물도 건조물과 불가분의 일체를 이루고 있는 경우에는 건조물에 포함된다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

부작위에 의한 방화는 인정될 수 없다.

[정답] X

[해설] 소화의무를 진 자가 소화할 수 있음에도 불구하고 그대로 방치한 경우에는 부작위에 의한 방화가 인정된다.

♣ 강의내용

1. 현주건조물방화죄(형법 제164조)

1. 의의

현주건조물방화죄란 사람이 주거로 사용하거나 사람이 현존하는 건조물 등에 불을 놓아 소훼함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄의 성격은 일반건조물 방화죄에 대한 불법가중적 구성요건이며, 추상적 위험범이다. 그러나 본죄의 미수범은 처벌한다.

2. 구성요건

(1) 행위의 객체

사람이 주거로 사용하거나 사람이 현존하는 건조물·기차·전차·자동차·선박·항공기 또는 광갱이다.

(가) 사람이 주거로 사용하거나 또는 현존하는

1) 사람

범인 이외의 모든 자연인이다. 범인의 가족·동거자 또는 친족도 공범이 아닌 한 여기의 사람에 속한다. 따라서 가족이 함께 살고 있는 집에 방화한 때에도 본죄가 성립한다. 그러나 범인 혼자 살고 있는 집인 때에는 일반건조물방화죄(제166조)가 성립한다. 辯4

2) 주거사용

주거란 일상생활을 영위하는 장소로 사용하는 의미의 사실상 주거로 사용하고 있는 곳이다. 반드시 기와침식에 사용할 장소일 필요는 없다(통설). 애당초 주거용으로 건조된 것일 필요는 없으며, 건조물의 일부분이 주거로 이용되면 건물전체가 주거사용에 해당된다.

그리고 사실상 주거에 사용되는 한 행위시에 주거자가 없는 빈집이어도 본죄의 대상이 된다. 주거사용의 적법성 여부나 소유관계도 불문한다.

3) 사람의 현존

사람의 현존이란 방화 당시에 건조물 등의 내부에 범인 이외의 자가 존재하는 것을 말한다. 사람의 현존은 일시적이어도 상관없다. 사람이 존재하면 주거사용 여부나 현존의 이유는 불문하고, 건조물 일부에 사람이 있으면 전체가 현주건조물이 된다.

(나) 건조물 등

건조물이란 가옥 기타 이에 준하는 토지에 정착된 공작물로 사람이 그 내부에 출입할 수 있는 것을 말하며, 방화죄의 건조물과 주거침입죄의 건조물이 반드시 일치하는 것은 아니다. 반드시 주거용일 필요는 없고 사람이 현존할 수 있는 것이면 그 구조·재료·규모 여하는 불문한다(ex. 토방굴, 방갈로, 천막). 그리고 건조물의 부속물도 건조물과 불가분의 일체를 이루고 있는 경우에는 건조물에 포함된다.

(2) 행위

불을 놓아 목적물을 소훼하는 것이다.

(가) 방화

목적물을 소훼하기 위하여 일부러 불을 놓는 일체의 행위를 말한다.

방화의 방법은 무제한하다. 목적물에 직접 방화하건 매개물을 이용하건 불문한다. 부작위에 의해서도 가능하다. 따라서 소화의무를 진 자가 소화할 수 있음에도 불구하고 그대로 방치한 경우에는 부작위에 의한 방화가 인정된다.

(나) 실행의 착수

목적물, 매개물 어디에든 방화하면 인정되므로 매개물만 연소된 경우에도 현주건조물방화죄의 미수가 성립한다. 실행에 착수했으나 방화행위를 종료하지 못했거나 방화행위를 종료했지만 소훼행위까지 이르지 못한 경우에도 여전히 미수만이 성립한다.

판례 (대판 2002.3.26. 2001도6641) 辯1 司46・49・50・51・53

피고인이 방화의 의사로 뿌린 휘발유가 인화성이 강한 상태로 주택주변과 피해자의 몸에 적지 않게 살포되어 있는 사정을 알면서도 라이터를 켜 불꽃을 일으킴으로써 피해자의 몸에 불이 붙은 경우, 비록 외부적 사정에 의하여 불이 방화 목적물인 주택 자체에 옮겨 붙지는 아니하였다 하더라도 현존건조물방화죄의 실행의 착수가 있었다고 봄이 상당하다.

[사실관계] 甲은 노환을 앓고 있는 노모의 부양문제로 처와 부부싸움을 자주 하는 등 가정불화와 최근 직장 승진대상에서 누락되는 등의 문제로 심한 정신적 갈등을 겪어오던 중, 甲의 집에서 위와 같은 사유로 자신의 아내와 심한 부부싸움을 하다가 격분하여 “집을 불태워 버리고 같이 죽어 버리겠다.”며 그 곳 창고 뒤에 있던 18ℓ들이 플라스틱 휘발유통을 들고 나와 처와 자녀 2명이 있는 자기의 집 주위에 휘발유를 뿌리고, 1회용 라이터를 켜 불을 놓았으나, 불길의 번지지 않는 바람에 그 뜻을 이루지 못한 채 미수에 그치고, 이로 인하여 甲을 만류하던 앞집 거주 乙로 하여금 약 4주간의 치료를 요하는 경부 및 체부 3도 화상을 입게 하였다.

(다) 소훼

화력에 의한 건조물의 손괴를 의미한다.

(라) 기수시기 - 독립연소설(통설, 판례)

불이 매개물을 떠나서 목적물에 옮겨 붙어 독립하여 연소할 수 있는 상태가 되면 소훼가 되어 기수가 된다.

(3) 고의

본죄의 고의는 불을 놓아 주거에 사용하거나 사람이 현존하는 건조물 등을 소훼하는 것에 대한 인식이다. 그러나 본죄는 추상적 위험범이므로 공공의 위험에 대한 인식은 필요 없다.

주목해야 할 점은 건조물의 일부를 주거로 사용하는 경우에 주거로 사용하지 않는 다른 부분만을 소훼할 의사로 방화한 경우에도 건조물 전부에 대한 현주건조물방화죄의 고의가 성립한다는 것이다. 예컨대 주거에 방화를 할 의사는 없이 주거와 붙어 있는 창고에만 방화를 한 경우에도 건조물 전부에 대하여 현주건조물방화죄의 고의가 인정된다.

판례 (대판 1984.7.24. 84도1245) 司51

피고인이 동거하던 공소외인과 가정불화가 악화되어 헤어지기로 작정하고 화감에 죽은 동생의 유품으로 보관하던 서적 등을 뒷마당에 내려 놓고 불태워 버리려 했던 점이 인정될 뿐 피고인이 위 공소외인 소유의 가옥을 불태워 버리겠다고 결의하여 불을 놓았다고 볼 수 없다면 피고인의 위 소위를 가리켜 방화의 범의가 있었다고 할 수 없다.

3. 죄수

- ① 방화죄의 보호법익인 공공의 안전을 고려하여 결정한다. 따라서 1개의 방화행위로 수개의 건조물을 소훼한 경우, 건물이 수인의 소유에 속한 경우 또는 동일지역 내에 있는 수개의 건조물에 대하여 순차로 방화한 때에는 1개의 방화죄만 성립한다.
- ② 적용법조가 다른 수개의 건조물을 소훼한 경우에는 원칙적으로 가중 중한 죄의 포괄일죄가 된다. 따라서 1개의 방화행위로 현주건조물과 비현주건조물을 소훼한 때에는 현주건조물방화죄만 성립한다. 반면에 현주건조물을 소훼할 목적으로 인접한 비현주건조물에 방화하였으나 연소되지 않은 때에는 현주건조물방화죄의 미수가 성립하고 비현주건조물에 대한 방화는 별도로 성립하지 않는다(법조경합).
- ③ 보험금을 편취할 목적으로 현주건조물 등에 방화한 후 보험금을 타낸 경우에는 현주건조물 등 방화죄와 사기죄의 실체적 경합이 된다. 辯4

II. 일반건조물, 일반물건방화죄

1. 일반건조물방화죄(형법 제166조)

(1) 의의

불을 놓아 사람이 주거로 사용하지 않고 사람이 현존하지도 않으며 공용이나 공익에도 사용되지 않는 건조물을 소훼함으로써 성립하는 범죄이다.

(2) 보호정도

- ① 건조물 등이 타인소유인 경우(제1항) : 추상적 위험범이다. 본죄의 미수범은 처벌한다.
- ② 건조물 등이 자기소유일 경우(제2항) : 구체적 위험범이다. 본죄의 미수범은 처벌하지 않는다.

(2) 구성요건

(가) 건조물 등이 타인소유인 경우(제1항)

자기의 소유에 속하는 물건(건조물 포함)이라도 압류 기타 강제처분을 받거나 타인의 권리 또는 보험의 목적물이 된 때에는 타인의 물건으로 간주한다(제176조). 이 때 강제처분에는 제한이 없으므로 국세징수법에 의한 체납처분, 강제경매절차에서의 압류 또는 형사소송에 의한 몰수물건의 압류 등을 포함한다. 그리고 타인의 권리에는 저당권·전세권·질권 또는 임차권 등이 포함된다. 辯4

따라서 甲은 자신의 창고가 「국세징수법」에 의한 체납처분에 의해 압류되자 핑계에 불을 놓아 소훼하였지만 공공의 위험을 발생케 하지 못한 경우에도 타인소유일반건조물방화죄는 추상적 위험범이므로 甲에게 타인소유일반건조물방화죄가 성립한다. → 만약 그 건조물이 자기소유일 경우에는 자기소유 일반건조물방화죄는 구체적 위험범이므로 공공의 위험이 발생하지 못한 경우에는 불가벌적 미수가 된다.

(나) 건조물 등이 자기소유일 경우(제2항)

범인 소유 이외에 공범의 소유도 포함된다. 그러나 소유권자의 동의를 있는 경우 또는 무주물인 경우도 자기소유물에 준한다. 한편, 본죄는 구체적 위험범이므로 자기소유일 경우에는 공공의 위험이 발생하지 않으면 본죄가 성립하지 않는다.

2. 일반물건방화죄(형법 제167조)

① 불을 놓아 현조건조물과 공용건조물에 해당하지 않는 일반물건을 소훼함으로써 성립하는 범죄이다. ② 구체적으로 공공위험이 발생하여야 하므로(구체적 위험범), 공공의 위험이 없으면 본죄는 성립하지 않는다. 다만 타인소유물인 경우에 재물손괴죄가 성립할 수 있다.

판례 (대판 2009.10.15. 2009도7421)

[1] 불을 놓아 무주물을 소훼하여 공공의 위험을 발생하게 한 경우에는 ‘무주물’을 ‘자기 소유의 물건’에 준하는 것으로 보아 형법 제167조 제2항을 적용하여 처벌하여야 한다.

[2] 노상에서 전봇대 주변에 놓인 재활용품과 쓰레기 등에 불을 놓아 소훼한 사안에서, 그 재활용품과 쓰레기 등은 ‘무주물’로서 형법 제167조 제2항에 정한 ‘자기 소유의 물건’에 준하는 것으로 보아야 하므로, 여기에 불을 붙인 후 불상의 가연물을 집어넣어 그 화염을 키움으로써 전선을 비롯한 주변의 가연물에 손상을 입히거나 바람에 의하여 다른 곳으로 불이 옮겨붙을 수 있는 공공의 위험을 발생하게 하였다면, 일반물건방화죄가 성립한다.

III. 연소죄(형법 제168조)

1. 개념

자기소유 일반건조물·일반물건에 대한 방화가 확대되어 현주건조물이나 공용 또는 타인소유의 건조물·물건에 연소한 경우를 처벌하는 범죄이다. 진정결과적 가중범이다.

2. 연소

행위자가 자기소유일반물건 또는 자기소유일반건조물에 방화한 불길이 예견하지 못했던 현주건조물 등에 불이 옮겨 붙어 소훼하는 것이다. 따라서 甲이 乙의 창고에 불을 지르자 강풍에 의해 불길이 번져 인접하고 있는 丙의 창고를 연소한 경우에는 연소죄가 아니라 타인소유일반건조물방화죄의 1죄가 성립한다.

3. 중한 결과에 대한 고의

본죄는 진정결과적 가중범이므로 처음부터 중한 결과에 대한 고의가 있으면 제164조 제1항, 제165조, 제166조 제1항, 제167조 제1항의 범죄가 성립한다.

♣ 확인학습문제

1. 甲은 원수인 A의 집을 소훼할 의사로 A의 집 옆에 붙어 있는 B의 창고에 방화를 하여 불길이 A의 집까지 옮겨 붙게 할 계획을 세웠다. 甲은 B의 창고에 불을 질렀으나 때마침 A의 집 쪽에서 강한 역풍이 불어와 A의 집에는 불길이 전혀 옮겨 붙지 않았고, B의 창고만이 전소되고 말았다. 이 경우 甲의 죄책은?
 - ① 연소죄
 - ② 현주건조물방화죄의 미수
 - ③ 자기소유 일반건조물방화죄
 - ④ 타인소유 일반건조물방화죄
 - ⑤ 현주건조물방화죄의 미수와 타인소유 일반건조물방화죄의 상상적 경합

[정답] ②

[해설] 현주건조물을 소훼할 목적으로 인접한 비현주건조물에 방화하였으나 연소되지 않은 때에는 현주건조물방화죄의 미수가 성립하고 비현주건조물에 대한 방화는 별도로 성립하지 않는다(법조경합).

2. 다음 방화죄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 범인 혼자 살고 있는 단독주택을 방화한 때에는 일반건조물방화죄가 성립한다.
- ② 자기소유 일반물건방화죄의 미수범은 처벌하지 않는다.
- ③ 사실상 주거에 사용되는 한 행위시에 주거자가 없는 빈집이어도 방화죄의 대상이 된다.
- ④ 매개물을 통한 점화에 의하여 건조물을 소훼하는 경우 범인이 그 매개물에 불을 켜서 불이 붙게 하여 연소작용이 계속될 수 있는 상태에 이르렀다면 방화죄의 실행의 착수가 있었다.
- ⑤ 보험금을 편취할 목적으로 현주건조물 등에 방화한 후 보험금을 타낸 경우에는 현주건조물 등 방화죄와 사기죄의 상상적 경합이 된다.

[정답] ⑤

[해설] 보험금을 편취할 목적으로 현주건조물 등에 방화한 후 보험금을 타낸 경우에는 현주건조물 등 방화죄와 사기죄의 실제적 경합이 된다.

3. 甲이 자신의 창고가 「국세징수법」에 의한 체납처분에 의해 압류되자 찾김에 불을 놓아 소훼하였지만 공공의 위험을 발생케 하지 못한 경우 甲의 죄책은?

- ① 무죄
- ② 현주건조물방화죄
- ③ 자기소유일반건조물방화죄
- ④ 타인소유일반건조물방화죄
- ⑤ 연소죄

[정답] ④

[해설] 형법 제176조에 의하여 국세징수법의 대상이 된 甲의 창고는 타인의 건조물로 간주되고, 타인소유일반건조물방화죄는 추상적 위험범이므로 甲의 방화행위가 공공의 위험을 발생케 하지 못한 경우에도 甲에게 타인소유일반건조물방화죄가 성립한다.

♣ 학습내용 정리

- 1. 현주건조물방화죄란 사람이 주거로 사용하거나 사람이 현존하는 건조물 등에 불을 놓아 소훼함으로써 성립하는 범죄이다.
- 2. 일반건조물방화죄는 불을 놓아 사람이 주거로 사용하지 않고 사람이 현존하지도 않으며 공용이나 공익에도 사용되지 않는 건조물을 소훼함으로써 성립하는 범죄이다.
- 3. 일반물건방화죄는 불을 놓아 일반물건을 소훼함으로써 성립하는 범죄이다.
- 4. 연소죄는 자기소유 일반건조물·일반물건에 대한 방화가 확대되어 현주건조물이나 공용 또는 타인소유의 건조물·물건에 연소한 경우를 처벌하는 범죄이다.

제34강 유가증권에 관한 죄

♣ 학습목표

- 유가증권의 의미를 설명할 수 있다.
- 유가증권위조·변조죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 허위유가증권작성죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 위조 등 유가증권행사죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 유가증권
- 유가증권위조와 변조
- 허위유가증권작성
- 위조 등 유가증권행사

♣ 사전테스트

1. 재산권 표시와 증권의 점유가 유가증권의 개념요소가 된다.
정답 : ○
2. 간접정범에 의한 유가증권의 위조나 변조도 가능하다.
정답 : ○
3. 단순한 제시·교부·비치만으로는 위조유가증권행사에 해당하지 않는다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

사자나 허무인 명의 유가증권을 위조한 경우 유가증권위조죄가 성립하지 않는다.

[정답] X

[해설] 외형상 일반인으로 하여금 진정하게 작성된 유가증권이라고 오신케 할 수 있을 정도로 작성된 것이라면 그 발행명의인이 가령 실재하지 않은 사자 또는 허무인이라 하더라도 그 위조죄가 성립된다(대판 2011.7.14. 2010도1025).

♣ 강의내용

1. 유가증권위조죄의 행위객체

대한민국 또는 외국의 공채증서·유가증권이다.

1. 공채증서

국가, 지방자치단체에서 발행하는 국채 또는 지방채와 같은 증권을 말한다. 공채증권은 유가증권의 예시에 불과하다.

2. 유가증권

(1) 의의

유가증권이란 물권·채권·사원권 등의 사법상의 재산권이 화체된 증권으로서 권리의 행사와 처분에 그 점유를 필요로 하는 것을 말한다. 여기서 유가증권은 위조된 유가증권의 원본을 말하는 것이므로 전자복사기 등을 사용하여 기계적으로 복사한 사본은 유가증권이 아니다.

판례 복사유가증권의 유가증권위조죄의 객체성(대판 1998.2.13. 97도2922)

辯2 司49

[사실관계] 甲은 그가 위조한 피해자 乙 명의의 유가증권(甲은 乙 및 丙으로부터 그 전에 미리 서명날인만을 받아놓은 백지 약속어음에 발행일 '93.4.15.', 금액 '일십팔억원정, 1,800,000,000', 수취인 'A, 甲'이라고 함부로 기재하여 위조하였다)인 약속어음 1매를 甲이 乙을 상대로 제기한 서울지방법원 94가단174352호 약속어음금청구사건에서 그 청구를 대여금청구로 변경하면서 그 소변경신청서에 이를 첨부하여 제출하여 행사하였다.

[판결요지] 위조유가증권행사죄에 있어서의 유가증권이라 함은 위조된 유가증권의 원본을 말하는 것이니 전자복사기 등을 사용하여 기계적으로 복사한 사본은 이에 해당하지 않는다.

(2) 요건

(가) 증권의 점유와 재산권의 화체

증권상에 표시된 권리를 행사하기 위해서는 해당 증권을 점유하고 있어야 한다. 따라서 재산권 표시와 증권의 점유가 유가증권의 개념요소가 된다. 이러한 의미에서 법률관계의 존부나 내용을 증명하는 증거자료의 하나일 뿐이며, 재산권이 표시되어 있지 않은 증거증권(증명증서), 즉 물품구입증, 영수증, 매매계약서, 차용증 등은 유가증권이 아니다.

여기서 유가증권에 표시되는 재산권은 물권, 채권, 사원권 등을 포괄한다. 반면에 유가증권은 반드시 유통성을 가질 필요가 없기 때문에(통설, 판례), 유통성 없는 철도·지하철 승차권, 승마투표권·복권·식권도 유가증권에 해당한다.

(2) 유가증권의 유효성

유가증권은 사법상 유효할 필요는 없고, 법률상 무효인 것이라도 일반인이 유효한 유가증권으로 오인할 정도의 외관을 갖고 있으면 본죄의 객체가 된다. 더 나아가 위조된 유가증권도 본죄의 객체가 되는 경우가 있다.

판례 (대판 1982.6.22. 82도677) 司44

타인이 위조한 액면과 지급기일이 백지로 된 약속어음을 구입하여 행사의 목적으로 백지인 액면란에 금액을 기입하여 그 위조어음을 완성하는 행위는 백지어음 형태의 위조행위와는 별개의 유가증권위조죄를 구성한다.

(3) 종류

- ① 유가증권의 범위와 관련하여 국내외에서 발행·유통되는 모든 유가증권은 본죄의 객체에 포함된다.
- ② 신용카드를 그 제시를 통하여 신용카드회원이라는 사실을 증명하거나 이를 사용하여 신용공여기능을 이용할 수 있는 증거증권 내지는 증표로서의 가치를 가짐에 불과하기 때문에 유가증권이 아니라 사문서로 봄이 상당하다.

(4) 유가증권의 발행자

유가증권의 발행자는 사인, 국가 또는 공공단체를 불문하고, 명의인이 실재하지 않아도 상관 없다.

판례 (대판 1996.5.10. 96도527)

司55

수표에 기재되어야 할 수표행위자의 명칭은 반드시 수표행위자의 본명에 한하는 것은 아니고 상호, 별명 그 밖의 거래상 본인을 가리키는 것으로 인식되는 칭호라면 어느 것이나 다 가능하다고 볼 것이므로, 비록 그 칭호가 본명이 아니라 하더라도 통상 그 명칭을 자기를 표시하는 것으로 거래상 사용하여 그것이 그 행위자를 지칭하는 것으로 인식되어 온 경우에는 그것을 수표상으로도 자기를 표시하는 칭호로 사용할 수 있다.

II. 유가증권의 위조와 변조

위조·변조이다. 위조·변조는 기본적 증권행위에 대한 위조·변조이다.

1. 위조

(1) 명의모용

- ① 위조란 작성권한 없는 자가 타인 명의를 모용(사칭)하여 유가증권을 작성하는 것이다. 이는 문서위조죄의 유형위조에 해당한다. 이 때 행위자에게 유가증권의 작성권한이 없어야 하므로 작성권한을 위임받은 자가 위임자 명의로 어음을 발행하는 것은 위조가 아니다.
- ② 위조는 본인의 명의를 사칭하는 것이다. 따라서 대리인·대표자의 자격을 사칭한 경우에는 자격모용에 의한 유가증권작성죄(제215조)가 성립한다. 그러나 대리권·대표권의 범위 안에서 위임의 취지에 위배되는 유가증권을 작성하는 경우 본죄의 위조가 되지 않는다. 다만 권리남용으로 배임죄 또는 허위유가증권작성죄(제216조)의 성부가 문제될 수 있다.

(2) 위조방법

위조방법은 무제한하다. 간접정범이나 기망에 의한 위조도 가능하다. 권한 없이 백지어음의 금액을 보충한 경우 또는 백지어음의 보충권을 남용하여 백지어음에 보충권을 엄청나게 넘는 금액을 기재하는 경우 유가증권위조죄가 성립한다. 즉 백지어음, 백지수표의 보충권남용의 정도가 사소할 때에는 유가증권위조죄가 성립하지 않으나 보충권의 남용의 정도가 심하여 새로운 어음, 수표의 발행이라고 볼 수 있을 정도일 때에는 유가증권위조죄가 성립한다.

(3) 위조정도

위조의 정도는 일반인에게 진정한 유가증권으로 오인될 정도면 족하다. 따라서 행사할 목적으로 허무인 명의의 약속어음을 작성하여도 일반인을 오신케 할 수 있을 정도이면 유가증권위조죄가 성립한다.

약속어음과 같이 유통성을 가진 유가증권의 위조는 일반거래의 신용을 해하게 될 위험성이 매우 크다는 점에서 적어도 행사할 목적으로 외형상 일반인으로 하여금 진정하게 작성된 유가증권이라고 오신케 할 수 있을 정도로 작성된 것이라면 그 발행명의인이 가령 실재하지 않은 사자 또는 허무인이라 하더라도 그 위조죄가 성립된다고 해석함이 상당하다. 그리고 사자 명의로 된 약속어음을 작성함에 있어 사망자의 처로부터 사망자의 인장을 교부받아 생존 당시 작성한 것처럼 약속어음의 발행일자를 그 명의자의 생존 중의 일자로 소급하여 작성한 때에는 발행명의인의 승낙이 있었다고 볼 수 없다.

2. 변조

(1) 의의

변조란 진정한 유가증권의 내용을 권한 없는 자가 동일성을 침해하지 않는 범위 안에서 변경하는 행위를 말한다. 예컨대 진정하게 성립된 유가증권의 발행일자, 액면 또는 지급인, 주소 등을 임의로 변경하는 것이 여기에 해당한다. 이 때 변경내용의 진실여부는 묻지 않는다.

(2) 내용

- ① 변조된 경우라 할지라도 유가증권의 동일성이 유지되어야 하므로 변경으로 인하여 동일성을 상실한 경우에는 위조가 된다. 또한 유가증권용지에 필요사항을 임의로 기재하여 새로운 유가증권을 만들거나 이미 실효된 유가증권을 가공하여 새로운 유가증권을 작성하는 경우에도 변조가 아니라 위조에 해당한다.
- ② 변조는 타인명의의 유가증권내용을 권한 없이 변경하는 것이다. 따라서 타인에게 속한 자기 명의의 유가증권에 대한 변조는 불가능하고, 허위유가증권작성죄나 문서손괴죄가 된다.

판례 (대판 2006.1.26. 2005도4764) **

[1] 유가증권변조죄에 있어서 변조라 함은 진정으로 성립된 유가증권의 내용에 권한 없는 자가 그 유가증권의 동일성을 해하지 않는 한도에서 변경을 가하는 것을 말하므로, 이미 타인에 의하여 위조된 약속어음의 기재사항을 권한 없이 변경하였다고 하더라도 유가증권변조죄는 성립하지 아니한다.

[2] 약속어음의 액면금액을 권한 없이 변경하는 것은 유가증권변조에 해당할 뿐 유가증권위조는 아니므로, 약속어음의 액면금액을 권한 없이 변경하는 행위가 당초의 위조와는 별개의 새로운 유가증권위조로 된다고 할 수 없다.

[사실관계] 피고인 甲은 ① A가 위조한 B명의의 약속어음의 기재사항을 권한 없이 변경하였고, ② C명의의 약속어음의 액면금액을 권한 없이 변경하였다. 甲은 B명의의 유가증권변조죄 및 C명의의 유가증권위조죄로 기소되었다. 항소심인 서울동부지방법원은 ① 유가증권변조죄의 유가증권은 진정으로 성립된 유가증권이므로 위조된 유가증권에 대한 유가증권변조죄는 성립할 수 없다는 이유로 A가 위조한 B명의의 약속어음의 변조죄에 대해서는 무죄를 선고하였고, ② C명의의 약속어음의 금액을 변경한 행위에 대해서는 유가증권위조죄가 아니라 유가증권변조죄를 인정하였다.

(3) 수단·방법

제한이 없다. 간접정범에 의한 변조도 가능하다.

III. 허위유가증권작성죄

판례 (대판 2005.10.27. 2005도4528) 司50

형법 제216조 전단의 허위유가증권작성죄는 작성권한 있는 자가 자기 명의로 기본적 증권행위를 함에 있어서 유가증권의 효력에 영향을 미칠 기재사항에 관하여 진실에 반하는 내용을 기재하는 경우에 성립하는바, 자기앞수표의 발행인이 수표의뢰인으로부터 수표자금을 입금받지 아니한 채 자기앞수표를 발행하더라도 그 수표의 효력에는 아무런 영향이 없으므로 허위유가증권작성죄가 성립하지 아니한다.

판례 (대판 2000.5.30. 2000도883) 司43·46

은행을 통하여 지급이 이루어지는 약속어음의 발행인이 그 발행을 위하여 은행에 신고된 것이 아닌 발행인의 다른 인장을 날인하였다 하더라도 그것이 발행인의 인장인 이상 그 어음의 효력에는 아무런 영향이 없으므로 허위유가증권작성죄가 성립하지 아니한다.

IV. 보론 - 위조 등 유가증권행사죄

- ① 본죄는 위조·변조·작성 또는 허위기재한 유가증권을 행사함으로써 성립하는 범죄이다. 단순한 제시·교부·비치만으로도 행사가 된다.
- ② 본죄에서 행사라 함은 위조·변조·작성 또는 허위기재된 유가증권을 진정한 유가증권으로 사용하는 것이다. 여기서 유가증권이라 함은 위조된 유가증권의 원본을 말하는 것이지 전자복사기 등을 사용하여 기계적으로 복사한 사본은 이에 해당하지 않는다.
- ③ 본죄는 타인이 진정한 유가증권으로 인식·열람할 수 있을 때 기수가 된다. 그밖에 송부·우송도 행사의 한 방법이다. 그러나 위조의 공모자간에만 위조유가증권이 있었을 경우에는 아직 행사죄를 구성하지 않는다.
- ④ 그리고 위조된 유가증권을 그 정을 알고 있는 자에게 교부하였더라도 피교부자가 이를 유통시킬 것임을 인식하고 교부하였다면 위조유가증권행사죄가 성립한다.

판례 (대판 2010.12.9. 2010도12553) 司55

위조유가증권의 교부자와 피교부자가 서로 유가증권위조를 공모하였거나 위조유가증권을 타에 행사하여 그 이익을 나누어 가질 것을 공모한 공범의 관계에 있다면, 그들 사이의 위조유가증권 교부행위는 그들 이외의 자에게 행사함으로써 범죄를 실현하기 위한 전단계의 행위에 불과한 것으로서 위조유가증권은 아직 범인들의 수중에 있다고 볼 것이지 행사되었다고 볼 수는 없다. → 유가증권위조죄의 공범사이에서의 위조유가증권 교부행위는 위조유가증권행사죄에 해당하지 않는다.

♣ 확인학습문제

1. 甲은 A의 명의를 모용하여 액면금 1천만원짜리 당좌수표를 작성한 다음 전자복사기를 이용하여 이 당좌수표에 대한 사본을 만들었다. 甲이 위의 사본을 자신의 거래상대방인 乙에게 보여주면서 자신의 신용력을 과시하였을 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 유가증권위조죄
- ② 유가증권위조죄와 위조유가증권행사죄의 실체적 경합
- ③ 유가증권위조죄와 위조유가증권행사죄의 상상적 경합
- ④ 위조유가증권행사죄
- ⑤ 무죄

[정답] ①

[해설] 위조유가증권행사죄에 있어서의 유가증권이라 함은 위조된 유가증권의 원본을 말하는 것이지 전자복사기 등을 사용하여 기계적으로 복사한 사본은 이에 해당하지 않는다(대판 1998.2.13. 97도2922).

2. 다음 유가증권에 관한 죄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 유통성 없는 철도·지하철 승차권, 승마투표권·복권·식권도 유가증권에 해당한다.
- ② 백지어음의 보충권을 남용하여 백지어음에 보충권을 엄청나게 넘는 금액을 기재하는 경우 유가증권위조죄가 성립한다.
- ③ 위조된 유가증권을 그 정을 알고 있는 자에게 교부하였더라도 피교부자가 이를 유통시킬 것임을 인식하고 교부하였다면 위조유가증권행사죄가 성립한다.
- ④ 수표에 기재되어야 할 수표행위자의 명칭은 반드시 수표행위자의 본명에 한하는 것이다.
- ⑤ 자기앞수표의 발행인이 수표의뢰인으로부터 수표자금을 입금받지 아니한 채 자기앞수표를 발행하더라도 그 수표의 효력에는 아무런 영향이 없으므로 허위유가증권작성죄가 성립하지 아니한다.

[정답] ④

[해설] 수표에 기재되어야 할 수표행위자의 명칭은 반드시 수표행위자의 본명에 한하는 것은 아니고 상호, 별명 그 밖의 거래상 본인을 가리키는 것으로 인식되는 칭호라면 어느 것이나 다 가능하다고 볼 것이다(대판 1996.5.10. 96도527).

3. 甲은 A가 위조한 B명의로의 약속어음의 금액란에 기재된 액면금액을 1억원에서 2억원으로 변경하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 유가증권위조죄
- ② 유가증권변조죄
- ③ 무죄
- ④ 유가증권변조죄와 동 행사죄
- ⑤ 허위유가증권작성죄

[정답] ③

[해설] ㉠ 이미 타인에 의하여 위조된 약속어음의 기재사항을 권한 없이 변경하였다고 하더라도 유가증권변조죄는 성립하지 아니한다. ㉡ 약속어음의 액면금액을 권한 없이 변경하는

것은 유가증권변조에 해당할 뿐 유가증권위조는 아니므로, 약속어음의 액면금액을 권한 없이 변경하는 행위가 당초의 위조와는 별개의 새로운 유가증권위조로 된다고 할 수 없다(대판 2006.1.26. 2005도4764).

♣ 학습내용 정리

1. 유가증권위조·변조죄는 행사할 목적으로 대한민국 또는 외국의 공채증서 기타 유가증권을 위조 또는 변조한 경우 성립하는 범죄이다.
2. 허위유가증권작성죄는 작성권한 있는 자가 자기 명의로 기본적 증권행위를 함에 있어서 유가증권의 효력에 영향을 미칠 기재사항에 관하여 진실에 반하는 내용을 기재하는 경우에 성립하는 범죄이다.
3. 위조 등 유가증권행사죄는 위조·변조·작성 또는 허위기재한 유가증권을 행사함으로써 성립하는 범죄이다.

제35강 사문서위조죄(형법 제231조)

♣ 학습목표

- 문서의 개념을 말할 수 있다.
- 문서의 위조와 변조의 내용을 설명할 수 있다.
- 문서죄의 죄수를 설명할 수 있다.
- 문서죄와 다른 범죄에 대한 관계를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 문서와 도화
- 유형위조
- 무형위조
- 명의인

♣ 사전테스트

1. 광의의 문서에는 문자로 표시된 협의의 문서 외에 도화가 포함된다.
정답 : O
2. 명의인은 문서의 실제작성자와 반드시 일치해야 한다.
정답 : X
3. 생략문서는 문서에 해당하지 않는다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

사문서의 무형위조도 원칙적으로 처벌의 대상이 된다.

[정답] X

[해설] 문서내용의 진실을 보호하는 무형위조는 공문서를 제외하고는 원칙적으로 위조개념에서 제외하여 처벌하지 않는다.

♣ 강의내용

1. 문서의 개념

1. 의의 및 본질

문서죄는 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서를 위조·변조함으로써 성립하는 범죄이다. 문서죄는 형법상 모든 위조죄의 기본적 구성요건에 해당한다. 문서죄의 보호의 정도는 추상적 위험범으로서의 보호이다.

그리고 문서죄의 본질과 관련하여 우리 형법은 형식주의에 입각하여 문서성립의 진정을 보호하는 유형위조는 공문서, 사문서를 묻지 않고 처벌한다. 그러나 문서내용의 진실을 보호하는 무형위조는 공문서를 제외하고는 원칙적으로 위조개념에서 제외하여 처벌하지 않는다. 다만 문서내용의 진실성을 특히 보호해야 할 경우에만 예외적으로 사문서의 무형위조를 처벌한다. ex) 허위진단서작성죄(제233조).

2. 문서의 개념

문서란 문자 또는 이를 대신하는 부호에 의해 사상이나 관념을 표시하는 물체로서(통설), 광의의 문서에는 문자로 표시된 협의의 문서 외에 도화가 포함된다.

(1) 문서의 3대 기능

(가) 계속기능

문서는 사람의 의사가 표시된 것으로 계속성이 있어야 한다. 그런데 문서는 문자 또는 이에 대신할 부호에 의한 의사표시가 있어야 계속성이 인정되는바, 이는 형법상 문서개념의 중심표지이다. 다만 문서의 계속성은 영구적일 필요는 없다.

판례 (대판 2008.4.10. 2008도1013) 辯3 司52·54

컴퓨터 모니터에 나타나는 이미지가 형법상 문서에 관한 죄의 '문서'에 해당하는지 여부(소극) - 컴퓨터 모니터 화면에 나타나는 이미지는 이미지 파일을 보기 위한 프로그램을 실행할 경우에 그때마다 전자적 반응을 일으켜 화면에 나타나는 것에 지나지 않아서 계속적으로 화면에 고정된 것으로는 볼 수 없으므로, 형법상 문서에 관한 죄에 있어서의 '문서'에는 해당되지 않는다고 할 것이다 → 피고인이 컴퓨터 스캔 작업을 통하여 만들어낸 공인중개사 자격증의 이미지 파일은 전자기록으로서 전자기록 장치에 전자적 형태로서 고정되어 계속성이 있다고 볼 수는 있으나, 그러한 형태는 그 자체로서 시각적 방법에 의해 이해할 수 있는 것이 아니어서 이를 형법상 문서에 관한 죄에 있어서의 '문서'로 보기 어렵다.

생략문서도 그 자체로부터 일정한 의사·관념을 해독할 수 있는 한 문서이다. ex) 백지위임장, 입장권, 은행의 입·출금전표, 소인, 은행의 접수일부인

그리고 사진기나 복사기 등을 사용하여 기계적인 방법에 의하여 원본을 복사한 문서, 이른바 복사문서는 사본이더라도 이에 대한 사회적 신용을 보호할 필요가 있으므로 문서위조 및 동행사회의 객체인 문서에 해당한다(대판 1989.9.12. 87도506 전원합의체). 辯1

우리 형법은 복사문서의 문서성을 입법적으로 해결한 바 있다(형법 제237조의 2).

(나) 증명기능

문서는 법적으로 중요한 사실을 증명할 만한 것이어야 한다. 문서의 증명기능은 증명능력과 증명의사를 내용으로 한다. 문서의 증명능력은 진정한 문서를 전제로 하므로 부진정문서의 작성은 문서에 관한 죄를 구성하지만, 부진정문서 그 자체는 문서위조·변조의 객체가 될 수 없다.

(다) 보장기능

의사표시의 내용을 보증할 수 있는 의사표시의 주체, 즉 명의인이 있어야 한다.

1) 명의인

작성명의인이란 문서에 나타난 의사나 관념 표시의 주체이다. 여기서 명의인은 자연인·법인·법인격 없는 단체를 불문하며, 명의인이 문서의 실제작성자와 반드시 일치하는 것은 아니다. 그리고 명의인이 특정되지 아니한 문서는 그 진정을 보호해야 할 실익이 없으므로 명의인은 특정되어야 한다.

2) 명의인의 실재 여부

문서의 명의인이 실재해야 하는가에 관해서 학설과 판례는 사자와 허무인 명의의 문서라도 공문서·사문서 구별없이 일반인에게 진정한 문서로 오신될 염려가 있으면 문서의 진정에 대한 공공의 신용이 저해될 수 있으므로 명의인이 실재할 필요가 없다는 입장이다.

판례 (대판 2005.2.24. 2002도18. 전원합의체판결) 辯1·4 司47·49·51·54·55

문서위조죄는 문서의 진정에 대한 공공의 신용을 그 보호법익으로 하는 것이므로 행사할 목적으로 작성된 문서가 일반인으로 하여금 당해 명의인의 권한 내에서 작성된 문서라고 믿게 할 수 있는 정도의 형식과 외관을 갖추고 있으면 문서위조죄가 성립하는 것이고, 위와 같은 요건을 구비한 이상 그 명의인이 실재하지 않는 허무인이거나 또는 문서의 작성일자 전에 이미 사망하였다고 하더라도 그러한 문서 역시 공공의 신용을 해할 위험성이 있으므로 문서위조죄가 성립한다고 봄이 상당하며, 이는 공문서뿐만 아니라 사문서의 경우에도 마찬가지라고 보아야 한다.

[사실관계] 甲은 중국 중의사 및 침구사 시험에 응시할 사람을 모집한 후 그들을 중국에 데려가 응시원서의 제출을 대행하면서 응시생의 임상경력증명서가 필요하게 되자, 임상경력증명서 양식에 응시생의 이름과 생년월일 및 학습기간 등을 기재한 다음, 의원직인란에 실재하지 않는 강남한의원이라고 기재하고 그 옆에 임의로 새긴 강남한원의 직인을 날인하여 강남한의원 명의의 임상경력증명서를 위조한 것을 비롯하여, 동일한의원과 일심한의원 명의의 임상경력증명서를 같은 방법으로 각 위조하여 행사하였다.

(2) 도 화

도화란 문자 이외의 상징적 부호로 사상을 표현한 것을 말한다(ex. 지적도, 인체도). 도화는 의사·관념을 표시한다는 점에서 문서와 동일한 성격을 가지고 있으므로 계속적 기능, 증명적 기능, 보장적 기능을 갖추고 있어야 한다. 따라서 도화에는 의사표시가 들어 있어야 한다. → 담뱃갑은 적어도 그 담뱃갑 안에 들어 있는 담배가 특정 제조회사가 제조한 특정한 종류의 담배라는 사실을 증명하는 기능을 하고 있으므로, 그러한 담뱃갑은 문서 등 위조의 대상인 도화에 해당한다(대판 2010.7.29. 2010도2705).

II. 문서의 위조와 변조

I. 사문서위조·변조죄의 의의

사문서위조·변조죄는 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조함으로써 성립하는 범죄이다.

2. 행위 : 위조 또는 변조하는 것이다.

(1) 위조

위조란 권한 없이 타인명의를 함부로 사용하여(冒用) 가짜문서(부진정문서)를 만드는 것이다. 즉 부진정문서를 작성하는 유형위조의 경우를 말한다.

(가) 작성권한 없는 자

위조가 성립하려면 먼저 문서를 작성할 권한이 없는 자가 문서를 만들어야 한다. 여기서 작성권한이란 문서를 작성할 수 있는 정당한 권한을 말한다.

- ① 명의인의 승낙·위임이 있는 경우 : 명의인의 사전승낙을 받은 경우는 작성권한이 있다고 보아야 할 것이므로 위조가 아니다. 이 때 사전승낙은 구성요건해당성을 배제하는 양해가 된다.

판례 (대판 1998.2.24. 97도183)

司52·55

문서의 위조라고 하는 것은 작성권한 없는 자가 타인 명의를 모용하여 문서를 작성하는 것을 말하는 것이므로 사문서를 작성함에 있어 그 명의자의 명시적이거나 묵시적인 승낙(위임)이 있었다면 이는 사문서위조에 해당한다고 할 수 없다.

- ② 위임의 범위를 초월한 경우 : 위임의 범위를 초월하여 위탁자명의로의 사문서를 작성하거나 위임의 취지에 위배하여 문서를 작성하는 경우는 위조이다. 작성 권한이 없는 경우에는 대리권·대표권이 없는 경우뿐만 아니라, 그 권한이 있어도 권한을 초월하거나 남용하는 경우에 문제가 된다.
- ③ 권한범위 안에서 권한남용 : 그러나 대리권 또는 대표권이 있는 자가 그 권한범위 안에서 권한을 남용하여 문서를 작성한 경우는 위조가 인정되지 않지만, 배임죄나 허위공문서작성죄는 문제가 된다.

판례 (대판 2008.11.27. 2006도9194)

司57

대표이사가 권한을 행사하는 과정에서 단순히 그 1인 주주의 위임 또는 승낙을 받지 않았다고 하여 그 대표권 행사가 권한을 넘어서는 행위가 되는 것은 아니다. 그러므로 주식회사의 대표이사가 실질적 운영자인 1인 주주의 구체적인 위임이나 승낙을 받지 않고 이미 퇴임한 전 대표이사를 대표이사로 표시하여 회사 명의의 문서를 작성한 사안에서, 문서위조죄의 성립이 부정된다.

(나) 타인명의로의 모용

타인명의로의 모용이란 타인의 명의를 사칭하여 그 의사표시가 타인이 한 것처럼 허위로 꾸미고, 그에 대한 착오를 야기하는 행위이다(동일성의 사칭). 타인명의로의 사칭으로 충분하고, 문서의 기재내용이 진실인가의 여부, 별도로 진정한 문서가 존재하는지의 여부, 그리고 실제 작성자가 문서에 표시되었는지 여부는 문제되지 않는다(유형위조).

(다) 문서의 작성

문서의 작성이란 작성자가 명의인의 의사에 반하여 문서를 현실적으로 창출하는 것을 말한다. 이 때 작성의 수단·방법은 무제한하다. 전혀 새로운 문서를 창출하는 것이 문서작성의 기본형태이다. 그러나 문서의 작성은 기존문서를 이용하는 것도 가능하다.

(라) 명의인을 기망하는 간접정범의 방식에 의해서도 가능

예컨대 명의인을 속여 명의인으로 하여금 진의에 반하여 문서에 서명·날인케 하는 경우, 명의인이 내용을 오신하고 있음을 이용하여 그의 의사와 다른 내용의 문서를 작성하게 한 경우 등을 예로 들 수 있다.

(마) 위조정도

문서의 형식적·내용적 측면에서 완전할 것을 요하지 않는다. 일반인이 진정문서로 오인할 수 있는 정도의 형식·외관을 갖추고 있으면 충분하다.

(2) 변조

변조란 정당한 권한 없이 타인명의의 진정문서를 동일성이 침해되지 않는 범위 안에서 변경을 가하는 것이다. 즉 이미 성립한 타인명의의 진정문서의 핵심내용이 아닌 부분을 변경하여 새로운 증명력을 가진 문서를 만들어 내는 것이다. 따라서 위조되거나 허위작성된 문서는 변조의 객체가 아니다(통설, 판례).

그리고 변조는 기존문서의 동일성을 상실시키지 않을 정도로 변경을 가하여 일종의 부진정문서를 작성하는 것이다. 따라서 동일성을 상실시키지 않을 정도가 위조와 변조를 구별하는 기준이 된다.

III. 죄수와 다른 범죄에 대한 관계

1. 죄수결정의 기준

문서위조·변조죄의 본질이 명의모용에 있다면 명의인의 수를 기준으로 죄수를 결정해야 한다.

판례 (대판 1987.7.21. 87도564) 司54

2인 이상 수인의 연명문서를 위조하는 행위는 하나의 행위이므로 수인에 대한 문서위조는 상상적 경합이 된다.

2. 인장위조죄와의 관계

위조사문서에 다시 위조인장을 사용한 경우는 법조경합의 흡수관계로 사문서위조죄만이 성립한다(대판 1978.9.26. 78도1787). 司46·47

♣ 확인학습문제

1. 甲은 사망한 A의 명의를 모용하여 부동산매매계약을 작성하고, 또 A의 명의의 인장을 새겨서 그 계약서 위에 날인을 하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 사문서위조죄와 사인위조죄의 실체적 경합
- ③ 사문서위조죄와 사인위조죄의 상상적 경합
- ④ 사문서위조죄
- ⑤ 사인위조죄

[정답] ④

[해설] 허무인·사망자 명의의 사문서를 위조한 경우, 사문서위조죄가 성립한다(대판 2005.2.24. 2002도18 전원합의체). 그리고 위조사문서에 다시 위조인장을 사용한 경우는 법조경합에 의하여 사문서위조죄만이 성립한다(대판 1978.9.26. 78도1787).

2. 다음 유가증권에 관한 죄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사문서를 작성함에 있어 그 명의자의 명시적이거나 묵시적인 승낙(위임)이 있었다면 이는 사문서위조에 해당한다고 할 수 없다.
- ② 컴퓨터 스캔 작업을 통하여 만들어낸 공인중개사 자격증의 이미지 파일도 형법상 문서에 관한 죄의 ‘문서’에 해당한다.
- ③ 담뱃갑은 문서 등 위조의 대상인 도화에 해당한다.
- ④ 2인 이상의 연명으로 된 문서를 위조한 경우 위 수개의 문서위조죄는 형법 제40조가 규정하는 상상적 경합범에 해당한다.
- ⑤ 위조되거나 허위작성 된 문서는 변조의 객체가 될 수 없다.

[정답] ②

[해설] 컴퓨터 모니터 화면에 나타나는 이미지는 이미지 파일을 보기 위한 프로그램을 실행할 경우에 그때마다 전자적 반응을 일으켜 화면에 나타나는 것에 지나지 않아서 계속적으로 화면에 고정된 것으로는 볼 수 없으므로, 형법상 문서에 관한 죄에 있어서의 ‘문서’에는 해당되지 않는다(대판 2008.4.10. 2008도1013).

3. A 주식회사의 대표이사 甲이 실질적 운영자인 1인 주주 乙의 구체적인 위임이나 승낙을 받지 않고 이미 퇴임한 전 대표이사 B를 대표이사로 표시하여 회사 명의의 문서를 작성한 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사문서위조죄
- ② 사문서변조죄
- ③ 자격모용에 의한 사문서작성죄
- ④ 사문서위조죄와 위조사문서행사죄
- ⑤ 무죄

[정답] ⑤

【해설】 대표이사가 권한을 행사하는 과정에서 단순히 그 1인 주주의 위임 또는 승낙을 받지 않았다고 하여 그 대표권 행사가 권한을 넘어서는 행위가 되는 것은 아니다. 그러므로 문서위조죄의 성립이 부정된다(대판 2008.11.27. 2006도9194).

♣ 학습내용 정리

1. 문서죄는 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서를 위조·변조함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 문서의 위조란 권한 없이 타인명의를 함부로 사용하여(冒用) 가짜문서(부진정문서)를 만드는 것이다.
3. 문서의 작성이란 작성자가 명의인의 의사에 반하여 문서를 현실적으로 창출하는 것을 말한다. 이 때 작성의 수단·방법은 무제한하다.
4. 문서의 변조는 기존문서의 동일성을 상실시키지 않을 정도로 변경을 가하여 일종의 부진정문서를 작성하는 것이다.

제36강 허위진단서작성죄와 허위공문서작성죄

♣ 학습목표

- 허위진단서작성죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 허위공문서작성죄에 대하여 설명할 수 있다.
- 허위공문서작성죄의 간접정범의 성부를 설명할 수 있다.
- 허위공문서작성죄와 다른 범죄에 대한 관계를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 허위진단서작성
- 허위공문서작성
- 무형위조
- 직무유기죄

♣ 사전테스트

1. 의사의 신분 없는 자가 의사의 명의를 모용하여 허위진단서·검안서 등을 작성한 경우는 사문서위조죄를 구성한다.
정답 : ○
2. 허위공문서작성죄에서 명의나 자격모용이라는 문서성립의 진정성은 문제되지 않는다.
정답 : ○
3. 허위공문서작성죄에서 공문서는 대외적인 문서에 국한되고 대내적인 기안문서는 포함되지 않는다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

공무원인 의사가 공무소의 명의로 허위진단서를 작성한 경우 허위진단서작성죄가 성립한다.

[정답] X

[해설] 공무원인 의사가 공무소의 명의로 허위진단서를 작성한 경우에는 허위공문서작성죄만이 성립하고 허위진단서작성죄는 별도로 성립하지 않는다(대판 2004.4.9. 2003도7762).

♣ 강의내용

I. 허위진단서작성죄(형법 제233조)

1. 의의

본죄는 의사, 한의사, 치과의사 또는 조산사가 진단서·검안서 또는 생사에 관한 증명서를 허위로 작성함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 사문서의 무형위조(내용위조)를 예외적으로 처벌하는 구성요건이다. 따라서 이러한 신분 없는 자가 신분자의 명의를 모용하여 허위진단서·검안서 등을 작성한 경우는 본죄가 아니라 사문서위조죄를 구성한다. 본죄는 행사의 목적을 필요로 하는 목적범이 아니다.

2. 허위의 의미

허위진단서작성죄는 원래 허위의 증명을 금지하려는 것이므로 그 내용이 허위라는 의사의 주관적 인식이 필요함은 물론, 실질상 진실에 반하는 기재일 것이 필요하다(대판 1990.3.27. 89도2083). 따라서 작성자가 허위라고 생각하고 기재했으나 진단서등에 기재한 내용이 실질적으로 진실에 부합하는 경우에는 허위작성이 인정되지 아니하여 본죄의 구성요건해당성이 배제된다.

따라서 의사가 교통사고 환자의 부탁을 받고 전치 3주 정도 되는 상해라고 생각하면서도 6주라고 진단서에 기재하였으나, 실제로 그 환자의 상해의 정도가 6주 정도에 이르렀을 때에는 본죄는 성립하지 않는다.

판례 (대판 1976.2.10. 75도1888)

司49

허위진단서작성죄는 의사가 사실에 관한 인식이나 판단의 결과를 표현함에 있어서 자기의 인식 판단이 진단서에 기재된 내용과 불일치하는 것임을 인식하고서도 일부러 내용이 진실 아닌 기재를 하는 것을 말하는 것이므로 의사가 주관적으로 진찰을 소홀히 한다던가 착오를 일으켜 오진한 결과로 객관적으로 진실에 반한 진단서를 작성하였다면 허위진단서작성에 대한 인식이 있다고 할 수 없으니 동 죄가 성립되지 아니한다.

II. 허위공문서작성죄(형법 제277조)

1. 의의

공무원이 행사할 목적으로 그 직무에 관하여 문서 또는 도화를 허위로 작성하거나 번개함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 그 성격상 공문서의 특별한 신용·증명성을 고려하여 문서의 무형위조를 처벌하기 위한 규정으로 문서성립의 진정성은 문제되지 않는다.

2. 행위주체

직무에 관하여 문서 또는 도화를 작성할 권한 있는 공무원이다(진정신분범). 공무원이라 할지라도 문서의 작성권한이 없는 자는 본죄의 주체가 될 수 없고, 공문서위조죄만이 성립한다. 작성권한은 통상 법령으로 정해지지만, 내규, 업무관행 등에 의해서도 정해질 수 있다.

작성권한이 있는 공무원이 그 권한의 범위 내에서 권한을 남용하여 공문서를 작성한 경우에도 본죄가 성립한다. 그리고 작성명의인이 아닌 경우에도 대리하여 전결권이 위임되어 있는 자는 본죄의 주체가 될 수 있지만(판례), 문서를 보충기재 할 권한만 위임되어 있는 자가 작성자의 직인을 사용하여 허위의 문서를 직접 작성한 때에는 공문서위조죄가 성립한다.

3. 행위객체

공무소 또는 공무원이 직무에 관하여 작성한 공문서 또는 공도화이다. 이 때 공문서는 대외적인 문서에 국한되지 않고 대내적인 기안문서도 포함된다. 작성권한 있는 공무원이 공정증서원본에 일부러 허위내용을 삽입, 기재한 경우에는 공정증서원본부실기재죄가 아니라 본죄에 해당한다.

4. 행위

문서 · 도화의 허위작성 · 변개이다.

(1) 허위문서의 허위작성

허위작성이란 문서에 진실에 반하는 허위내용을 기재하는 것이다. 작성권한 있는 자가 만든 허위문서이면 족하고, 명의여하는 불문한다. 대리권 또는 대표권을 가진 자가 본인명의로 허위문서를 작성한 때에도 본죄가 성립한다. 작성방법은 제한이 없다. 부작위에 의해서도 가능하다. 예컨대 작성자가 고의로 기재사항을 누락시키는 경우가 여기에 해당한다.

판례 (대판 1996.5.14, 96도554) 司44·51·57

허위공문서작성죄란 공문서에 진실에 반하는 기재를 하는 때에 성립하는 범죄이므로, 고의로 법령을 잘못 적용하여 공문서를 작성하였다고 하더라도 그 법령 적용의 전제가 된 사실관계에 대한 내용에 거짓이 없다면 허위공문서작성죄가 성립될 수 없는바, 당사자로부터 뇌물을 받고 고의로 적용하여서는 안 될 조항을 적용하여 과세표준을 결정하고 그 과세표준에 기하여 세액을 산출하였다고 하더라도 그 세액 계산서에 허위내용의 기재가 없다면 허위공문서작성죄에는 해당하지 않는다.

<허위작성을 인정한 판례>

- ① 가옥대장에 무허가건물을 허가받은 건물로 기재한 경우(대판 1983.12.13. 83도1458)
- ② 원본과 대조하지 않고 원본대조필 날인을 한 경우(대판 1981.9.22. 80도3180)
- ③ 준공검사를 하지 않고 준공검사를 하였다고 기재한 경우(대판 1990.10.16. 90도1307)
- ④ 공사가 완성되지 않은 것을 알면서 준공검사조서를 작성한 경우(대판 1995.6.13. 95도491)
- ⑤ 인감증명서 발급업무를 담당하는 甲이, 인감증명서 발급을 신청한 본인이 직접 출두한 바 없음에도 불구하고 본인이 직접 신청하여 발급받은 것처럼 인감증명서에 기재한 경우(대판 1997.7.11. 97도1082) 司56

(2) 변개

권한 있는 공무원이 진정하게 작성된 문서를 허위로 고치는 것이다. 작성권한 있는 자의 변경이라는 점에서 작성권한 없는 자의 변조와 구별된다(무형위조). 가필, 정정 등 그 방법은 무제한이지만, 최소한 이러한 방법을 통하여 내용이 허위로 바뀌어야 한다.

III. 허위공문서작성죄의 간접정범의 성부

1. 공무원이 아닌 자가 작성권자를 이용한 경우

공무원 아닌 자는 본죄의 정범이 될 수 있는 신분이 없기 때문에 공무원 아닌 자가 작성권자인 공무원을 이용하여 허위공문서를 작성케 한 경우에는 본죄의 간접정범이 성립할 수 없다.

형법은 소위 무형위조에 관하여서는 공문서에 관하여서만 이를 처벌하고 일반 사문서의 무형 위조를 인정하지 아니할 뿐 아니라 공문서의 무형위조에 관하여서도 동법 제227조 이외에 특히 공무원에 대하여 허위의 신고를 하고 공정증서원본, 면허장, 감찰 또는 여권에 사실 아닌 기재를 하게 할 때에 한하여 동법 제228조의 경우의 처벌규정을 만들고 더구나 위 227조의 경우의 형벌보다 현저히 가볍게 벌하고 있음에 지나지 않는 점으로 보면 공무원이 아닌 자가 허위의 공문서 위조의 간접정범이 되는 때에는 동법 제228조의 경우 이외에는 이를 처벌하지 아니하는 취지로 해석함을 상당하다.

다만 대법원은 최근에 공문서기안담당자가 본죄의 간접정범일 때 그와 공모한 사인은 간접정범의 공범, 즉 간접정범의 공동정범이 된다고 판시하여 가벌성의 범위를 확장하였다.

[사실관계] 피고인 甲이 향도예비군훈련을 받은 사실이 없음에도 불구하고 소속 예비군동대방위병인 乙에게 예비군훈련을 받았다는 내용의 확인서를 발급하여 달라고 부탁하자 동인은 작성권자인 예비군동대장에게 그 사실을 보고하여 그로부터 甲이 예비군훈련에 참가한 여부를 확인한 후 확인서를 발급하도록 지시를 받고서는 미리 예비군동대장의 직인을 찍어 보관하고 있던 예비군훈련확인서용지에 甲의 성명 등 인적사항을 기재하고 甲에게 교부하여 주었다.

[판결요지] 문서의 작성권한이 있는 공무원의 직무를 보좌하는 자가 그 직위를 이용하여 행사할 목적으로 허위의 내용이 기재된 문서 초안을 그 정을 모르는 상사에게 제출하여 결재하도록 하는 등의 방법으로 작성권한이 있는 공무원으로 하여금 허위의 공문서를 작성하게 한 경우에는 간접정범이 성립되고 이와 공모한 자 역시 그 간접정범의 공범으로서의 죄책을 면할 수 없는 것이고, 여기서 말하는 공범은 반드시 공무원의 신분인 자로 한정되는 것은 아니라고 할 것이다.

2. 공문서 작성보조자가 작성권자를 이용한 경우

(1) 문제점

가령 방위병 甲이 허위의 예비군 훈련증명서를 작성하여 그 정을 모르는 예비군 동대장 乙의 결재를 받아 증명서를 발급해 준 경우 이는 자기명의로 공문서를 작성할 권한은 없지만 기안을 담당하는 작성보조자가 정을 모르는 작성권자를 이용하여 허위공문서를 작성한 경우이다. 여기서 작성보조자 甲이 작성권자 乙을 이용하여 본죄의 간접정범이 될 수 있는가가 문제되는데, 이는 허위공문서작성죄는 작성권한 있는 공무원만이 행위주체가 될 수 있는 진정신분범이기 때문에 발생하는 문제이다.

(2) 학설 - 긍정설(사실상 또는 실질적 작성권한설)

기안을 담당하는 보조공무원은 문서의 작성명의인은 아니지만 사실상 또는 실질적으로 작성권한을 갖고 있으므로 간접정범이 성립한다.

(3) 판례 - 긍정설

경찰서 보안과장인 피고인 甲이 乙의 음주운전을 눈감아주기 위하여 그에 대한 음주운전자 적발보고서를 찢어버리고, 乙이 일련번호가 乙에 대한 음주운전자 적발보고서와 동일한 번호로 된 가짜 음주운전자 적발보고서를 구해 오자, 부하로 하여금 일련번호가 동일한 가짜 음주운전자 적발보고서에 丙에 대한 음주운전자 사실을 기재케 하여 그 정을 모르는 담당 경찰관으로 하여금 주취운전자 음주측정처리부에 丙에 대한 음주운전자 사실을 기재하도록 한 이상, 허위공문서작성 및 동 행사죄의 간접정범으로서의 죄책을 면할 수 없다.

(4) 결론

공문서작성의 현실은 대부분이 작성권자를 보조하는 지위에 있는 공무원이 문서를 작성하고 작성권자인 상사는 결재만 하는 형태로 이루어진다. 그럼에도 불구하고 신분이 결여되었다는 이유로 무죄를 인정하면 작성보조자에 대한 처벌의 흠결이 발생하는바, 이는 받아들이기 어렵다고 할 것이다. 긍정설이 타당하고, 위의 사례에서 甲은 허위공문서작성죄의 간접정범이 된다.

IV. 보론 - 타죄에 대한 관계

1. 허위진단서작성죄와의 관계

형법 제233조 소정의 허위진단서작성죄의 대상은 공무원이 아닌 의사가 사문서로서 진단서를 작성한 경우에 한정되고, 공무원인 의사가 공무소의 명의로 허위진단서를 작성한 경우에는 허위공문서작성죄만이 성립하고 허위진단서작성죄는 별도로 성립하지 않는다(대판 2004.4.9. 2003도7762).
辯1 司52・55・56

2. 직무유기죄와의 관계

판례 (대판 1999.12.24. 99도2240)

司44・49・52・55

수사업무에 종사하는 경찰관들이 18명의 도박범행사실을 적발하고 그들의 인적사항을 확인하였음에도 이를 상사인 파출소장에게 즉시 보고하여 그 도금(賭金) 등을 압수하고 도박범들을 도박죄로 형사입건하는 등 범죄수사에 필요한 조치를 다하지 아니하고 도박범들로부터 이를 묵인하여 달라는 부탁을 받고 그 도박사실을 발견하지 못한 것처럼 근무일지를 허위로 작성하고 소속 파출소장에게 이를 허위로 보고한 경우 공무원이 어떠한 위법사실을 발견하고도 직무상 의무에 따른 적절한 조치를 취하지 아니하고 위법사실을 적극적으로 은폐할 목적으로 허위공문서를 작성, 행사한 경우에는 직무위배의 위법상태는 허위공문서작성 당시부터 그 속에 포함되는 것으로 작위범인 허위공문서작성, 동행사죄만이 성립하고 부작위범인 직무유기죄는 따로 성립하지 아니한다.

♣ 확인학습문제

1. 의사 甲이 교통사고 환자 A의 부탁을 받고 전치 3주 정도 되는 상해라고 생각하면서도 6주라고 진단서에 기재하였으나, 실제로 A의 상해의 정도가 6주 정도에 이르렀을 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 허위진단서작성죄
- ② 사문서위조죄
- ③ 사문서변조죄
- ④ 공문서위조죄
- ⑤ 무죄

【정답】 ⑤

【해설】 작성자가 허위라고 생각하고 기재했으나 진단서등에 기재한 내용이 실질적으로 진실에 부합하는 경우에는 허위작성이 인정되지 아니하여 본죄의 구성요건해당성이 배제된다.

2. 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 乙이 허위공문서작성죄의 간접정범이 되는 경우 이에 공범으로 가담한 甲이 반드시 공무원의 신분이 있는 자로 한정되는 것은 아니다.
- ② 문서를 보충기재 할 권한만 위임되어 있는 자가 작성자의 직인을 사용하여 허위의 문서를 직접 작성한 때에는 공문서위조죄가 성립한다.
- ③ 가옥대장에 무허가건물을 허가받은 건물로 기재한 경우 허위공문서작성죄가 성립한다.
- ④ 공무원 아닌 자가 작성권자인 공무원을 이용하여 허위공문서를 작성케 한 경우에는 본죄의 간접정범이 성립할 수 없다.
- ⑤ 인감증명서 발급업무를 담당하는 甲이, 인감증명서 발급을 신청한 본인이 직접 출두한 바 없음에도 불구하고 본인이 직접 신청하여 발급받은 것처럼 인감증명서에 기재한 경우 허위공문서작성죄가 성립한다.

[정답] ④

[해설] 공무원 아닌 자는 본죄의 정범이 될 수 있는 신분이 없기 때문에 공무원 아닌 자가 작성권자인 공무원을 이용하여 허위공문서를 작성케 한 경우에는 본죄의 간접정범이 성립할 수 없다.

3. 수사업무에 종사하는 경찰관 甲이 18명의 도박범행사실을 적발하고 그들의 인적사항을 확인하였음에도 이를 상사인 파출소장에게 즉시 보고하여 그 도금(賭金) 등을 압수하고 도박범들을 도박죄로 형사입건하는 등 범죄수사에 필요한 조치를 다하지 아니하고 도박범들로부터 이를 묵인하여 달라는 부탁을 받고 그 도박사실을 발견하지 못한 것처럼 근무일지를 허위로 작성하고 소속 파출소장에게 이를 허위로 보고한 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 허위공문서작성죄
- ② 허위공문서작성죄와 직무유기죄
- ③ 공문서위조죄
- ④ 직무유기죄
- ⑤ 무죄

[정답] ①

[해설] 작위범인 허위공문서작성, 동행사죄만이 성립하고 부작위범인 직무유기죄는 따로 성립하지 아니한다(대판 1999.12.24. 99도2240).

♣ 학습내용 정리

- 1. 허위진단서작성죄는 의사, 한의사, 치과의사 또는 조산사가 진단서·검안서 또는 생사에 관한 증명서를 허위로 작성함으로써 성립하는 범죄이다.
- 2. 허위공문서작성죄는 공무원이 행사할 목적으로 그 직무에 관하여 문서 또는 도화를 허위로 작성하거나 변개함으로써 성립하는 범죄이다.
- 3. 공문서의 작성을 보조하는 공무원 甲이 작성권자 乙을 이용하여 허위공문서작성죄의 간접정범이 될 수 있다는 것이 판례의 태도이다.

제37강 위조등문서행사죄와 문서부정행사죄

♣ 학습목표

- 위조 등 문서행사죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 사문서부정행사죄에 대하여 설명할 수 있다.
- 공문서부정행사죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 위조통화행사죄와의 죄수관계를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 위조문서행사
- 사문서부정행사죄
- 공문서부정행사죄
- 사용권한 있는 자의 용도에 따른 사용

♣ 사전테스트

1. 사정을 아는 악의의 제3자나 공범자에게 위조된 문서를 제시·교부하는 것도 행사에 해당한다.
정답 : X
2. 위조된 문서의 작성 명의인이라고 하여 행사의 상대방이 될 수 없는 것은 아니다.
정답 : O
3. 위조된 문서를 우송한 경우에는 상대방이 실제로 그 문서를 보아야 기수가 된다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

간접정범을 통한 위조문서행사범행에 있어 도구로 이용된 자에게 행사한 경우에는 설사 그 도구가 문서가 위조된 것임을 알지 못한다고 하더라도 위조문서행사죄가 성립하지 않는다.

[정답] X

[해설] 간접정범을 통한 위조문서행사범행에 있어 도구로 이용된 자라고 하더라도 문서가 위조된 것임을 알지 못하는 자에게 행사한 경우에는 위조문서행사죄가 성립한다(대판 2012.2.23. 2011도14441).

♣ 강의내용

1. 위조 등 문서행사죄(형법 제234조)

1. 행사의 방법

행사방법은 무제한하다. 예컨대 제시·교부·후송·비치 등이 이에 해당한다. 그러나 단순한 휴대·소지만으로는 행사라고 할 수 없다(대판 1956.11.2. 4289형상240).

판례 (대판 2008.10.23. 2008도5200) 辯1·3 司54

[1] 위조문서행사죄에 있어서 행사라 함은 위조된 문서를 진정한 문서인 것처럼 그 문서의 효용방법에 따라 이를 사용하는 것을 말하고, 위조된 문서를 제시 또는 교부하거나 비치하여 열람할 수 있게 두거나 우편물로 발송하여 도달하게 하는 등 위조된 문서를 진정한 문서인 것처럼 사용하는 한 그 행사의 방법에 제한이 없다. 또한, 위조된 문서 그 자체를 직접 상대방에게 제시하거나 이를 기계적인 방법으로 복사하여 그 복사본을 제시하는 경우는 물론, 이를 모사전송의 방법으로 제시하거나 컴퓨터에 연결된 스캐너(scanner)로 읽어 들어 이미지화한 다음 이를 전송하여 컴퓨터 화면상에서 보게 하는 경우도 행사에 해당하여 위조문서행사죄가 성립한다. [2] 휴대전화 신규 가입신청서를 위조한 후 이를 스캔한 이미지 파일을 제3자에게 이메일로 전송한 경우, 이미지 파일 자체는 문서에 관한 죄의 '문서'에 해당하지 않으나, 이를 전송하여 컴퓨터 화면상으로 보게 한 행위는 이미 위조한 가입신청서를 행사한 것에 해당하므로 위조사문서행사죄가 성립한다.

2. 행사의 상대방

행사의 상대방도 무제한이지만, 상대방은 문서가 위조 또는 변조되었다는 사실을 몰라야 한다. 그러나 사정을 아는 악의의 제3자나 공범자에게 제시·교부하는 것은 행사가 아니다.

판례 (대판 1986.2.25. 85도2798) 辯3 司40·41

위조, 변조, 허위작성된 문서의 행사죄는 이와 같은 문서를 진정한 것 또는 그 내용이 진실한 것으로 각 사용하는 것을 말하는 것이므로, 그 문서가 위조, 변조, 허위작성되었다는 정을 아는 공범자들에게 제시, 교부하는 경우 등에 있어서는 행사죄가 성립할 여지가 없다.

판례 (대판 2012.2.23. 2011도14441) 司57

[1] 위조문서행사죄에 있어서의 행사는 위조된 문서를 진정한 것으로 사용함으로써 문서에 대한 공공의 신용을 해칠 우려가 있는 행위를 말하므로, 행사의 상대방에는 아무런 제한이 없고, 다만 문서가 위조된 것임을 이미 알고 있는 공범자 등에게 행사하는 경우에는 위조문서행사죄가 성립될 수 없으나, 간접정범을 통한 위조문서행사범행에 있어 도구로 이용된 자라고 하더라도 문서가 위조된 것임을 알지 못하는 자에게 행사한 경우에 위조문서행사죄가 성립한다. [2] 피고인이 위조·변조한 공문서의 이미지 파일을 甲 등에게 이메일로 송부하여 프린터로 출력하게 함으로써 '행사'하였다는 내용으로 기소되었는데, 甲 등은 출력 당시 위 파일이 위조된 것임을 알지 못한 사안에서, 피고인의 행위가 위조·변조공문서행사죄를 구성한다고 보아야 하는데도, 이와 달리 보아 무죄를 선고한 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

판례 (대판 2005.1.28. 2004도4663) 司56

위조문서행사죄에 있어서의 행사는 위조된 문서를 진정한 것으로 사용함으로써 문서에 대한 공공의 신용을 해칠 우려가 있는 행위를 말하므로, 행사의 상대방에는 아무런 제한이 없고 위조된 문서의 작성명의인이라고 하여 행사의 상대방이 될 수 없는 것은 아니다.

3. 기수시기

판례 (대판 2005.1.28. 2004도4663) 辯1

위조사문서의 행사는 상대방으로 하여금 위조된 문서를 인식할 수 있는 상태에 동으로써 기수가 되고 상대방이 실제로 그 내용을 인식하여야 하는 것은 아니므로, 위조된 문서를 우송한 경우에는 그 문서가 상대방에게 도달한 때에 기수가 되고 상대방이 실제로 그 문서를 보아야 하는 것은 아니다.

4. 위조통화행사죄와의 죄수관계

판례 (대판 2013.12.12. 2012도2249)

① 형법상 통화에 관한 죄는 문서에 관한 죄에 대하여 특별관계에 있으므로 통화에 관한 죄가 성립하는 때에는 문서에 관한 죄는 별도로 성립하지 않는다. 그러나 위조된 외국의 화폐, 지폐 또는 은행권이 강제통용력을 가지지 않는 경우에는 형법 제207조 제3항에서 정한 ‘외국에서 통용하는 외국의 화폐 등’에 해당하지 않고, 나아가 그 화폐 등이 국내에서 사실상 거래 대가의 지급수단이 되고 있지 않는 경우에는 형법 제207조 제2항에서 정한 ‘내국에서 유통하는 외국의 화폐 등’에도 해당하지 않으므로, ② 그 화폐 등을 행사하더라도 형법 제207조 제4항에서 정한 위조통화행사죄를 구성하지 않는다고 할 것이고, 따라서 이러한 경우에는 형법 제234조에서 정한 위조사문서행사죄 또는 위조사도화행사죄로 의율할 수 있다고 보아야 한다.

II. 사문서부정행사죄(형법 제236조)

판례 (대판 2007.3.30. 2007도629)

[1] 형법 제236조 소정의 사문서부정행사죄는 사용권한자와 용도가 특정되어 작성된 권리의무 또는 사실증명에 관한 타인의 사문서 또는 사도화를 사용권한 없는 자가 사용권한이 있는 것처럼 가장하여 부정한 목적으로 행사하거나 또는 권한 있는 자라도 정당한 용법에 반하여 부정하게 행사하는 경우에 성립한다.

[2] 실질적인 채권채무관계 없이 당사자 간의 합의로 작성한 ‘차용증 및 이행각서’는 그 작성명의인들이 자유의사로 작성한 문서로 그 사용권한자가 특정되어 있다고 할 수 없고 또 그 용도도 다양하므로, 설령 피고인이 그 작성명의인들의 의사에 의하지 아니하고 위 ‘차용증 및 이행각서’상의 채권이 실제로 존재하는 것처럼 그 지급을 구하는 민사소송을 제기하면서 소지하고 있던 위 ‘차용증 및 이행각서’를 법원에 제출하였다고 하더라도 그것이 사문서부정행사죄에 해당하지 않는다고 본 사례.

III. 공문서부정행사죄(형법 제230조)

1. 의의 및 성격

본죄는 공무원 또는 공무소의 문서·도화를 부정행사함으로써 성립하는 범죄로 권한 없는 자가 진정한 공문서를 권한 자처럼 사용하거나 또는 권한자라도 본래 용도를 벗어나서 사용하는 내용의 범죄이다. 본죄는 그 성격에 있어서 사문서부정행사죄에 비해 불법이 가중된 가중적 구성요건이다.

2. 구성요건

(1) 행위객체

이미 진정하게 성립된 공무소의 문서·도화이다. 따라서 이미 위조된 공문서는 위조공문서행사죄의 객체가 되며, 이미 허위내용으로 작성된 공문서를 부정행사하는 경우에는 허위작성공문서행사죄가 성립한다.

판례 (대판 2009.2.26. 2008도10851) 辯3

선박법 제8조 제2항 등 관계 법령의 규정에 의하면, 선박국적증서는 한국선박으로서 등록하는 때에 선박번호, 국제해사기구에서 부여한 선박식별번호, 호출부호, 선박의 종류, 명칭, 선적항 등을 수록하여 발급하는 문서이고, 선박검사증서는 선박정기검사 등에 합격한 선박에 대하여 항해구역·최대승선인원 및 만재할수선의 위치 등을 수록하여 발급하는 문서이다. 위 각 문서는 당해 선박이 한국선박임을 증명하고, 법률상 항행할 수 있는 자격이 있음을 증명하기 위하여 선박소유자에게 교부되어 사용되는 것이다. 따라서 어떤 선박이 사고를 낸 것처럼 허위로 사고신고를 하면서 그 선박의 선박국적증서와 선박검사증서를 함께 제출하였다고 하더라도, 선박국적증서와 선박검사증서는 위 선박의 국적과 항행할 수 있는 자격을 증명하기 위한 용도로 사용된 것일 뿐 그 본래의 용도를 벗어나 행사된 것으로 보기는 어려우므로, 이와 같은 행위는 공문서부정행사죄에 해당하지 않는다.

(2) 행위 : 부정행사이다.

부정행사란 이미 진정하게 성립한 진실한 내용의 공문서를 사용할 권한이 없는 자가 사용할 권한이 있는 자인 것처럼 가장하여 사용하는 것이다.

(가) 사용권한 없는 자의 용도에 따른 사용

사용권한 없는 자가 용도에 따라 사용한 경우에는 본죄가 성립한다는 점에는 이론이 없다.

판례 타인의 운전면허증을 행사한 사건(대판 2001.4.19. 2000도1985 전원합의체) 辯3 司44
· 49 · 53 · 55

[사실관계] 甲은 乙 명의의 된 乙 소유의 제1종 보통운전면허증 1장을 습득한 후 노상에서 주차문제로 丙과 다투던 중 丙에게 약 4주간의 치료를 요하는 상해를 가했다는 혐의로 현행범으로 체포되어 조사를 받던 중 조사경찰관으로부터 운전면허증의 제시를 요구받자 습득하여 소지 중이던 서울지방경찰청장 발행의 공문서인 乙 명의의 제1종 보통운전면허증을 마치 자신의 운전면허증인 것처럼 제시하였다.

[판결요지] [다수의견] 운전면허증은 운전면허를 받은 사람이 운전면허시험에 합격하여 자동차의 운전이 허락된 사람임을 증명하는 공문서로서, 운전면허증에 표시된 사람이 운전면허시험에 합격한 사람이라는 ‘자격증명’과 이를 지니고 있으면서 내보이는 사람이 바로 그 사람이라는 ‘동일인증명’의 기능을 동시에 가지고 있다. 운전면허증의 앞면에는 운전면허를 받은 사람의 성명·주민등록번호·주소가 기재되고 사진이 첨부되며 뒷면에는 기재사항의 변경내용이 기재될 뿐만 아니라, 정기적으로 반드시 갱신교부되도록 하고 있어, 운전면허증은 운전면허를 받은 사람의 동일성 및 신분을 증명하기에 충분하고 그 기재 내용의 진실성도 담보되어 있다. 그럼에도 불구하고 운전면허증을 제시한 행위에 있어 동일인증명의 측면은 도외시하고, 그 사용목적이 자격증명으로만 한정되어 있다고 해석하는 것은 합리성이 없다. 우리 사회에서 운전면허증을 발급 받을 수 있는 연령의 사람들 중 절반 이상이 운전면허증을 가지고 있고, 특히 경제활동에 종사하는 사람들의 경우에는 그 비율이 훨씬 더 이를 앞지르고 있으며, 금융기관과의 거래에 있어서도 운전면허증에 의한 실명확인이 인정되고 있는 등 현실적으로 운전면허증은 주민등록증과 대등한 신분증명서로 널리 사용되고 있다. 따라서 제3자로부터 신분확인을 위하여 신분증명서의 제시를 요구받고 다른 사람의 운전면허증을 제시한 행위는 그 사용목적에 따른 행사로서 공문서부정행사죄에 해당한다고 보는 것이 옳다.

(나) 사용권한 없는 자의 용도 이외의 사용

본죄의 부정행사는 사용권한이 없는 자가 본래의 사용용도에 따른 공문서의 사용만을 지칭하는 것으로 축소해석 해야 하므로 이 경우에는 부정행사를 인정할 수 없다(다수설, 판례).

판례 엄마·누나 사칭하여 휴대폰 개설한 사건(대판 2003.2.26. 2002도4935) 辯3 司47·56

[사실관계] 甲(남, 17세)은 ① 2000.4.경 이동전화기 판매대리점의 판매행사장에서 위 대리점에 근무하는 직원에게 甲이 습득하여 가지고 있던 乙(여, 25세)의 주민등록증을 제시하면서 “내 이름은 A이고 乙은 누나인데, 이동전화기를 구입해 오라고 하였다.”고 거짓말하면서 허무인인 A 명의로 이동전화 가입신청을 한 다음, 그와 같은 사정을 모르는 위 직원으로부터 이동전화기를 교부받고, ② 그 무렵 다른 기회에 다시 위 대리점 직원에게 甲이 보관하고 있던 丙(여, 40대)의 주민등록증을 제시하면서 “丙이 어머니인데, 어머니의 허락을 받았다.”고 거짓말하면서 丙 명의로 이동전화 가입신청을 하고 이동전화기를 교부받았다. 원심은 甲에게 점유이탈물횡령죄, 사문서위조죄 및 동행사죄, 사기죄에 대하여 유죄를 인정하였다.

[판결요지] [1] 사용권한자와 용도가 특정되어 있는 공문서를 사용권한없는 자가 사용한 경우에도 그 공문서 본래의 용도에 따른 사용이 아닌 경우에는 형법 제230조의 공문서부정행사죄가 성립되지 아니한다. [2] 피고인이 기왕에 습득한 타인의 주민등록증을 피고인 가족의 것이라고 제시하면서 그 주민등록증상의 명의 또는 가명으로 이동전화 가입신청을 한 경우, 타인의 주민등록증을 본래의 사용용도인 신분확인용으로 사용한 것이라고 볼 수 없어 공문서부정행사죄가 성립하지 않는다.

(다) 사용권한 있는 자의 용도이외의 사용

판례 (대판 1981.12.8. 81도1130)

공문서부정행사죄는 그 사용권자와 용도가 특정되어 작성된 공문서 또는 공도서를 사용권한 없는 자가 그 사용권한이 있는 것처럼 가장하여 부정한 목적을 행사하거나 또는 사용권한 있는 자라도 그 정당한 용법에 반하여 부정하게 행사하는 경우에 성립되는 것이라 할 것이므로 인감증명서나 등기필증과 같이 사용권한자가 특정되어 있는 것도 아니고 그 용도도 다양한 공문서는 설사 그 문서와 아무 관련 없는 사람이 문서상의 명의인인 양 가장하여 이를 행사하였다 하더라도 공문서부정행사죄가 성립되지 아니한다.

판례 (대판 1999.5.14. 99도206) 辯3 司49

주민등록표등본은 시장·군수 또는 구청장이 주민의 성명, 주소, 성별, 생년월일, 세대주와의 관계 등 주민등록법 소정의 주민등록사항이 기재된 개인별·세대별 주민등록표의 기재 내용 그대로를 인증하여 사본·교부하는 문서로서 그 사용권한자가 특정되어 있다고 할 수 없고, 또 용도도 다양하며, 반드시 본인이나 세대원만이 사용할 수 있는 것이 아니므로, 타인의 주민등록표등본을 그와 아무런 관련 없는 사람이 마치 자신의 것인 것처럼 행사하였다고 하더라도 공문서부정행사죄가 성립되지 아니한다.

♣ 확인학습문제

1. 甲은 A 명의를 모용하여 휴대전화 신규 가입신청서를 위조한 후 이를 컴퓨터에 연결된 스캐너로 읽어 들여 이미지화한 다음, 그 이미지 파일을 이메일로 그 위조사실을 모르는 B에게 마치 진정하게 성립된 것처럼 전송하여 컴퓨터 화면상에서 보게 하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사문서위조죄와 위조사문서행사죄의 상상적 경합
- ② 사문서위조죄와 위조사문서행사죄의 실체적 경합
- ③ 사문서위조죄
- ④ 위조사문서행사죄
- ⑤ 무죄

[정답] ②

[해설] 이미지 파일 자체는 문서에 관한 죄의 '문서'에 해당하지 않으나, 이를 전송하여 컴퓨터 화면상으로 보게 한 행위는 이미 위조한 가입신청서를 행사한 것에 해당하므로 위조사문서행사죄가 성립한다(대판 2008.10.23. 2008도5200).

2. 다음의 문서죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 타인의 운전면허증을 경찰관에게 신분확인용으로 제시한 경우 공문서부정행사죄가 성립되지 아니한다.
- ② 甲 선박에 의해 발생한 사고를 마치 乙 선박에 의해 발생한 것처럼 허위신고를 하면서 그에 대한 검정용 자료로서 乙 선박의 선박국적증서와 선박검사증서를 제출한 경우, 공문서부정행사죄가 성립하지 아니한다.
- ③ 실질적인 채권채무관계 없이 당사자 간의 합의로 작성한 '차용증 및 이행각서'를 이용하여 대여금청구소송을 제기하면서 이를 법원에 제출한 경우, 사문서부정행사죄에 해당하지 않는다.
- ④ 위조된 외국의 화폐, 지폐 또는 은행권이 외국에서 강제통용력이 없고 국내에서 사실상 거래 대가의 지급수단이 되지 않는 경우, 그 화폐 등을 행사한 행위가 위조통화행사죄를 구성하지 않더라도 위조사문서행사죄 또는 위조사도화행사죄로 의율할 수 있다.
- ⑤ 인감증명서나 등기필증과 같이 사용권한자가 특정되어 있는 것도 아니고 그 용도도 다양한 공문서는 설사 그 문서와 아무 관련 없는 사람이 문서상의 명의인인 양 가장하여 이를 행사하였다 하더라도 공문서부정행사죄가 성립되지 아니한다.

[정답] ①

[해설] 제3자로부터 신분확인을 위하여 신분증명서의 제시를 요구받고 다른 사람의 운전면허증을 제시한 행위는 그 사용목적에 따른 행사로서 공문서부정행사죄에 해당한다고 보는 것이 옳다(대판 2001.4.19. 2000도1985 전원합의체)

3. 17세 청소년인 甲은 길을 가다가 우연히 습득한 A의 주민등록증을 이동전화대리점에서 甲의 가족의 것이라고 직원에게 제시하면서 그 주민등록증상의 명의 또는 가명으로 이동전화 가입신청을 하고 무상으로 이동전화기를 교부받았다. 위의 사례에서 甲에게 성립하는 범죄가 아닌 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 점유이탈물횡령죄
- ② 사기죄
- ③ 공문서부정행사죄

- ④ 사문서위조죄
- ⑤ 위조사문서행사죄

【정답】 ③

【해설】 이 경우, 타인의 주민등록증을 본래의 사용용도인 신분확인용으로 사용한 것이라고 볼 수 없어 공문서부정행사죄가 성립하지 않는다(대판 2003.2.26. 2002도493).

♣ 학습내용 정리

1. 위조문서의 행사방법은 무제한하다. 예컨대 제시·교부·후송·비치 등이 이에 해당한다.
2. 사문서부정행사죄는 사용권한자와 용도가 특정되어 작성된 권리의무 또는 사실증명에 관한 타인의 사문서 또는 사도화를 사용권한 없는 자가 사용권한이 있는 것처럼 가장하여 부정한 목적으로 행사하거나 또는 권한 있는 자라도 정당한 용법에 반하여 부정하게 행사하는 경우에 성립한다.
3. 공문서부정행사죄에 있어 부정행사란 이미 진정하게 성립한 진실한 내용의 공문서를 사용할 권한이 없는 자가 사용할 권한이 있는 자인 것처럼 가장하여 사용하는 것이다.

제38강 공무원의 직무에 대한 죄

♣ 학습목표

- 직무유기죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 직권남용죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 불법체포·감금죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

직무유기
직권남용
권리행사방해
불법체포·감금

♣ 사전테스트

1. 직무유기죄는 부진정부작위범이다.
정답 : O
2. 직권남용죄에서 공무원의 일반적 직무권한은 반드시 법률상의 강제력을 수반하는 것임을 요한다.
정답 : X
3. 불법체포·감금죄는 부진정신분범이다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

세무공무원이 세금채납자를 체포·감금하는 행위도 직권남용죄에 해당한다.

[정답] X

[해설] 세무공무원이 세금채납자를 체포·감금하는 것처럼 일반적 직무권한과 아무런 관계없는 사항에 대한 행위는 직권남용이 될 수 없다.

♣ 강의내용

1. 직무유기죄(형법 제122조)

공무원이 정당한 이유 없이 직무수행을 거부하거나 직무를 유기함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 진정직무범죄이다. 진정직무범죄라 함은 공무원만이 정범이 될 수 있는 범죄이다. 여기서 공무원신분은 진정신분범에서의 신분과 일치한다. 이에 반하여 부진정직무범죄의 개념도 있는바, 이는 공무원 아닌 자도 범할 수 있지만, 공무원이 범한 때에는 형이 가중되는 범죄를 말한다.

양자의 구별의 실익은 직무범죄에 공범으로 가담한 비공무원의 죄책을 정하는 데 있다. 따라서 비공무원이 진정직무범죄에 가담한 경우에는 형법 제33조 본문에 의하여 공동정범, 교사범, 방조범이 될 수 있지만(통설), 부진정직무범죄에 가담한 경우에는 형법 제33조 단서에 따라 기본범죄가 성립할 뿐이다(통설).

유기행위의 계속으로 위법상태도 계속되기 때문에 본죄는 계속범이다.

판례 (대판 2013.4.26. 2012도15257)

형법 제122조에서 정하는 직무유기죄에서 ‘직무를 유기한 때’란 공무원이 법령, 내규 등에 의한 추상적 성실의무를 태만히 하는 일체의 경우에 성립하는 것이 아니라 직장의 무단이탈, 직무의 의식적인 포기 등과 같이 국가의 기능을 저해하고 국민에게 피해를 야기시킬 가능성이 있는 경우를 가리킨다. 그리하여 일단 직무집행의 의사로 자신의 직무를 수행한 경우에는 그 직무집행의 내용이 위법한 것으로 평가된다는 점만으로 직무유기죄의 성립을 인정할 것은 아니고, 공무원이 태만·분망 또는 착각 등으로 인하여 직무를 성실히 수행하지 아니한 경우나 형식적으로 또는 소홀히 직무를 수행한 탓으로 적절한 직무수행에 이르지 못한 것에 불과한 경우에도 직무유기죄는 성립하지 아니한다.

판례 (대판 1983.3.22. 82도3065)

직무유기죄는 이른바 부진정부작위범으로서 구체적으로 그 직무를 수행하여야 할 작위의무가 있는 데도 불구하고 이러한 직무를 버린다는 인식 하에 그 작위의무를 수행하지 아니함으로써 성립하는 것이다.

<직무유기를 인정한 경우>

- ① 직무유기죄는 구체적으로 그 직무를 수행하여야 할 작위의무가 있는 데도 불구하고 이러한 직무를 버린다는 인식하에 그 작위의무를 수행하지 아니하면 성립하는 것이다. 그러므로 경찰관이 불법체류자의 신병을 출입국관리사무소에 인계하지 않고 훈방하면서 이들의 인적사항조차 기재해 두지 아니하였다면 직무유기죄가 성립한다(대판 2008.2.14. 2005도4202).
- ② 학생군사교육단의 당직사관으로 주번근무를 하던 육군 중위가 당직근무를 함에 있어서 훈육관실에서 학군사관후보생 2명과 함께 술을 마시고 내무반에서 학군사관후보생 2명 및 애인 등과 함께 화투놀이를 한 다음 애인과 함께 자고 난 뒤 교대할 당직근무자에게 당직근무의 인계·인수도 하지 아니한 채 퇴근하였다면 직무유기죄가 성립된다(대판 1990.12.21. 90도2425). 司46·49

<직무유기를 부정한 경우>

- ① 직무유기죄는 공무원이 어떠한 형태로든 직무집행의 의사로 자신의 직무를 수행한 경우에는 그 직무집행의 내용이 위법한 것으로 평가된다는 점만으로 직무유기죄의 성립을 인정할 것은 아니다. 지방자치단체장이 전국공무원노동조합이 주도한 파업에 참가한 소속 공무원들에 대하여 관할 인사위원회에 징계의결요구를 하지 아니하고 가담 정도의 경중을 가려 자체 인사위원회에 징계의결요구를 하거나 훈계처분을 하도록 지시한 행위가 직무유기죄를 구성하지 않는다(대판 2007.7.12. 2006도1390). 辯3

- ② 통고처분이나 고발을 할 권한이 없는 세무공무원이 그 권한자에게 범칙사건 조사 결과에 따른 통고 처분이나 고발조치를 건의하는 등의 조치를 취하지 않았다고 하더라도, 구체적 사정에 비추어 그것이 직무를 성실히 수행하지 못한 것이라고 할 수 있을지언정 그 직무를 의식적으로 방임 내지 포기하였다고 볼 수 없다(대판 1997.4.11. 96도2753). 司49

II. 직권남용죄(형법 제123조)

1. 의의

공무원이 직권을 남용하여 다른 사람에게 의무없는 일을 하게 하거나 다른 사람의 권리행사를 방해함으로써 성립하는 범죄이다.

2. 행위주체

공무원이다. 여기서 공무원이라 함은 본죄의 성질상 명령·강제력을 수반하는 직무를 수행하는 공무원에 제한된다는 것이 다수견해의 태도이다. ex.) 경찰관, 검찰수사관, 교도관

다만 판례는 반드시 법률상의 강제력을 수반하는 것임을 요하지 않는다는 입장이다.

판례 (대판 2004.5.27. 2002도6251) 司55

직권남용죄는 공무원이 그 일반적 직무권한에 속하는 사항에 관하여 직권의 행사에 가탁하여 실질적, 구체적으로 위법·부당한 행위를 한 경우에 성립하고, 그 일반적 직무권한은 반드시 법률상의 강제력을 수반하는 것임을 요하지 아니하며, 그것이 남용될 경우 직권행사의 상대방으로 하여금 법률상 의무 없는 일을 하게 하거나 정당한 권리행사를 방해하기에 충분한 것이면 된다.

3. 행위

직권을 남용하여 사람으로 하여금 의무없는 일을 하게 하거나 사람의 권리행사를 방해하는 것이다.

(1) 직권남용

직권남용이란 공무원이 그의 일반적 권한에 속하는 사항에 관하여 그것을 불법하게 행사하는 것, 즉 형식적, 외형적으로는 직무집행으로 보이나 그 실질은 정당한 권한 이외의 행위를 하는 경우를 의미한다. 예컨대 세무공무원이 세금채납자를 체포·감금하는 것처럼 일반적 직무권한과 아무런 관계없는 사항에 대한 행위는 직권남용이 될 수 없다(司55). 직권남용은 작위·부작위를 불문한다.

판례 (대판 2007.7.13. 2004도3995)

직권남용죄는 공무원이 그 일반적 직무권한에 속하는 사항에 관하여 직권의 행사에 가탁하여 실질적, 구체적으로 위법·부당한 행위를 한 경우에 성립하고, 그 일반적 직무권한은 반드시 법률상의 강제력을 수반하는 것임을 요하지 아니하며, 그것이 남용될 경우 직권행사의 상대방으로 하여금 법률상 의무 없는 일을 하게 하거나 정당한 권리행사를 방해하기에 충분한 것이면 된다.

판례 (대판 2005.4.15. 2002도3453) 司54

형법 제123조의 직권남용죄에 있어서 직권남용이란 공무원이 그 일반적 직무권한에 속하는 사항에 관하여 직권의 행사에 가탁하여 실질적, 구체적으로 위법·부당한 행위를 하는 경우를 의미하고, 위 죄

에 해당하려면 현실적으로 다른 사람이 의무 없는 일을 하였거나 다른 사람의 구체적인 권리행사가 방해되는 결과가 발생하여야 하며, 또한 그 결과의 발생은 직권남용 행위로 인한 것이어야 한다.

(2) 의무 없는 일을 하게 함

법률상 의무 없는 일을 하게끔 하는 경우뿐만 아니라 법률상 의무가 있는 일이라도 의무의 내용을 불리하게 또는 과중하게 변경하는 경우를 포함한다. 본죄에서 말하는 “의무”란 법률상 의무를 가리키고, 단순한 심리적 의무감 또는 도덕적 의무는 이에 해당하지 아니한다.

판례 (대판 1991.12.27. 90도2800)

직권남용죄의 “직권남용”이란 공무원이 그의 일반적 권한에 속하는 사항에 관하여 그것을 불법하게 행사하는 것, 즉 형식적, 외형적으로는 직무집행으로 보이나 그 실질은 정당한 권한 이외의 행위를 하는 경우를 의미하고, 따라서 직권남용은 공무원이 그의 일반적 권한에 속하지 않는 행위를 하는 경우인 지위를 이용한 불법행위와는 구별되며, 또 직권남용죄에서 말하는 “의무”란 법률상 의무를 가리키고, 단순한 심리적 의무감 또는 도덕적 의무는 이에 해당하지 아니한다.

판례 (대판 2011.2.10. 2010도13766) 司54

서울특별시 교육감인 피고인이 인사담당장학관 등에게 지시하여 승진후보자명부상 승진 또는 자격연수 대상이 될 수 없는 특정 교원들을 적격 후보자인 것처럼 추천하거나 임의로 평정점을 조정하는 방법으로 승진임용하거나 그 대상자가 되도록 한 사안에서, 직무집행의 기준과 절차가 법령에 구체적으로 명시되어 있고 실무 담당자에게도 직무집행의 기준을 적용하고 절차에 관여할 고유한 권한과 역할이 부여되어 있다면 실무 담당자로 하여금 그러한 기준과 절차에 위반하여 직무집행을 보조하게 한 경우에는 ‘의무 없는 일을 하게 한 때’에 해당한다.

(3) 권리행사의 방해

법령상 인정된 정당한 권리를 행사하지 못하게 방해하는 것을 말한다.

판례 (대판 2010.1.28. 2008도7312)

[1] 직권남용권리행사방해죄에서 말하는 ‘권리’는 법률에 명기된 권리에 한하지 않고 법령상 보호되어야 할 이익이면 족한 것으로서, 공법상의 권리인지 사법상의 권리인지를 묻지 않는다고 봄이 상당하다.

[2] 경찰관 직무집행법의 관련 규정을 근거로 경찰관은 범죄를 수사할 권한을 가지고 있다고 인정한 다음, 이러한 범죄수사권은 직권남용권리행사방해죄에서 말하는 ‘권리’에 해당한다.

[3] 상급 경찰관이 직권을 남용하여 부하 경찰관들의 수사를 중단시키거나 사건을 다른 경찰관서로 이첩하게 한 경우, 일단 ‘부하 경찰관들의 수사권 행사를 방해한 것’에 해당함과 아울러 ‘부하 경찰관들로 하여금 수사를 중단하거나 사건을 다른 경찰관서로 이첩할 의무가 없음에도 불구하고 수사를 중단하게 하거나 사건을 이첩하게 한 것’에도 해당된다고 볼 여지가 있다. 따라서 위 두 가지 행위 태양에 모두 해당하는 것으로 기소된 경우, ‘권리행사를 방해함으로 인한 직권남용권리행사방해죄’만 성립하고 ‘의무 없는 일을 하게 함으로 인한 직권남용권리행사방해죄’는 따로 성립하지 아니하는 것으로 봄이 상당하다.

(4) 기수시기

의무 없는 행위 또는 권리행사를 방해하는 행위가 있는 것만으로는 부족하고, 피해자의 의무 없는 행위가 실행된 때 또는 권리행사방해의 결과가 발생한 때 기수가 된다.

판례 (대판 2006.2.9, 2003도4599) 司53

[1] 형법 제123조가 규정하는 직권남용권리행사방해죄에서 권리행사를 방해한다 함은 법령상 행사할 수 있는 권리의 정당한 행사를 방해하는 것을 말한다고 할 것이므로 이에 해당하려면 구체화된 권리의

현실적인 행사가 방해된 경우라야 할 것이고, 또한 공무원의 직권남용행위가 있었다 할지라도 현실적으로 권리행사의 방해라는 결과가 발생하지 아니하였다면 본죄의 기수를 인정할 수 없다.

[2] 정보통신부장관이 개인휴대통신 사업자선정과 관련하여 서류심사는 완결된 상태에서 청문심사의 배점방식을 변경함으로써 직권을 남용하였다 하더라도, 이로 인하여 최종 사업권자로 선정되지 못한 경쟁업체가 가진 구체적인 권리의 현실적 행사가 방해되는 결과가 발생하지는 아니하였다는 이유로 무죄를 선고한 원심의 판단을 수긍한 사례.

판례 (대판 1978.10.10. 75도2665)

司54

형법 제123조의 타인의 권리행사방해죄가 기수에 이르려면 행위에 결과가 발생한 것을 필요로 하므로 공무원의 직권남용이 있다 하여도 현실적으로 권리행사의 저해가 없다면 기수를 인정할 수 없다. 따라서 정보담당 경찰관이 증거수집을 위하여 정당 지구당의 집행위원회에서 쓰일 회의장소에 몰래 도청 장치를 하였다가 뜯겨서 도청을 못하였다면 회의진행을 도청 당하지 아니할 권리(기타 권리)가 침해된 현실적인 사실은 없으므로 직권남용죄의 기수로 논할 수 없음이 뚜렷하다.

III. 불법체포·감금죄(형법 제124조)

재판, 검찰, 경찰 기타 인신구속에 관한 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 그 직권을 남용하여 사람을 체포 또는 감금함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 그 성격에 있어서 체포·감금죄에 대하여 특수공무원이라는 신분으로 인하여 책임이 가중되는 부진정신분범이다. 본죄의 행위는 직권을 남용하여 사람을 체포·감금하는 것이다. 직권남용과 관계없이 인신을 구속하는 경우에는 단순체포·감금죄(제276조)가 성립한다.

판례 (대판 1991.12.30. 91모5)

감금죄에 있어서의 감금행위는 사람으로 하여금 일정한 장소 밖으로 나가지 못하도록 하여 신체의 자유를 제한하는 행위를 가리키는 것이고, 그 방법은 반드시 물리적, 유형적 장애를 사용하는 경우뿐만 아니라 심리적, 무형적 장애에 의하는 경우도 포함되는 것인바, 설사 피해자가 경찰서 안에서 직장동료인 피의자들과 같이 식사도 하고 사무실 안팎을 내왕하였다 하여도 피해자를 경찰서 밖으로 나가지 못하도록 그 신체의 자유를 제한하는 유형, 무형의 억압이 있었다면 이는 감금행위에 해당한다.

♣ 확인학습문제

1. 지방자치단체장 甲이 전국공무원노동조합이 주도한 파업에 참가한 소속 공무원들에 대하여 관할 인사위원회에 징계의결요구를 하지 아니하고 가담 정도의 경중을 가려 자체 인사위원회에 징계의결요구를 하거나 훈계처분을 하도록 지시한 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- | | |
|-----------|---------|
| ① 무죄 | ② 직무유기죄 |
| ③ 직권남용죄 | ④ 강요죄 |
| ⑤ 권리행사방해죄 | |

[정답] ①

[해설] 공무원이 이어떠한 형태로든 직무집행의 의사로 자신의 직무를 수행한 경우에는 그 직무집행의 내용이 위법한 것으로 평가된다는 점만으로 직무유기죄의 성립을 인정할 것은 아니다(대판 2007.7.12. 2006도1390).

2. 다음의 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 학생군사교육단의 당직사관으로 주번근무를 하던 육군 중위가 당직근무를 함에 있어서 훈육관실에서 학군사관후보생 2명과 함께 술을 마시고 내무반에서 학군사관후보생 2명 및 애인 등과 함께 화투놀이를 한 다음 애인과 함께 자고 난 뒤 교대할 당직근무자에게 당직근무의 인계, 인수도 하지아니한 채 퇴근하였다면 직무유기죄가 성립된다.
- ② 직권남용죄에서 말하는 “의무”는 법률상 의무만을 가리키는 것이 아니고, 단순한 심리적 의무감 또는 도덕적 의무도 이에 해당한다.
- ③ 직권남용죄에서 말하는 ‘권리’는 법률에 명기된 권리에 한하지 않고 법령상 보호되어야 할 이익이면 족한 것으로서, 공법상의 권리인지 사법상의 권리인지를 묻지 않는다.
- ④ 공무원의 직권남용이 있다 하여도 현실적으로 권리행사의 저해가 없다면 기수를 인정할 수 없다.
- ⑤ 공무원이 직권남용과 관계없이 인신을 구속하는 경우에는 단순체포·감금죄가 성립한다.

[정답] ②

[해설] 직권남용죄에서 말하는 “의무”란 법률상 의무를 가리키고, 단순한 심리적 의무감 또는 도덕적 의무는 이에 해당하지 아니한다(대판 1991.12.27. 90도2800).

3. A 경찰서 형사과 형사인 甲은 乙을 긴급체포한 후 乙에 대한 구속영장이 집행될 때까지 약 82시간동안 위 경찰서 조사계사무실 및 형사피의자 대기실 등에 있게 하면서 조사를 하였다. 그런데 乙이 경찰서 밖으로 나가지 못하도록 그 신체의 자유를 제한하는 유형, 무형의 억압이 있었으나, 乙은 경찰서 안에서 직장동료인 피의자들과 같이 식사도 하고 사무실 안팎을 내왕하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 직무유기죄
- ② 불법감금죄
- ③ 감금죄
- ④ 직권남용죄
- ⑤ 강요죄

[정답] ③

[해설] 설사 피해자가 경찰서 안에서 직장동료인 피의자들과 같이 식사도 하고 사무실 안팎을 내왕하였다 하여도 피해자를 경찰서 밖으로 나가지 못하도록 그 신체의 자유를 제한하는 유형, 무형의 억압이 있었다면 이는 감금행위에 해당한다(대결 1991.12.30. 91모5).

♣ 학습내용 정리

- 1. 직무유기죄는 공무원이 정당한 이유 없이 직무수행을 거부하거나 직무를 유기함으로써 성립하는 범죄이다.
- 2. 직권남용죄는 공무원이 직권을 남용하여 다른 사람에게 의무없는 일을 하게 하거나 다른 사람의 권리행사를 방해함으로써 성립하는 범죄이다.
- 3. 불법체포·감금죄는 재판, 검찰, 경찰 기타 인신구속에 관한 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 그 직권을 남용하여 사람을 체포 또는 감금함으로써 성립하는 범죄이다.

제39강 뇌물죄

♣ 학습목표

- 뇌물죄의 일반이론을 설명할 수 있다.
- 뇌물의 개념을 설명할 수 있다.
- 단순수뢰죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 뇌물공여 등 죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

뇌물
직무관련성
뇌물수수
뇌물공여
증뢰물전달

♣ 사전테스트

1. 뇌물이란 직무에 관한 부당한 이익 또는 불법한 보수를 말한다.
정답 : O
2. 뇌물과 직무행위 사이에는 급부와 반대급부라는 대가관계가 있어야 한다.
정답 : O
3. 포괄적 대가관계는 직무행위에 대한 대가관계로 인정될 수 없다.
정답 : X

♣ 돌발퀴즈

공무원은 뇌물공여죄의 주체가 될 수 없다.

[정답] X

[해설] 공무원도 뇌물공여죄의 주체가 될 수 있다.

♣ 강의내용

1. 뇌물죄의 일반이론

1. 의의

공무원 또는 중재인이 직무행위의 대가로 부당한 이득을 취득하는 것을 내용으로 하는 범죄이다.

2. 뇌물

(1) 개념

직무에 관한 부당한 이익 또는 불법한 보수를 말한다.

(2) 직무관련성

(가) 직무

공무원 또는 중재인이 그 직위에 따라서 담당하는 일체의 업무를 말한다. 뇌물죄와 관련된 직무의 개념은 직무유기죄나 직권남용죄의 직무보다 더 넓은 개념이다. 그러므로 직무행위는 국고 작용이나 행정사법작용이라도 관계없고, 행정상의 사실행위라도 무방하다. 또한 본죄의 직무는 공무원이 법령상 관장하는 직무행위뿐만 아니라 그 직무와 관련하여 사실상 처리하고 있는 행위 및 결정권자를 보좌하거나 영향을 줄 수 있는 직무행위를 포함한다.

(나) 직무관련성

직무에 관하여 공무원이 그의 지위에서 공무로 취급하는 모든 사무이다. 직접적 권한에 속하는 직무행위 뿐만 아니라 밀접한 관계가 있는 것을 포함한다. 직무상의 지위를 이용하거나 그 직무에 기한 세력을 기초로 공무의 공정성에 영향을 미치는 행위가 이에 해당한다. 가령 세무서 직원이 직무와 관련하여 담당 건설업자로 하여금 은행 대출을 받는 데 연대보증하게 한 경우이다.

판례 (대판 2003.6.13. 2003도1060) 辯3

뇌물죄는 직무집행의 공정과 이에 대한 사회의 신뢰에 기하여 직무행위의 불가매수성을 그 직접의 보호법익으로 하고 있으므로 뇌물성은 의무위반 행위나 청탁의 유무 및 금품수수 시기와 직무집행 행위의 전후를 가리지 아니한다 할 것이고, 따라서 뇌물죄에서 말하는 '직무'에는 법령에 정하여진 직무뿐만 아니라 그와 관련 있는 직무, 과거에 담당하였거나 장래에 담당할 직무 외에 사무분장에 따라 현실적으로 담당하지 않는 직무라도 법령상 일반적인 직무권한에 속하는 직무 등 공무원이 그 직위에 따라 공무로 담당할 일체의 직무를 포함한다 할 것이고, 수뢰후부정처사죄에서 말하는 '부정한 행위'라 함은 직무에 위배되는 일체의 행위를 말하는 것으로 직무행위 자체는 물론 그것과 객관적으로 관련 있는 행위까지를 포함한다.

(3) 부당한 이익

(가) 직무행위에 대한 대가관계

1) 내용

뇌물은 직무에 관한 부정한 보수이므로 뇌물과 직무행위 사이에는 급부와 반대급부라는 대가관계가 있어야 한다. 여기서 대가관계는 개개의 직무행위에 대해 구체적으로 관련성을 가질 필요는 없고, 직무에 관한 것이면 특정적·포괄적인 것을 불문한다(포괄적 대가관계).

알선수뢰죄에 있어서는 알선행위와의 사이에 대가관계가 있어야 한다. 예컨대 공무원이 주례를 서주고 사례를 받은 경우처럼 직무와 관계없이 또는 직무행위와 대가관계에 있지 않은 단순한 사적 행위에 대한 보수는 뇌물이 아니다.

판례 (대판 2013.4.11. 2012도16277) 司52·55

공무원이 수수한 이익에 직무행위에 대한 대가로서의 성질과 직무 외의 행위에 대한 사례로서의 성질이 불가분적으로 결합되어 있는 경우에는 그 전부가 직무행위에 대한 대가로서의 성질을 가진다.

2) 사교적 의례로서의 뇌물과 선물의 구별기준

원칙적으로 사교적 의례에 속하는 경우에는 뇌물성을 부정하지만, 다만 사교적 의례의 형식을 사용하고 있다 하여도 직무행위의 대가로서의 의미를 가질 때에는 뇌물이 된다. 따라서 재건축 추진위원장이 재건축조합의 소속한 설립인가를 위해 담당공무원에게 두 차례에 걸쳐 점심 식사를 제공한 경우, 뇌물공여죄의 성립이 인정된다(대판 2008.11.27. 2006도8779).

(나) 이익

받는 사람의 경제적·법적·인격적 지위를 유리하게 해 주는 것이다.

여기서 이익이란 재산·비재산 이익, 유형·무형이익을 불문한다. 이익은 반드시 제공 당시에 있을 필요는 없고, 장래에 약속된 것 또는 조건부 이익인 경우도 해당된다. 다만 비재산적 이익일 때에는 객관적으로 측정할 수 있는 내용을 가지고 있어야 한다.

- ① 뇌물수수죄나 뇌물공여죄에 있어서의 뇌물이란 금전, 물품 기타의 재산적 이익 등 사람의 수요, 욕망을 충족시키기에 족한 유형, 무형의 일체의 이익이 포함되므로 조합아파트 가입권에 붙은 소위 프리미엄도 뇌물에 해당한다(대판 1992.12.22. 92도1762).
- ② 직무와 관련하여 장래 시가양등이 예상되는 체비지의 지분을 낙찰원가에 매수한 것은 투기적 사업에 참여할 기회를 제공받은 것으로 뇌물수수죄에 해당된다(대판 1994.11.4. 94도129). 司52
- ③ ‘성적 욕구의 충족’(유사성교행위 및 성교행위)도 뇌물의 내용인 이익에 포함된다(대판 2014.1.29. 2013도13937).

(다) 이익의 부당성

뇌물죄에서 이익은 부당한 것이어야 한다. 따라서 법령에 의한 봉급·수당·여비·일당·상여금 또는 수수료 등 정당한 대가는 뇌물이 될 수 없다. 이 때 뇌물이 부정·부당하면 충분하고 그 사용용도가 반드시 부정할 필요는 없다. 따라서 뇌물을 고아원·양로원 등 사회봉사기관에 기탁하거나 공사현장 인부들의 식대 또는 홍보비로 사용한 경우에도 뇌물성이 인정된다.

II. 단순수뢰죄(형법 제129조)

1. 의의

공무원 또는 중재인이 직무에 관하여 뇌물을 수수·요구 또는 약속함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 성격상 뇌물죄의 기본적 구성요건이다.

2. 행위주체

공무원 또는 중재인이다

현재 공무원의 지위에 있는 자만이 본죄의 주체가 될 수 있고, 공무원이 되기로 예정되어 있는 자는 사전수뢰죄의 주체가 될 수 있을 뿐이다. 또한 공무원의 지위를 상실한 후에 뇌물을 수수한 자는 사후수뢰죄(제131조 제3항)의 주체는 될 수 있어도, 본죄의 주체는 될 수 없다. 그러나 다른 업무로 전직한 공무원이 전직 전의 직무에 관하여 뇌물을 수수·요구·약속하면 본죄가 성립한다.

3. 행위객체

뇌물이다.

판례 (대판 2007.10.12. 2005도7112) 司53·55

[1] 공무원이 관공서에 필요한 공사의 시행이나 물품의 구입을 위하여 수의계약을 체결하면서 해당 공사업자 등으로부터 돈을 수수한 경우, 그 돈의 성격을 공무원의 직무와 관련하여 수수된 뇌물로 볼 것인지, 아니면 적정한 금액보다 과다하게 부풀린 금액으로 계약을 체결하기로 공사업자 등과 사전 약정하여 이를 횡령(국고손실)한 것으로 볼 것인지 여부는, 종합적으로 고려하여 객관적으로 평가하여 판단해야 한다.

[2] 수의계약을 체결하는 공무원이 해당 공사업자와 적정한 금액 이상으로 계약금액을 부풀려서 계약하고 부풀린 금액을 자신이 되돌려 받기로 사전에 약정한 다음 그에 따라 수수한 돈은 성격상 뇌물이 아니고 횡령금에 해당한다.

4. 행위

직무에 관하여 뇌물을 수수·요구·약속하는 것이다. 공무원에게 청탁하였을 것을 요하지 않는다.

(1) 수수

영득의사로 뇌물을 취득하는 것이다. 영득의사 없이 반환을 위하여 일시 받아 둔 것은 수수가 아니지만, 영득의 의사로 수수한 것이라면 후에 반환하여도 본죄의 성립에는 지장이 없다. 여기서 유형재물은 점유취득으로, 무형이익은 현실적 이익의 향수로 수수가 된다.

판례 (대판 2008.3.13, 2007도10804) 辯1 司51·52·54

[1] 뇌물공여죄와 뇌물수수죄는 필요적 공범관계에 있다고 할 것이나, 필요적 공범이라는 것은 법률상 범죄의 실행이 다수인의 협력을 필요로 하는 것을 가리키는 것으로서 이러한 범죄의 성립에는 행위의 공동을 필요로 하는 것에 불과하고 반드시 협력자 전부가 책임이 있음을 필요로 하는 것은 아니므로, 오로지 공무원을 함정에 빠뜨릴 의사로 직무와 관련되었다는 형식을 빌려 그 공무원에게 금품을 공여한 경우에도 공무원이 그 금품을 직무와 관련하여 수수한다는 의사를 가지고 받아들이면 뇌물수수죄가 성립한다. [2] 피고인의 뇌물수수가 공여자들의 함정교사에 의한 것이기는 하나, 뇌물공여자들에게 피고인을 함정에 빠뜨릴 의사만 있었고 뇌물공여의 의사가 전혀 없었다고 보기 어려울 뿐 아니라, 뇌물공여자들의 함정교사라는 사정은 피고인의 책임을 면하게 하는 사유가 될 수 없다.

(2) 요구

요구란 뇌물취득의 의사로 상대방에게 그 공여를 청구하는 것이다. 상대방이 응했는지, 현실적으로 공여가 있었는지의 여부는 요건이 아니다.

(3) 약속

약속이란 양 당사자간에 뇌물수수를 합의하는 것이다. 목적물인 이익이 약속 당시에 현존할 필요는 없고 기대할 수 있으면 충분하고, 가액이 확정되었을 것도 요하지 않는다. 이 때 약속이 행의 여부는 불문한다.

판례 (대판 2012.11.15. 2012도9417)

형법 제129조의 구성요건인 뇌물의 ‘약속’은 양 당사자의 뇌물수수의 합의를 말하고, 여기에서 ‘합의’란 그 방법에 아무런 제한이 없고 명시적일 필요도 없지만, 장래 공무원의 직무와 관련하여 뇌물을 주고 받겠다는 양 당사자의 의사표시가 확정적으로 합치하여야 한다.

5. 공갈죄 - 공갈죄와 직무관련성과의 관계

뇌물죄는 공무원 또는 중재인이 직무와 관련하여 뇌물을 받음으로써 성립하는바, 공무원이 직무집행과 관련하여 상대방을 공갈하여 재물을 취득한 경우에도 공갈죄 이외에 수뢰죄가 성립하는가가 문제된다. 이에 대하여 학설과 판례는 공무원의 직무집행의 의사여부를 기준으로, 만약 직무집행의 의사 없이 이를 빙자하여 재물의 교부를 받은 때에는 공갈죄만 성립하고, 직무집행의 의사를 가지고 직무집행과 관련하여 재물을 취득한 때에는 수뢰죄와 공갈죄의 상상적 경합이 된다는 입장이다.

판례 세무공무원 수뢰사건(대판 1994.12.22. 94도2528) 辯1 司36・38・49・51・56・57

[판결요지] 공무원이 직무집행의 의사 없이 또는 직무처리와 대가적 관계없이 타인을 공갈하여 재물을 교부하게 한 경우에는 공갈죄만이 성립하고, 이러한 경우 재물의 교부자가 공무원의 해악의 고지로 인하여 외포의 결과 금품을 제공한 것이라면 그는 공갈죄의 피해자가 될 것이고 뇌물공여죄는 성립될 수 없다고 하여야 할 것이나, 세무공무원에게 세무조사라는 직무집행의 의사가 있었고, 과다계상된 손금 항목에 대한 조사를 하지 않고 이를 묵인하는 조건으로, 다시 말하면 그 직무처리에 대한 대가관계로서 금품을 제공받았으며, 세무조사의 상대방은 공무원의 직무행위를 매수하려는 의사에서 금품을 제공한 것이라면 뇌물죄가 성립한다.

III. 뇌물공여 등 죄(형법 제133조)

1. 의의

본죄는 뇌물을 약속·공여하거나 또는 공여의사를 표시한 경우 및 이러한 행위에 쓸 목적으로 제3자에게 금품을 요구하거나 그 정을 알면서 교부받은 경우에 성립하는 범죄이다. 본죄는 그 성격상 수뢰행위와 공범관계에 있는 중립행위 등을 별도로 처벌하는 규정으로서 비공무원에 의해 이루어지는 비신분범이다.

2. 행위주체

제한 없다. 공무원도 본죄의 주체가 될 수 있다.

3. 행위 - 제133조 제1항

(1) 약속

뇌물을 주고받는 두 당사자 사이에 뇌물에 관해 의사가 합치하는 경우이다.

(2) 공여

뇌물을 수수하도록 하는 것이다. 상대방이 뇌물을 수수할 수 있는 상태가 되면 충분하고, 공여상대방이 반드시 공무원일 것은 불필요하다. 따라서 공무원의 처나 가족도 포함된다.

(3) 공여의 의사표시

상대방에게 뇌물을 공여하겠다는 의사를 일방적으로 나타내는 것이다.

(4) 증뢰물전달행위(제133조 제2항)

증뢰물전달죄는 제3자가 증뢰자로부터 교부받은 금품을 수뢰할 사람에게 전달하였는지 여부에 관계없이 제3자가 그 정을 알면서 금품을 교부받음으로써 성립한다. 따라서 제3자가 그 교부받은 금품을 수뢰할 사람에게 전달하였다고 하여 증뢰물전달죄 외에 별도로 뇌물공여죄가 성립하는 것은 아니다. 더 나아가 공무원 또는 종재인이 제3자로부터 전달받은 금품을 즉시 증뢰자에게 반환한 경우에도 본죄가 성립한다.

증뢰물을 전달해달라고 교부하면 제3자 뇌물교부죄가 성립하고, 이를 전달할 의사로 교부받으면 제3자 뇌물취득죄가 성립한다.

판례 (대판 2002.6.14. 2002도1283)

辯1 司46·51

형법 제133조 제2항은 증뢰자가 뇌물에 공할 목적으로 금품을 제3자에게 교부하거나 또는 그 정을 알면서 교부받는 증뢰물전달행위를 독립한 구성요건으로 하여 이를 같은 조 제1항의 뇌물공여죄와 같은 형으로 처벌하는 규정으로서, 제3자의 증뢰물전달죄는 제3자가 증뢰자로부터 교부받은 금품을 수뢰할 사람에게 전달하였는지의 여부에 관계없이 제3자가 그 정을 알면서 금품을 교부받음으로써 성립하는 것이고, 본죄의 주체는 비공무원을 예정한 것이나 공무원일지라도 직무와 관계되지 않는 범위 내에서는 본죄의 주체에 해당될 수 있다 할 것이므로, 피고인이 자신의 공무원으로서의 직무와는 무관하게 군의관 등의 직무에 관하여 뇌물에 공할 목적의 금품이라는 정을 알고 이를 전달해준다는 명목으로 취득한 경우라면 제3자 뇌물취득죄가 성립된다.

4. 죄수

① 알선수뢰한 금원 중 일부를 증뢰한 경우에는 알선수뢰죄와 증뢰죄의 경합범이 성립한다(대판 1967.1.31. 66도1581).

② 뇌물공여죄가 성립되기 위하여서는 뇌물을 공여하는 행위와 상대방 측에서 금전적으로 가치가 있는 그 물품 등을 받아들이는 행위(부작위 포함)가 필요할 뿐이지 반드시 상대방 측에서 뇌물수수죄가 성립되어야만 한다는 것을 뜻하는 것은 아니다(대판 1987.12.22. 87도1699). 辯1 司47·57

♣ **확인학습문제**

1. 다음 뇌물죄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 뇌물성은 의무위반 행위나 청탁의 유무 및 금품수수 시기와 직무집행 행위의 전후를 가리지 아니한다.
- ② 뇌물죄와 관련된 직무의 개념은 직무유기죄나 직권남용죄의 직무보다 더 넓은 개념이다.
- ③ 재건축추진위원장이 재건축조합의 소속한 설립인가를 위해 담당공무원에게 두 차례에 걸쳐 점심 식사를 제공한 경우 뇌물공여죄가 성립한다고 볼 수 없다.
- ④ '성적 욕구의 충족'(유사성교행위 및 성교행위)도 뇌물의 내용인 이익에 포함된다.
- ⑤ 뇌물죄의 직무는 공무원이 법령상 관장하는 직무행위뿐만 아니라 그 직무와 관련하여 사실상 처리하고 있는 행위 및 결정권자를 보좌하거나 영향을 줄 수 있는 직무행위를 포함한다.

[정답] ③

[해설] 공무원이 직무와 관련하여 금품을 수수하였다면 비록 사교적 의례의 형식을 빌려 금품을 주고받았다 하더라도 그 수수한 금품은 뇌물이 된다. → 재건축추진위원장이 재건축조합의 소속한 설립인가를 위해 담당공무원에게 두 차례에 걸쳐 점심 식사를 제공한 사안에서, 뇌물공여죄의 성립을 인정한 사례(대판 2008.11.27. 2006도8779).

2. 시청의 위생과에서 음식점의 위생 상태를 점검하는 업무를 담당하는 공무원 甲은 음식점을 경영하고 있는 乙을 찾아가 “곧 정기검사가 있는데 수표 한 장 정도는 준비해 두어야 좋은 결과를 받을 수 있다. 만약 준비하지 않으면 영업정지를 받을지도 모른다.”라고 말하였다. 이에 두려움을 느낀 乙은 그 자리에서 바로 甲에게 현금 100만 원을 주었고, 이에 甲은 현금을 받아 챙겼다. 그러나 甲은 실제로 직무를 집행할 의사는 없었던 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 공갈죄와 수뢰죄의 상상적 경합
- ② 공갈죄와 수뢰죄의 실체적 경합
- ③ 수뢰죄
- ④ 공갈죄
- ⑤ 사전수뢰죄

[정답] ④

[해설] 공무원이 직무집행의 의사 없이 또는 직무처리와 대가적 관계없이 타인을 공갈하여 재물을 교부하게 한 경우에는 공갈죄만이 성립한다(대판 1994.12.22. 94도2528).

3. 다음의 뇌물죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 알선수뢰한 금원 중 일부를 증뢰한 경우라도 별도로 증뢰죄가 성립하는 것은 아니다.
- ② 뇌물공여죄가 성립되기 위하여서 반드시 상대방 측에서 뇌물수수죄가 성립되어야만 한다는 것을 뜻하는 것은 아니다.
- ③ 제3자가 그 교부받은 금품을 수뢰할 사람에게 전달하였다고 하여 증뢰물전달죄 외에 별도로 뇌물공여죄가 성립하는 것은 아니다.
- ④ 뇌물공여죄는 신분범이 아니다.
- ⑤ 조합아파트 가입권에 붙은 소위 프리미엄도 뇌물에 해당한다.

[정답] ①

[해설] 알선수뢰한 금원 중 일부를 증뢰한 경우에는 알선수뢰죄와 증뢰죄의 경합범이 성립한다(대판 1967.1.31. 66도1581).

♣ 학습내용 정리

1. 뇌물죄는 공무원 또는 중재인이 직무행위의 대가로 부당한 이득을 취득하는 것을 내용으로 하는 범죄이다.
2. 공무원 또는 중재인이 직무에 관하여 뇌물을 수수·요구 또는 약속함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 성격상 뇌물죄의 기본적 구성요건이다.
3. 뇌물공여 등 죄는 뇌물을 약속·공여하거나 또는 공여의사를 표시한 경우 및 이러한 행위에 쓸 목적으로 제3자에게 금품을 요구하거나 그 정을 알면서 교부받은 경우에 성립하는 범죄이다.

제40강 공무집행방해죄(형법 제136조)

♣ 학습목표

- 공무집행방해죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 직무집행의 적법성에 대하여 설명할 수 있다.
- 공무집행방해죄의 죄수의 판단기준을 설명할 수 있다.
- 위계에 의한 공무집행방해죄에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 공무집행방해
- 직무집행
- 직무집행의 적법성
- 위계에 의한 공무집행방해

♣ 사전테스트

1. 공무집행방해죄에서 협박은 상대방이 현실로 공포심을 가지야 하는 것을 요건으로 한다.
정답 : X
2. 실사를 담당하는 공무원이 불충분한 심사를 하여 허위라는 사실을 발견하지 못하여 출원허가가 나갔을 경우에도 위계에 의한 공무집행방해죄가 인정된다.
정답 : X
3. 공무집행방해죄와 업무방해죄의 관계에서 업무방해죄는 성립하지 않는다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

파출소 바닥에 인분을 뿌리고 재떨이에 인분을 담아 바닥에 던지는 경우에는 공무집행방해죄가 성립하지 않는다.

[정답] X

[해설] 공무원에 대한 직접적인 유형력의 행사뿐만 아니라 간접적인 유형력의 행사도 포함한다. 가령 파출소 바닥에 인분을 뿌리고 재떨이에 인분을 담아 바닥에 던지는 경우가 이에 해당한다.

♣ 강의내용

1. 행위객체 - 직무를 집행하는 공무원

1. 의의

직무를 집행하는 공무원을 폭행·협박함으로써 성립하는 범죄이다. 보호법익은 국가의 기능작용으로서 공무 그 자체이다(통설). 보호정도는 추상적 위험범으로서의 보호이다.

2. 행위의 주체

본죄의 주체에는 제한이 없다. 다만 단체 또는 다중의 위력을 보일 정도의 다수의 사람이 본죄를 저지를 때에는 특수공무방해죄가 된다.

3. 행위의 객체

직무를 집행하는 공무원이다.

(1) 공무원

법령에 의해 국가 또는 공공단체의 공무에 종사하는 자이다. 청원경찰(청원경찰법 제3조), 공소유지번호사(형소법 제265조)도 포함된다.

판례 (대판 2011.1.27, 2010도14484)

형법상 공무원이라 함은 국가 또는 지방자치단체 및 이에 준하는 공법인의 사무에 종사하는 자로서 그 노무의 내용이 단순한 기계적 육체적인 것에 한정되어 있지 않은 자를 말한다.

(2) 직무집행

공무원이 직무상 취급할 수 있는 사무를 처리하는 것이다.

(가) 직무

공무원의 직무이면 충분하고, 그 종류 및 성질은 불문한다. 따라서 직무집행이 강제적 성질을 가지는 권력적 작용에 제한되지 않는다.

(나) 직무를 집행하는

공무원이 현재 구체적인 직무를 집행하고 있어야 함을 의미한다. 직무에 종사 중이면 충분하고 반드시 직무집행이 진행되고 있을 것을 요하지 않는다. 따라서 직무집행에 착수하려고 한 때, 공무상 대기 중, 집무시간 중에 정해진 자리에 앉아 있는 경우 등은 직무집행에 속한다.

그러나 직무집행과 시간적·장소적으로 밀접한 관계에 있을 때에는 직무집행착수 이전의 준비행위나 직무완료 이후의 복귀행위도 직무집행에 포함된다.

판례 (대판 1999.9.21. 99도383) 司42·44·47

불법주차 차량에 불법주차 스티커를 붙였다가 이를 다시 떼어 낸 직후에 있는 주차단속 공무원을 폭행한 경우, 폭행 당시 주차단속 공무원은 일련의 직무수행을 위하여 근무중인 상태에 있었다고 보아야 하므로 공무집행방해죄의 성립한다.

[사실관계] 하반신 지체장애자인 甲은 서울지방법원 북부지원 앞 도로상에서 甲이 운전하는 승용차를 주차가 금지된 장소에 주차시킨 데 대하여 구청 소속 공무원으로서 불법주차단속원인 乙녀가 승용차 유리에 불법주차 과태료 스티커를 붙였다는 이유로 피해자의 차마를 양손으로 잡아당겨 찢고, 甲이 타고

있던 휠체어로 乙녀의 다리를 부딪치게 하여 乙녀에게 약 10일간의 치료를 요하는 양측하퇴부좌상의 상해를 입혔다.

(3) 직무집행의 적법성

(가) 적법성의 요부

위법한 직무집행에 대해서는 국민이 복종할 의무가 없고, 형법은 적법한 직무집행만을 보호하므로 직무집행은 적법해야 한다.

판례 (대판 2006.9.8, 2006도148)

辯3

검사나 사법경찰관이 수사기관에 자진출석한 사람을 긴급체포의 요건을 갖추지 못하였음에도 실력으로 체포하려고 하였다면 적법한 공무집행이라고 할 수 없고, 자진출석한 사람이 검사나 사법경찰관에 대하여 이를 거부하는 방법으로써 폭행을 하였다고 하여 공무집행방해죄가 성립하는 것은 아니다.

(나) 적법성의 의미

직무집행의 적법성은 실질적 적법성이 아니라 형식적 적법성을 의미한다(통설). 따라서 공무원의 직무집행이 단지 훈시규정에 어긋나는 정도의 하자밖에 없으면 형법적 보호가 인정된다. 또한 공무원이 법원 또는 관청의 판결이나 결정 또는 처분을 집행하는 때에도 그 실질적 적법성은 문제되지 않는다. 판례 역시 공무집행의 대상이 된 사실에 착오가 있을지라도 그 행위가 공무원의 적법행위라고 인정될 수 있을 때에는 공무집행방해죄가 성립된다는 입장이다.

(다) 적법성의 요건

① 직무집행행위가 해당 공무원의 추상적 직무권한에 속해야 한다.

② 직무집행행위가 법률에 정한 구체적 권한에 속해야 한다.

구체적으로 직무를 담당·실행할 수 있는 법적 전제로서 명령·할당·지정·위임이 있어야 하는 경우에는 그와 같은 법적 전제를 구비해야만 적법한 직무집행이 될 수 있다.

③ 직무행위가 공무원의 재량에 맡겨진 경우

다만 직무행위가 공무원의 재량에 맡겨진 경우에는 그 재량의 범위에서 행한 직무행위는 적법한 것으로 인정된다.

④ 직무집행이 법령에 정한 방식·절차에 의해야 한다.

II. 행위 - 폭행, 협박

폭행·협박이다.

1. 폭행

공무원에게 유형력을 행사하면 충분하고 공무원의 신체에 직접 가해질 필요는 없다(공익의 개념). 따라서 공무원에 대한 직접적인 유형력의 행사뿐만 아니라 간접적인 유형력의 행사도 포함한다. 가령 파출소 바닥에 인분을 뿌리고 재떨이에 인분을 담아 바닥에 던지는 경우가 이에 해당한다. 이 때 공무원의 보조자에 대한 폭행도 간접적으로 공무원에 대한 것으로 인정될 수 있으면 본죄의 폭행에 해당된다.

2. 협박

공포심을 갖게 할 목적으로 해악을 고지하는 것이다. 상대방이 현실로 공포심을 가지야 하는 것은 요건이 아니다.

3. 폭행·협박의 정도

폭행·협박은 공무집행을 방해할 수 있을 정도에 이를 것을 요하므로 공무원이 전혀 개의치 않을 정도의 경미한 폭행·협박은 적정한 공무집행이 방해될 우려가 없으므로 여기에 해당하지 않는다. 또한 폭행·협박은 직무집행공무원에 대하여 공무집행을 방해할 수 있을 정도로 적극적이어야 하므로 단순한 소극적 저항 또는 불복종은 제외된다.

4. 기수시기

폭행·협박이 가해졌을 때이다. 본죄는 추상적 위헌범이므로 직무집행이 현실로 방해되었음을 요하지 않는다(다수설. 판례 : 대판 1989.12.26. 89도1204).

5. 고의

판례 (대판 1995.1.24. 94도1949) 司52·57

공무집행방해죄에 있어서의 범의는 상대방이 직무를 집행하는 공무원이라는 사실, 그리고 이에 대하여 폭행 또는 협박을 한다는 사실을 인식하는 것을 그 내용으로 하고, 그 인식은 불확정적인 것이라도 소위 미필적 고의가 있다고 보아야 하며, 그 직무집행을 방해할 의사를 필요로 하지 아니 한다.

6. 죄수

(1) 죄수결정기준

공무원의 수에 따라 죄수를 결정한다. 동시에 여러 명의 공무집행을 방해하는 경우에는 수죄의 상상적 경합이 된다(대판 1961.9.28. 4291형상415).

(2) 업무방해죄와의 관계

공무집행방해죄와 업무방해죄의 관계에서 업무방해죄는 성립하지 않는다(법조경합의 특별관계).

III. 위계에 의한 공무집행방해죄(형법 137조)

1. 의의

위계에 의해 공무집행을 방해하는 행위를 공무집행방해죄에 준해 처벌하는 범죄이다.

2. 행위객체

공무원의 직무집행이다. 현재의 직무집행은 물론 장래의 직무집행도 포함한다.

판례 (대판 2003.12.26. 2001도6349)

위계에 의한 공무집행방해죄에서 공무원의 직무집행이란 법령의 위임에 따른 공무원의 적법한 직무집행인 이상 공권력의 행사를 내용으로 하는 권력적 작용뿐만 아니라 사경제주체로서의 활동을 비롯한 비권력적 작용도 포함되는 것으로 봄이 상당하다.

3. 행위

위계로써 공무집행을 방해하는 것이다. 여기서 위계란 상대방의 오인, 착각 또는 부지를 이용하는 모든 행위를 말한다. 기망, 유혹, 공연·비공연을 불문한다. 위계의 상대방이 직접 직무를 담당하는 공무원일 필요는 없고, 제3자를 기망하여 공무원의 직무를 방해하는 경우도 포함한다.

그러나 재판에서 실체적 진실발견은 재판관의 고유임무이고, 범죄수사에서 실체적 진실발견은 수사기관의 고유임무이기 때문에 재판, 범죄수사와 관련하여 허위진술, 허위신고 등이 있었다는 사실만으로 위계가 인정되지 않는다. 또한 관청의 인·허가처분도 출원사유가 사실과 부합되지 않을 수도 있음을 전제로 그 인·허가요건을 심사 결정하는 것이므로 출원자에게 진실한 자료 제출의 의무가 법에 의하여 강제되어 있지 않는 한 설령 제출된 허위자료를 근거로 출원허가를 해주었어도 곧바로 위계가 인정되는 것은 아니다.

이 경우 실사를 담당하는 공무원이 충분한 심사를 하였음에도 허위라는 사실을 발견하지 못하여 출원허가가 나갔을 경우에는 위계가 인정되지만, 출원허가가 담당공무원의 불충분한 심사 에 기인한 것일 때에는 위계가 인정되지 않는다.

판례 증거물인 혈액을 바꿔치기 한 사건(대판 2003.7.25. 2003도1609) 司46·47

음주운전을 하다가 교통사고를 야기한 후 그 형사처벌을 면하기 위하여 타인의 혈액을 자신의 혈액인 것처럼 교통사고 조사 경찰관에게 제출하여 감정하도록 한 행위는, 단순히 피의자가 수사기관에 대하여 허위사실을 진술하거나 자신에게 불리한 증거를 은닉하는 데 그친 것이 아니라 수사기관의 착오를 이용하여 적극적으로 피의사실에 관한 증거를 조작한 것으로서 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한다.

판례 (대판 1997.2.28. 96도2825) 辯2 司44·46·51·54·55

피고인이, 출원인이 어업허가를 받을 수 없는 자라는 사실을 알면서도 그 직무상의 의무에 따른 적절한 조치를 취하지 않고 오히려 부하직원으로 하여금 어업허가 처리기안문을 작성하게 한 다음 피고인 스스로 중간결재를 하는 등 위계로써 농수산국장의 최종결재를 받았다면, 직무위배의 위법상태가 위계에 의한 공무집행방해행위 속에 포함되어 있는 것이라고 보아야 할 것이므로, 이와 같은 경우에는 작위 범인 위계에 의한 공무집행방해죄만이 성립하고 부작위범인 직무유기죄는 따로 성립하지 아니한다.

♣ 확인학습문제

1. 다음의 공무집행방해죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 불법주차 차량에 불법주차 스티커를 붙였다가 이를 다시 떼어 낸 직후에 있는 주차단속 공무원을 폭행한 경우, 공무집행방해죄가 성립한다.
- ② 음주운전을 하다가 교통사고를 야기한 후 그 형사처벌을 면하기 위하여 타인의 혈액을 자신의 혈액인 것처럼 교통사고 조사 경찰관에게 제출하여 감정하도록 한 경우, 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한다.
- ③ 형법상 공무원이라 함은 국가 또는 지방자치단체 및 이에 준하는 공법인의 사무에 종사하는 자로서 그 노무의 내용이 단순한 기계적 육체적인 것에 한정되어 있지 않은 자를 말한다.
- ④ 동시에 여러 명의 공무집행을 방해하는 경우에는 수개의 공무집행방해죄의 상상적 경합이 된다.
- ⑤ 공무집행방해죄에 있어서의 범의는 미필적 고의로 충분하고, 또한 그 직무집행을 방해할 의사를 필요로 한다.

[정답] ⑤

[해설] 공무집행방해죄에 있어서의 범의는 상대방이 직무를 집행하는 공무원이라는 사실, 그리고 이에 대하여 폭행 또는 협박을 한다는 사실을 인식하는 것을 그 내용으로 하고, 그 인

식은 불확정적인 것이라도 소위 미필적 고의가 있다고 보아야 하며, 그 직무집행을 방해할 의사를 필요로 하지 아니한다(대판 1995.1.24. 94도1949).

2. 검사 A가 참고인 조사를 받는 줄 알고 검찰청에 자진출석한 변호사사무실 사무장 B를 긴급체포의 요건을 갖추지 못하였음에도 합리적 근거 없이 실력으로 긴급체포하자 그 변호사 甲이 이를 제지하는 과정에서 위 검사에게 상해를 가한 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 상해죄
- ③ 공무집행방해죄
- ④ 공무집행방해죄와 상해죄의 상상적 경합
- ⑤ 공무집행방해죄와 상해죄의 실체적 경합

[정답] ①

[해설] 수사기관에 자진출석한 사람이 긴급체포의 요건을 갖추지 못하였음에도 실력으로 자신을 체포하려고 한 검사나 사법경찰관에게 폭행을 가한 경우 공무집행방해죄가 성립하지 않고, 검사가 참고인 조사를 받는 줄 알고 검찰청에 자진출석한 변호사사무실 사무장을 합리적 근거 없이 긴급체포하자 그 변호사가 이를 제지하는 과정에서 위 검사에게 상해를 가한 것은 정당방위에 해당한다(대판 2006.9.8. 2006도148).

3. 某 광역자치단체 수산과 계장으로서 어업허가 신청업무를 담당하고 있던 甲이 출원인 乙이 어업허가를 받을 수 없는 자라는 사실을 알면서도 그 직무상의 의무에 따른 적절한 조치를 취하지 않고 오히려 부하직원으로 하여금 어업허가 처리기안문을 작성하게 한 다음 甲 스스로 중간결재를 하는 등 위계로써 농수산국장의 최종결재를 받은 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 위계에 의한 공무집행방해죄
- ③ 위계에 의한 공무집행방해죄와 직무유기죄의 상상적 경합
- ④ 위계에 의한 공무집행방해죄와 직무유기죄의 실체적 경합
- ⑤ 직무유기죄

[정답] ②

[해설] 이와 같은 경우에는 작위범인 위계에 의한 공무집행방해죄만이 성립하고 부작위범인 직무유기죄는 따로 성립하지 아니한다(대판 1997.2.28. 96도2825).

♣ 학습내용 정리

1. 공무집행방해죄는 직무를 집행하는 공무원을 폭행·협박함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 위법한 직무집행에 대해서는 국민이 복종할 의무가 없고, 형법은 적법한 직무집행만을 보호하므로 직무집행은 적법해야 한다.
3. 위계에 의한 공무집행방해죄는 위계에 의해 공무집행을 방해하는 행위를 공무집행방해죄에 준해 처벌하는 범죄이다.

제41강 도주와 범인은닉죄

♣ 학습목표

- 도주죄의 내용을 설명할 수 있다.
- 자기범죄에 대한 은닉·도피교사를 처벌할 수 있는지를 설명할 수 있다.
- 범인은닉·도피죄의 법리를 설명할 수 있다.
- 범인은닉·도피죄에 대한 친족 간의 특례를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

- 도주죄
- 도주원조
- 범인은닉·도피
- 자기범죄에 대한 은닉·도피교사

♣ 사전테스트

- 도주죄는 계속범이다.
정답 : X
- 범인 자신이 스스로 은닉·도피하는 행위는 범인은닉·도피죄를 구성하지 않는다.
정답 : O
- 무죄·면소판결이 확정된 자는 범인은닉·도피죄의 객체가 아니다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

범인은닉·도피죄의 대상은 진범인만을 포함한다.

[정답] X

[해설] 범인은닉죄는 형사사법에 관한 국권의 행사를 방해하는 자를 처벌하고자 하는 것이므로 형법 제151조 제1항 소정의 ‘죄를 범한 자’라 함은 범죄의 혐의를 받아 수사 대상이 되어 있는 자를 포함한다. 따라서 구속수사의 대상이 된 소송외인이 그 후 무혐의로 석방되었다 하더라도 위 죄의 성립에 영향이 없다(대판 1982.1.26. 81도193).

♣ 강의내용

1. 도주죄(형법 제145조)

1. 의의

본죄는 법률에 의하여 체포·구금된 자가 도주함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 즉시범이다. 보호법익은 국가의 구금권이고, 보호정도는 침해범으로서의 보호이다.

2. 행위주체

법률에 의하여 체포·구금된 자이다. 따라서 본죄는 진정신분범이다.

(1) 체포된 자

국가기관에 의해 현행범으로 체포된 자를 말한다. 사인에 의하여 현행범으로 체포된 자는 국가기관에 현실로 인도 될 때까지는 국가의 강제처분권에 대한 침해를 야기할 수 없으므로 본죄의 주체가 될 수 없다. 또한 구인도 실질적으로 체포와 동일하기 때문에 구인된 피고인·피의자도 본죄의 주체가 된다. 다만 구인된 증인은 국가형벌권실현의 직접적인 대상이 아니기 때문에 본죄의 주체에서 제외된다.

(2) 구금된 자

국가기관에 의하여 적법하게 감금된 자로서 수형자·미결구금자·감정유치 중인 자를 포함한다.

판례 (대판 2006.7.6, 2005도6810) 司49·57

사법경찰관이 피고인을 수사관서까지 동행한 것이 사실상의 강제연행, 즉 불법 체포에 해당하고, 불법 체포로부터 6시간 상당이 경과한 후에 이루어진 긴급체포 또한 위법하므로 피고인이 불법체포된 자로서 형법 제145조 제1항에 정한 ‘법률에 의하여 체포 또는 구금된 자’가 아니어서 도주죄의 주체가 될 수 없다.

(3) 본죄의 주체가 아닌 경우

가석방 중에 있는 자, 보석 중에 있는 자, 형의 집행정지나 구속의 집행정지 중에 있는 자, 경찰관직무집행법에 의해 보호 중에 있는 자 등은 제외된다.

3. 행위

도주로 도주란 피구금자가 구금상태로부터 이탈하는 것을 말한다. 일시적 이탈, 작위 및 부작위에 의해서도 가능하다.

4. 기수시기

본죄의 기수시기는 체포자 또는 간수자의 실력지배로부터 완전히 벗어난 때이다. 따라서 교도소의 외벽을 넘은 때에도 추적을 받고 있는 때에는 간수자의 실력적 지배를 벗어난 때라 할 수 없으므로 아직 기수가 아니다.

판례 (대판 1991. 10.11. 91도1656) 司48·57

도주죄는 즉시범으로서 범인이 간수자의 실력적 지배를 이탈한 상태에 이르렀을 때에 기수가 되어 도주행위가 종료하는 것이고, 도주원조죄는 도주죄에 있어서의 범인의 도주행위를 야기시키거나 이를 용이하게 하는 등 그와 공범관계에 있는 행위를 독립한 구성요건으로 하는 범죄이므로, 도주죄의 범인이

도주행위를 하여 기수에 이른 이후에 범인의 도피를 도와 주는 행위는 범인도피죄에 해당할 수 있을 뿐 도주원조죄에는 해당하지 아니한다.

II. 범인은닉·도피죄(형법 제151조 제1항)의 구성요건

I. 의의

범인은닉·도피죄는 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 자를 은닉·도피하게 함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 기수 이후에도 본범을 은닉하는 행위 또는 본범의 도피를 용이하게 하는 행위가 계속되는 한 본죄는 종료되지 않는다. 따라서 본죄는 계속범이다(통설, 판례).

2. 행위주체

범인이외의 자라면 아무런 제한도 없다.

(1) 자기은닉·도피행위

범인 자신이 스스로 은닉·도피하는 행위는 본죄를 구성하지 않는다. 이 때 이 행위의 법적 성질에 대해서는 본죄의 범인은 타인을 의미하므로 범인의 자기도피는 본죄의 구성요건에 해당하지 않는다.

(2) 본범의 공동정범

범인이 아닌 자면 본죄의 주체가 될 수 있으므로 공동정범 중의 1인이 다른 공동정범을 도피하게 한 경우에는 본죄가 성립한다(통설, 판례 : 대판 1958.1.14. 4290형상393). 司50

(3) 자기은닉·도피의 교사

(가) 문제점

범인이 제3자를 교사하여 자신을 은닉하도록 한 경우에 범인은닉죄의 교사범으로 처벌할 수 있는가의 문제이다. 이 문제는 정범으로 처벌할 수 없는 자를 교사범으로 처벌할 수 있는가와 본죄에 있어서 자기비호권의 한계에 관한 문제이다.

(나) 판례 - 긍정설

판례 (대판 2006.12.7. 2005도3707)

辯1·3 司49·50·51·53·55

[1] 범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당하는바, 이 경우 그 타인이 형법 제151조 제2항에 의하여 처벌을 받지 아니하는 친족, 호주 또는 동거 가족에 해당한다 하여 달리 볼 것은 아니다. [2] 무면허 운전으로 사고를 낸 사람이 동생을 경찰서에 대신 출두시켜 피의자로 조사받도록 한 행위는 범인도피교사죄를 구성한다.

[사실관계] 피고인 甲은 무면허 상태로 프라이드 승용차를 운전하고 가다가 화물차를 들이받는 사고를 일으켜 경찰에서 조사를 받게 되었다. 甲은 무면허로 운전한 사실 등이 발각되지 않기 위해, 동생인 乙에게 “내가 무면허상태에서 술을 마시고 차를 운전하다가 교통사고를 내었는데 운전면허가 있는 네가 대신 교통사고를 내었다고 조사를 받아 달라”고 부탁하였다. 乙은 이를 승낙하고 대전동부경찰서 교통사고조사계 사무실에서 자신이 위 프라이드 승용차를 운전하고 가다가 교통사고를 낸 사람이라고 허위 진술을 하여 피의자로서 조사를 받았고, 이에 甲은 범인도피교사죄로 기소되었다.

(3) 범인도피행위 도중에 가담한 경우

판례 (대판 2012.8.30. 2012도6027)

甲이 수사기관 및 법원에 출석하여 乙 등의 사기 범행을 자신이 저질렀다는 취지로 허위자백하였는데, 그 후 甲의 사기 피고사건 변호인으로 선임된 피고인이 甲과 공모하여 진범 乙 등을 은폐하는 허위자백을 유지하게 함으로써 범인을 도피하게 하였다는 내용으로 기소된 사안에서 범인도피죄는 범인을 도피하게 함으로써 기수에 이르지만, 범인도피행위가 계속되는 동안에는 범죄행위도 계속되고 행위가 끝날 때 비로소 범죄행위가 종료된다. 따라서 공범자의 범인도피행위 도중에 그 범행을 인식하면서 그와 공동의 범의를 가지고 기왕의 범인도피상태를 이용하여 스스로 범인도피행위를 계속한 경우에는 범인도피죄의 공동정범이 성립하고, 이는 공범자의 범행을 방조한 중범의 경우도 마찬가지이다.

2. 행위객체 - 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 자

(1) 벌금 이상의 형에 해당하는 죄

이는 법정형이 벌금 또는 그 이상의 형을 포함하고 있는 범죄를 말한다. 선택형으로 구류·과료를 포함하고 있는 범죄도 여기에 해당하지만, 단순히 구류·과료로 처벌되는 범죄는 제외된다. 따라서 가령 甲이 단순도박죄(법정형 500만원 이하의 벌금 또는 과료)의 혐의로 숨어 다니는 친구 乙을 자기 집에 며칠 동안 머물게 해 주어도 본죄가 성립한다.

(2) 죄를 범한 자

(가) 범위

- ① 정범·교사범·방조범과 예비·음모한 자도 포함하며, 구성요건에 해당하고 위법·유책해야 할 뿐만 아니라 처벌조건·소추조건을 구비해야 한다. 가령 甲이 타인의 살인행위를 방조한 친구 乙을 그 정을 모르는 다른 친구 丙에게 알선하여 丙의 집에 머물게 해 준 경우에도 본죄가 성립한다.
- ② 따라서 무죄·면소판결이 확정된 자, 공소시효의 완성, 형의 폐지, 사면에 의하여 소추 또는 처벌의 가능성이 없는 자는 본죄의 객체가 아니다. 반드시 유죄판결이 확정되었거나 공소가 제기되었음을 요하지 않는다. 수사개시의 전후도 불문하므로 아직 수사기관에 포착되지 않아 수사대상이 되어 있지 않은 자도 포함된다.

(나) 진범인 여부

진범인 여부에 대해서는 진범인이 아닐지라도 범죄혐의를 받고 수사 또는 소추 중인 자를 은닉하는 행위는 국가의 형사사법작용을 침해하는 점에서는 진범인을 은닉하는 경우와 마찬가지이므로 수사 또는 소추 중인 범죄혐의자도 포함한다(다수설, 판례).

이에 의하면 가령 甲이 친구 乙이 절도죄의 혐의를 받고 있는 사실을 알고 있지만 진범이 아니라고 생각하고 乙을 자기 집에 며칠 동안 머물게 해 준 경우에도 본죄가 성립한다.

판례 (대판 1982.1.26, 81도1931)

司46·48·57

범인은닉죄는 형사사법에 관한 국권의 행사를 방해하는 자를 처벌하고자 하는 것이므로 형법 제151조 제1항 소정의 '죄를 범한 자'라 함은 범죄의 혐의를 받아 수사 대상이 되어 있는 자를 포함한다. 따라서 구속수사의 대상이 된 소송외인이 그 후 무혐의로 석방되었다 하더라도 위 죄의 성립에 영향이 없다.

3. 행위 - 은닉 또는 도피하게 하는 것

(1) 은닉

범인을 감추어 주는 일체의 행위이다.

(2) 도피하게 하는 것

은닉 이외의 방법으로 수사관의 발견·체포를 어렵게 하는 일체의 행위이다. 도피하게 하는 행위는 체포·구금상태를 전제하지 않고, 널리 범인에 대한 발견·체포를 곤란·지연·불가능하게 하는 일체의 행위라는 점에서 도주나 도주원조보다 넓은 개념이다.

따라서 범인 아닌 자가 수사기관에서 범인임을 자처하고 허위사실을 진술하여 진범의 체포와 발견에 지장을 초래하게 한 행위는 범인은닉죄에 해당한다. 가령 甲이 교통사고를 내서 사람을 사망하게 하였다는 혐의를 받고 있는 자신의 상관인 乙을 위하여 자신이 그 사고를 낸 운전자라고 경찰에게 허위진술을 한 경우 이는 범인 아닌 다른 자를 진범이라고 내세우는 경우 등과 같이 적극적으로 허위의 사실을 진술하여 수사관을 기만, 착오에 빠지게 함으로써 범인의 발견 체포에 지장을 초래케 하는 경우이므로 본죄가 성립한다. 다만 도주죄나 도주원조죄가 기수에 이르기 전에 피구금자를 도피케 하는 것은 그것 자체가 도주원조에 해당하므로 도피케 하는 행위는 도주죄나 도주원조죄가 기수 이후에만 성립이 가능하다.

판례 (대판 2010.1.28. 2009도10709) 辯3 司56

① 게임산업진흥에 관한 법률 위반, 도박개장 등의 혐의로 수사기관에서 조사받는 피의자가 사실은 게임장·오락실·피씨방 등의 실제 업주가 아니라 그 종업원임에도 불구하고 자신이 실제 업주라고 허위로 진술하였다고 하더라도, 그 자체만으로 범인도피죄를 구성하는 것은 아니다. 다만, ② 그 피의자가 실제 업주로부터 금전적 이익 등을 제공받기로 하고 단속이 되면 실제 업주를 숨기고 자신이 대신하여 처벌받기로 하는 역할(이른바 ‘바지사장’)을 맡기로 하는 등 수사기관을 착오에 빠뜨리기로 하고, 단순히 실제 업주라고 진술하는 것에서 나아가 게임장 등의 운영 경위, 자금 출처, 게임기 등의 구입 경위, 점포의 임대차계약 체결 경위 등에 관해서까지 적극적으로 허위로 진술하거나 허위 자료를 제시하여 그 결과 수사기관이 실제 업주를 발견 또는 체포하는 것이 곤란 내지 불가능하게 될 정도에까지 이른 것으로 평가되는 경우 등에는 범인도피죄를 구성할 수 있다.

판례 (대판 2003.2.14. 2002도5374) 司47·57

[1] 형법 제151조 소정의 범인도피죄에서 ‘도피하게 하는 행위’는 그 자체로는 도피시키는 것을 직접적인 목적으로 하였다고 보기 어려운 어떤 행위의 결과 간접적으로 범인이 안심하고 도피할 수 있게 한 경우까지 포함되는 것은 아니다. [2] 참고인이 수사기관에서 범인에 관하여 조사를 받으면서 그가 알고 있는 사실을 묵비하거나 허위로 진술하였다고 하더라도, 그것이 적극적으로 수사기관을 기만하여 착오에 빠지게 함으로써 범인의 발견 또는 체포를 곤란 내지 불가능하게 할 정도의 것이 아니라면 범인도피죄를 구성하지 않는다. [3] 수사절차에서 작성되는 신원보증서는 체포된 피의자 석방의 필수적인 요건이거나 어떠한 법적 효력이 있는 것은 아니므로, 신원보증서를 작성하여 수사기관에 제출하는 보증인이 피의자의 인적 사항을 허위로 기재하였다고 하더라도, 그로써 적극적으로 수사기관을 기만한 결과 피의자를 석방하게 하였다는 등 특별한 사정이 없는 한, 그 행위만으로 범인도피죄가 성립되지 않는다고 한 사례.

[사실관계] 乙은 음주운전으로 某 경찰서에서 현행범으로 체포되었는바, 乙은 특가법위반(도주차량) 등으로 기소중지된 자로서 이를 숨기기 위하여 丙의 운전면허증을 경찰관에게 제시하여 丙의 행세를 하였고, 乙에 대한 신원보증인 甲은 위 경찰서 교통사고처리계 사무실에서 사안이 경미하다는 이유로 담당경찰관이 乙을 석방하기로 하면서 그로부터 신원보증을 요구받게 되자, 乙이 丙의 인적 사항을 모용하고 있다는 사실을 알면서도 丙의 주민등록번호 및 허위의 주소 등을 신원보증서에 기재하여 乙이 석방되도록 하였다.

III. 죄수와 친족간의 특례

1. 죄수

① 동일한 범인을 은닉하고 도피하게 하면 본죄의 포괄일죄이다. ② 같은 사건의 수명의 범인을 하나의 행위로 은닉 또는 도피하게 하면 수 죄의 상상적 경합이 된다.

2. 친족간의 범행

제151조 제2항 및 제155조 제4항은 친족, 호주 또는 동거의 가족이 본인을 위하여 범인도피죄, 증거인멸죄 등을 범한 때에는 처벌하지 아니한다고 규정하고 있는바, 사실혼관계에 있는 자는 민법 소정의 친족이라 할 수 없어 위 조항에서 말하는 친족에 해당하지 않는다(대판 2003.12.12. 2003도4533). 司50·56

법적 성질은 책임조각사유가 된다.

♣ 확인학습문제

1. 甲은 무면허 상태로 승용차를 운전하고 가다가 교통사고를 일으켜 경찰에서 조사를 받게 되었다. 甲은 무면허로 운전한 사실 등이 발각되지 않기 위해, 동생인 乙에게 “내가 무면허 상태에서 술을 마시고 차를 운전하다가 교통사고를 내었는데 운전면허가 있는 네가 대신 교통사고를 내었다고 조사를 받아 달라”고 부탁하였다. 이에 乙은 경찰서 교통사고조사계 사무실에서 자신이 위 승용차를 운전하고 가다가 교통사고를 낸 사람이라고 허위 진술을 하여 피의자로서 조사를 받았다. 이 경우 甲과 乙의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲 : 범인도피교사죄, 乙 : 범인도피죄
- ② 甲 : 무죄, 乙 : 범인도피죄
- ③ 甲 : 범인도피교사죄, 乙 : 무죄
- ④ 甲 : 무죄, 乙 : 위계에 의한 공무집행방해죄
- ⑤ 甲과 乙은 모두 무죄

【정답】 ③

【해설】 범인이 자신을 위하여 타인으로 하여금 허위의 자백을 하게 하여 범인도피죄를 범하게 하는 행위는 방어권의 남용으로 범인도피교사죄에 해당하는바, 이 경우 그 타인이 형법 제151조 제2항에 의하여 처벌을 받지 아니하는 친족, 호주 또는 동거 가족에 해당한다 하여 달리 볼 것은 아니다(대판 2006.12.7. 2005도3707).

2. 다음의 설명 중 옳지 않는 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 신원보증서를 작성하여 수사기관에 제출하는 보증인이 피의자의 인적 사항을 허위로 기재하였다고 하더라도, 그로써 적극적으로 수사기관을 기망한 결과 피의자를 석방하게 하였다는 등 특별한 사정이 없는 한, 그 행위만으로 범인도피죄가 성립되지 않는다.
- ② 범인 아닌 자가 수사기관에서 범인임을 자처하고 허위사실을 진술하여 진범의 체포와 발견에 지장을 초래하게 한 행위는 범인은닉죄에 해당한다.
- ③ 도주죄의 범인이 도주행위를 하여 기수에 이르면 이후에 범인의 도피를 도와 주는 행위는 범인도피죄에 해당할 수 있을 뿐 도주원조죄에는 해당하지 아니한다.

- ④ 범인 스스로가 도피한 때에는 범인도피죄가 성립하지 않으며, 공동정범 중의 한 사람이 다른 공범을 도피하게 한 때에도 범인도피죄가 성립하지 아니한다.
- ⑤ 사실혼관계에 있는 자는 민법 소정의 친족이라 할 수 없어 범인도피죄에서 말하는 친족에 해당하지 않는다.

[정답] ④

[해설] 범인이 아닌 자면 본죄의 주체가 될 수 있으므로 공동정범 중의 1인이 다른 공동정범을 도피하게 한 경우에는 본죄가 성립한다(대판 1958.1.14. 4290형상393).

3. 게임산업진흥에 관한 법률 위반 및 도박개장 등의 혐의로 수사기관에서 조사받는 피의자 甲은 사실은 게임장·오락실·피씨방 등의 실제 업주가 아니라 그 종업원임에도 불구하고 자신이 실제 업주라고 허위로 진술하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무죄
- ② 범인도피죄
- ③ 범인도피죄의 중범
- ④ 증거인멸죄
- ⑤ 위계에 의한 공무집행방해죄

[정답] ①

[해설] 게임산업진흥에 관한 법률 위반, 도박개장 등의 혐의로 수사기관에서 조사받는 피의자가 사실은 게임장·오락실·피씨방 등의 실제 업주가 아니라 그 종업원임에도 불구하고 자신이 실제 업주라고 허위로 진술하였다고 하더라도, 그 자체만으로 범인도피죄를 구성하는 것은 아니다(대판 2010.1.28. 2009도10709).

♣ 학습내용 정리

1. 도주죄는 법률에 의하여 체포·구금된 자가 도주함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 범인은닉·도피죄는 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 자를 은닉·도피하게 함으로써 성립하는 범죄이다.
3. 범인은닉·도피죄에서 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 자에는 정범·교사범·방조범과 예비·음모한 자도 포함하며, 구성요건에 해당하고 위법·유책해야 할 뿐만 아니라 처벌조건·소추조건을 구비해야 한다.
4. 형법 제151조 제2항 및 제155조 제4항은 친족, 호주 또는 동거의 가족이 본인을 위하여 범인도피죄, 증거인멸죄 등을 범한 때에는 처벌하지 아니한다고 규정하고 있다.

제42강 위증죄(형법 제152조)

♣ 학습목표

위증죄에서 증인의 의미를 설명할 수 있다.

위증죄에서 허위진술의 내용을 설명할 수 있다.

증언거부권의 불고지와 위증의 인정 여부에 대한 관계를 설명할 수 있다.

자기 사건에 대한 위증교사가 성립하는지를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

위증

증인과 선서

허위의 진술

자수·자백

♣ 사전테스트

1. 형사피고인이나 민사소송의 당사자도 위증죄의 증인이 될 수 있다.

정답 : X

2. 위증죄에서 진술의 대상은 경험한 대상에 한정되는 것이 아니라 주관적 평가나 가치판단도 포함한다.

정답 : X

3. 증인에 대한 신문절차가 종료한 때 기수가 된다.

정답 : O

♣ 돌발퀴즈

허위라고 인식하고 진술했더라도 진술의 내용이 객관적 사실과 부합하는 경우 위증죄가 성립하지 않는다.

[정답] X

[해설] 위증죄에 있어서의 허위의 공술이란 증인이 자기의 기억에 반하는 사실을 진술하는 것을 말하는 것으로서 그 내용이 객관적 사실과 부합한다고 하여도 위증죄의 성립에 장애가 되지 않는다(대판 1989.1.17. 88도580).

♣ 강의내용

1. 행위주체 - 증인

1. 위증죄의 의의

본죄는 법률에 의해 선서한 증인이 허위진술을 함으로써 성립하는 범죄이다. 본죄는 그 성격에 있어서 진정신분범·자수범·의무범이다.

2. 행위주체

법률에 의해 선서한 증인이다. 선서하지 않은 증인은 본죄의 주체가 될 수 없다.

(1) 법률에 의한 선서

(가) 범위

선서는 법률이 정한 형식에 따라 유효하게 성립해야 하고 선서하게 할 권한이 있는 기관에 대해 행한 선서여야 한다. 여기서 법률이란 법률뿐만 아니라 법률의 위임에 의한 명령, 기타의 하위입법 등을 포함한다. 민사소송, 형사소송, 비송사건, 징계사건, 특허사건의 경우가 포함된다.

(나) 선서의 유효성

- ① 선서 받을 권한이 있는 기관에 대한 선서이어야 하므로 검사 또는 사법경찰관에 대한 선서는 유효한 선서가 아니다.

판례 (대판 2003.7.25. 2003도180) 司50·52

제3자가 심문절차로 진행되는 가처분 신청사건에서 증인으로 출석하여 선서를 하고 진술함에 있어서 허위의 공술을 하였다고 하더라도 그 선서는 법률상 근거가 없어 무효라고 할 것이므로 위증죄는 성립하지 않는다.

- ② 선서의 취지를 이해하지 못하는 선서무능력자의 선서는 효력이 없으므로 선서무능력자가 (재판부의 착오로 인하여) 선서를 하고 위증을 하더라도 위증죄가 성립하지 않는다.

(2) 증인

법원 또는 법관에 대해 자신의 경험을 진술하는 제3자이다. 소송절차의 증인인 한 반드시 변론기일에 공판정에 서는 증인이어야 할 필요도 없다. 예컨대 수사절차에서의 증인신문청구(형사소송법 제221조의2)로 인한 증인신문의 경우도 포함된다.

(가) 형사피고인, 민사소송의 당사자

제3자가 아니므로 증인능력이 없다. 주식회사의 대표이사도 민사소송의 당사자가 된다.

판례 (대판 1998.3.10. 97도1168) 司41·43·47

민사소송의 당사자는 증인능력이 없으므로 증인으로 선서하고 증언하였다고 하더라도 위증죄의 주체가 될 수 없고, 이러한 법리는 민사소송에서의 당사자인 법인의 대표자의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

(나) 공동피고인

공범자인 공동피고인은 증인적격이 없으나, 공범자가 아닌 공동피고인은 증인적격이 인정된다.

판례 (대판 2008.6.26. 2008도3300) 辯1 司52・56

[1] 공범인 공동피고인은 당해 소송절차에서는 피고인의 지위에 있으므로 다른 공동피고인에 대한 공소사실에 관하여 증인이 될 수 없으나, 소송절차가 분리되어 피고인의 지위에서 벗어나게 되면 다른 공동피고인에 대한 공소사실에 관하여 증인이 될 수 있다. [2] 게임장의 종업원이 그 운영자와 함께 게임 산업진흥에 관한 법률 위반죄의 공범으로 기소되어 공동피고인으로 재판을 받던 중, 운영자에 대한 공소사실에 관한 증인으로 증언한 내용과 관련하여 위증죄로 기소된 사안에서, 소송절차가 분리되지 않은 이상 위 종업원은 증인적격이 없어 위증죄가 성립하지 않는다. → 대항범인 공동피고인의 경우에도 동일한 법리가 적용된다(대판 2012.3.29. 2009도11249).

(다) 증언거부권자

증언거부권자가 진술거부권을 행사하지 않고 선서한 후 증언을 한 경우 또는 형사소추를 받게 될 염려 때문에 위증을 한 경우에도 본죄가 성립한다. 증언거부권은 증인의 권리이지 의무는 아니기 때문이다.

판례 (대판 2012.10.11. 2012도6848)

형사소송법 제148조는 피고인의 자기부죄거부특권을 보장하기 위하여 자기가 유죄판결을 받을 사실이 발로될 염려 있는 증언을 거부할 수 있는 권리를 인정하고 있고, 그와 같은 증언거부권 보장을 위하여 형사소송법 제160조는 재판장이 신문 전에 증언거부권을 고지하여야 한다고 규정하고 있으므로, 소송절차가 분리된 공범인 공동피고인에 대하여 증인적격을 인정하고 그 자신의 범죄사실에 대하여 신문한다 하더라도 피고인으로서의 진술거부권 내지 자기부죄거부특권을 침해한다고 할 수 없다. 따라서 증인신문절차에서 형사소송법 제160조에 정해진 증언거부권이 고지되었음에도 불구하고 위 피고인이 자신의 범죄사실에 대하여 증언거부권을 행사하지 아니한 채 허위로 진술하였다면 위증죄가 성립된다.

① 증언거부권을 고지 받지 못한 경우

판례 (대판 2010.1.21.2008도942 전원합의체판결) 辯2 司55・56

[1] 법률에 규정된 증인 보호 절차라 하더라도 개별 보호절차 규정들의 내용과 취지가 같지 아니하고, 당해 신문 과정에서 지키지 못한 절차 규정과 그 경위 및 위반의 정도 등 제반 사정이 개별 사건마다 각기 상이하므로, 이러한 사정을 전체적・종합적으로 고려하여 볼 때, 당해 사건에서 증인 보호에 사실상 장애가 초래되었다고 볼 수 없는 경우에까지 예외 없이 위증죄의 성립을 부정할 것은 아니라고 할 것이다.

[2] 재판장이 신문 전에 증인에게 증언거부권을 고지하지 않은 경우에도 당해 사건에서 증언 당시 증인이 처한 구체적인 상황, 증언거부사유의 내용, 증인이 증언거부사유 또는 증언거부권의 존재를 이미 알고 있었는지 여부, 증언거부권을 고지 받았더라도 허위진술을 하였을 것이라고 볼 만한 정황이 있는지 등을 전체적・종합적으로 고려하여 증인이 침묵하지 아니하고 진술한 것이 자신의 진정한 의사에 의한 것인지 여부를 기준으로 위증죄의 성립 여부를 판단하여야 한다. 그러므로 헌법 제12조 제2항에 정한 불이익 진술의 강요금지 원칙을 구체화한 자기부죄거부특권에 관한 것이거나 기타 증언거부사유가 있음에도 증인이 증언거부권을 고지받지 못함으로 인하여 그 증언거부권을 행사하는 데 사실상 장애가 초래되었다고 볼 수 있는 경우에는 위증죄의 성립을 부정하여야 할 것이다.

[1] 전 남편에 대한 도로교통법 위반(음주운전) 사건의 증인으로 법정에 출석한 전처(前妻)가 증언거부권을 고지받지 않은 채 공소사실을 부인하는 전 남편의 변명에 부합하는 내용을 적극적으로 허위 진술한 사안에서, 증인으로 출석하여 증언한 경위와 그 증언 내용, 증언거부권을 고지받았더라도 그와 같이 증언을 하였을 것이라는 취지의 진술 내용 등을 전체적・종합적으로 고려할 때 선서 전에 재판장으로부터 증언거부권을 고지받지 아니하였다 하더라도 이로 인하여 증언거부권이 사실상 침해당한 것으로 평가할 수는 없다는 이유로 위증죄의 성립을 긍정한 사례.

② 증언거부권이 없는 경우

[1] 이미 유죄의 확정판결을 받은 피고인은 공범의 형사사건에서 그 범행에 대한 증언을 거부할 수 없을 뿐만 아니라 나아가 사실대로 증언하여야 하고, 설사 피고인이 자신의 형사사건에서 시종일관 그 범행을 부인하였다 하더라도 이러한 사정은 위증죄에 관한 양형참작사유로 볼 수 있음은 별론으로 하고 이를 이유로 피고인에게 사실대로 진술할 것을 기대할 가능성이 없다고 볼 수는 없다. [2] 자신의 강도상해 범행을 일관되게 부인하였으나 유죄판결이 확정된 피고인이 별건으로 기소된 공범의 형사사건에서 자신의 범행사실을 부인하는 증언을 한 사안에서, 피고인에게 사실대로 진술할 기대가능성이 있으므로 위증죄가 성립한다.

II. 행위 - 허위의 진술

1. 허위의 의미 - 주관설

증인이 자기가 기억에 반하는 진술을 하는 것이 허위라는 견해이다. 허위는 증언과 기억의 불일치가 된다(통설, 판례).

위증죄에 있어서의 허위의 공술이란 증인이 자기의 기억에 반하는 사실을 진술하는 것을 말하는 것으로서 그 내용이 객관적 사실과 부합한다고 하여도 위증죄의 성립에 장애가 되지 않는다.

<허위성을 인정한 판례>

- ① 잘 모르는 사실을 단정하여 진술한 경우(대판 1985.8.20. 85도868)
- ② 선서를 하고서 진술을 하였으나 자신이 그 증언내용에 관한 사실을 잘 알지 못하면서도 잘 아는 것으로 증언한 경우(대판 1986.9.9. 86도57)
- ③ 들어서 알게 된 사실(전문사실)을 마치 목격하여 알게 된 것처럼 진술한 경우(대판 1985.10.8. 85도783)
- ④ 타인으로부터 전해들은 금품의 전달사실을 마치 자신이 전달한 것처럼 진술한 경우(대판 1990.5.8. 90도448) 司41・56
- ⑤ 방에서 개최된 회의를 마당에서 구경하고 회의에 참석하였다고 진술한 경우(대판 1968.10.29. 68도1063)
- ⑥ 피고인이 증언당시 확실한 기억이 나지 않았음에도 불구하고 확실한 기억이 있는 것처럼 진술한 경우(대판 1971.7.6. 71도815) 司42

<허위성을 부정한 판례>

- ① 증인의 진술이 경험한 사실에 대한 법률적 평가이거나 단순한 의견에 지나지 아니하는 경우(대판 1996. 2.9. 95도1797) 司41

- ② 경험을 통하여 기억하고 있는 사실을 진술한 이상 그 진술이 객관적 사실에 부합되지 아니하거나 경험한 사실에 기초한 주관적 평가나 그 법률적 효력에 관한 견해를 부여한 부분에 다소의 오류나 모순이 있는 경우(대판 1984.2.14. 83도37) 辯2 司43

2. 진술

진술이란 증인이 경험한 사실을 기억하는 대로 표명하는 것이다.

- ① 진술의 대상은 경험한 대상에 한정되고, 주관적 평가나 가치판단은 제외된다.
- ② 진술방법은 제한이 없다. 구두·몸짓·표정 등에 의해서도 가능하다. 단순한 진술거부는 진술이 아니다. 그러나 자기가 기억하는 사실의 전부 또는 일부를 진술하지 않음으로써 전체적인 진술내용이 허위가 되면 부작위에 의한 위증이 성립할 수도 있다.
- ③ 진술내용은 증인신문의 대상이 되면 무엇이든 가능하다. 따라서 그 공술의 내용이 당해 사건의 요증사실일 필요도 없고 재판결과에 영향을 미칠 필요도 없다. 직접신문에 대한 진술임을 요하지 않고 반대신문에 대한 진술도 이에 해당한다.

3. 기수시기

1회의 증인신문절차에서 증언은 포괄적으로 1개의 행위로 이해되므로 증인에 대한 신문절차가 종료한 때 기수가 된다. 따라서 종료 전에 시정하면 죄가 되지 않는다. 진술 후에 선서를 하는 경우에는 선서를 종료한 때 기수가 된다(대판 1974.6.25. 74도1231).

판례 (대판 2010.9.30. 2010도7525) 司41 · 43 · 55 · 56

증인의 증언은 그 전부를 일체로 관찰·판단하는 것이므로 선서한 증인이 일단 기억에 반하는 허위의 진술을 하였더라도 그 신문이 끝나기 전에 그 진술을 철회·시정한 경우 위증이 되지 아니한다고 할 것이나, 증인이 1회 또는 수회의 기일에 걸쳐 이루어진 1개의 증인신문절차에서 허위의 진술을 하고 그 진술이 철회·시정된 바 없이 그대로 증인신문절차가 종료된 경우 그로써 위증죄는 기수에 달하고, 그 후 별도의 증인 신청 및 채택 절차를 거쳐 그 증인이 다시 신문을 받는 과정에서 종전 신문절차에서의 진술을 철회·시정한다 하더라도 그러한 사정은 형법 제153조가 정한 형의 감면사유에 해당할 수 있을 뿐, 이미 종결된 종전 증인신문절차에서 행한 위증죄의 성립에 어떤 영향을 주는 것은 아니다.

III. 공범관계 - 자기범죄에 대한 위증교사

1. 간접정범·공동정범

본죄는 자수범이므로 선서한 증인 이외의 사람은 간접정범이나 공동정범이 될 수 없다.

2. 교사·방조범

교사·방조범은 가능하므로 비신분자가 선서한 증인을 교사·방조하여 본죄를 범하게 하면 교사범 또는 중범이 된다(형법 제33조 본문).

3. 자기의 형사사건에 관한 위증교사죄의 성부

형사피고인이 자기의 형사사건에 관해 타인을 교사하여 위증하게 한 경우 판례는 위증교사죄의 성립을 인정한다.

판례 (대판 2004.1.27. 2003도5114) 辯2 司54 · 55

피고인이 자기의 형사사건에 관하여 허위의 진술을 하는 행위는 피고인의 형사소송에 있어서의 방어권을 인정하는 취지에서 처벌의 대상이 되지 않으나, 법률에 의하여 선서한 증인이 타인의 형사사건에 관하여 위증을 하면 형법 제152조 제1항의 위증죄가 성립되므로 자기의 형사사건에 관하여 타인을 교사하여 위증죄를 범하게 하는 것은 이러한 방어권을 남용하는 것이라고 할 것이어서 교사범의 죄책을 부담케 함이 상당하다.

IV. 보론 - 죄수와 자수·자백의 특례

1. 죄수

- ① 같은 사건, 같은 법정에서 여러 번 위증을 한 경우 또는 일회의 선서로 하나의 사건에 여러 번 허위진술을 한 경우에는 포괄일죄가 된다.
- ② 형사처분을 받게 할 목적으로 타인을 무고하고, 또 재판에서 위증한 경우에는 위증죄와 무고죄의 경합범이 된다.

2. 자수·자백의 특례

(1) 의의

재판 또는 징계처분의 확정 전에 자백·자수하면 그 형을 감경 또는 면제한다(제153조). 법적 효과는 필요적 감면사유이다. 여기서 자백이란 허위진술을 한 사실을 고백하는 것이다. 스스로 고백한 경우뿐만 아니라 법원 또는 수사기관의 심문을 받아 자백한 경우도 포함된다.

반면에 자수란 범인 자신이 자발적으로 자시의 범죄사실을 수사기관에 신고하여 그 소추를 구하는 의사표시이다.

(2) 자백·자수의 시기

증언한 사건의 재판 또는 징계처분이 확정되기 전까지, 즉 신문절차가 종결한 이후부터 재판 또는 징계처분이 확정되기 전까지이다. 확정되기 전이면 법원 또는 징계기관에 의하여 이미 진술이 허위라는 사실이 간과되었어도 무방하다.

(3) 자백·자수의 주체

본조는 정범뿐만 아니라 공범에 대해서도 적용된다. 다만 형의 감면은 자백·자수한 자에게만 적용된다.

♣ 확인학습문제

1. 다음의 위증죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 위증죄에 대하여는 간접정범이나 공동정범이 성립할 수 없다.
- ② 피고인이 증언당시 확실한 기억이 나지 않았음에도 불구하고 확실한 기억이 있는 것처럼 진술한 경우 위증죄가 성립한다.
- ③ 같은 사건, 같은 법정에서 여러 번 위증을 한 경우 또는 일회의 선서로 하나의 사건에 여러 번 허위진술을 한 경우에는 위증죄의 포괄일죄가 된다.

- ④ 甲이 자신의 강도상해 범행을 일관되게 부인하였으나 유죄판결이 확정된 甲이 별건으로 기소된 공범의 형사사건에서 자신의 범행사실을 부인하는 증언을 한 경우 위증죄가 성립한다.
- ⑤ 위증죄에서 자백은 스스로 고백한 경우뿐만 아니라 법원 또는 수사기관의 심문을 받아 자백한 경우도 포함된다.

[정답] ④

[해설] 자신의 강도상해 범행을 일관되게 부인하였으나 유죄판결이 확정된 피고인이 별건으로 기소된 공범의 형사사건에서 자신의 범행사실을 부인하는 증언을 한 사안에서 피고인에게 사실대로 진술할 것이라는 기대가능성이 있으므로 위증죄가 성립한다(대판 2008.10.23. 2005도10101).

2. 다음의 위증죄에 대한 기술 중 옳지 않는 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 경험을 통하여 기억하고 있는 사실을 진술한 이상 그 진술이 객관적 사실에 부합되지 아니하거나 경험한 사실에 기초한 주관적 평가나 그 법률적 효력에 관한 견해를 부연한 부분에 다소의 오류나 모순이 있는 경우에는 위증죄가 성립하지 않는다.
- ② 타인으로부터 전해들은 금품의 전달사실을 마치 자신이 전달한 것처럼 진술한 경우 위증죄가 성립한다.
- ③ 주식회사의 대표이사도 민사소송의 당사자가 되는 것이므로 위증죄의 주체가 될 수 없다.
- ④ 위증죄에서 자수·자백에 대한 형의 감면은 자백·자수한 자에게만 적용된다.
- ⑤ 공범인 공동피고인은 당해 소송절차에서는 피고인의 지위에 있으므로 어떠한 경우에도 다른 공동피고인에 대한 공소사실에 관하여 증인이 될 수 없다.

[정답] ⑤

[해설] 공범인 공동피고인은 당해 소송절차에서는 피고인의 지위에 있으므로 다른 공동피고인에 대한 공소사실에 관하여 증인이 될 수 없으나, 소송절차가 분리되어 피고인의 지위에서 벗어나게 되면 다른 공동피고인에 대한 공소사실에 관하여 증인이 될 수 있다(대판 2008.6.26. 2008도3300).

3. 甲은 사촌동생 乙과 그의 여자친구 A와 함께 호텔 객실에서 밤새 술을 마시다가 술에 약한 乙이 깊은 잠에 빠지자 A를 강간을 하였다. 그 후 A의 고소로 甲은 불구속 기소되었는데, 乙은 이 사건의 결정적인 증인으로서 재판정에 출두해서 증언을 하게 되었다. 재판기일 전날 乙을 만난 甲은 자신이 乙의 재정적 후원자임을 상기시키면서 자신이 A를 강간한 사실이 없다고 법정에서 증언하도록 시켰다. 재판장은 乙이 甲의 사촌동생이라는 사실을 간과하고 증언거부권을 고지하지 않은 상태에서 증언을 하도록 하였다. 甲의 재정적 지원이 절실했던 乙은 증인선서 후 甲이 A를 강간한 것이 아니라 둘이 합의하에 성관계를 가진 것이라고 거짓으로 증언하였다. 이 경우 甲과 乙의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲과 乙은 모두 무죄
- ② 甲 : 위증교사죄, 乙 : 위증죄
- ③ 甲 : 무죄, 乙 : 위증죄
- ④ 甲 : 무죄, 乙 : 위증죄
- ⑤ 甲 : 증거인멸교사죄, 乙 : 무죄

[정답] ②

【해설】 ㉠ 증언거부사유가 있음에도 증언거부권을 고지받지 못함으로 인하여 그 증언거부권을 행사하는 데 사실상 장애가 초래되었다고 볼 수 있는 경우 위증죄의 성립이 부정된다(대판 2010.2.25. 2009도13257). → 乙은 甲의 재정적 지원이 절실했던 터이므로 어차피 위증을 할 수밖에 없었고, 증거거부권의 불고지는 증언거부권을 행사하는 데 아무런 장애가 될 수 없다. 乙에게는 위증죄가 성립한다. ㉡ 자기의 형사피고사건에 관하여 타인을 교사하여 위증하게 한 경우, 위증교사죄의 성립이 인정된다(대판 2004.1.27. 2003도5114).

♣ 학습내용 정리

1. 위증죄는 법률에 의해 선서한 증인이 허위진술을 함으로써 성립하는 범죄이다.
2. 증인이란 법원 또는 법관에 대해 자신의 경험을 진술하는 제3자이다.
3. 위증죄에서 비신분자가 선서한 증인을 교사·방조하여 본죄를 범하게 하면 위증죄의 교사범 또는 종범이 된다(형법 제33조 본문).
4. 위증죄에서 자백·자수의 시기는 증언한 사건의 재판 또는 징계처분이 확정되기 전까지, 즉 신문절차가 종결한 이후부터 재판 또는 징계처분이 확정되기 전까지이다.

제43강 무고죄(형법 제156조)

♣ 학습목표

- 무고죄에서 공무소 또는 공무원의 의미를 설명할 수 있다.
- 무고죄에서 허위사실의 신고의 내용을 설명할 수 있다.
- 무고죄에서 주관적 구성요건으로서 고의와 형사처분을 받게 할 목적에 대하여 설명할 수 있다.
- 자기 사건에 대한 무고교사가 성립하는지를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

무고
형사처분과 징계처분
허위사실의 신고
자수·자백

♣ 사전테스트

1. 무고죄에서 허위사실은 형사처분의 원인이 되는 것이어야 한다.
정답 : O
2. 무고죄에서 익명에 의한 범죄사실의 신고는 가능하지 않다.
정답 : X
3. 무고죄의 죄수판단의 기준은 무고당한 자의 수가 기준이 된다.
정답 : O

♣ 돌발퀴즈

스스로 본인을 무고하는 자기무고도 무고죄를 구성한다.

[정답] X

[해설] 스스로 본인을 무고하는 자기무고는 무고죄의 구성요건에 해당하지 아니하여 무고죄를 구성하지 않는다(대판 2008.10.23. 2008도4852).

♣ 강의내용

1. 행위의 주체 및 객체

1. 무고죄의 의의

타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소·공무원에 대해 허위사실을 신고함으로써 성립하는 범죄이다(진정목적범).

2. 행위의 주체 및 객체

공무소 또는 공무원이다. 본죄의 객체는 무고에 대해 직권을 행사할 수 있는 공무소·공무원에 제한된다. 즉 형사처분에서는 검사, 사법경찰관, 그 보조자 기타 범죄수사자 및 그 감독자 등이 이에 해당하고, 징계처분에서는 심사결정의 직권 있는 소속기관장, 징계처분을 촉구할 수 있는 기관 등을 포함한다. 그밖에 수사기관을 통할하는 대통령,이나 관내 경찰서장을 지휘·감독하는 도지사, 그리고 조세범칙행위에 대하여 벌금 상당액의 통고처분을 하거나 검찰에 이를 고발할 수 있는 권한을 가지고 있는 국세청장도 포함된다.

판례 (대판 2007.3.30. 2006도6017) 司50

타인 명의의 고소장을 대리하여 작성하고 제출하는 형식으로 고소가 이루어진 경우, 무고죄의 주체 - 비록 외관상으로는 타인 명의의 고소장을 대리하여 작성하고 제출하는 형식으로 고소가 이루어진 경우라 하더라도 그 명의자는 고소의 의사가 없이 이름만 빌려준 것에 불과하고 명의자를 대리한 자가 실제 고소의 의사를 가지고 고소행위를 주도한 경우라면 그 명의자를 대리한 자를 신고자로 보아 무고죄의 주체로 인정하여야 한다.

판례 (대판 2010.11.25. 2010도10202) 司55

[1] 구 변호사법 제92조, 제95조, 제96조, 제100조 등 관련 규정에 의하면 변호사에 대한 징계처분은 형법 제156조에서 정하는 '징계처분'에 포함된다고 봄이 상당하고, 구 변호사법 제97조의2 등 관련 규정에 의하여 그 징계 개시의 신청권이 있는 지방변호사회의 장은 형법 제156조에서 정한 '공무소 또는 공무원'에 포함된다. [2] 피고인이 변호사인 피해자로 하여금 징계처분을 받게 할 목적으로 서울지방변호사회에 위 변호사회 회장을 수취인으로 하는 허위 내용의 진정서를 제출한 사안에서, 무고죄를 인정한 원심판단을 수긍한 사례.

판례 (대판 2014.7.24. 2014도6377)

형법 제156조 무고죄에서 '징계처분'이란 공법상의 감독관계에서 질서유지를 위하여 과하는 신분적 제재를 말한다. 그런데 사립학교 교원은 학교법인 또는 사립학교경영자가 임면하고(사립학교법 제53조, 제53조의2), 그 임면은 사법상 고용계약에 의하며, 사립학교 교원은 학생을 교육하는 대가로 학교법인 등으로부터 임금을 지급받으므로 학교법인 등과 사립학교 교원의 관계는 원칙적으로 사법상 법률관계에 해당한다. 따라서 학교법인 등의 사립학교 교원에 대한 인사권의 행사로서 징계 등 불리한 처분은 사법적 법률행위의 성격을 가진다. 그러므로 사립학교 교원에 대한 학교법인 등의 징계처분은 형법 제156조의 '징계처분'에 포함되지 않는다고 해석함이 옳다. → 피고인이 사립대학 교수들인 피해자들로 하여금 징계처분을 받게 할 목적으로 국민권익위원회에서 운영하는 범정부 국민포털인 국민신문고에 민원을 제기한 행위가 무고죄에 해당한다고 볼 수 없다.

II. 행위 - 허위사실의 신고

허위사실을 신고하는 것이다.

1. 허위사실

(1) 허위의 의미

허위란 신고의 내용이 진실과 일치하지 않는 경우이다. 신고내용이 진실과 부합하면 본죄는 성립하지 않으며, 신고자가 그 신고내용을 허위라고 믿었다 하더라도 그것이 우연히 객관적으로 진실한 사실에 부합할 때에는 허위사실의 신고에 해당하지 않아 무고죄는 성립하지 않는다. 객관적 진실에 합치하는 이상, 국가의 사법기능에 아무런 장애가 되지 않기 때문이다.

객관적 진실과 부합하지만 하면 무고죄가 성립하지 않는다는 점에서 허위를 증인 개인의 주관적 기억에 반하는 것을 기준으로 삼는 위증죄와 구별된다.

판례 (대판 1991.10.11, 91도1950) 司36·52

무고죄는 타인으로 하여금 형사처분 등을 받게 할 목적으로 신고한 사실이 객관적 진실에 반하는 허위사실인 경우에 성립되는 범죄로서 신고자가 그 신고내용을 허위라고 믿었다 하더라도 그것이 객관적으로 진실한 사실에 부합할 때에는 허위사실의 신고에 해당하지 않아 무고죄는 성립하지 않는 것이며, 한편 위 신고한 사실의 허위 여부는 그 범죄의 구성요건과 관련하여 신고사실의 핵심 또는 중요내용이 허위인가에 따라 판단하여 무고죄의 성립 여부를 가려야 한다.

신고한 사실의 허위 여부는 그 범죄의 구성요건과 관련하여 신고사실의 핵심 또는 중요내용이 허위인가에 따라 판단하므로 신고사실의 전부가 반드시 허위일 필요는 없다. 그러나 위법성 조각사유와 같이 범죄성립을 조각하는 사유가 있음을 알고도 이를 숨기고 신고한 때에는 허위사실의 신고에 해당한다.

판례 (대판 1998.3.24. 97도2956) 司48

위법성조각사유가 있음을 알면서도 “피고소인이 허위사실을 공표하였다.”고 고소함으로써 공직선거및 선거부정방지법 제250조의 허위사실공표죄로 처벌되어야 한다고 주장한 것과 같이 볼 수 있는 경우 무고죄의 성립이 인정된다.

(2) 허위신고의 정도

- ① 허위사실은 형사처분의 원인이 되는 것이어야 한다. 즉 수사권의 발동을 촉구할 수 있는 정도가 되어야 한다. 따라서 신고사실의 일부에 허위의 사실이 포함되어 있다고 하더라도 그 허위부분이 범죄의 성부에 영향을 미치는 중요한 부분이 아니고, 단지 신고한 사실을 과장한 것에 불과한 경우에는 무고죄에 해당하지 않는다.

판례 (대판 2008.8.21. 2008도3754) 辯4 司52

피고인 자신이 상대방의 범행에 공범으로 가담하였음에도 자신의 가담사실을 숨기고 상대방만을 고소한 경우, 피고인의 고소내용이 상대방의 범행 부분에 관한 한 진실에 부합하므로 이를 허위의 사실로 볼 수 없고, 상대방의 범행에 피고인이 공범으로 가담한 사실을 숨겼다고 하여도 그것이 상대방에 대한 관계에서 독립하여 형사처분 등의 대상이 되지 아니할뿐더러 전체적으로 보아 상대방의 범죄사실의 성립 여부에 직접 영향을 줄 정도에 이르지 아니하는 내용에 관계되는 것이므로 무고죄가 성립하지 않는다.

- ② 또한 신고한 사실이 국가의 사법기능을 위태롭게 할 소지가 없어서 형사처분·징계처분의 원인이 되지 않는 때, 예컨대 신고사실에 대해 벌칙규정이 없는 경우도 무고가 아니다.

판례 송이버섯 채취권사건(대판 2007.4.13. 2006도558)

司52·56

[1] 타인에게 형사처분을 받게 할 목적으로 ‘허위의 사실’을 신고한 행위가 무고죄를 구성하기 위하여는 신고된 사실 자체가 형사처분의 원인이 될 수 있어야 할 것이어서, 가령 허위의 사실을 신고하였다고 하더라도 그 사실 자체가 형사범죄로 구성되지 아니한다면 무고죄는 성립하지 아니한다.

[2] “피고소인이 송이의 채취권을 이종으로 양도하여 손해를 입었으니 엄벌하여 달라”는 내용의 고소사실이 횡령죄나 배임죄 기타 형사범죄를 구성하지 않는 내용의 신고에 불과하여 그 신고 내용이 허위라고 하더라도 무고죄가 성립할 수 없다.

판례 (대판 1995.12.5. 95도1908)

辯4 司44·48·50

객관적으로 고소사실에 대한 공소시효가 완성되었더라도 고소를 제기하면서 마치 공소시효가 완성되지 아니한 것처럼 고소한 경우에는 국가기관의 직무를 그르칠 염려가 있으므로 무고죄를 구성한다.

- ③ 피무고자는 특정되어야 한다. 반드시 성명을 표시할 필요는 없으나 누구를 무고하였는지 인식할 수 있어야 한다.

2. 신고

자진하여 사실을 고지하는 행위이다(신고의 자발성) 따라서 신고의 자발성이 인정되어야 하므로 피고인이 수사기관에 한 진정 및 그와 관련된 부분을 수사하기 위한 검사의 추문에 대한 대답으로서 진정내용 이외의 사실에 관하여 진술한 경우는 신고가 아니다.

신고의 방법도 제한이 없다. 구두·서면을 불문하고, 고소장·진정서, 원본·사본도 불문한다. 명의 여부도 상관없으므로 익명으로도 가능하며, 객관적으로 누구라는 것을 알 수 있으면 피무고자의 성명·주소를 밝힐 필요도 없다.

판례 (대판 1996.2.9. 95도2652) 司48

무고죄에 있어서의 신고는 자발적인 것이어야 하고 수사기관 등의 추문에 대하여 허위의 진술을 하는 것은 무고죄를 구성하지 않는 것이지만, 당초 고소장에 기재하지 않은 사실을 수사기관에서 고소보충조서를 받을 때 자진하여 진술하였다면 이 진술 부분까지 신고한 것으로 보아야 한다.

3. 기수시기

허위신고가 해당 공무소 또는 공무원에게 도달한 때이다. 구두신고의 경우는 진술과 동시에 기수가 되고, 문서우송의 경우는 해당기관에 도달한 때이다. 본죄는 미수범처벌규정이 없으므로 우편으로 발송하였으나 아직 도달하지 아니한 때에는 본죄가 성립하지 않는다. 그러나 문서가 도달하여 수사관이나 조사관이 볼 수 있는 상태에 있으면 기수가 되고 현실적으로 열람·수사개시·공소제기의 여부는 불필요하다.

III. 주관적 구성요건 - 고의와 목적

1. 고의

판례 (대판 2007.3.29. 2006도8638) 司51・52・55

[1] 무고죄는 타인으로 하여금 형사 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 진실함의 확신이 없는 사실을 신고함으로써 성립하므로, 그 신고사실이 허위라는 것을 신고자가 확신할 필요는 없다. 즉, 미필적 고의로 족하다.

[2] 1통의 고발장에 의하여 수개의 혐의사실을 들어 고발한 경우, 그 중 일부 사실이 진실이고 다른 사실이 허위이면 그 허위사실 부분이 독립하여 무고죄를 구성하는지 여부(적극)

판례 (대판 2006.5.25. 2005도4642) 司52

신고한 사실이 객관적 사실에 반하는 허위사실이라는 요건은 적극적인 증거가 있어야 하며, 신고사실의 진실성을 인정할 수 없다는 소극적 증명만으로 곧 그 신고사실이 객관적 진실에 반하는 허위사실이라고 단정하여 무고죄의 성립을 인정할 수는 없다.

2. 목적

타인으로 하여금 형사처분・징계처분을 받게 할 목적이 있어야 한다(진정목적범).

(1) 타인

- ① 타인은 특정인으로서 살아있는 사람이어야 한다. 법인도 포함된다. 그러나 사자나 허무인에 대한 무고 또는 스스로 본인을 무고하는 자기무고는 국가의 적정한 사법기능 또는 징계권행사가 위태롭게 될 우려가 없기 때문에 본죄의 구성요건에 해당하지 않는다. 辯4
- ② 자기무고는 본죄의 구성요건해당성이 없으므로 타인에게 자기를 무고하도록 교사한 경우에는 교사범이 성립하지 않으며, 자기와 타인이 공범관계에 있다고 신고한 경우에는 타인과 관련된 부분에 대해서만 본죄가 성립한다. 한편 피무고자의 동의를 받아 무고하는 경우에는 본죄의 주된 보호법익인 국가의 심판기능의 적정을 침해하게 되므로 무고죄가 성립한다.

판례 (대판 2005.9.30. 2005도2712) 司57

무고죄는 국가의 형사사법권 또는 징계권의 적정한 행사를 주된 보호법익으로 하고 다만, 개인의 부당하게 처벌 또는 징계받지 아니할 이익을 부수적으로 보호하는 죄이므로, 설사 무고에 있어서 피무고자의 승낙이 있었다고 하더라도 무고죄의 성립에는 영향을 미치지 못한다.

(2) 자기 사건에 대한 무고교사의 인정 여부

타인에게 자기를 무고하도록 교사한 경우에 이는 방어권의 남용으로 무고죄의 교사범이 성립한다(판례).

판례 (대판 2008.10.23. 2008도4852) 司51・54・55

피무고자의 교사・방조 하에 제3자가 피무고자에 대한 허위의 사실을 신고한 경우 피무고자에게 무고의 교사・방조죄가 성립되는지 여부(적극) - 형법 제156조의 무고죄는 국가의 형사사법권 또는 징계권의 적정한 행사를 주된 보호법익으로 하는 죄이나, ① 스스로 본인을 무고하는 자기무고는 무고죄의 구성요건에 해당하지 아니하여 무고죄를 구성하지 않는다. ② 그러나 피무고자의 교사・방조 하에 제3자가 피무고자에 대한 허위의 사실을 신고한 경우에는 제3자의 행위는 무고죄의 구성요건에 해당하여 무고죄를 구성하므로, 제3자를 교사・방조한 피무고자도 교사・방조범으로서의 죄책을 부담한다.

(3) 형사처분 또는 징계처분

형사처분은 형법에 의한 형벌뿐만 아니라 소년법에 의한 보호처분을 포괄한다. 징계처분은 공법상의 감독관계에서 질서유지를 위하여 과하는 신분적 제재를 말한다.

(4) 목적

본죄의 목적은 미필적 인식으로 충분하고 결과발생을 희망할 필요가 없다(미필적 인식설)

IV. 보론

1. 죄수판단의 기준

국가의 심판기능은 사람에 따라 별도로 발생하므로 무고당한 자의 수가 기준이 된다.

2. 자수·자백에 대한 특례

신고한 사건의 재판 또는 징계처분이 확정되기 전에 자백 또는 자수한 경우는 그 형을 감경 또는 면제한다(제157조).

판례 (대판 1995.9.5, 94도755)

무고죄에 있어서 형의 필요적 감면사유에 해당하는 자백이란 자신의 범죄사실, 즉 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고하였음을 자인하는 것을 말하고, 단순히 그 신고한 내용이 객관적 사실에 반한다고 인정함에 지나지 아니하는 것은 이에 해당하지 아니한다.

♣ 확인학습문제

1. 다음의 무고죄에 대한 설명 중 잘못된 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 피무고자의 교사·방조 하에 제3자가 피무고자에 대한 허위의 사실을 신고한 경우 제3자를 교사·방조한 피무고자도 교사·방조범으로서의 죄책을 부담한다.
- ② 1통의 고발장에 의하여 수개의 혐의사실을 들어 고발한 경우, 그 중 일부 사실이 진실이고 다른 사실이 허위이면 그 허위사실 부분이 독립하여 무고죄를 구성한다.
- ③ 피고인 자신이 상대방의 범행에 공범으로 가담하였음에도 자신의 가담사실을 숨기고 상대방만을 고소한 경우에도 무고죄가 성립한다.
- ④ 객관적으로 고소사실에 대한 공소시효가 완성되었더라도 고소를 제기하면서 마치 공소시효가 완성되지 아니한 것처럼 고소한 행위는 무고죄를 구성한다.
- ⑤ 무고죄의 목적은 미필적 인식으로 충분하고 결과발생을 희망할 필요가 없다.

[정답] ③

[해설] 피고인 자신이 상대방의 범행에 공범으로 가담하였음에도 자신의 가담사실을 숨기고 상대방만을 고소한 경우, 피고인의 고소내용이 상대방의 범행 부분에 관한 한 진실에 부합하므로 이를 허위의 사실로 볼 수 없고, 전체적으로 보아 상대방의 범죄사실의 성부에 직접 영향을 줄 정도에 이르지 아니하는 내용에 관계되는 것이므로 무고죄가 성립하지 않는다(대판 2008.8.21. 2008도3754).

2. 다음의 무고죄에 대한 기술 중 옳지 않는 것은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 변호사에 대한 징계처분은 무고죄에서 정하는 ‘징계처분’에 포함되지 않는다.
- ② 신고자가 그 신고내용을 허위라고 믿었다 하더라도 그것이 우연히 객관적으로 진실한 사실에 부합할 때에는 무고죄는 성립하지 않는다.
- ③ 신고사실의 진실성을 인정할 수 없다는 소극적인 증명만으로 곧 그 신고사실이 객관적인 진실에 반하는 허위사실이라고 단정하여 무고죄의 성립을 인정할 수 없다.
- ④ 무고죄에서 형사처분은 형법에 의한 형벌만 포함하고, 소년법에 의한 보호처분을 포괄하는 것은 아니다.
- ⑤ 무고죄에 있어서 형의 필요적 감면사유에 해당하는 자백에는 단순히 그 신고한 내용이 객관적 사실에 반한다고 인정함에 지나지 아니하는 것은 이에 해당하지 아니한다.

[정답] ①

【해설】 변호사에 대한 징계처분은 형법 제156조에서 정하는 ‘징계처분’에 포함되고, 그 징계 개시의 신청권이 있는 지방변호사회의 장이 같은 조에서 정한 ‘공무소 또는 공무원’에 포함된다(대판 2010.11.25. 2010도10202).

3. 甲은 “피고소인 乙은 1998.11.3. 甲의 사이에 甲이 1999년부터 2008년까지 10년간 乙 소유의 이 사건 전답을 경작·관리함과 아울러 이 사건 임야에 자생하는 송이를 채취하고, 乙에게 그 대가를 지급하기로 하는 내용의 토지경작관리계약을 체결하였는데, 乙이 2002.7.경 丙에게 이 사건 임야에 자생하는 송이의 채취권을 이중으로 넘겨주어 甲으로 하여금 손해를 입게 하였으므로 乙을 엄벌하여 달라”는 취지의 허위사실을 날조하여 경찰서에 신고하였다. 이 경우 甲의 죄책은?(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무고죄 ② 사기죄
③ 공무집행방해죄 ④ 위증죄
⑤ 무죄

[정답] ⑤

【해설】 가령 허위의 사실을 신고하였다 하더라도 그 사실 자체가 형사범죄로 구성되지 아니한다면 무고죄는 성립하지 아니한다. 그러므로 “피고소인이 송이의 채취권을 이종으로 양도하여 손해를 입었으니 엄벌하여 달라”는 내용의 고소사실이 횡령죄나 배임죄 기타 형사범죄를 구성하지 않는 내용의 신고에 불과하여 그 신고 내용이 허위라고 하더라도 무고죄가 성립할 수 없다(대판 2007.4.13. 2006도558).

♣ 학습내용 정리

1. 무고죄는 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소·공무원에 대해 허위사실을 신고함으로써 성립하는 범죄이다(진정목적범).
2. 무고죄에서 공무소 또는 공무원'이란 징계처분에 있어서는 징계권자 또는 징계권의 발동을 촉구하는 직권을 가진 자와 그 감독기관 또는 그 소속 구성원을 말한다.
3. 무고죄에서 허위란 신고의 내용이 진실과 일치하지 않는 경우이다.
4. 무고죄에 있어서 형의 필요적 감면사유에 해당하는 자백이란 자신의 범죄사실, 즉 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고하였음을 자인하는 것을 말한다.

	낙태죄 헌법불합치 결정
2주차 1차시	제269조(낙태) ①부녀가 약물 기타 방법으로 낙태한 때에는 1년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.> ②부녀의 촉탁 또는 승낙을 받아 낙태하게 한 자도 제1항의 형과 같다. <개정 1995. 12. 29.> ③제2항의 죄를 범하여 부녀를 상해에 이르게 한 때에는 3년 이하의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 7년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.> [헌법불합치, 2017헌바127, 2019. 4. 11. 형법(1995. 12. 29. 법률 제5057호로 개정된 것) 제269조 제1항, 제270조 제1항 중 ‘의사’에 관한 부분은 모두 헌법에 합치되지 아니한다. 위 조항들은 2020. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다] 제270조(의사 등의 낙태, 부동의낙태) ①의사, 한의사, 조산사, 약제사 또는 약종상이 부녀의 촉탁 또는 승낙을 받아 낙태하게 한 때에는 2년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.> ②부녀의 촉탁 또는 승낙없이 낙태하게 한 자는 3년 이하의 징역에 처한다 ③제1항 또는 제2항의 죄를 범하여 부녀를 상해에 이르게 한 때에는 5년 이하의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 10년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.> ④전 3항의 경우에는 7년 이하의 자격정지를 병과한다. [헌법불합치, 2017헌바127, 2019. 4. 11. 형법(1995. 12. 29. 법률 제5057호로 개정된 것) 제269조 제1항, 제270조 제1항 중 ‘의사’에 관한 부분은 모두 헌법에 합치되지 아니한다. 위 조항들은 2020. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다]